

ÖNSÖZ

Otuzlu yaşlarımda bana “hukukçu olmasaydın hangi mesleği seçerdin” diye sorduklarında hep “iç mimar olmak isterdim” diye cevap verdim. Hala da aynı cevabı veriyorum. Belki bunda en önemli sebeplerden biri yirmili yaşlarımdan bu yana en iyi dostlarımdan birkaçının mimar yada iç mimar olmasıdır. Bunun dışında sokaklarda yürüdüğümde ister istemez başımı yukarıya kaldırıp, binalara ve onların hangi mimari dönemlerin izlerini taşıdığına bakarım, Bir eve veya işyerine girdiğimde ise gözüm dekorasyonda kullanılan detaylara kayar ve kendimi tutamayıp oranın sahibine dekorasyonla ilgili görüşlerimi aktarırım.

Yaptığım yurt dışı seyahatlerde şehrin taş binalarının bulunduğu merkezlerine giderek önceki yerel mimari örneklerine bakmayı ve arkeolojik yerleşim yerlerini dolaşarak mimari ile tarihin buluşma noktalarını incelemeyi pek ihmal etmem. Mısır ve Tayland’da bu bağlamda çok heyecanlandığımı hatırlıyorum. İtalya’da Bernini tarafından yapılan saraylar ve çeşmelerin görkemi başımı döndürür. Jules Hardouin Mansart’ın Fransa’da yaptığı eserler ve Versailles Sarayı da bence önemli çalışmalardır. Son dönem mimarlardan Zaha Hadid ve Kişo Kurokawa beni çok etkileyen önemli çağdaş eserlere imza atmışlardır.

Barok ve gotik çalışmaları sebebiyle son dönem mimarlardan Gaudi Usta’ya ise özel bir gönül bağım vardır. Yaşamımdaki en dip spirüüel deneyimlerden biri Barselona’daki büyük Usta’nın eseri “Sagrada Familia”da gerçekleşmiştir. Mimar Sinan’ın Şehzade Camisi, Süleymaniye Camisi ve Selimiye Camisi gibi eserlerini de gerçekten etkileyici bulurum.

Bu sebeplerle belki, bugüne kadar bir çok mimar, iç mimar ve onların şirketlerinin hukuk danışmanlığını yapma fırsatım oldu. Yaptığım işler dolayısıyla zaten ilgi alanlarımdan biri olan fikişsel ve sanatsal ürünler alanına bir de mimari eserler üzerine bir çalışma yaparak katkıda bulunma fikrim oluştu.

Laleli’deki Teyyare Apartmanı ve Sirkeci’deki 4. Vakıf Han ile Mimar Kemalettin Bey, Sirkeci’deki Büyük Postahane ile Mimar Vedat, birçok eserleriyle Recai Akçay, Sedad Hakkı Eldem ve Behruz Çinici, son dönem mimarlarından Hasan Mingü, Emre Arolat, Hakan Kıran ve Mus-

tafa Toner'lere ulaşan Ülkemiz mimari ve içmimari yolculuğu birçok ulusal ve uluslararası çapta sanatsal başarıları içinde barındırır.

Ancak hemen fark edersiniz ki bir mimar veya iç mimar bir sanatsal anlayış içinde birkaç önemli eser oluşturduktan sonra, o eserlerin çizgileri birçok mimar yada müteahhit tarafından taklit edilir ve orijinal sanatsal çalışmanın o ilk birkaç örneğinin lezzetinden çok uzak birçok kopya mimari dizayn veya dekorasyon her yerde boy gösterir.

İşte bu yüzden o mimarın sanatsal ve fikirsel zenginliğinin başkalarının kötü kopyalarla taklit edilmesi zevksizliğinin önüne geçmek gerekir. Tayland'da yapılmış on dolarlık bir rolex nasıl orijinalinin verdiği işlev ve hazzı vermezse, aynı şekilde Philip Stark'ın yarattığı bir koltuğun Çağlayan'da taklit edilmiş bir versiyonu aynı oturma keyfi ve sanatsal tatmin duygusunu vermez. Bu taklitler diğer yandan ilk eseri oluşturan sanatçıya sıkıntı da yaratır. Bir yanda manevi olarak eserinin formundan uzak kopyaları ile insanların estetiksel kazıklanması diğer yandan mali olarak kendisine sürekli bir gelir sağlayacak tasarım ve projelerin bedava kullanılması onun sıkıntılarının iki cephesidir.

Halbuki bu alanda, yüzyıllardır ahlaki ve son iki-üç yüzyıldır da hukuki koruma var. Ancak mimar ve iç mimarların yaratımları üzerinde hangi haklara sahip oldukları ve bu haklarını nasıl koruyacaklarına ilişkin yayınlar çok sık yapılmadığı için yeni çalışmalar ile bu alanın vurgulanması gerekmektedir.

Çalışma arkadaşım Avukat Filiz Ceritoğlu'nun hazırladığım malzemeler doğrultusunda bir kısmının yazımını üstlendiği, Doç. Dr. Gülçin Elçin Grassinger'in zaman ayırarak öneriler sunduğu ve Mine Koç'un bilgisayara aktarmada emek verdiği kitabımız; mimarların ve iç mimarların hakları konusundaki bilinme eksikliğini ulusal ve uluslararası yasa ile kurallardan yararlanarak doldurma gayreti içindedir. Doğru ve yararlı işler yapan, gelecek öngörenlere katkıda bulunmak başlıca dileğimizdir.

Gürsel Öngören

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	I
İÇİNDEKİLER.....	III
I. GİRİŞ.....	1
II. MİMAR VE MİMARİ HİZMETLER.....	3
III. ESER KAVRAMI VE MİMARİ ESERLERİN FSEK'TEKİ YERİ	25
<i>A. ESER.....</i>	<i>25</i>
1. Sahibinin Hususiyetini Taşımaya: Subjektif Şart	27
2. FSEK'te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması: Objektif Şart.....	29
<i>B. FSEK'TEKİ MİMARİ ESERLER KAVRAMI.....</i>	<i>30</i>
1. FSEK madde 2/b.3 de Yer Alan Mimari Yapının Plan ve Projeleri	31
2. FSEK madde 4/b.3 de Yer Alan Mimarlık Eserleri.....	35
IV. ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE FSEK'TEKİ MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ.....	39
<i>A. ESER SAHİPLİĞİ.....</i>	<i>39</i>
<i>B. FSEK'TEKİ MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ.....</i>	<i>45</i>
V. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI	49
<i>A. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN MANEVİ HAKLARI</i>	<i>56</i>
1. Eseri Umuma Arz Yetkisi.....	56
2. Adın Belirtilmesi Yetkisi.....	58
3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi	61
4. Eserin Aslına Varma Yetkisi	67
<i>B. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN MALİ HAKLARI</i>	<i>69</i>
1. İşleme Hakkı	70
2. Çoğaltma Hakkı	74
3. Yayma Hakkı	78
4. Temsil Hakkı.....	82
5. Yayın ve Umuma İletim Hakkı.....	84

6. Pay Alma (İzleme) Hakkı	87
VI. YAPI MALİKİNİN HAKLARI	89
VII. HAKLARIN KULLANILMASI VE DEVRİ	95
VIII. MİMARİ PROJE DÜZENLEME SÖZLEŞMESİ.....	107
<i>A. TANIMI VE İÇERİĞİ</i>	<i>107</i>
<i>B. KONUSU</i>	<i>107</i>
<i>C. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE KURULMASI.....</i>	<i>110</i>
<i>D. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ</i>	<i>115</i>
<i>E. MİMAR VE İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SONA ERMESİ</i>	<i>119</i>
IX. ESER SAHİBİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI	133
<i>A. KAMU DÜZENİ DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA</i>	<i>133</i>
<i>B. GENEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA</i>	<i>134</i>
<i>C. ÖZEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE GETİRİLEN SINIRLANDIRMA </i>	<i>137</i>
<i>D. HÜKÜMETE TANINAN YETKİLERLE SINIRLANDIRMA</i>	<i>139</i>
X. HAKLARIN KORUNMA SÜRELERİ	143
XI. MİMARİ ESERLERE İLİŞKİN TECAVÜZLER VE DAVA YOLUYLA KORUNMASI	147
<i>A. HUKUK DAVALARI</i>	<i>148</i>
1. Eser Sahibinin Tespiti Davası:.....	148
2. Tecavüzün Ref'i Davası:	150
3. Tecavüzün Meni Davası:	153
4. Tecavüzün Tespiti Davası:	154
5. Tazminat Davaları:	155
6. Diğer Davalar ve Talepler:	162
<i>B. CEZA DAVALARI</i>	<i>163</i>
1. Mali Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar	166
2. Manevi Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar.....	168
3. Diğer Suçlar	170

XII. HUKUK VE CEZA DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER	171
<i>A. İHTİYATİ TEDBİRLER</i>	<i>171</i>
<i>B. HÜKMÜN İLANI.....</i>	<i>172</i>
<i>C. ZABIT, MÜSADERE VE İMHA</i>	<i>173</i>
XIII. GÖREVLİ MAHKEMELER	177
MİMARİ ESERLERLE İLGİLİ YARGI KARARLARI.....	179
MİMARLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ	285
MİMARİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ	289
KAYNAKÇA.....	293
SON SÖZ	297

I. GİRİŞ

Son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmeler sayesinde, sanayi toplumu düşüncesi yerini bilgi toplumu düşüncesine bırakmıştır. Bilgi toplumunda üretimdeki unsurlar hammadde ve makine ilişkisinden çok bilgi ve teknolojiye dayalı olup, yaratıcı düşünceye dayalı fikirsel ve sanatsal ürünler ön plana çıkmaktadır. Fikirsel ve sanatsal yaratımlardan etkilenen teknolojik üretim de bu yaratımlara dayalı yeni tip ürünler oluşturmaktadır. Bilgi üretiminin artması; yeni ürünlerin ortaya çıkmasının yanı sıra, fikirsel ve sanatsal ürünlerden yeni yararlanma şekilleri ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Klasik mülkiyet ilişkisi ve mülkiyeti koruyan sistemlere ilişkin kurallar, yeni ürünleri ve eski ürünlere ilişkin yeni yararlanma şekillerini yaratanları ve üretenleri koruyamamıştır. Bu sebeple mülkiyete ilişkin kurallardan da yararlanarak yeni koruyucu kurallar üretmek gerekmiştir. Gelişmelerin sonucunda, fikirsel ve sanatsal çalışmaları yaratanları ve yaratıcılardan bazı hakları alıp bu ürünleri üretenleri korumak amacıyla uluslararası sözleşme hükümleri ve “*Fikir ve Sanat Eserleri Mevzuatı*” oluşturulmuştur. Bu hükümlerin veya kuralların hepsine birden “*Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku*” adı verilmektedir.

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku sürekli devinim içindedir. Eserlerin üretiminde kullanılan malzemelerin ve eser üretme yöntemlerinin ilerleyen teknoloji doğrultusunda gelişmesi uygulanacak hukuk kurallarını da etkilemektedir. Bilgi işlem teknolojisindeki hızlı atılımlar ile Dünyadaki ucuz iş gücünün Global Ekonomi’ye başta Uzakdoğu halkları olmak üzere katılması yepyeni iş yapma ve üretim yöntemleri ortaya çıkarmıştır. Her türlü heykel ve tablo, iç dekorasyonda kullanılan ürünler ileri teknoloji ile kopyalanmaktadır. Mimari projelerin tasarımları ise gelişmiş ülkelerde yapıldıktan sonra, ölçülerle birlikte Hindistan veya Çin’deki düşük ücretle çalışan mimarlara veya teknikerlere gönderilmekte ve saat farkı dolayısıyla ertesi sabah plan ve projeler halinde ünlü mimarların bilgisayarlarında müşteriye sunulmaya hazır olarak bulunmaktadır. Gerek kopyacılık ve gerekse eserlerin bir kısmının kimliği belirsiz ucuz işgücü ile oluşturulması fikri haklarda yeni sorunları çözümleyen yeni kurallar belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Hukukçular da bu yeni ihtiyaçlar doğrultusunda yeni kurallar oluşturarak Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku’nu dinamikleştirmektedir.

Bu alanda gerek ilk getirilen kurallar ve gerekse şartlar ve teknoloji gereğince yeni eklenen kurallar ile fikirsel ve sanatsal hak sahiplerine, yasaklama da dahil tekel niteliğinde birçok yetkiler sağlanmıştır. Bu şekilde fikirsel ve sanatsal hak sahibi; izni olmadan başkalarının kendi fikirsel ve sanatsal mülkiyet hakkını kullanmasını kolayca engelleyebilmekte, ürettiği eserin kullanım şekli doğrultusunda piyasa değerinin üç katı tazminat alabilmekte ve izinsiz kullananların hapisle cezalandırılacağı yasal yolları harekete geçirebilmektedir.¹ Fikirsel ve sanatsal mülkiyet hakları, haksız rekabeti yasaklayabilme yeteneğinin yanında manevi haklara yönelik saldırıları da önlemeyi sağlamaktadır.

Kısacası Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku; eserlere, sahiplerinin haklarına ve korumaya ilişkin kuralların tümünü içerir. Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar; eser sahibinin maddi menfaatlerini tecavüzlere ve sömürülere karşı korur, eser sahibine ekonomik yararlanma olanakları sağlar, eser sahibinin izni olmadan eserin alenileşmesine ve değiştirilmesine engel olur ve onun eser sahibinin isteğine uygun bir şekilde adıyla veya müstear bir adla yada anonim olarak kamuya sunulmasını gerçekleştirir. Bu şekilde hak sahibine eseri üzerinde maddi ve manevi anlamda tasarruf yetkileri bahşeder.²

Ancak, bu haklara sahip olabilmek için her şeyden önce fikirsel ve sanatsal emek sonucu ortaya çıkan ve Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku kapsamında korunmaya değer olan bir “eser” bulunmalıdır. Ortada bir eser varsa, bunun sahibi ve hakları hukuk kuralları doğrultusunda belirlenebilir.

Tüm bu açıklamalar ışığında esas konumuz olan “mimari eserler” açısından bilgi aktarımı için; önce “mimar” ve “mimari hizmetler” sonra mimari çalışmaların “eser” kavramı içindeki yeri, daha sonra hak sahibine verilen yetki ve haklara olan saldırılara karşı korunma yöntemleri üzerinde duracağız.

¹ Bkz. Ünal TEKİNALP, Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, , İstanbul, Eylül 2004, s. 7.

² TEKİNALP, age., s. 8.

II. MİMAR VE MİMARİ HİZMETLER

Mimar mesleğini, mimarlık hizmetleri şartnamesine uygun olarak icra ederken insanların yaşamlarını geçirdikleri kentsel mekanları, yapıları, yapı içinde yer alacak eylemler bütünü için en uygun mekansal çevreyi tasarlamak, kullanıcının fizyolojik, psikolojik ve ergonomik ihtiyaçlarını ve isteklerini kavramak ve gerekli çözümlere ulaşmak, bunların birbirleriyle uyumlu biçimlenmelerini denetlemek, yapının; sağlıklı, kullanışlı ekonomik, sağlam, güvenli, estetik olarak ve doğal kentsel ve tarihi çevresi ile uyumlu ve planlama ilkelerine uygun şekilde tasarlamak ve inşa edilerek tamamlanmasını sağlamak için çaba gösterir. Bu sorumluluğu yerine getirmek üzere, tasarımın başarısı için gerektiğinde diğer meslek grubu ve sanatçılarla birlikte çalışabilir. Onların çalışmalarının kendi tasarımı ile uyumlu ve bütünlük içinde olması için; eşgüdüm içinde çalışma yapar ve yapılmasını gözetir.³

Mimarın sorumluluklarını yerine getirirken başka uzmanların katkılarına başvurmuş olması, onun tasarımı ve uygulama denetimi ile gerçekleştireceği yapının her yönüyle kullanıcılarına eksiksiz ve kusursuz olarak teslim edilmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tasarımının sorumluluğunu bir bilim ve sanat adamı olarak taşır. Bu nedenle kendisinden beklenen sonuca ulaşabilmesi için, eseri olan yapıyı kent bütünü içinde yakın çevresi ile birlikte değerlendirerek her yönüyle bir bütün olarak tasarlar. Eseri olan yapının iç mekanlarının kullanıcı istek ve gereksinmelerine uygun olarak düzenlemesi, iç ve dış mekanlarda kullanılacak mobilyaların tasarımı -mimarlığın doğal sonucu olarak- mimarın tasarım ve mesleki denetim sorumluluğu kapsamındadır.⁴

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği” ne bağlı “Mimarlar Odası” tarafından çıkarılan ve 25833 sayılı Resmi Gazetede 02.06.2005 tarihinde yayınlanan “*Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği* (MHDY)” madde 4 de “**Mimar**; mimarlık hizmetlerini,

³ TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi Ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi”nden alınmıştır.

⁴ TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi Ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi”nden alınmıştır.

eğitimi, uzmanlığı ve çalışma konularına göre, Mimarlar Odasının ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaya yetkili, yükümlülüklerini yerine getirerek üyelik sıfatını ve ünvanını koruyan, çalışması kısıtlanmamış serbest, kamu görevlisi ya da ücretli çalışanları ifade etmektedir”. Bu maddede **kamu çalışanı mimar**; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan mimarlar ve **ücretli çalışan mimar** ise; hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar olarak tanımlanmaktadır. Aynı maddede **serbest mimar**; 3458 sayılı *Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun*, 6235 sayılı *Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu*, yürürlükteki kanunlar ve yönetmelik hükümlerinin verdiği yetki ile mimarlık hizmet alanlarından birini yada bir kaçını kendi hesabına yada ortak olarak yapan ve durumunu Mimarlar Odasına onaylatmış, serbest mimarlar listesine kayıtlı mimarı ifade etmektedir.

3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun’un 1. maddesine göre; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mühendislik ve mimarlık ünvan ve yetkisi ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı belgelerden birine sahip olmaları gerekir.

- Mühendislik veya mimarlık eğitimini gösteren Türk üniversitelerinden verilen diplomalar;

- Programlarının yüksek mühendis veya mimar okulları programlarına eşit olduğu kabul edilen bir yabancı yüksek mühendis veya yüksek mimar okulundan diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler;

- Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna eşit olduğu kabul edilen ülke dahilindeki diğer mühendis veya mimar okullarından verilen diplomalar;

- Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına eşit olduğu kabul olunan bir yabancı mühendis veya mimar okulundan diploma almış olanlara usulüne göre verilecek ruhsatnameler.

Bu Kanun’un 7. maddesi gereğince; "Kanun’un 1. maddesinde belirtilen diploma veya ruhsatnamelerden birine sahip olmayanlar Türkiye’de mühendis veya mimar unvanı ile çalıştırılmaz, imzalarla sanat icra edemezler, bu ünvanları kullanarak oy veremezler ve imza da koyamazlar”. Kanun’un 8. maddesi de; yukarıdaki madde hükümlerine aykırı harekette bulunanlara ağır para cezasıyla ve tekrarı halinde para cezasıyla beraber ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezası verileceğini, maddede yazılı diploma ve ruhsatnameye sahip olmayanları bu belgelere sahip olanlara

özel ünvan ve yetkilerle işlerinde kullanan kimselerle tüzel kişilerin temsilcilerinin de aynı şekilde cezalara mahkum edileceğini düzenlemektedir.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 33. maddesine göre; Türkiye'de mühendislik ve mimarlık meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını gerektiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki eğitim yapabilmeleri için uzmanlıklarına uygun bir odaya kaydolmak ve üyelik durumunu korumak mecburiyetindedirler.

6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 25. maddesine göre; Odalara kayıtlı meslek mensuplarından bu kanuna aykırı hareketleri görülenlerle, meslekle ilgili işlerde gerek kasten ve gerekse ihmal göstererek zarara sebebiyet veren veya akdettiği mukavelelere uymayan veyahut meslek şeref ve haysiyetine engel durumları tesbit olunlara kayıtlı bulundukları oda haysiyet divanınca ihtar, para cezası, meslekten geçici yasaklama ve odadan ihraç cezaları verilir. 28. madde gereğince Odadan ihraç edilenler süresiz olarak, meslekten geçici olarak yasaklananlar ise, yasaklama süresi içinde hiçbir şekil ve biçimde mesleki faaliyette bulunamazlar. Bunlar Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından derhal bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara duyurulur. 31. maddeye göre, Odalardan ihraç kararı ancak umumi hükümlere göre medeni haklarını kaybetmiş olanlar veya meslek camiasından uzaklaştırılmalarında mutlak zaruret görülenler hakkında verilebilir.

“Mimarlık- Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret- Asgari Çizim ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği (Mim-Müh HAÇDEY)” madde 6 gereğince; yapı üretiminin gerçekleştirilmesine esas, proje ve kontrollük hizmetleri uzmanlık ve çalışma konularına göre ilgili oda üyesi mimar ve mühendisler tarafından yapılır. Her türlü serbest mimarlık, mühendislik, müşavirlik hizmetlerinin yapılabilmesi için, gerçek veya tüzel kişi ve kurumlar, ilgili meslek odalarından, meslek odasının öngördüğü gerekli belgeleri almak zorundadırlar.

MHDY madde 6'ya göre; mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri, *“serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi”*⁵ tabi mimarlık hizmetleridir. Bu hizmet-

⁵ **Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi:** Mimarlar Odası tarafından verilen ve her yıl yenilenen, serbest mimarın serbest mimarlık hizmeti yapmaya yetkili olduğunu belirleyen belgedir. **Tescil:** Mimarın, Mimarlar Odasına başvurarak serbest mi-

ler serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz. Mimarlar Odasının MHDY gereğince belirlediği kurallar açısından; Odaya kayıt ve tescil için mimarın belli disiplin cezalarının bulunmaması, üyelik aidatını ödemiş olması ve birçok belgenin hazırlanmış olması gibi koşullar gereklidir.

MHDY madde 14'e göre; Mimarlar Odasına tescilini ve tescil yenilemesini yapan serbest mimarlara serbest mimarlık hizmetleri yapmaya yetkili olduğunu belirten "serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi" ile birlikte serbest mimarlık mührü verilir. Serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve serbest mimar mührü olmayan mimarlar, serbest mimarlık hizmeti yapamazlar. Serbest mimarlık hizmetleri; ilgili kanunlar, yönetmelikler, Mimarlar Odasının şartname, tarife ve mimari proje çizim ve sunuş standartlarına uygun olarak yürütülür.

MHDY 10. maddesi gereğince; sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimarlar, çalıştığı sermaye şirketine ait gayri menkuller üzerinde, kazanç amacı gütmeksizin, şirket ana sözleşmesinde belirlenmiş iştigal konularını yürütmek üzere, yalnızca şirket tarafından kullanılacak kendilerine ait binaları için aşağıda yazılı hususları yerine getirmeleri koşulu ile; serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın serbest mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak; fenni mesuliyet üstlenemez, üçüncü şahısların işleri için serbest mimarlık hizmeti veremezler. Sermaye şirketlerinde hizmet sözleşmesi ile çalışan mimar; bahsi geçen iş ile ilgili mimari hizmeti Mimarlar Odası tarafından belgelenmeden mimarlık hizmeti yapamaz ve çalışmasına imza koyamaz.

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'un 9. maddesine göre; Devlet daire ve kurumlarıyla belediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurları çalışma saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz özel şekilde sanatlarını icra edemez-

marlık hizmetleri büro tescil belgesi almasıdır. **Tescil yenileme:** Serbest mimarın, bu Yönetmelik hükümlerini yerine getirdikten sonra serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesini her yıl onaylatması işlemidir. **Mimari proje müellifi sicil durum belgesi:** Mimarın ürettiği projeleri kurum ve kuruluşlara vermeden önce ilgili Mimarlar Odası biriminden aldığı belgedir. **Mimari fenni mesul sicil durum belgesi:** Serbest mimarın fenni mesuliyetini üstleneceği yapının kurum ve kuruluşlarına müracaat etmeden önce ilgili Mimarlar Odası biriminden aldığı belgedir. (Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği (MHDY) Madde 4)

ler. Ancak serbest meslek mensubu bulunmayan ve mahallin belediye ve Bayındırlık idarelerinin müracaatı ve en büyük mülkiye âmirinin izniyle zorunluluk bulunduğu belli olan yerlerde, onay ve denetimi kendilerine veya mensubu oldukları mahalli idarelere ait olmayan, ülkenin gelişmesiyle (imarıyla) ilgili özel mesleki işleri devamlı olmamak ve dışarıda yazıhane açmamak ve asıl görevlerini çalışma saatleri dışında yapmak şartıyla memurlar; iş kabul edebilirler. Profesörlük, öğretmenlik ve doçentlik birinci fıkrada yazılı yasaklama düzenlemesinden istisnadır. Yine MHDY madde 11'e göre; kamu kurumlarında çalışan mimarlar, bu kuruluşların kendilerine ait yapı işleri için serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın mimarlık hizmetleri verebilirler. MHDY madde 12'ye göre ise; mimarlık eğitimi veren üniversitelerin kadrolu öğretim elemanları, eğitim, öğretim ve bilimsel araştırmaya katkıda bulunmayı ön planda tutmak koşuluyla uzmanlık konularında bağlı bulundukları üniversitelerin döner sermaye işletmelerinin yetkilendirmesi ve bazı hususları yerine getirmek koşuluyla serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi aranmaksızın üniversitelerin ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının asli işlerine yönelik mimarlık hizmeti verebilirler. Ancak, fenni mesuliyet üstlenemezler.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 33. maddesine göre de; kamu kurumu ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri mensuplarının meslek ve uzmanlıklarıyla ilgili Odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.

MHDY madde 13 gereğince; mimar kendisi, eşi, annesi, babası, kardeşleri ve çocukları gerçek kişi olarak, iş sahibi konumunda olduğu durumlarda ve ticari amacı olmayan kendi kullanımları için yaptıracakları binalarda, serbest mimarlık hizmetlerini, bu durumu belgelemek ve bir defaya mahsus olmak üzere, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi ve fatura aranmaksızın asgari ücret üzerinden mesleki denetim bedeli ödeyerek yapabilirler. Bu durumu belirlenen mimarın; disiplin cezası nedeniyle mesleki faaliyetini yapmaya engel bir kısıtlılığının bulunmaması, Mimarlar Odasınca düzenlenen imza sirküleri, taahhütname, başvuru ye-

rine geçen formu şahsen doldurmuş ve imzalamış olması ve üyelik aidatını ödemiş olması gerekir.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun 33. ve 34. maddelerine göre; Türkiye'de Devlet daireleri ile resmi ve özel bütün kurum şahıslara karşı re'sen veya yerli müesseselerle müştereken taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlık ile ilgili işlerde yalnız bu işe münhasır kalmak ve Odalar Birliği'nin görüşünü almak ve Bayındırlık Ve-kaletinin onayından geçmek şartıyla yabancı uzman çalıştırabilirler. Yabancı müteahhit veya yabancı kuruluşlar, Türkiye'de Devlet daireleri ile resmi ve özel kuruluş ve şahıslara karşı re'sen veya yerli kuruluşlarla birlikte taahhüt ettikleri mühendislik veya mimarlıkla ilgili işlerde, yalnız bu işe münhasır kalmak kaydıyla, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının ve Odalar Birliğinin görüşleri alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen çalışma izni ile yabancı uzman çalıştırabilirler. Bu maddede yazılı hususlardan başka işlerde yabancı yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimar kullanılabilmesi Odalar Birliği İdare Heyeti'nin görüşü üzerine Bayındırlık Bakanlığı'nca karar verilmesine bağlıdır. Yalnız Devlet daireleri ile resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından danışma görevleriyle getirilen ve teknik eğitim için gelenler bu şarta tabi değildirler. Bunlar da ancak getirdikleri iş konusu kapsamında kalarak bunların dışında mesleki faaliyette bulunamazlar. Bu madde kapsamına girmeyen işlerde yabancı mühendis ve yüksek mühendisler ile mimar ve yüksek mimarlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Odalar Birliğinin görüşleri alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca verilen çalışma izni ile çalıştırılabilir. Bu maddeler gereğince gelen yabancı meslek mensupları Türkiye'de bir aydan fazla kaldıkları takdirde ihtisaslarına en yakın odaya müracaatla geçici üye olarak kaydolunurlar. Bu maddelerdeki yazılı sorumlulukları yerine getirmeyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye'de mesleki faaliyetten yasaklanırlar.

MHDY, **mimarlık hizmetlerini**; uygulamaya, yapmaya, kabule ve imzaya mimarın yetkili olduğu, her türlü araştırma, danışmanlık, bilirkişilik, etüt, tasarım, plan, proje, resim ve hesapların hazırlanması ve bunların uygulanması ile her türlü denetim ve kontrollük hizmetleri olarak tanımlamıştır. **Serbest mimarlık hizmetleri** ise, sadece serbest mimarlık hizmetleri tescil belgesi sahibi mimarın ya da bu Yönetmelikte tanımlanan istisna koşulları taşıyan mimarın yapmaya yetkili olduğu mimarlık hizmetleri olarak ifade edilmektedir.

Mimarın ihtisasına, formasyonuna ve iştiğal konusuna göre; müellif olarak tasarlamaya, uygulamaya, kabule, imzaya yetkili ve sorumlu olduğu **mimarlık hizmet alanları** MHDY madde 5'te şu şekilde sayılmıştır.

a) Mimari tasarım hizmetleri: Mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon hizmetleri ve imalat projesi çalışmalarıdır.

b) Mimari uygulama ve yönetimi hizmetleri: Mimari mesleki kontrollük, proje ve şantiye koordinasyonu ve planlaması; şantiye şefliği, saha mimarlığı; mimari fenni mesuliyet, kontrollük, geri besleme çalışmaları ve kabul teslim çalışmalarıdır.

c) Mimari danışmanlık hizmetleri: Mimari danışmanlık, müşavirlik, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, raportörlük; mimari proje yönetimi, yapılabirlik, fizibilite çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keşif ve şartname hazırlanmasıdır.

d) Mimari eğitim çalışmaları: Mimari eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

e) Diğer sanatsal çalışmalar: Sanat eseri seçimi, maket çalışmaları, üç boyutlu görsel çalışmalar ve benzeri hizmetlerdir.

Mimar ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir.

Mimarlık hizmetlerinin sınıflandırılması konusundaki bir başka düzenleme de TMMOB tarafından 22.12.2006 tarihinde kabul edilen “*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi* (Mim HŞEABT)’nde” bulunmaktadır. Mim HŞEABT madde 5 gereğince; mimarın ihtisasına, formasyonuna ve iştiğal konusuna göre müellif olarak tasarlamaya, uygulamaya, kabule, imzaya yetkili ve sorumlu olduğu **mimarlık hizmet alanları** yukarıda belirttiğimiz MHYD'deki ifadeden biraz daha genişçe şu şekilde düzenlenmiştir.

a) **Mimari tasarım hizmetleri:** Mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon hizmetleri, mimari iç mekan düzenleme ve donanımı tasarımı hizmetleri, imalat projesi, mimari çevre düzenlemesi hizmetleri, kentsel tasarım hizmetleri, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planlarıdır.

b) **Mimari Uygulama ve Yönetimi Hizmetleri:** Uygulama sürecince, mimar ya da mimarlar tarafından verilen, mimari mesleki kontrollük (MUS), inşaat yönetimi, proje ve şantiye koordinasyonu ve planlaması;

şantiye şefliği, saha mimarlığı; mimari fenni mesuliyet, kontrollük, yapı denetimi; geri besleme çalışmaları, kabul teslim çalışmalarıdır.

c) Mimari danışmanlık hizmetleri: Mimarın, ihtisas ve iştigal konusu ile ilgili olarak uzmanlığına danışılmak üzere mimari danışmanlık, müşavirlik, bilirkişilik, hakemlik, eksperlik, jüri üyeliği, raportörlük; mimari proje yönetimi, yapılabilirlik, fizibilite çalışmaları, program hazırlığı, özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlığı, iş ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, ihale dosyası hazırlanması, karşılaştırmalı keşif, şartname hazırlanması, v.b.gibi hizmetlerdir.

d) Mimari eğitim çalışmaları: Mimari eğitim ve öğretim çalışmalarıdır.

e) Diğer sanatsal çalışmalar: Sanat eseri seçimi, maket çalışmaları, üç boyutlu görsel çalışmalar, animasyon, mimari eğitim ve öğretim çalışmaları ve benzeri hizmetlerdir.

Ayrıca mimar; ulusal ve uluslararası düzenlemelerle tanımlanacak yeni mesleki hizmet alanlarında da bu düzenlemeler çerçevesinde hizmet verir. Bu hizmetler iş sahibi ile mimar arasında yapılan özel sözleşme hükümlerine göre yerine getirilir.

TMMOB tarafından 22.12.2006 tarihinde kabul edilen “*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi* (Mim HŞEABT)” nin 7. maddesi gereğince; **Mimari Proje Hizmetleri İş Aşamaları** şu şekilde alt gruplara ayrılır.

1) Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması: Hazırlık çalışmaları, iş sahibinin olanaklarının, ihtiyaçlarının ve taleplerinin belirlenmesi, imar durumu, kadastro, altyapı-enerji, arsanın doğal ve zemin özelliklerinin saptanması ve gerekli belgelerinin derlenmesi, tasarım ve uygulama aşamalarında izlenecek yol ve uygulanacak çalışma yönteminin kararlaştırılması, tasarım ve uygulama çalışmalarına mimarın yardımcısı olarak katılacak mühendisler ve diğer uzmanların yapacağı çalışmaların ve bunların koordinasyon şeklinin saptanması amacı ile mimar tarafından yapılan çalışmalardır. Bu sayılanların yanında aşağıdaki çalışmalar da bu aşamaya girer.

- İş dosyası açılması ve iş sahibi tarafından verilen ihtiyaç programının irdelenmesi.
- İş sahibi tarafından temin edilen idari, hukuki ve teknik belge ve bilgilerin incelenmesi.

- İnşaat yapılacak yerin görülmesi ve incelenmesi (toprak altı ve alt yapı hariç).
- Mevcut yapılardaki tadilat işlerinde basit ve şematik rölöve çıkarılması yada iş sahibinin verdiği projelerin incelenmesi.
- İş sahibinin karar vermesine yardımcı olacak açıklıkta eskiz çalışmalarının yapılması.

Mimar, yukarıdaki inceleme ve etütlerini “**Fikir Projesi** (basit ön proje)” şeklinde somutlar ve sunar. Bu dosyada vaziyet planı, yerleşim planı, kat planları ve prensip kesiti, mimari açıklama raporu, alan hesapları (gerekirse hacim hesapları), genel maliyet hesabı (ilan edilen B.B. m² B.F.'na dayanarak) yer alır ve dosya iş sahibine 2 nüsha olarak sunulur. Mimar, bu aşamada iş sürelerini, sözleşmenin kapsayacağı iş aşamalarını, birlikte çalışılacak mühendis ve diğer uzmanlık alanlarını belirlemiş ve iş sahibine önermiş olmalıdır.

2) Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması : Bu aşamada yapılan tasarlama çalışmaları, kesin veya uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce, hazırlık ön etüt çalışmalarında belirlenmiş, yorumlanmış ve değerlendirilmiş bilgilerin projede yansıtılması amacını taşır.

Kaynak kaybının önlenmesi, ekonomik, sağlam, güvenli, kullanışlı, çevresi ile uyumlu yapıların gerçekleştirilmesi amacıyla, uygulama projelerinin hazırlanmasına geçilmeden önce; hazırlık çalışmaları sırasında belirlenmiş ihtiyaç programının, işlev şemasının, arsa, alt yapı, iklim, kadastro, imar durumu, doğal yapı, çevre düzeni, iş sahibi istekleri vb. verilerin ve mimarın aldığı kararların kesinleşmiş olması gerekir. Ön proje çalışmaları, aynı zamanda mimar ile iş sahibi arasında tasarıma yönelik mutabakatların sağlandığı, onaylanması durumunda mimarın telif hakkını kazandığı iş aşamasıdır.⁶

- Yeni yapılara ait ön projelerde; vaziyet planının hazırlanması, yapı/yapıların yerleşme planının hazırlanması, yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun sağlanması, arazi doğal-fiziki yapısı ve yol kotu ile yapı ilişkisinin sağlanması, otopark, sığınak, kapıcı-teknisyen bölümleri bilgilerinin tasara yansıtılması, iklim verileri-

⁶ Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması, mimarın telif haklarını kazandığı iş aşaması olarak Yönetmelikte düzenlenmişse de bizce ileride açıklayacağımız şekilde “eser” niteliği olan tasarımlar ve Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları İş Aşaması’ndaki planlar da telif hakları olan çalışmalardır. Bkz. Yargıtay Kararları No:57

nin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin saptanması, çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin yansıtılması, çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasara yansıtılması, yapıda genel olarak kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve özet mahal listesinin hazırlanması, ön proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması, yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir ve birbirini tekrarlayan mahallerin (otel tip odaları gibi) daha ayrıntılı çizimleri yapılır. Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir.

- Mevcut yapı tadilatlarında:

- Rölöveler.⁷

- Teknik inceleme raporları. (Gerektiğinde sondaj yapılması ve uzmanlara inceleme raporları hazırlatılmasını iş sahibi sağlar)

- Yapının ve çevresindeki yapıların yerinde incelenmesi ve tadilat durumlarının saptanması

- Rölöve planları üzerine öneri tadilat projesinin hazırlanması

Hazırlanan ön proje dosyası iş sahibine 3 nüsha olarak sunulur. İş sahibinin onayı alınır.

3) Kesin Proje Çalışmaları İş Aşaması : Esasen Ön Proje Çalışmaları İş Aşaması sonunda, bir yapının ön projelerinin tamamlanması ve iş sahibi tarafından kabul edilmesinden sonra uygulama projelerinin hazırlanmasına başlamak için gerekli araştırma, bilgilenme ve etütlerin tamamlanmış olduğu ve bunların ön projelere yansıtıldığı kabul edilmektedir. Ancak, bazı durumlarda ön proje çalışmaları aşamasında meydana gelen değişiklikler iş sahibinin gerekli görmesi ya da talep etmesi, ya da ön projeler aşamasında prensipleri belirlenmiş bazı teknik özelliklerin, uygulama projeleri çalışmalarına başlanmadan kesinleştirilmek istenmesi durumunda; mimar, yapının kesin projelerini hazırlar.

Kesin projeler, onaylanmış ön projelere uygun olarak hazırlanır ve gerçekleştirilecek yapının mimarisi ve yapıım tekniği konularında daha ayrıntılı ve kesinleşmiş bilgiler ve etütleri içerir, ön proje çalışmaları sırasında yeterince değerlendirilemeyen ya da tasara yansıtılamayan veriler

⁷ Rölöve çizimleri iş sahibi tarafından sağlanmamışsa mimar ücretinin ayrıca ödenmesi karşılığında bunları hazırlar. Korunması gereken kültür varlıkları rölöveleri “*Korunması Gerekli Kültür Varlıklarının Rölöve-Restitüsyon-Restorasyon Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedeli Tarifesi*” ne göre hazırlanır.

(iklim, coğrafya, hidroloji, jeoloji, geoteknik, alt yapı, çevre düzeni vb.) kesin proje aşamasında değerlendirilir, aynı zamanda, YYM belirlenmesinde kullanılır.

• Yeni yapılara ait kesin projelerde :

- Vaziyet planının kesinleştirilmesi,
- Yapı/yapıların yerleşme planının kesinleştirilmesi,
- Yerleşme planının kadastro sınırları ve imar durumu ilişkisinin ve uygunluğunun kesinleştirilmesi,
- Arazi doğal-fiziki yapısı ile yol kotu ile yapı ilişkisinin kesinleştirilmesi,
- Arsa/arazi zemin bilgilerinin tasara yansıtılması, alınan önlemlerin belirtilmesi,
- Otopark, sığınak, kapıcı-teknisyen vb. bölümlere ait bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi,
- Elektrik, su, havagazı, doğal gaz, PTT temini ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması,
- Mekanik ulaşım donatımı ile ilgili ön bilgilerin temini ve tasara yansıtılması,
- Güvenlik donatımı (paratoner, alarm vb.) ile ilgili bilgilerin temini ve tasara yansıtılması,
- İklim verilerinin değerlendirilmesi, iklim özelliklerine göre alınan önlemlerin kesinleştirilmesi,
- Su, ısı ve ses yalıtımları özelliklerinin belirlenmesi,
- Isıtma, soğutma, iklimlendirme, havalandırma prensiplerinin belirlenmesi ve tasara yansıtılması,
- Yangına karşı önlemlerin tasara yansıtılması,
- Deprem, rüzgar, özel yük ve sarsıntı etkilerine karşı önlemlerin tasara yansıtılması,
- Çevre yapıların ve doğa özelliklerinin belirlenmesi ve alınan önlemlerin tasarda kesinleştirilmesi,
- Çevre (bahçe) düzenleme ile ilgili bilgilerin tasarda kesinleştirilmesi,
- Yapıda kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve mahal listesinin hazırlanması,

- Kesin proje çalışmaları ile ilgili buraya kadar yazılı bilgileri içeren açıklama raporunun hazırlanması,
- Yapının tüm birbirinden farklı planları, 2 adet kesit ve birbirinden farklı görünüşleri çizilir.
- Birbirini tekrarlayan mahallerin (otel tip odaları gibi) daha ayrıntılı çizimleri yapılır. Farklı mahallerin tefrişleri gösterilir.

Hazırlanan Kesin Proje dosyası iş sahibine 3 nüsha olarak sunulur. İş sahibinin onayı alınır.

4) Uygulama Projesi İş Aşaması : Yapının inşa edilebilmesi için, statik projenin yapım özelliklerini ve ölçülerini, yapıda yer alan tüm donatım sistemlerinin yapıyı etkileyen bütün elemanlarını, sistem detaylarının ve imalatlarla ilgili tüm bilgileri ve referansları, montaj özelliklerini içeren, gerekli tüm ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı, büro ve şantiyede her türlü imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve yeterlilikte, kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile onaylanmış ön proje ya da kesin projeye uygun olarak hazırlanmış projelerdir.

Mimari uygulama projesi, aynı zamanda koordinasyon projesidir. Yapıda yer alan tüm malzemeler, imalatlar, bileşenler, donatımlarla ilgili bilgilerin referans ya da kodlarını içerir. İnşaat, tesisat, elektrik mühendisleri ya da diğer teknik uzmanlar tarafından hazırlanmış projelerde yapıyı etkileyen kısımların bilgileri mimari uygulama projesinde şematik olarak gösterilir.

Mimari uygulama projesi, yapıda kullanılan tüm imalat ve malzemelerin kullanıldığı yerleri, birleşme şekillerini, biçimlerini ve özelliklerini yansıtır, ilgili sistem ve montaj detaylarıyla, imalat detaylarının referanslarını içerir, imalat pozlarını belirler.

Mimari uygulama projesi, yapıda yer alan değişik işçiliklerin birbirleri ile sorumluluk sınırlarını belirleyen belgedir. Uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerinin esasını teşkil eder.

Yüklenici-yapımcıların hiç bir şekilde tereddüt etmeden ve hataya düşmeden yapım (inşaat) tekliflerini hazırlayabilecekleri bilgileri, açıklamaları ve ayrıntıları içermelidir. Kesin Mahal Listeleri uygulama projesinin ekidir.

Mimari uygulama projesi, sistem ve montaj detayları ve imalat detayları iş aşamaları ile birlikte yürütülür ve bir bütündür.

5) Sistem ve Montaj Detayları İş Aşaması : Uygulama projesi çalışmaları ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine uygun olarak hazırlanan, kolayca inşa edilebilmesi için yapının özellik gösteren ve özen gösterilerek yapılması istenen bölümlerinin, bu bölümlerde kullanılan malzeme ve imalatların açılımları, özellikleri ve birleşme detaylarını, ayrıntılı ölçülerini, detaylarla ilgili tüm referanslarını içeren, büroda ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile standartlara uygun olarak hazırlanmış ve çizilmiş resimlerdir.

Sistem ve montaj detayları, (cephe, çatı, temel, merdiven, kapı, pencere, ıslak hacimler vb.) en az plan, kesit ve görünüş olarak ifade edilir.

6) İmalat Detayları İş Aşaması : Uygulama projeleri ile birlikte yürütülen, uygulama projelerine ve sistem ve montaj detaylarına uygun olarak hazırlanan, yapının, şantiye dışında, atölyelerde, fabrikalarda imal edilerek yerine montajı yapılan; kapılar, pencereler, camekanlar, korkuluklar, prefabrik yapı elemanları, doğrama madeni aksamı, asma tavanlar, duvar kaplama ve lambri detayları, yapının döşemi (tefrişi ve mobilyaları) ile ilgili malzeme ve imalatlar, sağlık döşemi (lavabo, duş teknesi, klozet vb.) ya da bunlara benzer yapı elemanlarının, imalatlarının yapılabilmesi için hazırlanan ayrıntılı çizimleridir.

Genellikle imalatçı firmalar tarafından hazırlanan imalat detayları mimarın olurundan sonra uygulanır. Bu durumda, mimar bu bileşenlerin montaj ve koordinasyon detaylarının hazırlanmasından ve bunların diğer yerinde imalatlarla ya da bileşen şeklindeki imalatlarla uyumunu sağlamakla yükümlüdür. Mimar, kendi buluşu olan yapı elemanları ya da bileşenlerinin imalatlarının yapılabilmesi için imalata yönelik detaylarını kendisi hazırlar.

İmalat detayları standartlara uygun olarak hazırlanır. İmalatı ilgilendiren malzemelerin değişik noktadaki şekilleri ve birleşme biçimleri ayrı ayrı gösterilir. Tüm imalat boyutları verilir, malzemeleri yazılır, malzeme açılımları gösterilir, kullanılan malzemelere ait referans numaraları ya da poz no'ları verilir.

7) Teknik Şartnameler İş Aşaması: Mimar tarafından hazırlanan projelerin uygulama için her türlü bilgiyi içermesi gerekir. Çizili belgelerde yer alamayacak imalat ve inşaatla ilgili teknik bilgiler, yazılı belgelerle "Teknik Şartnameler"le verilir.

Teknik şartnameler, yapıda kullanılan her imalatın bünyesinde yer alan malzemelerin özellikleri, üretim şekli, imalata sokuluş koşulları,

imalatında ve montajında özen gösterilecek hususları, işçiliklerin nasıl yapılacağı, hangi toleranslarla hareket edileceği, zayıat miktarları, ölçüm ve deney şekli, söz konusu imalatın diğer imalatlarla ayrılma ve birleşme biçimi, taşıma, yükleme boşaltma, istifleme koşulları, imalatla kullanılacak değişik malzemelerin miktarları vb. gibi hususları belirleyen yazılı belgelerdir.

8) Metraj - Keşif ve Maliyet Analizi İş Aşaması: Mimar, yapının iş sahibi ile mutabık kaldığı Yapı Maliyet Tavanı (YMT) sınırları içerisinde tamamlanmasına dikkat etmelidir. Bu nedenle, yapının metrajının özenli ve dikkatli bir şekilde yapılması ve keşfinin sağlıklı hazırlanması gereklidir.⁸ Yapı Maliyet Tavanı iş sahibi tarafından onaylandıktan sonra projelerin uygulamasına ve inşaatın ihalesine geçilebilir.

9) İhale Belgelerinin Hazırlanması İş Aşaması: Mimar, iş sahibi ile mutabık kaldığı ihale şekline uygun olarak, projelerini hazırladığı yapının inşaatının yüklenici / yapımcılara topyekun ya da kısım kısım ihale edilmesini sağlayacak şekilde ihale belgelerini hazırlar.⁹

⁸ Ayrıca mimar;

- Yapının inşaatında yer alacak tüm imalatların miktarlarının eksiksiz olarak ve doğru biçimde belirlenmiş olması, uygulamada yapının yeterli şekilde denetlenmesini kolaylaştırır.
- Hazırladığı uygulama ve detay projeleri ile teknik şartnamelerine dayanarak yapının nicelik dökümünü ve metrajını hazırlar ya da hazırlatır.
- Yapının uygulama projelerinin hazırlanmasına katılan inşaat, tesisat ve elektrik mühendisleri ile diğer uzmanların yaptığı kendi işleri ile ilgili metrajların uyumunu sağlar.
- Hazırlanan metrajlar esas alınarak yapının ya da yapıların her biri için ayrı ayrı olmak üzere keşifler hazırlanır.
- Metrajlar ve keşifler yapı bölümleri ve yapı elemanları gruplarına göre ayrı ayrı yapılır.
- Gerekli görüldüğünde keşiflerin hazırlanmasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün yürürlükte olan birim fiyatları kullanılır.
- Fiyatları Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Birim Fiyatları ya da rayiç bedelleri ile belirlenmemiş imalatların maliyet analizleri ve birim fiyat tarifleri yapılır.

Bu şekilde mimar tarafından belirlenen Yapı Maliyet Tavanı iş sahibinin onayına sunulur.

⁹ Bu aşamanın detayları şunlardır: Mimar;

- İş sahibiyle inşaatın ve ihalesinin nasıl yapılacağına karar verir.
- Özel Teknik Şartnameyi hazırlar. (Projelerle birlikte teklif almak üzere kullanılır)

10) İhale Yapılması İş Aşaması: Sistem ve Montaj Detayları İş Aşamasını yapmış olsun ya da olmasın, iş sahibi tarafından ihale yapılması sürecinde kendisine yardımcı olunması, danışmanlık yapılması istenirse; mimar, teklif vermek isteyen yapımcılara ihale belgeleri ve projeler üzerinde diledikleri gerekli açıklamaları yapar.¹⁰ İş sahibi, kiminle sözleşme yapacağına kendisi karar verir ve bunun sorumluluğunu taşır. Mimarın iş sahibine yüklenici/yapımcı önermesi onun yapacağı işlerin sorumluluğunu mimara yüklemeyiz.

"Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)" nin 7. maddesi gereğince; **Mimari Mesleki Kontrollük (MUS) Hizmeti İş Aşamaları** şu şekilde alt gruplara ayrılır.

1) Mimari Mesleki Kontrollük (MUS) İş Aşaması¹¹: İş sahibi tarafından ihalesi yapılarak inşaat sözleşmesine bağlanan ya da imalat bö-

-
- Teklif sahiplerinin tekliflerini nasıl hazırlayacaklarını açıklayan "Teklif Alma Şartnamesi"ni hazırlar.
 - İş sahibinin yüklenici/yapımcılarla imzalayacağı "Sözleşme Taslağı"nı hazırlar.
 - İhale dosyası, yukarıdaki belgelere ilave olarak uygulama projeleri ve teknik şartnameleri içerir.
 - Mimar, yukarıdaki belgelerin tümünü düzgün dosyalar içerisinde 2 nüsha olarak iş sahibine teslim eder.

¹⁰ Ayrıca Mimar;

- Mutabık kalınan ya da iş sahibinin uygun gördüğü ihale şekline göre ihale belgelerinin hazırlanması iş aşamasında hazırlanan ihale belgelerine ve ihale şartnamesine uygun olarak, ihaleyi ilan eder ya da teklif alınacak yapımcıları ihaleye davet eder.
- Yeterlilik durumları sınanmasına karar verilmişse, teklif verecek olan ya da veren yapımcıların belgelerini inceleyerek ve gerekli istihbaratı yaparak yeterliliklerini inceleyerek ya da bu çalışmayı yapan komisyona katılır.
- Herhangi bir teklif alma ya da eksiltme işlemi sonucunda uygun teklifin saptanabilmesi için çeşitli yönlerden incelemelerde bulunur. Teklifleri, önerilen birim fiyatlar, toplam fiyat, toplam indirim süre, yapım teknolojisi, teknik yeterlilik (kadro, makine-ekipman vb) teminatlar vb. karşılaştırmalar yaparak irdeler.
- İhaleye katılan teklif sahiplerinin tekliflerinin ekonomik ve teknik yönden değerlendirmesini yapar.
- İnceleme ve irdeleme sonuçlarını bir rapor ile iş sahibine bildirir.
- İş sahibinin yüklenici/yapımcılarla yapacağı sözleşmeleri hazırlar ve imzalanmasında danışmanlık yapar.

¹¹ Mim-Müh HAÇDEY madde 6 gereğince asıl proje yanında yada ayrıca üstlenilecek kontrollük hizmetleri şunlardır:

l mleri ayrı ayrı  stencilere yaptırılarak inřa edilen yapının/yapıların proje ve řartnamelerine uygun olarak inřa edilmesi mimar tarafından mesleki y nden kontrol edilir. Mimari mesleki kontroll k hizmeti (MUS) proje m elli f mimarın sorumluluęunda y r t l r. Mimar, mimari mesleki kontroll ę n  (MUS)  stlendięi iřlerin; s zleřme eklerine, řartnamelere, fen ve sanat kurallarına uygun olarak ve iř programı gereęince iyi bir řekilde yapılıp s resinde bitirilmesini saęlamakla g revli ve sonu larından sorumludur. Yapı  retim s recinin b t nl ę  ilkesi ile bir yapının uygulama denetimi m elli f mimardan bařkasına verilemez. Ancak, mimarın oluru, aczi ya da mesleęini uygulayamaz duruma d řmesi durumunda iř sahibi uygulama denetimini m elli f mimarın tavsiye ettięi bir bařka mimara verebilir.

Mimar, mimari mesleki kontroll k hizmetleri(MUS) kapsamında;

- İnřaatın iř sahibi adına mimari mesleki kontroll k hizmetlerini (MUS) y r t rken, inřaat s resince, iřle ilgili her t rl  teknik ve mimari konuda iř sahibine yardımcı olur.
- İř, hizmet ve yapım talimatlarını hazırlar, iře bařlama izinlerini verir. (İře bařlama talimatı ile proje, ihale ve yapım s zleřmesi kapsa-

-
- a) **řantiye řeflięi** : Yapı  retimi veya mimarlık m hendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın plan, proje, resim ve hesaplarına, fen ve sanat kaidelerine, iřçi saęlıęı ve iř g venlięi esaslarına, genel řantiye organizasyonu iřlerine dair teknik mevzuata uygun olarak mesleki kontroller ve fenni mesul n direktifleri doęrultusunda y r t lmesi ve denetlenmesinin ilgili mimar ve m hendislerce yapılmasıdır.
 - b) **Mesleki Kontroll k** : Yapı  retiminin veya mimarlık m hendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın yapımı sırasında, y r rl kteki yasa, y netmelik, řartname ve projelerine uygunluęunun mimar ve m hendislerce uzmanlık konularına g re ayrı ayrı denetlenmesidir.
 - c) **Fenni Mesuliyet** : Yapı  retiminin veya mimarlık, m hendislik hizmeti gerektiren herhangi bir imalatın onaylı proje, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasının saęlanması i in s rveyan, řantiye řefi ve mesleki kontroll k hizmetlerinin koordinasyonu, yapı  retimi ile ilgili her t rl  hususun y r rl kteki imar yasası, imar planı, y netmelikleri ve lejantları ile TMMOB Kanun ve y netmelikleri a ısından denetlenmesi ve t m bu hususların ger ekleřtirilmesinde iřverene, resmi kontrol kurumlarına ve meslek odalarına karřı mimar ve m hendislerce  stlenilen yetki ve sorumluluklardır.

“Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri řartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HřE-ABT)” madde 4 de **Mimari mesleki kontroll k (Mesleki Uygulama Sorumluluęu-MUS)**; yapıların, proje, řartname, s zleřme ve ekleri, fen ve sanat kurallarına uygun olarak iř programı gereęince, m elli f mimar tarafından verilen mimarlık hizmeti olarak tanımlanmıřtır.

mında olmayan ve iş sahibine ilave harcama gerektiren iş talimatları iş sahibi tarafından da imzalanmalıdır.)

- Şantiye toplantıları düzenler ve bunları yönetir, inşaat ile ilgili olarak yapılan imalatların niteliklerinin belirlendiği şantiye tutanakları ve diğer kayıtları hazırlar ve yüklenici/yapımcı ve iş sahibi ile karşılıklı imzalar.

- İnşaat sürecinde yüklenici/yapımcıların ya da imalatçıların, malzemelerin seçiminde iş sahibine yardımcı olur; işin seyrine paralel olarak düzenlenmesi gereken tutanak ve protokolleri, iş sahibinin onayından geçmek kaydı ile imzalar.

- Yeterli bilgiyi ya da gerekli açıklamayı sağlamayan projelerin uygulamasını kolaylaştıracak ek proje ve detaylarını hazırlar ya da hazırlattırır.

- Yüklenici tarafından meydana getirilen her türlü imalat ve uygulamayı yapacağı düzenli ya da habersiz şantiye ziyaretleri ile yerinde inceler, projesine ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder, uygunluğunu sağlamak üzere yüklenici/yapımcılara gerekli talimatları verir. Bu talimatlar yüklenici/yapımcıları işlerini projelerine, şartnamelere, standartlara, fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması yükümlülüğünden kurtarmaz.

- Her türlü inşaat, imalat, tesisat ve montajı, boyut ve şekillerine uygun olarak, proje ve detaylarına göre eksiksiz yaptırır, onaylı projesi olmayan ve proje müellifinin mührünü taşımayan hiç bir işi yaptırmaz.

- Uygun olmayan durumlarda yıktırıp yeniden yaptırır; yıkılıp yeniden yapılmasında yarar sağlanmayan ve bu şekli ile kalmasında sakınca görülmeyen eksiklikleri, kesin hesapta gereğini yapmak üzere iş sahibine bildirerek "Şantiye Talimat Defteri"ne kaydeder.

- Mimar, yüklenici firma ya da firmalar ile iş sahibi arasında herhangi bir anlaşmazlık halinde gerekli teknik verileri istendiği taktirde iş sahibine sunar.

- İşlerin ilerlemesine paralel olarak ödemelerin yapılmasını iş sahibine önerir.

2) Yapıldı Projeleri Teslimi İş Aşaması: Mimar, kendisinden istenmişse ve sözleşmede belirtilmişse, inşaatın tamamlanmasından sonra, tüm imalatların fiilen gerçekleşme durumları ile yapıda tesis edilen elektrik ve tesisat donanımı bilgilerini proje orijinalleri üzerine işler ve gerekli açıklamaları yapar. Mimar, yine kendisinden istenmişse ve sözleşmede

belirtilmişse, “Yapıldı Projesi” nin, 1 takım şeffaf kopyasını, istenildiğinde gerektiğinde çoğaltılabilmesi amacıyla üzerine “Yapıldı Projesi” yazıp, imzalayıp, mühürledikten sonra iş sahibine teslim eder. Projelerin orijinalleri mimar tarafından muhafaza edilir. Muhafaza süresi en az 10 yıldır.

3) Kesin Hesaplar İş Aşaması (Yapı Kesin Maliyetinin Belirlenmesi): Yapının kabulünün yapılmasından önce (sözleşmenin yürürlükten kalkması yada kaldırılması durumunda), mimar yapının kesin hesaplarını hazırlar yada başkası tarafından hazırlanmışsa bunları inceler ve onaylar. Kesin hesapların yapılmasında, uygulama sürecinde yapılan kesin metraja dayanan hakedişler ile tamamlanan kesin metrajlar, tutanaklar, ataşmanlar ve rölöveler esas alınır. Yapılmışsa, "Yapıldı Projeleri" kesin hesaplara dayanak alınır. Hazırlanan kesin hesaplar yüklenici/yapımcı ve mimar tarafından imzalanır ve iş sahibine verilir.

4) Kabul-Teslim İş Aşaması: Mimar, yüklenici/yapımcının müracaatı üzerine yapıyı inceler ve ilgili kısımlarını inşaat, tesisat ve elektrik mühendislerine incelettirerek, kabulün yapılmasına engel bulunmadığına dair iş sahibine rapor verir. Yapının bu ilk muayenesinde kabulü engelleyen durumlar varsa, bunları belirler ve yüklenici ya da yapımcılardan bu eksik ve kusurların tayin ettiği süre içerisinde giderilmesini ister. İş sahibi tarafından yapılacak kabul işlem ve incelemelerinde hazır bulunur ve iş sahibine yardımcı olur.

Yerinde yapılan inceleme sonucu yapının sözleşme ve eklerine, projelerine, şartnamelerine ve genel olarak bilinen fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığı belirlenirse, yapının kabulü yapılır ve durum bir tutanağa bağlanır. Bu "Kabul Tutanağı" yüklenici/yapımcı, mimar ve iş sahibi tarafından imzalanır. Proje ve şartnamelere uygun olmayan inşaat ve imalatların uygun duruma getirilip getirilemeyeceğine, uygun duruma getirilemeyeceklerin yapı niteliğini bozanlarının parasal karşılığını mimar belirler ve iş sahibine bildirir.

Kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra imzalanan "Kabul Tutanağı" ile Mimarlar Odası'na başvurulurak “İş Bitimi Belgesi”¹² alınır.

5) Geri Besleme Çalışmaları İş Aşaması: Mimar, yapının tamamlanıp kullanılma açılmasından sonra kullanıcıların tamamlanmış yapı ile ilişkili tepkilerini ve düşüncelerini derler, değerlendirir, bir sonraki işi için

¹² MHDY’ye göre, **iş bitim belgesi**; mesleki kontrollük ve fenni mesuliyet görevlerini üstlenen mimarın talebi halinde, yapı kullanma izin başvurusundan önce Mimarlar Odası tarafından düzenlenen belgedir.

gerekli dersleri çıkarır, sonuçları bir rapor ile iş sahibine ve Mimarlar Odası'na sunar. Mimarlar Odası, mimarlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, mimara ve iş sahibine herhangi bir yükümlülük getirmeyen bu çalışmaların mimar tarafından yapılmasını yararlı bulmaktadır.

“Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)” nin 7. maddesi gereğince; **Mimari Fenni Mesuliyet (MUS) Hizmeti** İş Aşamaları şu şekilde alt gruplara ayrılır.

1) Mimari Fenni Mesuliyet (TUS)¹³ İş Aşaması: Mimari fenni mesuliyet (TUS) hizmetleri "Mimari Fenni Mesuliyet (TUS) Hizmetleri Şartnamesi"ne göre yürütülür.

Bu iş aşaması, Mimari Mesleki Kontrollüğü (MUS) üstlenmiş mimar tarafından üstlenilebileceği gibi, bir başka mimar tarafından da üstlenilebilir. İş sahibi, mimari fenni mesuliyet (TUS) hizmetlerini, ayrı bir sözleşme düzenlemek koşulu ile bir başka mimara yaptırabilir. Bir yapının Mimari Fenni Mesuliyeti'ni (TUS) üstlenen mimarın yapının inşa edildiği il sınırları içerisinde mesleki faaliyetini sürdürmesi ve sürekli çalıştığı etkinlik bölgesindeki yetkili ve görevli şubeye kaydolması gerekir.

2) Kabul-Teslim İş Aşaması:

Mimar, yüklenici/yapımcının müracaatı üzerine yapıyı inceler ve ilgili kısımlarını inşaat, tesisat ve elektrik mühendislerine incelettirerek, kabulün yapılmasına engel bulunmadığına dair iş sahibine rapor verir. Yapının bu ilk muayenesinde kabulü engelleyen durumlar varsa, bunları belirler ve yüklenici ya da yapımcılardan bu eksik ve kusurların tayin ettiği süre içerisinde giderilmesini ister.

Yerinde yapılan inceleme sonucu yapının sözleşme ve eklerine, projelerine, şartnamelerine ve genel olarak bilinen fen ve sanat kurallarına uygun yapıldığı belirlenirse, yapının kabulü yapılır ve durum bir tutanağa bağlanır. Bu "Kabul Tutanağı" yüklenici/yapımcı, mimar ve iş sahibi tara-

¹³ “Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)” madde 4 de Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Mimari TUS) Hizmetleri ise; 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ile yapı denetimine tabi olmayan yerlerde kamu adına yapıların, yürürlükteki Kanun, İmar planı, ilgili yönetmelik hükümleri, Türk standartları, bilimsel kurallar, teknik şartnameler, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenen yapı ruhsatı eki projelerine göre gerçekleştirilmesinin denetlenmesine yönelik, mimar tarafından üstlenilen mimarlık hizmetleridir. Bu hizmet, imar mevzuatında “Fenni Mesuliyet Hizmetleri” olarak adlandırılan hizmetler kapsamındadır.

findan imzalanır. Proje ve şartnamelere uygun olmayan inşaat ve imalatların uygun duruma getirilip getirilemeyeceğine, uygun duruma getirilemeyeceklerin yapı niteliğini bozanlarının parasal karşılığını mimar belirler ve iş sahibine bildirir.

Kabul işlemlerinin tamamlanmasından sonra imzalanan "Kabul Tutanağı" ile Mimarlar Odası'na başvurularak "İş Bitimi Belgesi" alınır.

Genel mimari hizmetlere ilişkin bu açıklamalardan sonra, şimdi de **İçmimari Hizmetleri**'ne ilişkin açıklamalara geçelim.

TMMOB Mimarlar Odası, "İç Mekan Düzenlemesi ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi" gereğince, içmimari hizmetleri; dekorasyon ve mobilya tasarımı ile seçimi gibi birçok hizmetin alt alta gelmesi ile oluşmaktadır. İçmimari hizmetlerini oluşturan bu iş türleri şöyle gruplandırılmıştır.

1) İç Mekan düzenlemesi ve Dekorasyon hizmetleri:

İç mekan düzenleme ve mobilya tasarımı hizmetleri mimarın standart mimarlık hizmetleri kapsamında yapılan ve tasarladığı yapının bünyesinde yer alan mekanların tefriş ve düzenleme işleri dışında; tasarımı ve/veya uygulama denetimi kendisi veya bir başka mimar tarafından gerçekleştirilmiş bir yapının bünyesinde yer alan iç mekanların yapının kullanım şekli, kullanıcıların istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve mekanın işlevlerine ve boyutlarına uygun olarak sabit ve hareketli mobilya ve dekoratif elemanlar kullanılarak gerçekleştirilen tefriş ve düzenlemeler için mimar tarafından yapılan tasarım ve uygulama aşamalarını kapsayan hizmetlerdir. Bu hizmetler aşağıdaki gibi alt gruplara bölünmüştür.

1.1. Ön inceleme ve eskiz çalışmaları:

Ön inceleme ve eskiz çalışmaları; işveren tarafından verilen ihtiyaç programının incelenmesi, dekorasyonu yapılacak mahallerin incelenmesi, gerekli ise rölövelerinin çıkarılması, eskiz çalışmalarının yapılması ile başlayan mimar tarafından yapılan çalışmalardır. İşveren tarafından verilen "ihtiyaç programı"nın ayrıntılı olarak incelenmesi, tefriş ve düzenlenmesi yapılacak mahallerin yerinde incelenmesi ve çizili projeleri yoksa yada gerektiğinde bu mahallerin basit rölövesinin çıkarılmasıdır.

Eskiz çalışmaları tek öneri şeklinde olacağı gibi bir kaç seçenekli olabilir. İşverenin seçtiği yada değişiklik istediği eskiz çalışması üzerinden anlaşma sağlanır. İşverene sunmak üzere yapılan eskizlere dayanılarak 1. Keşif çıkartılması da bu çalışmaya dahildir.

1.2. Ön proje çalışmaları:

Ön inceleme ve eskiz çalışmaları üzerinde belirlenmiş, yorumlanmış, değerlendirilmiş bilgilerin projeye yansıtılmasıdır. Ön proje çalışmaları üzerinde anlaşma sağlanan eskiz çalışmasına dayanılarak ve yapılacak işin işveren tarafından tam olarak anlaşılmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiş plan, keşif ve görünüşleri kapsar.

Ön projenin tanımlanmasını içeren ve yapılacak imalatların teknik ve tasarım özelliklerini açıklayan rapor hazırlanır. Ön projelere dayanılarak hazırlanmış daha ayrıntılı bir keşif yapılır.

1.3. Uygulama ve detay projeleri:

Ön projeye uygun olarak hazırlanan projeler (uygulama projeleri) ve bununla birlikte yürütülen imalat özelliklerinin, kullanılacak malzemelerin hazırlanabilmesi için yapılan ayrıntılı çizimlerdir. Detaylar uygulama projelerinde belirtilen işlerin her hangi bir açıklamaya ve yoruma ihtiyaç göstermeden tatbik edilebilir nitelikte olmalıdır. Onaylanmış ön projelere göre tüm mahallerin tefriş ve dekorasyon planları hazırlanır ve planlar üzerine gerekli açıklamalar yazılır. Yapılacak imalatlarla ilgili yeterli açıklıkta bilgi veren ve imalat özelliklerini, kullanılacak malzemeleri, renklerini belirleyen ayrıntı çizimleri yapılır. Çizimlerle yeterli ifadesini bulmayan imatlara ilişkin teknik şartname hazırlanır. Bu şartnamede imalat ve montaj özellikleri, malzemeler ve malzeme referansları, renk ve renk referansları, toleranslar vb. bilgiler yer alır.

Uygulama ve detay projeleri Çalışmasında, gerekirse ihale hazırlıkları da yapılır. İhale hazırlığı olarak; özel ve genel koşulların, tarafların sorumluluk ve yükümlülüklerin ihale, teklif verme ve sözleşme koşullarının, imalat ve inşaat süre ve koşullarının belirlendiği şartname hazırlanır. Projeler ve yazılı belgeler incelenmek ve onaylanmak üzere işverene üç nüsha sunulur. Gerekiyorsa “tadilat ruhsatı” başvuru dosyası hazırlanır.

1.4. İhale yapılması:

Proje kapsamındaki çeşitli inşaat ve imalat bölümleri ile ilgili değişik yüklenici, imalatçı yada satıcılardan teklifler alınır. Teklifler karşılaştırılarak incelenir. İşveren’e seçim yapabilmesi için bir rapor olarak sunulur. İşveren tarafından seçilen yüklenici, imalatçı ya da satıcılarla imzalayacağı sözleşmeler ve ekleri hazırlanır.

1.5. Uygulama ve İmalatın denetlenmesi (teslim alma-kabul dahil):

Yüklenici, imalatçı yada satıcılar tarafından hazırlanan imalat resimleri incelenerek onaylanır ve bunların dekorasyon projelerine uyumu sağlanır. İmalat ve montaj sürelerinin belirlendiği iş programı hazırlanır. Atelyelerde yapılan imalatlar kontrol edilir. Şantiyede yapılan imalatlar ve montajlar kontrol edilir. Gerektiğinde imalat ve montajlara yardımcı olacak ilave çizimler yapılır. İşveren ile birlikte işlerin kabulüne katılır, imalatların kabulünde ve malzemelerin teslim alınmasında İşveren'e yardımcı olunur. İş süresince yüklenici, imalatçı yada satıcı hakkedışleri kontrol edilir ve ödenmesi için işverene gönderilir. İş tamamlama teslim alma, geçici ve kesin kabul tutanakları düzenlenir.

2) Mobilya tasarımı

Yapının bünyesinde yer alan ve mimarın standart mimarlık hizmetleri kapsamında yapılan tefriş ve düzenleme işleri dışında mimar özel mobilya yada tefriş ve dekorasyon elemanları tasarımı ve bunların üretim ve denetim aşamalarını kapsayan hizmetlerdir.

3) Mobilya seçimi

Bir yapının iç mekanlarında kullanılacak, başkaları tarafından tasarlanmış, imal edilmiş ve satışa sunulmuş mobilyaların seçilmesi ve satın alınarak kullanılmasında mimar, işverene danışmanlık yapar ve yardımcı olur yada işverenin oluru ile onun adına bu seçimi yapar. Bu hizmet kapsamında, tasarım ve uygulama denetimi ve hizmeti yoktur. Sergilenen katalog üzerinden ya da numunesinden seçtiği mobilya elemanlarının teslimi için; imalatı gerekiyorsa mimar, -işveren kendisinden isterse- imalatın kalitesinde ve seçilen numunesine uygun olmasını denetler.

III. ESER KAVRAMI VE MİMARİ ESERLERİN FSEK'TEKİ YERİ

A. ESER

Uluslararası Sözleşmelerde “eser” kavramı hakkında bir tanım tam olarak yapılmamıştır. Örneğin Bern Sözleşmesi’nde “eser” kavramının tanımı yapılmamakla birlikte, eser türlerinin sayıldığı 2. maddede, eserle ilgili iki önemli özellikten bahsedilmektedir. Bu özelliklerinden biri eserin özgün (orijinal) olması¹⁴ iken diğeri, eserin yaratıcı düşünce ürünü olmasıdır.¹⁵ *Evrensel Fikir Hakları Sözleşmesi*’nde (Universal Copy Convention/ kısaca Evrensel Sözleşme) ise; eserlerin insan aklının emeğinden, insanların düşünce ürünlerinden doğduğu belirtilmektedir.

Yine Bern Sözleşmesi’nin 4. maddesinin b bendinde; bu Sözleşme’de öngörülen korumanın, Birlik ülkelerinin birinde yapılan mimari eserlerin veya Birlik ülkelerinin birinde bulunan bir bina veya diğer yapılarda bulunan diğer sanat eserlerinin sahiplerine uygulanacağı belirtilmiştir.

Bern Sözleşmesi’nde ayrıca yaratıcı düşünce ürünü özgün eserlerin türleri sayılmıştır. Sözleşme’nin 2. maddesinde; edebiyat ve sanat eserleri içinde genel ve ayrıntılı bir sıralama yapılmaktadır. Buna göre; “*edebiyat ve sanat eserleri deyimi, ifade şekli ne olursa olsun, edebiyat, bilim ve sanat alanındaki kitaplar, dergiler ve diğer yazılar, konferanslar, kitaplar, vaazlar, eserler ve gösteri eğlenceleri, sözlü veya sözsüz müzik kompozisyonları, sinema tekniğine benzer bir yöntemle ifade edilen sinema eserleri, çizim, sulu ve yağlı boya resim, mimarlık, heykeltıraşlık, oymacılık ve taş basma eserleri, fotoğraf tekniğine benzer bir yolla elde edilen fotoğraf eserleri, uygulamalı sanat eserleri, resimlendirmeler, haritalar, planlar, krokiler ve coğrafya, topografya, mimari ve bilimsel boyutlu eserler gibi bütün ürünleri içerir*” şeklinde ifade edilmiştir.

¹⁴ Brüksel Anlaşması madde 2/2, Paris Anlaşması madde 2/3.

¹⁵ Brüksel Anlaşması madde 2/3, Paris Anlaşması madde 2/5.

Bern Sözleşmesi, 9 Eylül 1886 tarihli “**Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Sözleşme**” adıyla bu alandaki ilk uluslararası düzenlemedir. Türkiye de bu Sözleşme’yi kabul etmiştir.

Unesco’nun öncülüğünde, 1952 yılında gerçekleştirilen “*Evrensel Fikir Hakları Sözleşmesi*”nde ise; eser türleri bakımından ayrıntıya girilmemiş, sadece 1. maddesinde “*yazılar, müzik, dramatik ve sinematografik eserler ile resim, heykeltıraşlık ve oymacılığı içeren edebiyat ve bilim eserleri sahipleri*” ifadesi ile yetinilmiştir.¹⁶ Türkiye bu sözleşmeyi halen¹⁷ kabul etmemiştir.

Yine Türkiye’nin taraf olduğu 1961 tarihli Roma Sözleşmesi’nde ise; eser kavramı ele alınmamış; “*icracı sanatçı, fonogram, plak yapımcısı, yayım, çoğaltma, radyo ve televizyon yayınları, tekrar yayın*” gibi terimlerin tanımı yapılmıştır.

Bern ile Roma Sözleşmesi ve Avrupa Birliği uyum sürecinde çeşitli Birlik direktiflerinden etkilenecek şekilde şekillendirilen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) ilk maddesi ise **eseri**; “... **sahibinin hususiyetini taşıyan**¹⁸ ve ... **ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulü** ...” şeklinde tanımlamıştır. Maddede belirtilen özellikleri bünyesinde bulunduran bir yaratım, eser statüsünde kabul edilir ve FSEK kapsamında korumadan yararlanır.

Bu yasal dayanaklardan yola çıkarak bir fikirsal yada sanatsal ürünün eser olarak tanımlanabilmesi için gereken özellikleri veya şartları şu şekilde sıralayabiliriz;

1. Sahibinin hususiyetini (özellikliğini) taşıması (**subjektif şart**)
2. FSEK’te öngörülen eser türlerinden birine dahil olması (**objektif şart**).

Sayılan bu özellikler neticesinde bir çalışmanın eser sayılabilmesi için, fikir düzeyinde kalmayıp dış dünyaya yansıtılmış olması da gerek-

¹⁶ Bilge KILIÇ, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı, Legal Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, C.1, S.1, Legal Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2005, s. 108-109.

¹⁷ 2006 yılı için.

¹⁸ “Sahibinin hususiyetinden maksat eserin, sahibinin kişiliğinden aldığı özelliktir.” Mustafa ATEŞ, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerinde Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin Yayınları, Ankara, 2003, s. 57-59.

mehtedir.¹⁹ Söz konusu unsurların bir çalışmada bulunup bulunmadığının tespiti mahkemeler tarafından görevleri gereği araştırılmaktadır.²⁰

1. Sahibinin Hususiyetini Taşması: Subjektif Şart

Bir eserin sahibinin özelliğini taşıyor olması, o eserin daha önceki eserlerden bağımsız olması ve yaratanın fikirsel veya sanatsal emeği sonucunda var olması demektir. Elbette bu ifadeden “*daha önce hiç yapılmamış olanın yapılması*” anlamı çıkmamalıdır. Başka bir eserden esinlenmek, ilham almak mümkündür; ancak, bu ilham veya esinlenme başkasının eserini gaspa veya intihale²¹ yahut taklide²² varacak ölçüde olmamalıdır. Başkasına ait bir esere, küçük veya büyük bazı fikirsel ve sanatsal katkılar ekleyerek sahiplenilmesi etik açıdan ve hukuken yasaktır. İşte tam bu anlamda eser; bağımsız olmalı, yaratıcısından izler taşımalıdır. Hirsch²³ ve

¹⁹ Halil ARSLANLI, Fikri Hukuk Dersleri, II: Fikir ve Sanat Eserleri, İstanbul, 1954, s. 2-3; Mustafa Reşit BELGESAY, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 1955, İstanbul, s. 14; Şeref ERTAŞ/ K. Emre GÖKYAYLA, “Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı” Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yay., İzmir, 2000, s. 408 Naklen SULUK/ORHAN, Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, Cilt II, Genel Esaslar Fikir ve Sanat Eserleri, Arıkan Yayınları, İstanbul, 2005, s.141-142.

²⁰ “Davacı, kendisinin maddi yükünü de yüklenerek yaptığı kazılarda çıkan eserler hakkında yayın yapma hakkının kendisine ait olduğu halde davalı tarafından, haksız olarak bir kısım eserlerin resim ve krokilerini yayınlamak suretiyle kendisinin hakkına tecavüz edildiğini ileri sürmüştür. Mahkeme ise kazılarda çıkarılan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümlerine göre değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir. Zira Yasanın isminden de anlaşılacağı üzere bu Yasanın uygulanması için ortada kişinin yarattığı bir eserin mevcut olması gerektiğini vurgulamıştır.” 4.HD., 1.7.1978, E. 1976/5913, K. 1977/7617; Senai OLGAC, Fikir Hakları ve Yayın Sözleşmeleri, Ankara, 1979, s.99; Gürsel ÜSTÜN, Fikri Hukukta İşleme Eserler, Besam, İstanbul, 2001, s. 4 vd. Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 134 vd. (Yargıtay Kararları No: 3)

²¹ İntihâl, başkasına ait bir eseri kendine mâl etmedir.

²² Yargıtay bir kararında; “bir kitabın maksadını haklı gösterecek orandan fazla şekilde; alıntılar, benzetmeler yaparak, dil, üslup, dizayn, örnekleme konularında davacıya ait kitaptan alıntılar yapılmak suretiyle kitabın bu şekilde içerik ve sayfa düzeninde birebir benzerlikler göstermesini taklit olarak kabul etmiştir.” 11.HD., 26.1.1995, E. 1994/7727, K. 1995/461. (Yargıtay Kararları No: 8)

²³ HIRSCH, Hukuki Bakımdan Fikri Say. C. II, Fikri Haklar (Telif Hukuku), İstanbul, 1943, s. 12.

Ayiter²⁴, hususiyet kavramını “*herkes tarafından vücuda getirilmeyen, yani ancak yaratıcı bir fikri çaba mahsulü*”; Yarsuvat²⁵, “*orijinal, yani özgünlük ölçütünün olması*”; Erel²⁶ ise, “*yaratıcı gücün yansıması*” şeklinde değerlendirmişlerdir.

Kanaatimizce, bir yaratının sübjektif şarta sahip olmasını; eser sahibinin kendi emeği sonucunda, varolanlardan önemli ölçüde değişik (yoksa “taklit” olur, “eser” olmaz) bir ürün yapılması ve bu yapılan ürünün eser sahibinden izler taşıması olarak değerlendirebiliriz.

Yargıtay bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında²⁷; yaratının “eser” sayılıp sayılmaması açısından, “somut şekilde **bağımsız bir çalışma ve emek unsurunun varlığı**”nı barındırıp barındırmadığı ve **özgünlük** taşıyıp taşımadığı” hususlarının belirleyici olacağını söylemektedir.

Görüldüğü gibi sübjektif şarta ilişkin olarak, kesin çizgilerle bağımsızlık ve daha önce yapılanlara hiçbir şekilde benzemezlik şartı aranmamaktadır. Fikri Hukuk; mevcut malzemenin başka türlü şekillendirilmesini, tasnifini yahut mevcut bir fikir veya anlayışın farklı tarzda incelenmesini, açıklanmasını veya yorumunu da kabul etmektedir.²⁸ Nitekim bazı bilimsel eserlerde, sözlüklerde, haritalarda²⁹, içtihat dergileri ve benzerlerinde eser sahibinin özelliği; kullanılan bilimsel ve teknik malzeme arasında belirgin şekilde fark edilmeyebilir. Buna rağmen bu tarz çalışmalarda belirlenen fikri emeğin korunması gerektiği şüphesizdir ve yukarıda açıklandığı anlamda “sahibinin özelliğini taşıma” şartı var olduğu ölçüde, bunlar da eser sayılırlar.³⁰ Ancak taklitçilikte bu sübjektif şart bulunmaz

²⁴ Nuşin AYİTER, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, 2. Bası, Ankara, 1981, s.6 Naklen SULUK/ORHAN, age., s.142.

²⁵ Duygun YARSUVAT, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Bası, İÜSBF Yay., İstanbul, 1984, s. 41 Naklen SULUK/ORHAN, age., s.142.

²⁶ Şafak EREL, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998, s.27.

²⁷ 11. HD., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672. (Yargıtay Kararları No: 58)

²⁸ Halil ARSLANLI, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir Ve Sanat Eserleri, İstanbul, 1954, s. 7 Naklen EREL, age., s.27-28.

²⁹ “Davacının çizmiş olduğu haritanın, davalılarca izinsiz çoğaltılarak ücretli ve ücretsiz dağıtılması nedeniyle açılan ve çizilen haritanın bağımsız bir emek sonucunda, **özgün şekilde yapıp yapılmadığının** tespitinden sonra yapılan tecavüzün FSEK kapsamında değerlendirilmesine ilişkin bir davadır.” 11.HD., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672. (Yargıtay Kararları No: 58)

³⁰ EREL, age., s.34.

ve Yargıtay taklitçiliği veya başkasının eseriyle çok benzer eserler oluşturmayı FSEK'e aykırı bulmuş ve bu nedenle tazminata hükmetmiştir.³¹

Eserin sahibinin özelliğini taşıması şartının kabul edilmesi ile, meydana getirilen fikirsel veya sanatsal eser ile eser sahibi arasındaki bağ ortaya konmuş olur. Böylece herkes tarafından kolayca veya rasgele meydana getirilebilecek fikir ve sanat ürünlerinin tamamının eser sayılması da önlenmiştir.³² Örneğin bir mimar tarafından inşaat projesinin çizilmesinde, ortaya çıkan fikir ürününün eser sahibinin özelliğini taşıdığını söyleyebiliriz. Buna karşılık, mimariden anlamayan bir kimsenin, rasgele bir mimari taslak çizmesi, bu taslağın eser niteliğini taşıdığını göstermez. Yine yurt dışında bir yabancı mimarın özelliğini taşıyan bir yapıyı gören ve bunu İstanbul'da yapılan bir iş merkezinde taklit eden bir türk mimarı, yapının başka bir mimar tarafından İzmir'de taklit edilmesi karşısında, yaratım kendi özelliklerini taşımadığından hukuksal korumadan tam olarak yararlanamaz.

2. FSEK'te Öngörülen Eser Türlerinden Birine Dahil Olması: Objektif Şart

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, yukarıda anılan 1. maddesiyle bir çalışmaya ilişkin olarak “eser” niteliğinin tespitinde subjektif şartın yanında, insan duyularıyla doğrudan yada dolaylı olarak algılanabilir olmasını aramaktadır. Yani henüz düşünce olan gerçek hayata yansımayan fikirler FSEK korumasından yararlanamazlar. Gerçek dünyaya yansıyan fikirlerin eser olabilmesi için ise; FSEK'te yer alan ve sınırlayıcı bir şekilde eser olarak sayılan,

1. İlim ve edebiyat eserleri,
2. Musiki eserler,
3. Güzel sanat eserleri,
4. Sinema eserleri veya

³¹ “Davacının eseri olan “En Zayıf Halka” isimli yarışma programının davalı şirketçe izin alınmadan ve anlaşma olmaksızın; aynı format, içerik ve kurallarla “Kim Gitsin” ismiyle yayınlanması nedeniyle tecavüz edildiğine ilişkin açılan davada; davalının eylemleri FSEK'e aykırı bulunmuş ve tazminata hükmedilmiştir.” 11.HD., 21.9.2004, E. 2003/12452, K. 2004/8678. (Yargıtay Kararları No: 53)

³² Şeref ERTAŞ/ K. Emre GÖKYAYLA, Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah EDİS'e Armağan, İzmir, 2000, s. 409.

5. İşleme ve derleme eserler

kategorilerinden birine girmesi gerekmektedir.

Sayılan bu eser kategorilerinin içindeki eser türleri açısından ise; örnekleme yöntemi geçerli olup, zaman içinde farklı alt türler çıkabilir. Sözgelimi ilim ve edebiyat eserleri kategorisi içinde yer alan eser çeşitleri FSEK’de “*herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan eserler ve her biçim altında ifade edilen bilgisayar programları ve bir sonraki aşamada program sonucu doğurması koşuluyla bunların hazırlık tasarımları; her nevi rakslar, yazılı koreografi eserleri, pandomimalar ve buna benzer sözsüz sahne eserleri; bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya (bu sayılanlara) ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, mimari maketler, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri*” şeklinde sayılanlarla sınırlı değildir. Değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler sonucunda bambaşka tür eserlerin ortaya çıkması mümkündür. Ancak bunların eser olduğunun tespiti ve hangi kategori içinde değerlendirileceği netleştirilmelidir.

Pozitif hukuk bakımından eser niteliğinin tespiti için şekil unsuruna yer verilmesinin en önemli sonucu, fikirsel ürünün bu şekil altında ifadesi halinde eser olduğu karinesinin doğmasıdır.³³

B. FSEK’TEKİ MİMARİ ESERLER KAVRAMI

Mimarın, mimari eserleri meydana getirmesinin bir aşamasını oluşturan (ve fikir aşamasını geçmiş) hazırlık çalışmaları ve diğer aşamasını oluşturan yapılar³⁴ iki farklı grup mimari eserler olarak FSEK’te ayrı ayrı eser türleri içerisinde değerlendirilmektedir.

Konut, işyeri, alışveriş merkezi, fabrika, depo, köprü, kule, müze veya sanat merkezi gibi ne amaçla düşünülmüş olursa olsun bir yapının ortaya çıkması, fikir halinden dış dünyaya yansıyacak somut boyuta gelebilmesi için; öncelikle tasarlanması gerekmektedir. Söz konusu tasarımlar; projeler, planlar, krokiler veya maketler şeklinde olabilmektedir. Bu anlamda mimari yapının oluşumu sırasında başvurulacak krokiler, avan proje-

³³ AYİTER, age., s. 39 Naklen EREL, age., s.38.

³⁴ “Mimarlık-Mühendislik Hizmetleri Ve Asgari Ücret-Asgari Çizim Ve Düzenleme Esasları Yönetmeliği (Mim-Müh HAÇDEY)” madde 4’e göre **Yapı**; karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların parçalarını ifade eder.

ler, projeler veya planlar, tasarımlar, maketler -şartlarının mevcudiyeti halinde- mimari eserler olarak FSEK kapsamında korunacak eserlerdir. FSEK madde 2 de yer alan **“İlim ve Edebiyat Eserleri”** başlığı altında *“bedii vasfı bulunmayan her nevi teknik ve ilmi mahiyette fotoğraf eserleriyle, her nevi haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler, coğrafya ve topografyaya (bu sayılanlara) ait maket ve benzerleri, her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri, endüstri, çevre ve sahne tasarım ve projeleri”* ilk gruba giren mimari eserlerdir.

FSEK madde 4 de yer alan **“Güzel Sanat Eserleri”** başlığı altında estetik değere sahip olan (bedii vasfı bulunan) **“mimarlık eserleri”** yani *yapılar* da ikinci grup olarak FSEK tarafından korunan mimari çalışmalardır.

Bir yapı olarak ortaya çıkmış mimari eserlere, mimari yapının kendisine ve mimari eserin hazırlık çalışmalarına uygulanan FSEK hükümleri değindiğimiz gibi farklı maddelerde incelenmişlerdir. Dolayısıyla FSEK dahilinde korunabilmeleri için ortaklaşa genel şartların yanında farklı şartlar da aranmaktadır. FSEK madde 4 de yer alan mimari eserlerin korunması için *“estetik nitelik”*te olması aranır; oysa FSEK madde 2 de mimari yapının planı ve projesinin *“teknik ve ilmi özellik”*te olması gerek-mekte ancak bedii vasfı³⁵ taşıması aranmamaktadır. Çünkü bedii vasıf olması halinde mimari çalışma 4. maddedeki güzel sanat eserleri grubuna girer. Ancak bedii vasfı bulunmayan bilimsel ve teknik nitelik taşıyanlar ise, 2. maddedeki ilim eseri sayılmaktadır.

Yapılan açıklamalar dahilinde, FSEK madde 2 de yer alan mimari plan ve projeleri ve FSEK madde 4 de yer alan *“mimarlık eseri”* olan *“mimari yapı”* kavramını ayrı başlıklar altında irdelemek gerekmektedir.

1. FSEK madde 2/b.3 de Yer Alan Mimari Yapının Plan ve Projeleri

Mimarlığın uygulanması, kentsel planlama ve tasarım, inşaat, ek inşaat, koruma, restorasyon ve bir binada veya bir binalar grubunda kullanım değişikliği gibi mesleki hizmetlerin yapılmasından oluşur.³⁶ Bu mes-

³⁵ Bedii; örneği olmayan, güzel, nadide, güzellik ölçülerine uyan, beğenilen anlamına gelir.

³⁶ Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) Mimarlık Pratiği İçin Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat Metni'nin Politikalarına İlişkin Öneri Kılavuzları, Kodlar, Standartlar, Üretim Bilgileri, Şartnameler Ve Diğer İnşaat Dokümanları (UIA Mesleği Uygulama Komisyonu'nun 4-5 Nisan

leki hizmetlere, planlama, arazi kullanım planlaması, şehir planlama, hazırlık çalışmaları, tasarımlar, maketler, çizimler, şartnameler ve teknik dokümanlar, başkaları (danışman mühendisler, şehir plancıları, peyzaj mimarları ve benzeri diğer uzmanlar) tarafından hazırlanmış bulunan teknik dokümantasyonun gerektiği şekilde ve herhangi bir sınırlama olmasının koordinasyonu, inşaat ekonomisi, sözleşme uygulaması, inşaatın denetlenmesi (bazı ülkelerde “kontrol” olarak da tanımlanır) ve proje yönetimi de dahildir.

Bu açıklama doğrultusunda mimarların faaliyetlerinin ana kısmını oluşturan ilk grup mimari eserlere ve bunların tanımlarına geçelim.

Plan; bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim olarak tanımlanabilmektedir.³⁷

Avan Proje (Ön Proje); belli bir yapının kesin ihtiyaç programı, öngörülen maliyet tavanı, arsa verileri ve varsa proje yarışmasındaki jüri tavsiyesine uygun çözüm getiren projedir. Ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesit, görünüşler ve mimari rapor bulunur.³⁸

Kesin Proje; belli bir yapının onanmış ön projesine göre bu aşama için gerekli gelişmeleri de kapsayan, tüm yapı elemanlarının ölçülendirilip inşaat sistem ve gereçlerinin belirtildiği projedir.³⁹

Uygulama ve Detay Projeleri; belli bir yapıya ait onanmış kesin projeye göre, bu aşama için gerekli gelişmeleri, detaylara uygun ölçüde mimari elemanları, statik ve tesisatın inşaatı etkileyen ölçülerini, detay referanslarını ve gereç açıklamalarını kapsayan ve inşaatın her safhasında büro ve şantiyede kullanılabilecek nitelikte hazırlanmış olan projelerdir. Uygulama projesinde kat ve çatı planları ile kesit ve görünüşler de bulunur.⁴⁰

Uygulama projesi; sistem, montaj ve imalat detay planları ile birlikte gerçekleştirilir ve bunlar hep birlikte bir bütün oluşturulur. Bu detay plan-

2003 tarihinde Tokyo’da yaptığı toplantıda gözden geçirilmiş 28 Şubat 2003 tarihli taslaktır.) www.mo.org.tr adlı siteden alınmıştır.

³⁷ www.tdk.gov.tr

³⁸ MMHŞ, md.9.1.1.

³⁹ Göktürk UYAN, İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Beta Yayınları, 1. Bası, İstanbul, Şubat 2006, s. 24.

⁴⁰ MMHŞ, md. 9.1.3.

ları daha büyük ölçekte (1/20, 1/5 veya 1/1 ölçeklerinde) hazırlanırlar.⁴¹ Uygulama projesi, yapının maliyet tavanının belirlenmesi amacıyla yapılan metraj ve keşiflerinin esasını oluşturur.⁴²

FSEK madde 2/b.3 de mimari eserler; plan, proje, mimarlık tasarımı ve projeleri, mimari maketler şeklinde sayılmıştır. Bu sayılanlar sınırlı olmayıp sadece örnek olarak verilmiştir ve bu örnekler arttırılabilir. Avan projeler de bu sayılanlara eklenebilir. Bu maddede iç mimari ve peyzaj gibi mimarinin yan dallarından örnek verilmemesi, bu yan dalların kapsam dışında kaldığını göstermez.

Söz konusu maddede yer alan mimari proje kavramı “ilim eseri” olarak tanımlanmaktadır. Böylece mimari projeler, bilimsel güvence altına alınmış olmaktadır. Bu eserlerin tespit edildiği materyal önemli değildir. Bu eserler kağıda olduğu gibi manyetik ve dijital ortamların üzerine iki ya da üç boyutlu olarak tespit edilebilir.

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun bu hükmü 4110 sayılı Kanun değişiklikleriyle getirilmiştir. 1901 tarihli Alman Telif Hakları Kanunu'ndan esinlenerek alınan bu bentte sayılanlar açısından, estetik (bedii) nitelik önem taşımaz; şayet estetik özelliği de bulunuyorsa, o eser ayrıca güzel sanat eseri olarak da korunmaktadır.

İlim eseri kategorisine giren eserlerin amacı, *belirli bir bilimsel veya teknik konuyu yüzey yada cisim halinde canlandırarak öğretmek yahut açıklamaktır.*⁴³

Yaratılan plan ve projelerde veya mimarlığa ait maket ve benzerlerinde yaratıcının özelliği bulunmalıdır. Ancak bu özelliğin tespiti, diğer eserlere göre daha zordur; zira herkes tarafından yararlanılıp uygulanacak bilimsel ve teknik verilerle metotlar kullanılarak meydana getirilecek eserler arasında zorunlu bazı benzerlikler olacaktır. Bu durumda eserin bağımsız bir çalışma ürünü mü olduğu, yoksa önceki bir eserden kopya mı edildiği araştırılmalıdır. Bağımsız ve yaratıcı bir fikri çalışmanın varlığı tespit edilebildiği sürece, aynı bilimsel ve teknik konuya ait olmaktan doğan benzerlikler, bu şekilde meydana getirilmiş eserlerin her birinin korunmalarına engel değildir.⁴⁴ “Bu tür eserlerde sahibinin özelliğini taşıma

⁴¹ MMHŞ, md. 9.14; MİM HŞEABT, md. 2.2.4; MPÇSS, md.9.

⁴² MİM HŞEABT, md. 2.2.4.

⁴³ EREL, age., s.42.

⁴⁴ EREL, age., s.43.

kıstası, orijinal olmaktan çok, sarf edilen bağımsız emek unsurunda aranmalıdır”⁴⁵ diye bir görüş de ileri sürülmesine rağmen, yaratıcılık taşıyan emek ne kadar çok ve yoğun olursa olsun “eser” kapsamına giremediğinden; bizce, FSEK korumasından yararlanamaz. Hele günümüzde mimarların kullandığı bilgisayar programlarında bulunan tip projeleri düşündüğümüzde bu yorum daha da amaca uygun olmaktadır.

Erel, “FSEK madde 2 bent 3 hükmünde 4110 sayılı Kanuna eklenen “... her çeşit mimarlık ve şehircilik tasarım ve projeleri,” ibaresini, gereksiz bularak; maddenin “*bedii niteliği bulunmayan her nevi teknik ve bilimsel nitelikteki fotoğraf eserleri, her türden haritalar, planlar, projeler, krokiler, resimler ile coğrafya, topografya ve mimarlığa ait maketler ve benzerleri*” şeklindeki eski halinin bunları da kapsayacak genişlikte olduğunu söylemektedir. Erel’in işaret ettiği bu noktaya esasen bizde katılmaktayız; zira daha öncede bahsettiğimiz gibi Kanunda yer alan kategorilerin içerisinde yer alan eser türleri örnek mukabilinde sayılmış ve değişen şartlar dahilinde içtihatlar veya kıyas yoluyla bunlara her zaman yenilerinin ilave edilmesi mümkündür.

Avrupa Topluluğu ve Türk Hukuku’nda; mimarlık, çevre ve şehircilik⁴⁶ gibi taşınmaz yapı tasarımlarının⁴⁷, Tasarım Mevzuatı olan 554 sayılı **Endüstriyel Tasarımların Korunmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname**’ye (EndTasKHK) göre korunup korunmayacağı hususunda açık bir hüküm bulunmamakla birlikte ağırlıkta olan görüşe göre, taşınmaz tasarımları sadece FSEK hükümlerine göre korunup, tasarım mevzuatıyla korunmaz.⁴⁸ Fakat bunların içinde yer alan nesnelerin tasarımları Tasarım Mevzuatına göre korunmaktadır. Örneğin kapının, pencerenin, çitin ve mobilyaların tasarımları bu şekilde korunur.

⁴⁵ Hamide TOPÇUOĞLU, Fikri Haklar Ders Notları, Ankara, 1964, s. 41 Naklen EREL, age., s.43.

⁴⁶ Şehir planlarının eser olarak kabul edilebilmesi için; çalışmada teknik ve ilmi bir mahiyet bulunmalı ve ayrıca açıklayıcı ve yol gösterici olmalı, ayrıca Yargıtay’ın 11.HD.’nin 10.10.2002 tarihli ve 8275/8839 sayılı kararında da belirttiği gibi hususiyet (yaratıcısının özelliğini taşıma) unsurunun da bulunması gerekmektedir.

⁴⁷ Mimari eserler, FSEK m. 2 ve 4’te ayrı ayrı düzenlenmiştir. 2. maddede mimari tasarım ve projeler düzenlenmiştir. 4. maddede ise, mimari eserin bizzat kendisi eser sayılmıştır. Bunların koruma şartları birbirinden farklıdır. Anılan bu iki maddedeki şartları karşılamak kaydıyla bir mimari plan ve proje uygulanarak oluşturulan bir yapıda, iki ayrı eser var olacaktır. Bkz. ERTAŞ/GÖKYAYLA, age., s. 412.

⁴⁸ SULUK/ORHAN, age., s.166.

Mimarlığın bir çalışma alanı da iç mimaridir. Özellikle iç mimarın, iç mekanlara ilişkin binanın parçası olan düzenlemeleri yukarıda anlattığımız **FSEK** madde 2/b.3'e göre korunmaktadır. Pencerelerin yeri, salonun şekli ve görüntüsü, odaların ve diğer yaşam alanlarının konumlanması, tüm yaşam alanlarının yüksekliği, şekli, derinliği, ışıkla ilişkileri, renklerle ilişkilerine dair tasarımlar ve projeler FSEK 2/b.3 kapsamında, bunların bitmiş ve uygulanmış hali ise “yapı”ya dahil biçimde FSEK 4. madde kapsamında korunmaktadır. Öte yandan iç mimarının yoğun kullanımı; eşyaların yerleştirilmesi, eşyaların dizaynı ve şekline de odaklanmaktadır ve bunların tasarım, plan ve projeleri de FSEK 2/b.3 kapsamında korunur.

Krokiler, resimler, maketler, tasarımlar ve benzeri eserlerin endüstriyel model ve resim olarak kullanılması, düşünce ve sanat eseri olma sıfatlarını etkilememektedir. Şayet her iki mevzuata göre aranan şartlar mevcutsa, bu durumda FSEK ve EndTasKHK korumasından da faydalanılmaktadır.

2. FSEK madde 4/b.3 de Yer Alan Mimarlık Eserleri

Güzel sanat eserleri görme duyumuza hitap ederek estetik bir haz uyandıran, bir yüzey üzerinde yahut cisim halinde oluşmuş fikir ürünleridir. Güzel sanat eserlerinin herhangi bir şekilde dil ile ifadeleri söz konusu değildir ve bunlar durağan (statik) nitelikte olduklarından, kural olarak sabit bir ifade⁴⁹ ve tespit vasıtasına ihtiyaç gösterirler.⁵⁰ Hem bu özelliği, hem de *mutlaka taşımaları gereken “estetik nitelik”* nedeniyle, güzel sanat eserleri diğer eser kategorilerinden ayrılır.

Güzel sanat eserinin yaratılmasında kullanılan malzemenin ve eserin tahsis amacının önemi bulunmamaktadır. Malzeme olarak altın, demir, taş, tuğla, tahta, seramik, buz ve hatta bahçe mimarisinde olduğu gibi bitkiler kullanılabilir. Keza, sırf sanat amacıyla meydana getirilmiş eserler kadar,

⁴⁹ Günümüzdeki bazı sanat eserlerinde, bu sabit ifadenin yanı sıra değişen ifadelerin de olduğunu unutmamak gerekir. Bu yüzden tanımdaki aslına sadık kalmak amacıyla metin olduğu gibi verilmiştir. Ama “sabit bir ifade” ibaresi tanımdan çıkarılabilir de.

⁵⁰ ARSLANLI, age., s. 23, not 2; mamafih ses ve ışık gösterilerini de, statik nitelikte olmasalar bile gerekli özellik ölçülerine uymak ve estetik değer taşımak kaydıyla güzel sanat eseri saymak gerekir kanısındayız. AYİTER, mimari bir mekan içinde cereyan eden ses ve ışık gösterilerini, Kanundaki eser kategorilerinden hiçbirine girmeyen yani bir eser türü saymaktadır. (AYİTER, age., s. 46) Naklen EREL, age., s. 47.

el işleri yahut bir süsleme sanatıyla bezenerek estetik nitelik kazandırılmış gündelik eşya da güzel sanat eseri sayılabilir. Diğer taraftan sanat eserinin tek parça halinde yaratılmış olması da şart değildir; muhtelif parçaların bir araya getirilmesiyle elde edilen estetik görüntü, bahçe veya peyzaj mimarisi, mimari külliyeler, tiyatro dekorları vs. de güzel sanat eseri olarak korunabilir.⁵¹

Ayrıca güzel sanat eserlerinin diğer bir özelliği de bunların tek olmalarıdır. Ancak eserin farklı parçalarının bir araya getirilmeleriyle yaratılıyor olması o eserin tek olmadığı anlamına gelmemektedir. Orijinali tek olan bir güzel sanat eserinin mekanik veya reprografik araçlarla yahut seri üretimle kopyalar çıkarılması sadece çoğaltma hakkını ilgilendiren bir husustur; yoksa ortaya yeni bir güzel sanat eseri çıkmış olmaz.⁵² Örneğin bir mimarın kendi kişisel özelliklerini kullanarak tasarladığı bir binanın sitede altı tane olarak yapılması veya bir içmimarın yaptığı koltuğun, sandalyenin veya masanın maketini yapmasının ardından bunun seri üretim halinde piyasaya sunulması çoğaltma hakkının konusunu oluşturmaktadır

FSEK madde 4/b.3 de yer alan mimari eserler, FSEK madde 2/b.3 de bulunan ilim ve edebiyat eserleri arasında sayılan mimari tasarım, plan ve projelerden farklıdırlar. Orada tasarım, plan ve projelerin çizimleri korunurken, burada estetik değeri olmak şartıyla yapının özellikle kendisi korunmaktadır.⁵³ Plan, kroki ve maketler, yukarıda belirtildiği üzere md.2/b.3 hükmüne göre bilimsel fikir eseri olarak korunurlar; bunların korunması için mimarın az çok bağımsız bir fikri çalışması sonucu olmaları yeterlidir. Halbuki bunların uygulanmasıyla ortaya çıkacak mimari yapı sadece mimarın özelliğini yansıtmakla değil, aynı zamanda **estetik nitelik** taşımak şartıyla korunabilir.⁵⁴

Mimari yapılar az veya çok projeyi yapan mimarın özelliğini taşır, fakat bir mimari yapı her şeyden önce fonksiyonel olmak, belirli ihtiyaçları karşılamak zorundadır. Bu zorunluluk mimarın serbest yaratma im-

⁵¹ EREL, age., s.47.

⁵² EREL, age., s.47.

⁵³ ARSLANLI, age., s. 24; s.26; YARSUVAT, age., s.63 Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 205.

⁵⁴ EREL, age., s.48.

kanlarını kısıtlayacağından, yapının estetik niteliği de ona göre değerlendirilmelidir.⁵⁵

Kanun'un bu maddesinde geçen "mimarlık" kelimesinin içerisine; iç mimari, peysaj, kentsel tasarım gibi mimarlık alanına dahil olan diğer alanlar da girmektedir. Böylece bu alanlardaki eserler de FSEK'deki korumadan faydalanmaktadırlar.

Mimarlık eseri olarak yapı, taşınmaz niteliğinde olduğu için kural olarak EndTasKHK'nın korunmasından faydalanamaz. Ama yapının içindeki iç mimaride kullanılan eşyaların şartlarını taşıması halinde hem FSEK kapsamında hem de EndTasKHK'nın kapsamında korunacağını tekrar belirtiriz.

⁵⁵ Mimari eserlerin korunmasında "estetik hususiyetten vazgeçmenin daha uygun olacağı" yolundaki fikir (Ayiter, age., s. 58 ve orada anılan Troller) FSEK md. 4/1'in açık ifadesi karşısında kabul edilemez.

IV. ESER SAHİPLİĞİ KAVRAMI VE FSEK'TEKİ MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ

A. ESER SAHİPLİĞİ

MHDY'e göre, **proje müellifi**; 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanun'u ve 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre, tasarladığı projenin müelliflik hakkını kazanmış eser sahibi mimar ya da mimarlardır.

Aynı Yönetmelik, **eser sahipliğini** ise; mimarın 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre kazandığı başkasına devredilemeyen hakkı olarak tanımlanmıştır.

FSEK madde 8/1 hükmü kısaca, “bir fikir ve sanat eserinin sahibi onu vücuda getirendir” demektedir. Eser kavramını incelerken değinildiği üzere, her türlü fikir ürünü değil; sadece eser sahibinin özelliğini taşıyanlar eser sayılacağından, eser sahibi, *yaratıcı gücünün özelliğini meydana getirdiği fikir ve sanat ürününe yansıtan şahıstır*. Bu tanımdaki eser sahibinin onu yaratan gerçek kişi olacağı ifadesi, yaratma gerçeği ilkesi olarak anılmaktadır. Bu ilkenin kaynağı tabii hukuk olup, sahibinin hususiyetini taşıması şartıyla uyum içinde bulunmaktadır. Zaten tüzel kişilerin içinde bulunan gerçek kişilerden ayrı fikirselsel ve sanatsal faaliyetleri bulunmadığı için fikri ürün yapmaları da mümkün olmamaktadır.

FSEK madde 8 de bulunan “bir eserin sahibi onu meydana getiren- dir” ana kuralı çerçevesinde; bir mimarlık eserinin sahibi de onu meydana getiren kişidir. Bu kişi çoğunlukla mimar olup, kimi zamanda mimari diploması olmayan biri de olabilir.⁵⁶ Ana kural bu olmakla birlikte; çalışma ilişkisi olan bazı hallerde Kanun onu bizzat üreten veya yaratandan başkasına esere ilişkin “sahiplik” ölçüsünde bazı haklar tanımaktadır. Bu

⁵⁶ Ancak daha önce genişçe açıkladığımız gibi mimar veya iç mimar olmayan birinin eseri yaratmasından sonra bunu uygulayabilmesi sorunludur. Zira mimar olmayanların sanat icra etmesine ilişkin yasaklama ve hapis cezaları söz konusudur. Fakat bu düzenleme, eser sahibinin mutlaka mimar olmasını ve mimarın da Odaya kayıtlı olmasını veya yetkisinin sınırlandırılmış olmamasını gerektirmez. Başka bir ifade ile mimar olmayanlar veya yetkisiz mimarlar da eser sahibi olabilir. Bkz. II. MİMAR VE MİMARİ HİZMETLER bölümünde mimarın anlatıldığı kısım.

hallerde eser sahibi gibi sayılan kişinin, eserin yaratılması faaliyetine katkısı; onun özünü oluşturan “özgün fikir ürününü meydana getirmek” değil; bu ürünün ortaya çıkışını sağlayan bir takım hukuksal ve ekonomik ilişkilerde bulunmasıdır.

Bu ekonomik ve hukuksal ilişkiler, eseri; eser sahibiymiş gibi işverenlerin veya sözleşmesel ilişki sahiplerinin kullanmasına yol açabilir. Aslında eser sahibi yine yaratıcıdır; ancak, eser sahibinin eserden doğan bazı haklarının kullanımı bu kişilere geçmiştir. Bu kullanım çoğunlukla mali hakların kullanılmasıyla ilgilidir; yoksa eserin sahibinde ve manevi hakların eserin yaratıcısı tarafından kullanılması durumunda bir değişiklik yoktur. Söz konusu haller; çalışanların işleri gereği yaptıkları eserlerde ortaya çıkmaktadır. FSEK 18/II de; *“aralarındaki özel sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça; memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserler üzerindeki haklar bunları çalıştıran veya tayin edenlerce kullanılır. Tüzel kişilerin uzuvları hakkında da bu kural uygulanır.”* hükmü düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre; bir kişinin yanında çalışan kişilerin, ürettiği eserlerin mali haklarını kullanma yetkisi çalıştırana aittir. Her ne kadar maddede “haklar” ibaresi yazılmakta ise de, bu ibareden anlaşılması gereken sadece mali haklardır. Manevi haklar yine eser sahibince kullanılmaya devam eder.

FSEK 18. maddeye göre bir mimari eserin yaratımı; çalıştıran ve tayin eden gerçek veya tüzel kişinin memuru, işçisi veya hizmetlisi tarafından yapılmış olursa ve eserin üzerindeki (mali) hakların işçi veya hizmetli tarafından kullanılacağı özel olarak bir sözleşme ile düzenlenmemişse veya işin mahiyetinden “bu eserlerin mali hakları çalışanlarıdır veya mali hakları çalışanlarca kullanılır” şeklinde bir sonuç çıkarılması mümkün değilse, mimari planı veya projeyi hazırlayan kişi eserin sahibi olmakla birlikte, eserden kaynaklanan mali hakları ve her türlü yararlanma, kullan-dırma ile devir haklarını işveren kullanır. Bu sistemi sürekli iş ilişkisine özgüleyebiliriz. Sigortalı veya sigortasız olarak bir işverenin yanında çalışanların, çalışma dönemi içinde yarattıkları eserlerin hakları işverence kullanılır.

Ancak çalışan ve işveren arasındaki özel bir sözleşmede veya işin mahiyeti açısından aksinin gösterilmesi hallerinde mali hakların işverence kullanılması sistemi işlemez. İşin mahiyetinin aksini göstermesi çeşitli biçimlerde olabilir. Mesela bir mimar, mimarlık şirketine idareci veya kontrolör olarak girmiştir ve hizmet sözleşmesi veya iş tanımında bu görev tanımı açıkça bellidir. Bu durumda çalışan idareci mimar, görev tanımının

dışında bir çalışma yaparak bir eser yaratmışsa, bu durumda FSEK madde 18 bu esere uygulanmaz ve mali haklar işverence kullanılamaz.

Buradaki “kullanma” kavramına da değinmek gerekir. Mali haklar işverence kullanılırken, gelirler ve nemalar açısından eser sahibi adına vekaletli veya vekaletsiz olarak bir iş mi görülmektedir? Yani önce işveren kullanacak sonra gelip parayı çalışana mı verecektir? Bu soruların yanıtı “hayır” olmalıdır. İşveren kullanır ve nemaları kendisinde kalır. Çalışanın gidip, “sen bu hakları benim adıma kullandın, getir parayı veya yarısını ver” diyemez. Çünkü çalışan bu çalışmayı işveren adına yapmaktadır ve mali anlamda karşılığını almaktadır. Tabii ki çalışan ve işveren arasında başka bir paylaşım sözleşmesi varsa, o zaman sözleşme hükümleri doğrultusunda mali haklar kullanılır ve çalıştıran sözleşmenin gereğini yerine getirmelidir. FSEK madde 18'deki “tayin” kelimesi “çalışanı işe tayin” olarak anlaşılmalıdır, burada BK madde 385'de olduğu gibi “eserin içeriğini tayin edip, etmeme”den bahsedilmemektedir. Ayrıca içerik tayini bir fikirdir, aslolan “fikir” değil “eser”dir, yani eserin sahibinin özelliğini taşıyarak yaratılması ve bir plan veya proje haline getirilmesidir.

Kanunda 2001 yılında yapılan değişiklikle eskiden “mali haklar” işverene aitken şimdi; sadece “mali hakları kullanma hakkı” işverene geçmiştir. Kanun'un daha önceki metnine göre; işveren ve çalıştıranların eser sahibi sıfatına sahip olduğu gibi bir sonuç çıkmaktaydı. Bu durumda mimar olmayan herhangi bir vatandaşın, bir mimarlık ofisi açarak ücretli olarak yanında çalıştırdığı mimarların yarattıkları projelerin sahibi olması şeklinde bir sonuç doğmaktaydı. Fakat yapılan bu değişiklik sonrasında ülkemizde sıkça rastlanan ve eserin gerçek yaratıcısı olan mimarların haklarına zarar veren bu durum kaldırılmıştır. Memur, işçi veya çalışan kavramı bazen işin özelliğine göre değişebilir. Erel'e göre sürekli bir ilişki olmaksızın vekalet, hizmet veya istisna ilişkisi de çalıştıranın mali hakları kullanma yetkisine sahip olduğu çalışma ilişkileri olarak görülse bile bizce kapsamı bu kadar genişletmemek gereklidir.⁵⁷ İstisna sözleşmesi yani eser sözleşmesi zaten tarafların hak ve yükümlülüklerini açıkça düzenlediğinden, içerdiği şartlara bakarak mali hakların kime ait olduğu konusunda sorun çözülür. Eğer hakların kime ait olduğu açıkça düzenlenmedi ise; FSEK madde 52 ve diğer maddeler doğrultusunda sorun çözülür.

⁵⁷ Şafak EREL, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.81

Bir mimari proje, mal sahibi veya uygulayacak olan yapımcısı (yüklenicisi) tarafından aralarında sürekli bir iş ilişkisi olmayan üçüncü bir kişiye (mimara, mühendise) hazırlanmış olabilir. Bu durumda tarafların aralarında yazılı sözleşme önem kazanır. Sözleşme ile eser üzerindeki haklar; mal sahibi, yüklenici veya hazırlatana devredilmedikçe yada lisans (ruhsat) verilmedikçe mali ve manevi hakları kullanma yetkisi mimar veya yanında çalışanlardadır. Bu cümlede söylendiği gibi mali haklar, devir işlemi veya lisans yoluyla devredilebilir. Kural olarak FSEK 52. maddeye göre, mali haklara dair sözleşme ile tasarrufların yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesi şarttır. Bu yazılı olma zorunluluğu emredici şekil kuralıdır. Ancak bazen işin niteliğine bakarak Yargıtay'ın da belirttiği gibi “dürüstlük kuralı” gereği, arada yazılı bir sözleşme ve lisans verme yazılı olarak olmasa bile, iş sahibi edimlerini yerine getirmişse; projenin parasını ödeyen ve eser sahibine karşı yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmiş kişiye bu projeyi belirli bir yapıya uygulamak, yani bu projeye göre inşaatı yapmak yetkisinin geçtiğini söyleyebiliriz. Bu şekildeki “geniş” yorumu sadece olayın özellikleri bu sonucu gösteriyorsa istisnai olarak yapabiliriz. Yoksa mali hakların devri açısından taraflar arasında mutlaka yazılı sözleşme aranmak gerekir. İş sahibi parayı ödediği için belirli bir inşaatı bu projeyi uygulamak yetkisine sahip olmakla birlikte; eserin daha sonra mevzuattaki değişiklikler sonucu değiştirilmek gereğinin ortaya çıkması veya zamanla eskimesi yada sonradan satın alan üçüncü kişilerin zevkleri doğrultusunda değiştirilmesi hukuki sorunlar yaratır. Eserde değişiklik yapılmasına karşı koymak, eser sahibinin manevi hakkı olduğundan bu değişiklikler ilke olarak sadece kendisi tarafından yapılır ve bu manevi hakkın devri mümkün değildir. Bu sorunu aşmak için iş sahipleri tarafından en azından “eserde değişiklik yapma” hakkında izin veya yetki alınmasında yarar vardır.

Kanun'daki 18. ve 52. maddelere ilişkin bu düzenlemeler; Ülkemizde çok sık rastlanan ve mimarlık mesleğinin toplumda yanlış tanınmasına neden olan, mimarı, sadece ruhsat projesi çizen bir teknik adam olarak gören anlayışın son bulmasını sağlamıştır.⁵⁸

FSEK 18. madde ile; eser sahipliği hakkını değil, kullanma hakkını işverene verirken Borçlar Kanunu'nun 385. maddesi; sadece yayınlanan eserler için, işçilerin yarattıkları eserlerde doğrudan tüm hakları yayıncıya

⁵⁸ Bkz. Salih Zeki PEKİN, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile Kazanımlarımız ve Mimar Olarak Yapmamız Gerekenler, Mimarlık Dergisi, 1995/266, s.9.

vermektedir. 385. maddeye göre; yayıncının, tayin ettiği plan dairesinde bir eser meydana gelmişse, eseri yaratanlar sözleşmedeki bedele hak kazanır. Bu eser üzerindeki haklar (telif hakları) ise; işverene ait olur. Bu olasılık sadece bir mimari kitap yayını için yayıncının tayin ettiği şekilde mimarların eser yaratması dolayısıyla gerçekleşebilir. Burada planı işveren (eseri içeriği ve niteliğiyle tayin eden) vermektedir. Bu durumda işveren gerçek kişi olabileceği gibi tüzel kişi de olabilir. Böylece anılan hükme göre, tüzel kişi de eser sahibi olabilecektir.⁵⁹ Bu madde uyarınca önemli olan ayrıntılı hazırlık emirleri dolayısıyla yaratıcının sadece işverenin bir yardımcısı olarak görülmesidir. Var olan hal ve şartlara göre böyle bir durum kabul edilirse, gerçek bir yayım sözleşmesinin varlığından söz edilemez. Yayımlayanın planı tam ve esaslı değilse; BK madde 385 uygulanamaz.

Mimari eseri meydana getirirken mimarın, diğer bazı uzmanların çalışmalarından yararlanmış olması, yararlanılan kişilere eser sahibi oldukları iddiasında bulunma hakkını vermemektedir.⁶⁰

Çalıştıran ve görev veren işverenlerin personeli tarafından üretilen eserler üzerindeki mali hakları kullanma hakkının, TEKİNALP'in de savunduğu gibi, çalıştıranların eser sahibi oldukları ve oluşturulan eserler üzerinde mali haklar yanında manevi yetkilere de sahip bulundukları şeklinde yorumlanması bizce yanlıştır.⁶¹ Zira eserin yaratıcısına ait olan manevi hakların devredilmesi mümkün değildir. Yine FSEK'e göre mali haklar münhasıran eser sahibine aittir ve istisnası yazılı sözleşme ile devredilmesi veya FSEK 18'deki hükme dayanarak çalıştıran tarafından kullanılabilmesidir. Yargıtay 11. HD. verdiği bir kararda; hazırlanan ders ve sınav materyallerinin hazırlayan kişi tarafından yayınlanmasına karşı açılan davada, mali hak sahibinin davacı okul olduğunu kabul etmiş, ancak davacının manevi hakların sahibi olmadığını (yani manevi hakların eseri yaratan kişiye ait olduğunu) belirterek, eseri yaratan ve yayınlayan kişiye karşı manevi tazminata hak kazanamadığını vurgulamıştır.⁶² Yine Yargı-

⁵⁹ ÜSTÜN, özellikle büyük bilgisayar programlarında hak sahibinin tüzel kişilerin olmasının uygulamada bir ihtiyaç olduğunu, bu ihtiyacın da Hukukumuzda BK madde 385 ile karşılandığını savunmaktadır.

⁶⁰ Salih Zeki PEKİN, agm, s.9.

⁶¹ TEKİNALP, age., s.135.

⁶² "Birden fazla kişinin iştiraki ile vücuda getirilen eser, ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eser üzerindeki haklar eser sahiplerini bir araya getiren gerçek veya tüzel ki-

tay 2003 tarihinde verdiği bir kararda; davacı firmaya ait projeleri, kendi yararına kullanan önceki işçiyi tazminata mahkûm etmiştir.⁶³

FSEK'teki eser sahipliği sıfatı; marka, patent, tasarım ve faydalı modeldeki sahiplikten farklı olarak tescille değil, eserin doğumuyla birlikte ortaya çıkmakta, tescil veya kamuya sunum gibi bir işleme ihtiyaç duymamaktadır. Eser Sahipliği için, maddi bir fiil olarak eserin meydana getirilmesi (*ipso jure*) yeterlidir ve eser sahibinin fiil ehliyetinin varlığı gerekmemektedir. Çünkü eserin dış dünyaya yansıyacak şekilde ortaya çıkmasıyla birlikte hak da kendiliğinden doğmaktadır.

FSEK kapsamında tescil ilkesinin benimsenmemesi, uygulamadaki hak sahipliğinin belirlenmesi açısından ispat güçlükleri oluşmaktadır. Bunu önlemek için Kanun Koyucu hak sahipliğinin ispatı açısından bazı karinelere değinmiştir:

a. Yayınlanmış eser nüshalarında veya güzel sanat eserlerinin aslında, o eserin sahibi olarak adını ya da müstear adını kullanan kimse, aksi ispatlanana kadar o eserin sahibi sayılmaktadır (FSEK madde 11/I, Bern madde 15)

b. Umumi yerlerde veya radyo-TV aracılığı ile verilen konferans ve temsillerde, mutad şekilde eser sahibi olarak tanıtılan kimse o eserin sahibi sayılmaktadır; meğer ki eserde eser sahibi olarak başkasının adı yazılmış olsun (FSEK madde 11/II).

Bu iki karine kullanılarak eser ve hak sahibi ilk aşamada belirlenebilir. Öte yandan bu iki karinenin aksi ispatlanarak, gerçek eser sahibinin kim olduğu her zaman ortaya çıkarılabilir.

şiler tarafından kullanılır hükmünden hareketle; hazırlanan ders ve sınav materyallerinin mali hak sahibinin Okul olduğu kabul edilmiştir.” 11.HD., 04.06.2001 tarihli, 2687/5080 sayılı yayınlanmamış kararı. Naklen TEKİNALP, age., s.135. (Yargıtay Kararları No: 40)

⁶³ “Davacı firma bünyesinde çalışan davalılardan birinin işçi, diğerinin ise genel müdür olarak çalışırken; sadakat yükümlülüklerini ihlal ederek başka bir firma ile anlaşmış ve görevlerinden istifa etmişlerdir. Daha sonra çalıştıkları firmada yaratılan şirkete ait proje işlemlerini kendi yararlarına ve yeni firmaları adına kullanmışlardır. Yargılama sonunda yaptıkları bu eylem nedeniyle tazminata mahkum edilmişlerdir.” 11. HD., 15.5.2003, E. 2003/2276, K. 2003/4996. (Yargıtay Kararları No: 46)

B. FSEK'TEKİ MİMARİ ESER SAHİPLİĞİ

Günümüzde olduğu kadar eskiden de sanatın çok önemli bir dalını oluşturan mimarlık; dar anlamda yapıların teknik ve bilimsel temelini oluşturan tasarım, plan ve projeleri hazırlamak, yapıların gerçekleştirilmesi aşamasında denetim ve yönetim hizmetlerini üstlenerek yapıyı ortaya çıkarmak biçiminde tanımlanabilmektedir. Mimar ise; yapı projesini, yapı sanatı ve tekniği kurallarına göre tasarlayan ve düzenleyen, yapının gerçekleştirilmesine kadar yöneten ve denetleyen, teknik bilgisi ve becerisi olan meslek sahibi kimsedir.⁶⁴ Fakat *mimar, yapı süresince tüm aşamaları tamamlama şartı olmadan, sadece tasarım, avan proje, uygulama projesi, planlar aşamalarından birini yapıp, yaptığı bu kısımların üzerinde de eser sahibi olabilir.*

Yukarıda belirttiğimiz gibi mimari yapının esere ilişkin haklarının kime ait olduğu FSEK'teki genel şartlar ve karineler dikkate alınarak belirlenmektedir. Ancak mimarlık hizmetlerinin ve dolayısıyla mimarın yükümlülüklerinin sırasıyla; tasarım, kroki, ön (avan) proje, kesin proje, uygulama ve tafsilat (detay) projeleri, gider tahmini (yaklaşık yapı maliyeti), ihale dosyasının düzenlenmesi hizmetleri, yapının mesleki denetim hizmetleri, yapının teknik bakımından denetimi ve yönetimi hizmetleri (teknik uygulama sorumluluğu) gibi işler olduğu düşünülünce; mimari eser sahipliğinin kimi zaman birden fazla kişinin ortak emeği sonucunda oluşacağını söyleyebiliriz.

Birden çok şahsın emeği sonucunda bir eser meydana geldiyse bu durumda; eserin kısımlara ayrılıp ayrılmamasına göre eser sahipliği değişmektedir. Şayet yaratılan eser, kısımlara ayrılabilirse; yaratıcı kişilerden her biri meydana getirdiği kısmın sahibi olmaktadır (FSEK madde 9/1). Birden fazla mimarın yarattığı eserlere bu kural uygulanır. Ancak meydana getirilen eser tam tersine ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa; eserin sahibi onu meydana getirenlerin birliğidir (FSEK madde 10/1). Ancak, bir eserin vücuda getirilmesi sürecinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlarda, yardımcının da esere ortak olduğu sonucu çıkarılmamalıdır. Yargıtay; bu konudaki bir kararında davacıların davalının yarattığı eserde katkıları bulunduğu gerekçesiyle eser sahibi sayılmalarını talep ettikleri bir davada; eserin hazırlanmasında davacıların yaratıcı çaba

⁶⁴ Walter Sauter'e atfen Doç. Dr. İbrahim KAPLAN, Türk İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara, 1983, s. 7 Naklen Yargıtay'ın 4 HD., 28.5.1984, E. 1984/2865, K. 1984/5113. (Yargıtay Kararları No: 5)

ve katkılarının bulunmadığını, eserin yaratılmasına sadece yardım ettiklerini belirterek davacıların taleplerini reddetmiştir.⁶⁵

Ayrılmaz bir bütün teşkil eden esere muhtelif yaratıcıların sarf ettikleri fikri emek aynı nitelikte yahut aynı yoğunlukta olmayabilir. Bu durum yaratıcıların iştirak halinde eser sahibi olmalarına engel değildir, yeter ki sarf edilen fikri emek eserde yaratıcının özelliğini yansıtabilsin. Mesela güzel bir sanat eserinin yaratılmasında fikir vererek yardımcı olmak veya bir bilimsel eserin hazırlanması için belge veya bibliyografya araştırması yapmak, sonradan meydana getirilen esere bir katkı sağlamaz ve iştirak halinde eser sahipliğine yol açmaz.

Mimari eserlerde eser sahipliği, FSEK madde 10/I'e göre; birden fazla kişinin birlikte vücuda getirdikleri eserin ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi halinde eser sahipleri arasında bir birliğin bulunduğu sonucuna varılacaktır. Kanundaki "**eserin ayrılmaz bir bütün teşkil etmesi**" ifadesinden amaç, eserin yaratılmasında yapılan katkıların, eserin bütününden ayrı olarak tek başlarına telif haklarına konu olamayacaklarını ve mali açıdan değerlendirilemeyeceklerini belirtmektir. Başka deyişle eserin ayrılmaz bütün olması halinde; eseri meydana getiren parçalar, eserin bütünlüğünü ve eser niteliğini bozmadan ondan ayıramayacaklarından -ayrılışlar bile- kendi başlarına eser sayılamazlar. Ancak bu durum eserdeki yaratıcı kişilerin özelliğinin de tek ve bölünmez olduğu anlamına gelmez.

⁶⁵ Walter Sauter'e atfen Doç. Dr. İbrahim KAPLAN, Türk İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara, 1983, s. 7 naklen. Yargıtay'ın 4. HD., 28.5.1984, E. 1984/2865, K. 1984/5113 nolu (Yargıtay Kararları No: 5) kararında; davacılar Sadi ve Zarif; davalı Erdoğan ve diğer davalı Erdem'in miras bırakanı Hamit Zübeyir ile birlikte "Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi" isimli eseri hazırladıklarını, ancak Zübeyir'in ölümünden sonra davalı Erdem'in eseri yalnız Hamit adına basılmak üzere eser sahibi olarak Kültür Bakanlığı'na verdiğini, bu nedenle ortak esere ait telif ücretinin hangi oranda paylaştırılacağı'nın tespitine karar verilmesini istemişlerdir. Mahkeme, eser sahibinin Hamit olduğunu kabul etmiş, ancak eserin hazırlanmasında davacılar ve davalı Erdoğan'ın katkıları gözetilerek 12 ciltlik eserin hazırlanmış haliyle yayınlanması durumunda telif ücretinin % 65'inin Hamit varisi Erdem, % 15'inin davacı Sadi, % 10'unun Zarif ve %10'unun da davalı Erdoğan'a ait olacağının tespitine karar vermiştir. Mahkemenin, eserin sahibinin Hamit olduğu yolundaki kabulü doğrudur; ancak buna rağmen eserin telif hakkı bedelini taraflar arasında paylaşması ise hatalı olmuştur. Davacıların yardımları nedeniyle sözleşmeye dayanan bir alacak hakları varsa bir eda davasıyla istenmesi olanağı olduğu da unutulmamalıdır." şeklinde karar verilmiştir. 4. HD., 22.10.1992, E. 1991/5141, K. 1992/11254. (Yargıtay Kararları No: 7)

Ortaklaşa yapılan bir mimari projede⁶⁶, sanatkârlardan her birinin özelliği konunun uzmanları tarafından eserin bütünü içinde ayırt edilebilir.⁶⁷ Ne var ki özellik taşıyan bu parça ve bölümlerden hiçbirisi bağımsız eser sayılmaz ve kendi başlarına değerlendirilemezler.⁶⁸

Eserdeki ve eser sahipleri arasındaki bu birlik içindeki mülkiyet ilişkisi, iştirak halinde (elbirliği halinde) mülkiyettir. Ve bu birliğe adi şirket hakkındaki hükümler uygulanmaktadır. Fakat yukarıda belirttiğimiz gibi eserin meydana getirilmesi sırasında yapılan teknik hizmetler ve yardımlar eser sahipliği birliğinin oluşmasına yeterli değildir. Bu nedenle teknik hizmeti yapanlar veya yardımcıları birlik içinde eser sahibi olarak değerlendirilmemelidir.

Yukarıda (66 nolu dipnotta) belirtilen Yargıtay kararında; ön avan projesini hazırlayan mimarlar arasında eser sahipleri birliği olup olmadığı araştırılması sırasında şu kriterler üzerinde durulmuştur: Tarafların eserin bütününe göre oluşturdukları oranın matematiksel olarak açıklanması ve bu şekilde belirlenecek oranın eser açısından ortak çalışma ürünü sayılabilecek bir seviyeye ulaşip ulaşmadığının belirlenmesi; davacının projenin oluşumu sırasında henüz öğrenci olması da dikkate alınarak; tarafların dava konusu esere katkıları belirlenirken; -mimarlık bilgilerinin, tecrübelelerinin ve savundukları mimari çizgi, biçim, hacim ve sanat anlayışlarının kısacası- mimari kariyerlerinin göz önünde tutulması.

⁶⁶ “Davacı, 1961 tarihli projenin 1951 tarihli (önceki ve eski) projeye dayanmadığını, tamamen yeni ve bağımsız bir proje olduğunu ve bunun tarafların ortak katkısıyla gerçekleştirildiğini iddia etmektedir. Bilirkişilerce son projeye göre; eserin bütününde sanat, estetik ve mimari detaylar yönünde önemli değişiklikler bulunup bulunmadığı, sonraki projenin yeni bir proje sayılıp sayılamayacağı belirlenmeli, sonraki değişiklikler eserin ana karakterini değiştirmiyorsa, tasarım ve mimari anlayış açısından ayrı ilk projedeki ilkelere dayanıyorsa dava reddedilmelidir. Eğer ikinci proje; birinciden tamamen nitelikte ya da çok az etkilenmiş yeni bir proje mahiyetinde kabul ediliyorsa, değişikliğe konu hususlarda ve bütün ayrıntılarda taraflardan hangisinin biçim ve kompozisyon yönünden sanat ve mimarlık anlayışıyla teknik bilgisinin egemen olduğu ortaya konmalı ve davacı katkılarının eserin bütününe göre oluşturduğu oran matematiksel olarak belirlenip, bu oranın eserin ortak çalışma unsuru sayılabilecek bir düzeye ulaşip ulaşmadığı belirtilmelidir. (4. HD. 28.5.1984, E. 84/2865, K.84/5113, YKD Aralık 1984, s. 1790-1795). (Yargıtay Kararları No: 5)

⁶⁷ AYİTER, age., s. 100; aksi fikir, ARSLANLI, age., s. 68 Naklen EREL, age., s. 72.

⁶⁸ EREL, age., s. 72.

Ortak (müşterek) eserlerde ise durum biraz daha farklıdır. Ortak eserlerde eser sahiplerinin esere olan katkıları birbirinden ayrılabilir. Oysa yukarıda açıklanan birlik mülkiyeti halinde katkılar ayrılmaz. Ortak eserleri şu şekilde örnekleleyebiliriz; bir mimari yapının oluşturulması için avan projesinin bir mimar tarafından, yapı projesinin başka bir mimar tarafından yapılması. Bu durumlarda iki mimarın ayrılabilen çalışmasıyla oluşan mimari yapı üzerinde FSEK madde 9 kapsamında bir ortaklık vardır. Ve uygun düştüğü ölçüde Medeni Kanun'un paylı mülkiyete ilişkin hükümleri uygulanmaktadır.

Ortak (müşterek) eserlerde önemli olan nokta, bütünü oluşturan kısımların kendi başlarına telif haklarına konu olabilmeleri ve iktisaden değerlendirilebilme imkânının bulunmasıdır. Bu imkânın fiilen kullanılmış olup olmaması yahut bağımsız kısımların eser bütününe olan katkılarının nitelik ve yoğunluğu veya bazı kısımlar ayrıldıktan sonra eserin bütününe değer kaybedip kaybetmemesi önem taşımaz.⁶⁹ Müşterek eser sahiplerinden her biri kendi oluşturduğu kısım üzerinde mali ve manevi hak sahibi olmakta ve bunları bizzat kullanabilmektedirler. Ancak müşterek eserin tamamı üzerindeki haklar eser sahiplerinin tümüne aittir. Bu hakların kullanılmasına ilişkin kararlar ancak eser sahiplerinin oybirliği ile alınabilmektedir.

⁶⁹ AYİTER, age., s. 99 Naklen EREL, age., s.76.

V. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN HAKLARI

Fikir ve sanat eserleri konusunda her ülke kendi kültür ve hukuk anlayışı çerçevesinde eser sahiplerine bazı haklar tanımış ve bunları iç hukuk kuralları olarak belirlemiştir. Ancak fikir ve sanat eserlerinin ülke sınırlarını aşarak diğer ülkelerde yaşayan insanlar tarafından da sevilmesi, yararlı bulunması ve kullanılması sebebiyle ülkesel düzenlemeler yeterli olmamış, eser sahiplerinin haklarının aynı biçimlerde ülke dışında, diğer ülkelerde de korunması gerekmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar 1883 yılında Paris Sözleşmesi’ni ve 1886 yılında bu Sözleşme’nin geliştirildiği Bern Sözleşmesi’ni ortaya çıkarmıştır. Bern Sözleşmesi’ni imzalayan ülkeler, Sözleşme’deki kuralları kendi ülkeleri için **“asgari hukuki koruma kuralları”** olarak belirlemiş ve iç hukuklarına bu asgari kuralları mutlaka almıştır. Kültür ve hukuk düzenleri gelişmiş ülkeler Bern Sözleşmesi’ndeki bu asgari kurallarla yetinmeyip, ülkelerinde eser sahiplerine Bern Sözleşmesi’nde belirtilenlerden daha geniş haklar tanımışlardır. Zaten Bern Sözleşmesi de bunu amaçlamıştır. Bern Sözleşmesi’nin 19. maddesi, fikişsel ve sanatsal haklar açısından **“bu Sözleşme hükümleri, Birlik ülkeleri mevzuatı ile tanınan daha geniş bir korumadan yararlanma isteğine engel oluşturmaz”** ve 20. maddesi **“Birlik ülkelerinin hükümetleri, aralarında eser sahiplerine bu Sözleşme ile tanınan haklardan daha geniş haklar veren veya bu Sözleşmeye aykırı hükümler içermeyen özel anlaşmalar yapma hakkını saklı tutarlar”** diyerek bu amacı açıkça ortaya koymuştur. Sözleşmelerle sadece olmazsa olmaz asgari kuralları koyma amacı; Bern Sözleşmesi’nden sonra hazırlanan Roma Sözleşmesi, WIPO Sözleşmeleri ve AB Direktiflerinin hepsinde sürdürölmektedir.

İşte Bern Sözleşmesi’ne uygun hazırlanan bizim Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’muz, daha sonra ortaya çıkan uluslararası hukuk sözleşme ve kurallarındaki gelişmeler paralelinde asgari koruma yanında, ayrıca ülkemizdeki fikir ve sanat eserleri üretimini teşvik etmek için daha geniş hukuki koruma kurallarını ve hakları eser ve diğer hak sahiplerine tanımıştır.

Aslında, FSEK doğrudan ne eser sahibini ne de eseri korumaktadır. Korunan sadece belli bir eser bağlamında eser sahibinin mali ve manevi menfaatleridir.⁷⁰ Bu ilke FSEK madde 13’de yer almaktadır. Bahsi geçen

⁷⁰ TEKİNALP, age., s. 145.

bu hüküm “*fikir ve sanat eserleri üzerinde sahiplerinin mali ve manevi menfaatleri kanun dairesinde himaye görür*” şeklinde düzenlenmektedir. Burada çıkan anlam şudur; FSEK, eser üzerindeki hakları manevi ve mali haklar olarak ayırmış ve devamı maddelerinde bunları sınırlayıcı bir biçimde sayarak düzenlemiştir. Ayiter ve Erel yapılan bu ayrımı yapay bulmaktadırlar ve aslında mali ve manevi hakların birbirlerine sıkı şekilde bağlı olduğunu savunmaktadırlar. Bu görüş; “*mali haklardan olan eseri yayma hakkının kullanılabilmesi, bir manevi hak olan eseri kamuya sunma (umuma arz) yetkisi bulunmadan mümkün değildir. Keza eserin kamuya sunulmasında eser sahibinin adının açıklanması veya eserin bozulup değiştirilmesi, eser sahibinin manevi olduğu kadar mali çıkarlarını da zede-ler*”⁷¹ şeklinde ifade edilmektedir. Nitekim bir tasarımın, eskizin, krokinin, çizimin veya maketin, Kanun’daki “haber verme” gibi istisnalar dışında, mimarının izni olmadan bir yayın organında yayınlanması, bir sergide sergilenmesi veya bir televizyon programına konu edilmesi; hem mimarın umuma arz yetkisine (manevi hakkına) hem de eseri yayma hakkına (mali hakkına) saldırı sonucunu doğurmaktadır.

Manevi ve mali hakların gruplar halinde ve sınırlayıcı olarak sayılması bazı faydalar ve sakıncalar taşımaktadır. Sayılan hakların nitelik ve kapsamının etraflıca düzenlenebilmesinin faydası, bunlara yapılacak teca-vüzlerin açık olarak tespiti olanağıdır. Sakıncası ise, teknik gelişmeler sonucu eserden yeni yararlanma olanakları doğması halinde, eser sahibinin bunlar üzerinde bir hak iddia edememesi ve başkalarının bu yoldan eserden yararlanmalarına engel olamamasıdır.⁷² Örneğin gelişen teknoloji sonucu mimar tarafından oluşturulan bir projenin aslından ikinci kopyasının (ozalitinin) çıkarılması ve bunun internet ortamına sunulması. Modern bazı kanunlar, Fransız ve Alman kanunları; eser üzerindeki yetkileri sınırlayıcı bir biçimde saymak yerine, eser sahibinin tek ve kapsamlı bir hakkı olduğunu kabul etmişlerdir. Bern Sözleşmesi de; mali ve manevi haklar arasında bir ayrım yapmamakta ve mükerrer 6. maddesi ile mali ve manevi haklar kategorileri arasında ilişkiyi “*eser sahibinin haiz olduğu mali haklardan müstakil olarak ve bu hakların devrinden sonra dahi eserin kendi eseri olduğunu beyan etmek ve bu eserin kendi şeref ve şöhretine zarar verecek her türlü bozuluşuna, parçalanışına ve herhangi bir şekilde de-ği-*

⁷¹ AYİTER, age., s. 99 Naklen EREL, age., s. 76.

⁷² ARSLANLI, age., s. 79 Naklen EREL, age., s.111.

şikliğe uğratılmasına muhalefet etmek hakkını bütün hayatı boyunca muhafaza eder”⁷³ şeklinde ifade etmektedir.

Hukuk düzeni, eserin meydana gelmesiyle birlikte eser sahibine manevi ve mali haklar vererek, bunları korumaktadır. Kısacası, eser üzerindeki her türlü manevi ve mali hakkın doğumu için sadece bir eserin yaratılmış olması yeterli olmaktadır.

Ancak bu suretle doğan hakların eser sahibi tarafından bizzat kullanılabilmesi bakımından, manevi ve mali haklar arasında bir ayırım yapılmalıdır.⁷⁴ Manevi hakların kişilik haklarıyla olan ilgisini göz önüne alan Kanun Koyucu, bu hakların kullanılmasında eser sahibinin temyiz kudreti (ayırt edebilme gücü)⁷⁵ olmasını yeterli görmekte ve temyiz kudreti olan küçüklerle, mahcurların manevi hakları kullanmakta kanuni temsilcilerinin rızasına dahi muhtaç olmadıklarını belirtmektedir (FSEK madde 18/ son cümle). Bu hüküm, kişilik haklarının kullanılmasına ilişkin Medeni Kanun madde 16/II hükmüne paraleldir. Buna karşılık mali haklar malvarlığına ilişkin haklar oldukları için, bunların eser sahibi tarafından kullanılması olağan ehliyet şartlarına tabidir.⁷⁶

Manevi haklar, doğrudan eser sahibinin kişiliğine bağlıdır. FSEK madde 18’e göre, eser sahibi gerçek kişiye yaşadığı sürece, tüzel kişi ise tüzel kişilik devam ettiği müddetçe madde 14, 15 ve 16 uyarınca sahip olduğu manevi hakları kullanır. Bu haklar sınırlı sayılma prensibine göre şu şekilde sıralanabilmektedir.

- a. Eseri umuma arz yetkisi
- b. Adın belirtilmesi yetkisi
- c. Eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkisi
- d. Eserin aslına ulaşabilme yetkisi.

Bu sayılan haklar kişiliğe bağlı oldukları için mirasa konu olmamaktadırlar. Ancak FSEK madde 19 da belirtildiği gibi eser sahibinin ya-

⁷³ Bu hüküm Sözleşmenin Paris değişikliği madde 6 bis (1)’de de aynen tekrarlanmaktadır.

⁷⁴ EREL, age., s.112.

⁷⁵ Ayırt Etme Gücü Olanlar (TMK madde 13): Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, Türk Medeni Kanununa göre ayırt etme gücüne sahiptir.

⁷⁶ EREL, age., s.112.

kınları⁷⁷, mali hakları devralanlar yada lisans alanlar veya gereğinde K lt r ve Turizm Bakanlıęı tarafından kullanılabilir. Buna g re; ilk olarak, eser sahibinin yak nları bu hakları kullanabilirler. Bunlar kullanmazlarsa ikinci olarak, eser sahibinden veya halefinden mali hakları iktisap edenler kullanabilirler.     nc  olarak ise; bazı  artların varlıęı halinde K lt r ve Turizm Bakanlıęı da manevi hakları kullanabilir.

Mali haklar, eserden ekonomik olarak yararlanma ve bunun  eklini tayin etme olanaęını tek ba ına ve sadece eser sahibine veren, ona eserden     nc  ki ilerin izinsiz yararlanmalarına engel olma yetkilerini tanıyan mutlak haklardır. Eserden ekonomik yarar saęlanabilmesi i in onun ekonomik y nden deęerlendirilmesi gerekmektedir. Bu  zelliklere sahip ve Kanun'da sınırlı sayı prensibi  er evesinde sayılmış mali haklar  u  ekilde sıralanmaktadır.

- a.   leme Hakkı
- b.  oęaltma Hakkı
- c. Yayma Hakkı
- d. Temsil Hakkı
- e. Yayın ve Umuma  letim Hakkı
- f. Pay Alma ( zleme) Hakkı

Her ne kadar kanun mali hakları t rleri itibariyle sınırlandırmı sa da (FSEK madde 20), bu h k m mali hakların yararlanma  ekli bakımından

⁷⁷ 11. HD., 22.12.2005, E. 2004/14950, K. 2005/12769 ; “Davacılar murisi oldukları eserin, izinleri olmadan, davalı yayıncı  irket tarafından yayınladıęını belirterek maddi ve manevi tazminat ve verilecek kararın gazetede ilanını talep etmi lerdir. Bunun neticesinde Yargıtay’a intikal eden olayda  u sonuca varılmıştır; 5846 sayılı FSEK’in 63. maddesi gereęince, bu Kanun ile tanınan mali haklar miras yolu ile intikal etmektedir. Eser sahibinin aynı Kanun’dan doęan manevi hakları ise  l m  halinde miras ılarına intikal etmemekle birlikte, eser sahibinin  l m nden sonra manevi hakları kullanabilecek olanlar; tayin edilmi se vasiyeti tenfiz memuru, tayin edilmi se saę kalan e i,  ocukları, mansup miras ıları, ana babası ve karde idir. G r len davada,   leme eser sahibinin miras ısı olan davalıların isteminin, eserin davalı  irket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK’in 14. maddesi yoluyla aynı Yasa’nın 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduęuna g re, FSEK’in 19/1. maddesi uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olamayacaęı i in istem reddedilmi tir.” (YKD., Cilt: 32, Sayı: 4, Nisan 2006). (Yargıtay Kararları No: 61) G r ld ę  gibi sayılan ki ilerin eserin manevi haklar a ısından k t  kullanımlarını engelleme yetkileri olmakla beraber tazminat hakkı yoktur.

bölünmesine engel değildir.⁷⁸ Bir mali hakkın konusunu teşkil eden yararlanma şekilleri teknik gelişmelere göre değişebilir veya genişleyebilir.⁷⁹ Örneğin mimari bir projenin bir dergide yayınlanarak umuma iletilmesi yararlanma biçiminin yanı sıra gelişen teknoloji neticesinde internette web sitelerinde yayınlanma aşamasına gelinmiştir. Yine aynı şekilde kopyalanan mimari projeler artık e-mail yöntemiyle şahıslar arasında gönderilmek ve printer’da basılmak suretiyle çoğaltılmaktadır. Yine içinde mimari projelerin birçok türünü kullanıcılara sunan bilgisayar programları, yayma mali hakkının değişik uygulamalarıdır.

Manevi hakların aksine, mali haklar hakkında eser sahibinin malvarlığından tamamen çıkacak şekilde tasarruf işlemleri yapılabilir. Ayrıca manevi haklarda olduğu gibi, mali haklar hakkında sadece kullanılması açısından yetki verilmesi de mümkündür; bu iş lisans sözleşmesi niteliğindeki ruhsat verme yoluyla olur⁸⁰ (FSEK madde 48/I, II). Mali hakların devri ve lisans verilmesi ileride ayrıntılı olarak incelenecektir.

Mali bir hakkın kararlaştırılan zamanda veya uygun bir süre içinde kullanılmaması halinde, bu yüzden menfaatleri ihlal edilen eser sahibi, FSEK madde 58 gereğince sözleşmeden cayabilir. Mali haklara ilişkin bu "*cayma hakkı*" da eser sahibinin manevi haklarından ve manevi hakları kullanma yetkisinin geri alınması hususundaki FSEK madde 14/III hükmüne paraleldir. Gerçi Kanun sırf mali hakkın kullanılmamasından bahsetmekte ise de mali haklarla manevi haklar birbirine bağlı olduğundan, mali hakkın kullanılmaması aynı zamanda manevi hakka da tecavüz teşkil eder.⁸¹ Ancak diğer manevi haklardan ve bunları kullanma yetkisinin geriye alınmasından feragat mümkün değilken, cayma hakkından sadece önceden vazgeçilemez, cayma hakkından hakkın doğumundan sonra ise vazgeçmek mümkündür. Keza cayma hakkının kullanılması sözleşmeyle iki yıla kadar ertelenebilir (FSEK madde 58/son fıkra).

Tüm bu açıklamalar ışığında doktrinde varılan nokta olarak, eser sahibine tanınan mali ve manevi hakların olumlu (izin verme) ve olumsuz (yasaklama yetkisi) olmak üzere iki ayrı yönü bulunduğunu söyleyebiliriz. Olumlu yönü; kanunen eser sahibine verilen hakların ancak eser sahibi

⁷⁸ ARSLANLI, age., s. 172 EREL, age., s.114.

⁷⁹ EREL, age., s.114.

⁸⁰ ARSLANLI, age., s. 172 vd.; AYİTER, age., s. 206 vd. Naklen EREL, age., s.114.

⁸¹ ARSLANLI, age., s. 82-83; AYİTER, age., s. 219-220 EREL, age., s.114.

veya onun izin verdiği kimselerce kullanabilmesidir. Örneğin bir mimari projenin uygulanarak inşa edilebilmesi için mimarının izin vermesi gerekmektedir. Olumsuz yönü ise; eser sahibinin, elindeki hak ve yetkilerle eserlerin izinsiz olarak kullanılmasını engelleyebilmesidir. Bir mimarın hazırladığı avan projesinin, başka bir mimar tarafından uygulama projesi haline dönüştürülmesi halinde mimar, izni olmadığı için bu kullanımı engelleyebilmektedir.

Olumlu veya olumsuz hak kullanımı kapsamında; mimari yapının oluşumu sırasında uygulama alanı bulan ve FSEK kapsamında bilimsel eserler olarak korunan; tasarım, kroki, ön (avan) proje, kesin proje, plan, maket, uygulama ve detay (detay) projelerinin yanında, bu projelerin hayata geçirilmesiyle “yapı” şeklinde oluşan mimarlık eserinin kendisi de bulunmaktadır.

Ancak eski “Hakkı Telif Kanunu”nda mimari eserlerin plan ve projeleri korunurken, bizzatıhi mimari eserin kendisi yani yapı korunmamaktaydı. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile hem plan ve projeler hem de mimari eserin kendisi de (yapı) koruma altına alınmıştır.

Eklemeliyiz ki, FSEK uygulamalarında; mimari eserin korunması konusunda bazı haklar açısından diğer eser türlerinden farklı bir tutum izlenmektedir. EREL’in görüşü; eserde değişiklik yapma ilkesinin çok sıkı bir biçimde kullanılamayacağı yönündedir. EREL’e göre; mimari eserlerde haklı nedenlerle, eser sahibinin izni olmadan da değişikliğin yapılabileceği kabul edilmektedir.⁸² Buna göre; mimar sadece mesleki şeref ve itibarını veya eserin mahiyet ve özelliğini bozan değişikliklere karşı çıkabilmektedir. Çünkü, bu görüş uyarınca, mimari eserler diğer güzel sanat eserlerinden farklı olarak bir işleve (fonksiyona) sahiptir. O kadar ki; bu eserlerde işlev, estetik niteliğin önüne geçtiği için, mimari eserlerde değişiklik yapmak çoğu zaman estetik zevkten ziyade ihtiyaçtan doğmaktadır. Ancak her ne kadar değiştirme konusunda serbestiden bahsedilse de bunun sınırsız olduğu düşünülmemelidir.⁸³ Bizim de katıldığımız görüş; mimarın şeref ve itibarı zarara uğruyorsa yada eserin temel estetik niteliği bozuluyorsa bu serbestinin olmadığıdır. ÜSTÜN ise; mimari eserlerdeki değişiklik konusundaki serbestinin tamamen karşısında yer almakta ve bir mimari eserde yapılan esaslı değişikliğin, çoğu kez FSEK madde 6.f.1’de değinilen işlenme anlamında olacağını belirterek, böylece asıl eser sahibinin iş-

⁸² EREL, age., s.125 vd.

⁸³ SULUK/ORHAN, age, s.350 vd.

lenme hakkının ihlal edileceğini savunarak, eser sahibinin haklı menfaatleri gerektiğinde mülkiyet hakkının bu menfaatler karşısında gerilemesinin icap ettiğini vurgulayarak serbesti görüşünü eleştirmektedir.^{84 85}

Uluslararası hukuki metinler ve FSEK dışında, mimarlık mesleği hakkındaki bazı düzenlemeler de mimarların eser sahipliği haklarından bahsetmektedir. TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi Ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi Ve Ücret Tarifesi”nde madde 4 de “mimarın telif hakları” başlığı altında şu konular düzenlenmiştir.

- İç mekan düzenleme ve mobilya tasarımı hizmetleri telif hakları kapsamındadır.

- Mimarın hazırladığı proje, çizim, resim ve maketler mimarın eseridir, onun izni olmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, alenileştirilemez, umuma arz edilemez, dağıtılamaz ve işveren tarafından başka bir işte ve amaçla kullanılamaz.

- İç mekan düzenleme ve mobilya tasarımı hizmetleri, farklı bir mimarın tasarladığı yapı içinde yer alan mekanlar içinde yapılıyorsa, binanın (eser) proje müellifinin eseri üzerindeki kazanılmış tüm müelliflik ve telif hakları saklıdır. İç mekan düzenleme ve mobilya tasarımı hizmetlerini üstlenmiş olan mimar, verilen iç mekan düzenleme ve mobilya tasarımı hizmeti herhangi bir tadilatı gerektiriyorsa söz konusu eserin proje müellifinden izin almak zorundadır. Bu hizmetler öncelikle yapı müellifine aittir.

- Eserlerin ne şekilde alenileştirileceğine, umuma arz edileceğine, çoğaltılacağına ve dağıtılacağına mimarın kendisi karar verir.

- İşveren, mimarın tasarlanmış, imal yada inşa edilmiş eserini reklam, satış yada tanıtım amacıyla yayınlamak isterse bundan mimara bilgi vermek durumundadır ve her koşulda bu yayında mimarın eseri olduğunu belirtmek zorundadır.

- Mimarın proje ve çizimlerine dayanılarak imal edilmiş yapı ve dekorasyon elemanları, mobilyalar ve diğer unsurlar mimarın eseridir. Eserlerinin ne şekilde yayınlanacağına mimarın kendisi karar verir. İşveren mimarın tasarlanmış, imal yada inşa edilmiş eserini reklam satış yada tanıtım amacıyla yayınlamak isterse mimara bilgi vermek durumundadır ve her koşulda bu yayında mimarın eseri olduğunu belirtmek zorundadır.

⁸⁴ Gürsel ÜSTÜN, Fikri Hukukta İşleme Eserler, Besam Yayınları, İstanbul, 2001, s.117 vd.

⁸⁵ Bkz. AYİTER, N., age. s.9; ayrıca bkz. UNESCO, age., s. 15; ILGAZ, D. / ÜSTÜN, age., s.22 Naklen ÜSTÜN, age., s.119.

Fark ettiğiniz gibi, bu “Tarife”, uluslararası düzenlemeler ve FSEK kadar kapsamlı olmayıp, sadece bazı başlıkları saymaktadır. Tabii ki sayarken de bazı kavramları birbirine karıştırmaktadır. Aşağıda zaten bunları her bir ilgili bölümde genişçe açıklayacağız.

Şimdi mimari eserlerle ilgili bu farklı düşünceler nedeniyle mali ve manevi hakları Yargıtay kararları ışığında tek tek inceleyelim.

A. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN MANEVİ HAKLARI

1. Eseri Umuma Arz Yetkisi

FSEK madde 14 uyarınca; *“bir eserin umuma arz edilip edilmemesi, yayımlanma zamanını ve tarzını münhasıran eser sahibi tayin etmektedir. Bütünü veya esaslı bir kısmı âlenileşmemiş olan, yahut ana hatları herhangi bir suretle henüz umuma tanıtılmayan bir eserin muhtevası hakkında ancak o eserin sahibi malûmat verebilir. Eserin umuma arz edilmesi veya yayımlanma tarzı, sahibinin şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise eser sahibi, başkasına yazılı izin vermiş olsa bile eserin gerek aslının, gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılması veya yayımlanmasını menedebilir. Menetme yetkisinden sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Diğer tarafın tazminat hakkı saklıdır.”*⁸⁶

Bu hükmü dikkate aldığımızda, umuma arzın (kamuya sunmanın); eserin sahibinin kontrolünden yani fiili hakimiyetinden çıkacak şekilde üçüncü kişilere açıklanması ve eserin ilgililere sunulması olduğu sonucuna varabiliriz. Ancak bu üçüncü kişiler eser sahibinin aile ve yakınları dışındaki kişiler olarak algılanmalıdır. Yani eserin “umuma arz edilmesi” o eserin alenileşmesi anlamına gelmektedir. Ancak eserin alenileşmesine karar verirken mimarların çok dikkatli olmaları gerekmektedir. Birçok mimarın başına gelen tipik olay; hazırladıkları ön projenin teslim alınmasının ardından “işten vazgeçtim” denerek bu projeyi bir başkasına uygulama projesi haline getirip uygulayan iş sahiplerinin bulunmasıdır. Bu anlamda örneğin incelenmesi için işverene teslim edilen bir fikir projesinin ya da bir ön projenin mimarın teyidi olmadan alenileşmiş sayılmaması gerekmektedir. Böylece henüz alenileşmemiş bir eserden her ne şekil ve tarzda olursa olsun faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine ait ol-

⁸⁶ Bern Sözleşmesinin 11. maddesi, “Edebiyat ve sanat eserleri sahipleri, eserlerinin... her türlü araçla topluma iletilmesine...izin verme hususunda inhisari bir hak sahibidir” şeklinde düzenlenmiştir.

*maktadır ve mimar iş sahibini bu konuda yazılı olarak haberdar etmeli ve uyarmalıdır.*⁸⁷

Mimari yapılar açısından bu durumu irdelediğimizde; mimari eserler, genellikle umuma açık yerlerde inşa edileceğinden, kamuya sunma yetkisi daha en başta kullanılmış olmaktadır. Ancak tasarım, maket, plan ve projeler için mimar, bu eserleri ne zaman isterse o zaman kamuya açıklayabilir. Bu konuda mimara o işi veren iş sahibi bile eser hakkında mimardan izin almadan üçüncü kişilere bilgi veremez, açıklama yapamaz. Bu ihlal, daha çok iş sahiplerinin yapılan projeyi bir halkla ilişkiler veya pazarlama faaliyeti çerçevesinde medya aracılığıyla duyurma şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak işveren, mimardan bilgi verme ve umuma arz için yazılı olarak yetki alabilir ve bu doğrultuda Medyaya ve üçüncü kişilere açıklama yapabilir. Aksi halde işveren hem tazminat davaları ve hem de iki yıldan başlayan hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir.

Eğer eserin bütünü veya önemli bir kısmı kamuya sunularak alenilemişse, yahut ana hatları herhangi bir şekilde kamuya sunulmuşsa, bu eserin ne olduğu hakkında iş sahibi üçüncü kişilere bilgi verebilir.

Eserin kamuya sunulmasına mimar karar verdiğine göre, inşaatı bitmiş bir yapının kullanıma açılmasına da mimar karar verecektir. Bu durumda mimar, tasarımına uygun olmayan, fen ve sanat kurallarına uygun olarak inşa edilmeyen yapının yeterli olmadığı sonucuna varırsa, eserini umuma arz etmeyebilir. Mimarının izni olmadan “iskan ruhsatı” verilemeyecektir. Bu durumu kimse göze alamayacağı için dolaylı olarak mimara, inşaatı denetleme (sanatsal ve teknik gözetim) hakkı verilmiş olmaktadır. Böylece mimarlar tasarımlarının uygulanma sürecine katılabilmektedirler. Aynı kural iç mimari uygulamaları için de geçerlidir.

Kanun’un umuma arz ifadesi ile aynı zamanda binanın kullanıma açılması, “oturulması ve kullanılmasına” izin verilmesi anlamı çıkmaktadır. *Bu hak yapılan tasarım için, tasarımını yayınlatıp yayınlamama hakkının kullanılmasını diğer sanatçılar gibi mimara da tanımaktadır.*⁸⁸ Yayınlatma hakkının yanı sıra mimarın yayınlanma zamanını ve nasıl yayınlanacağını belirleme hakkı da bulunmaktadır. Yukarıda belirtilen 14.

⁸⁷ Salih Zeki PEKİN, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile Kazanımlarımız ve Mimar Olarak Yapmamız Gerekenler, Mimarlık Dergisi, 1995/266, s.8.

⁸⁸ Salih Zeki PEKİN, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası ile Kazanımlarımız ve Mimar Olarak Yapmamız Gerekenler, Mimarlık Dergisi, 1995/266, s.8.

maddede; mimari projenin veya tasarımın kamuya sunuş şekli ve tarzı mimarın şeref ve itibarını zedeleyecek mahiyette ise, mimarın; yayınlana umuma sunuş için yazılı izin vermiş olsa bile, kötü bir tarzda kamuya tanıtılmayı veya yayımlanmasını yasaklayabileceği düzenlenmiştir. Mimarın, şeref ve itibarını zedelese bile her şartta yayınlanmasına önceden izin vermesi veya yasaklama yetkisinden yapılan sözleşme ile önceden vazgeçmesi hükümsüzdür. Ancak mimarın yasaklama yetkisini kullandığı durumlarda, kusursuz olan yayıncı tarafın da uğramış olduğu zararlara ilişkin tazminat hakkı saklıdır.

2. Adın Belirtilmesi Yetkisi

FSEK madde 15; “*eseri, sahibinin adı veya müstear ad ile yahut ad-sız olarak, umuma arz etme veya yayımlama hususunda karar vermek salâhiyeti münhasıran eser sahibine aittir. Bir güzel sanat eserinden çoğaltma ile elde edilen kopyalarla bir işlenmenin aslı veya çoğaltılmış nüshaları üzerinde asıl eser sahibinin ad veya alâmetinin, kararlaştırılan veya âdet olan şekilde belirtilmesi ve vücuda getirilen eserin bir kopya veya işlenme olduğunun açıkça gösterilmesi şarttır. Bir eserin kimin tarafından vücuda getirildiği ihtilâflı ise, yahut herhangi bir kimse eserin sahibi olduğunu iddia etmekte ise, hakikî sahibi, hakkının tespiti mahkemen isteyebilir. Eser niteliğindeki mimarî yapılarda, yazılı istem üzerine eserin görülen bir yerine, eser sahibinin uygun göreceği malzeme ile silinmeyecek biçimde eser sahibinin adı yazılır.*” şeklinde düzenlenmiştir.⁸⁹

Bu madde ışığında adın belirtilmesi yetkisini şu şekilde açıklayabiliriz; FSEK madde 15/1’de yer alan eser sahibine ait “adın belirtilmesi hakkı” esas itibarıyla; eser sahibi olarak tanıtılmayı amaçlanmaktadır. Hatta Yargıtay’ın 1978 tarihli bir kararında; eser yayımlanırken, eser sahibinin adının belirtilmemesinin maddi ve manevi tazminata dayanak oluşturacağı belirtilmiştir.

Yine Yargıtay’ın 1999 tarihli başka bir kararında; her türlü projenin eser sayılacağı, davacının üstlendiği inşaatın tanıtım levhasında davacı adı yer almadığından manevi tazminat gerekeceği belirtilmiştir.⁹⁰

⁸⁹ Bern Sözleşmesinin 10. maddesi, eserin her türlü kullanımında eser sahibinin adı ve kaynağın belirtilmesi gerektiğini düzenlemektedir.

⁹⁰ 11. HD., 24.6.1999, 1999/3793 E., 1999/5726 naklen. Arzu Genç ARIDEMİR, Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları, İstanbul, 2003, s. 26.

Bu şekilde mimarlar; çalışmalarının sadece proje ve çizim olarak al-
gılanmasının önüne geçmekte, “üretilen eser ve yapı” ile “mimarın adı ve
projeleri” arasında hukuksal bir bağ kurabilmektedirler.

Adın belirtilmesi yetkisiyle eser ile eser sahibi arasında bir bağ ku-
rulmaktadır. Bern Anlaşması’nın 6. (mükerrer) maddesinde asgari hakların
arasında yer alan bu yetki, eserin kullanıldığı herhalde geçerli olmaktadır.

Netice olarak, FSEK’in 15. maddesine göre, mimari yapılarda, yazılı
istem üzerine yapının görünen bir yerine ve silinmeyecek bir şekilde, eser
sahibinin belirleyeceği bir malzeme ile eser sahibinin adı yazılabilmektedir.

Öğretinin savunduğu görüşe göre; mimari eserlerdeki “**adın kulla-
nılması hakkı**” yazılı talebe bağlıdır ve bu talep ancak, mimari eser ta-
mamlanıncaya kadar ileri sürülebilmektedir.⁹¹ Bu görüş çerçevesinde mi-
mari eserlerin yapımı tamamlanınca artık bu haktan yararlanmak söz ko-
nusu olmamaktadır.

Eser sahibini korumayı amaçlayan FSEK kuralları dikkate alındı-
ğında, adın belirtilmesi talebinde bulunabilmeyi yapının tamamlanması
süresi ile sınırlamak görüşünün hatalı olduğu sonucuna varabiliriz. Bizce
adın belirtilmesi talebi her zaman ve yapı tamamlandıktan sonra da eser
sahibinin yazılı bir beyanıyla yapılabilmelidir. Ancak Yargıtay’ın -ücretle
ilgili olsa da- bir kararında⁹²; “hak sahibinin sessiz kalması halinde hak-
kını sonradan ileri sürmesinin Medeni Kanun madde 2 ye aykırı olacağı”
sonucuna varılarak, sınırlamacıların görüşüne üstünlük tanınmaktadır.
Yargıtay’ın bu tutumunu yeni davalarda değiştireceği inancındayız.

Yargıtay, mimari eserlerdeki “adın belirtilmesi yetkisi” hakkındaki
bir başka kararında⁹³; 1957 yılından 1967 yılına kadar birlikte çalışan da-
vacı ve davalıların bu dönemlerde yaptıkları plan ve projelerin ortak ol-

⁹¹ SULUK/ORHAN, age., s.351.

⁹² “Davacı, davalı yayın kuruluşunda davaya konu teşkil eden yazılarını yazmaya başla-
dığı 6.8.1995 tarihinden davanın açıldığı tarih olan 11.11.1999 tarihine kadar 200 adet
yazı için hiçbir ücret talep etmeden yazılarını düzenleyerek vermiş olup, bu yayın ku-
ruluşundan ayrıldıktan sonra (bu davada) ücret ödenmesine ilişkin istemde bulunması
üzerine; Mahkeme; davacının hobi amaçlı yazdığını, sadece isminin duyulmasını iste-
diğini belirterek zamanında ücret istemediğinden davayı reddetmiştir. Yargıtay’da
temyiz aşamasında, sonradan ücret istemi MK md. 2’de ifadesini bulan objektif iyi
niyet kurallarına aykırı düştüğü için Mahkeme kararı kabul edilmiştir.” 11. HD.,
22.3.2001, E. 2001/11107, K. 2001/2279. (Yargıtay Kararları No: 39)

⁹³ 11. HD., 4.5.2000, E. 2000/600, K. 2000/3862. (Yargıtay Kararları No: 33)

ması nedeniyle; daha sonradan dergilere verilen demeçlerde o dönemlere ait olan eserlerin, davacının ismi hiç zikredilmeden, sadece davalı tarafından yapıldığına ilişkin ifadelerin bulunması sebebiyle davacı, hakkının haleldar edildiğini belirterek tazminat davası açmıştır. Ancak yapılan yargılama sonucunda; söz konusu açıklamanın yaratılmış eserlerin tanıtılmasına yönelik olmadığı ve davalı mimarın kendisini ve eserlerini tanıtmaya yönelik monografi olması gerekçesiyle ve ortak eserin otobiyografide kullanılmasında diğer eser sahibinin adının yeterince belirtilmesi durumunda hak ihlalinden bahsedilemeyeceği sonucuna varılmıştır. Bu karardaki önemli nokta; davalının kendi yaşamı ve yarattığı eserleri tanıtmak amacıyla yayınladığı otobiyografi niteliğindeki kitapta, bir bölümde yaratılan ortak eserin diğer sahiplerinden bahsetmemekle beraber başka bölümlerde katkıları bulunan diğer kişilerden ve diğer eser yaratıcılarından yeterince bahsetmiş olmasıdır ki, bu sebeple FSEK madde 15/3 teki hakkın ihlal edilmediği sonucuna ulaşılmıştır. Eğer ortak eseri yaratan kişilerden hiç bahsetmeden, eser sahiplerinden biri tarafından eserleri kendi yaratmış gibi bir anlam çıkaran açıklama yapılırsa bu durumda hukuka aykırılık söz konusu olur.

Mimari eserler, plan ve projelerde eser sahibinin adının belirtilmesi konusunda Yargıtay dolaylı olarak kararlar da vermiştir. Bu kararlar daha çok eserin değiştirilmesi sonucu mimarın isminin kaldırılması açısından- dır. Bu konuyu aşağıda ayrı bir bölümde inceleyeceğiz, ancak ad koyma konusunda küçük bir açıklamada bulunalım. Yargıtay; eser sahibinin izni olmadan yapılan değişiklik hallerinde değişikliklerin ortadan kaldırılmasına -ancak, kamunun ve malikin menfaatlerine önemli ölçüde zarar gelmeyecekse ve eski hale iadesi mümkünse- karar vermekte ve eserin eski hale getirilmesine hükmetmektedir. Eğer bu şartlar mevcut değilse eser sahibi, sadece özgün eserdeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığının tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırılmasını isteyebilir.⁹⁴ Ayrıca istem doğrultusunda eser sahibinin manevi hakları tecavüze uğradığı için manevi tazminata hükmedilmesi de söz konusu olabilmektedir.

FSEK madde 15/2 bazı eserlerin niteliğinden hareketle özel hükümler öngörmektedir. Bir güzel sanat eserinin işleme suretiyle meydana getirilmesi veya kopyalanması halinde (doğaldır ki işleme veya kopyalama için eser sahibinden izin almak gerekir); mevcut eserin bir kopya ve iş-

⁹⁴ 11.HD., 6.7.1998, E.1998/3202, K.1998/5147 – YKD, C.19, S.4/1998, s.289-290 ve BATİDER, C.XIX, S.4/1998, s. 289 vd. (Yargıtay Kararları No: 21)

leme olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Buradaki amaç, kopyayı yapan kişinin, toplumu yanıltmasını önlemektir. Ayrıca kopyanın kötü olması halinde gerçek eser sahibinin adının belirtilmesi nedeniyle eser sahibinin itibarının zedelenmesinin de önüne geçilmiş olmaktadır.

FSEK madde 15/3; bir eserin kimin tarafından yapıldığının ihtilaflı olduğu durumlarda, eser sahibinin tespiti davasının açılabileceğini düzenlemektedir.

3. Eserde Değişiklik Yapılmasını Önleme Yetkisi

FSEK madde 16; *“Eser sahibinin izni olmadıkça eserde veyahut eser sahibinin adında kısaltmalar ekleme ve başka değiştirmeler yapılmaz. Kanunun veya eser sahibinin müsaadesiyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğaltan, yayımlayan, temsil eden veya başka bir suretle yayan kimse; işleme, çoğaltma, temsil veya yayım tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeleri eser sahibinin hususî bir izni olmaksızın da yapabilir. Eser sahibi, kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirilmeleri menedebilir. Menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür.”* şeklinde düzenlenmiştir.

Bern Sözleşmesi'nin de mükerrer 6. maddesinde; eser sahibinin *“eserin kendi eseri olduğunu beyan etmek ve bu eserin kendi şeref ve şöhretine zarar veren her türlü bozuluşuna, parçalanışına veya herhangi bir şekilde değişikliğe uğratılmasına yahut aynı eserin başka herhangi bir suretle haleldar edilmesine muhalefet etmek hakkını”* muhafaza edeceği ve bu hakkın onun *“ölümünden sonra, hiç değilse mali hakların ortadan kalkmasına kadar”* devam edeceği belirtilmektedir.⁹⁵

Anayasa madde 90'a göre; imzalanmış uluslararası sözleşmeler kanun hükmünde olduğundan Bern ile FSEK arasında çelişki halinde uluslararası sözleşme hükümleri esas alınmaktadır.

Bir yaratının eser olarak adlandırılabilmesi ve hukuki korumalardan yararlanabilmesi için sahibinin hususiyetini (özelliklerini) taşıması gerektiğinden bahsetmiştik. Bu nedenle bir eserde değişiklik yapmak kimi zaman o eserin özelliğine zarar vermek anlamına gelmektedir. Eser sahibinin özelliği eserin bütününde veya eserin kimliğini belirleyici bir parçasında

⁹⁵ Ayrıca, Bern Sözleşmesinin 12. maddesi; eser sahiplerinin eserlerinin her türlü değişikliğine izin verme konusunda inhisari hak sahibi olduğunu belirtmektedir.

da görülebileceği için eserin özelliğini etkileyecek bu tür parçasının değiştirilmesi, çoğu zaman bu hakkı ihlal etmek anlamına gelir ve tazmin edilmesi gerekir.

Bu açıklama dahilinde FSEK 16. maddesini şu şekilde detaylandırabiliriz;

Eserin adı ve muhtevası ile şekil olarak eserin kendisi bir bütünlük arz ettiği için; bu bütünlüğün korunmasında eser sahibinin manevi bir çıkarının olduğu oldukça açıktır. Bu nedenle ondan izinsiz, eserde veya “yapı”da özelliği (veya sahibinin kişiliğini kötü yönde) etkileyecek her değişiklik hak ihlali sayılmaktadır. Eserin adı yahut muhteva veya biçimi yönünden eserin kendisinde yapılacak bir değişikliğe karşı koyma hakkı; yukarıdaki görüşler doğrultusunda, ya eser sahibinin şeref ve itibarının zedelenmesi veya eserin nitelik ve özelliğinin bozulması halinde söz konusudur.⁹⁶

FSEK madde 16/1 de belirtildiği gibi; eser üzerinde sahibinin izni olmadan değişiklik yapılmayacağına ilişkin kural sadece eser için değil aynı zamanda, eserin ismine ilişkin değişiklikleri de kapsamaktadır.

FSEK madde 16/2; esere ilişkin mali hakların devri sırasında eser sahibinin, eserde değişiklik yapma yetkisini de yazılı bir belge veya bir sözleşme maddesiyle işverene tanımış olabileceğinden veya işlenme, özellikle çoğaltma (yani yapının imal edilmesi, projelerin binaya uygulanması), temsil veya yayma haklarını devir almış olanların, bu haklarını kullanabilmeleri için eserde zaruri olan değiştirmeleri yapabileceklerinden bahsetmektedir. Mimari eserler için; mimari yapı sayılan bir eserin bir şekilden başka bir şekle sokulmasına mimarı (eserin gerçek sahibi) tarafından izin verilmişse ve bu değişmeyi bir başkası yapıyorsa ve yapılan değiştirme değişikliği yapanın hususiyetini taşıyorsa bu bir işlemdir ve ortaya çıkan yapı yeni bir eser sayılmaktadır. Anlaşılabacağı gibi mimari eserde işlenme olabilmesi için eser sahibi olan mimarın izni gerekmektedir.

Ancak yapılan değişiklik *objektif olarak* eser sahibinin şeref ve itibarını düşürüyor yahut eserin nitelik ve özelliğini bozuyor ise eser sahibi (önceden izin vermiş olsa bile) bu değişikliklere karşı koyabilir ve eserin kamuya sunulmasını engelleyebilir. Eser sahibinin bu konudaki yetkisin-

⁹⁶ Bir güzel sanat eserinin hususiyet ve tamamiyetini her türlü değiştirici davranış manevi tazminat talebi için yeterlidir (HGK. 11/2/1983, E. 1981/4-70 K. 1983/123, ÇEVİK: age.,s. 22 not 9). (Yargıtay Kararları No: 4)

den sözleşmeyle tamamen feragati de FSEK madde 16/3 gereğince hükümsüzdür.⁹⁷

Bir mimari eserde zorunlu olanlar dışındaki değişikliklere izin verme yetkisi yaratıcısı mimar tarafından kullanılabilir ve miras yoluyla intikale yahut üçüncü şahıslara devredilmeye elverişli değildir. Eserde yapılacak haksız değişikliklere karşı, eser sahibi hukuk ve ceza davalarıyla korunmuştur. Yargıtay 1996 tarihli bir kararında; “atık su tesisine ilişkin projenin FSEK kapsamında ve korunması gerekli bir ilmi fikir eseri olduğunu, *davacının izin ve muvafakati olmadan proje tadilatı yapılamayacağını*, eser üzerindeki davacı logosu kaldırılarak davalı şirketin levhasının asılmasını davacının haklarına tecavüz olarak kabul etmiştir. Ancak maddi zarara uğrandığı ispat edilemediğinden Mahkeme maddi tazminat istemini reddetmiştir.”⁹⁸

Yargıtay 2001 yılındaki verdiği bir kararda; “güzel sanat eserinin (mimari proje), haksız ve eser sahibinin rızası olmadan değiştirilmesi halinde, eski halin iadesi mümkünse ve değişikliğin kaldırılması kamunun ve malikinin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa, eserin eski hale getirileceğini ...” belirtmiştir. Ayrıca bu kararda, “şayet değişiklik nedeniyle bir infaz (yani bazı kısımların yıkılması) yapılacaksa, bu infazın ne şekilde yapılacağının da karar kısmında ayrıntılı olarak açıklanarak ve somut olarak eski hale getirme kararı verilmesi gerektiği” üzerinde durulmuştur.⁹⁹

Yapı ve bina niteliğindeki mimari eserlerin -anıtlar ve benzerleri bir yana bırakılırsa- estetik olma özelliği dikkate alındığında güzel sanat eseri olarak değerlendirileceğini; bilimsel eserler kapsamına giren plan, proje,

⁹⁷ Yargıtay 15.HD. E. 1992/490, K. 1992/1984, T. 15.4.1992: “...yapılarak davalıya teslim edilen projelerin sahibi davalı bankadır. (...) sözleşmeye ekli proje yapım şartnamesinde ...projeler idarece tasdik edildikten sonra bankanın malı olacağından, *banka gerekli gördüğü her türlü tadilatı işin seyrine göre proje müellifinin muvafakatini almadan yapabilecektir* denmekle beraber, eser sahibi kayıtsız şartsız izin vermiş olsa bile şeref ve itibarın yahut eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değişikliklere muhalefet hakkını muhafaza eder. Yasanın açık hükmü gözetilerek; davacının manevi tazminat istediği yönünde (...) projenin uygulama projesine dönüşürülmesi sebebiyle, (...) eserin manevi tazminatı gerektirecek nitelikte mahiyet ve hususiyetinin bozulup bozulmadığı hususunda rapor alınması... gereklidir” (Y.K.D. Cilt 18, Sayı 10, Ekim 1992, s. 1585-1586) (Yargıtay Kararları No: 6)

⁹⁸ 11. HD., 1.7.1996, E. 1996/2451, K.1996/4820. (Yargıtay Kararları No: 13)

⁹⁹ 11. HD., 29.3.2001, E. 2001/143, K.2001/2548. (Yargıtay Kararları No: 40)

tasarı ve maketlerdeki koruma yerine burada yapının kendisinin koruma altına alındığını tekrarlamalıyız. Ancak mimarlık eserlerinde, estetik olma özelliğinin dışında bir özelliğinin olması daha gerekmektedir. O da fonksiyonel olma zorunluluğudur. Fonksiyonel olma, yani kullanım ve ihtiyaçlara cevap verme unsuru, mimari eserleri diğer güzel sanat eserlerinden ayıran en önemli özelliktir. Bu unsur itibariyle eser sahibi olarak mimarın eserde değişiklik yapılmasını men etme hakkı (FSEK madde 16), diğer güzel sanat eserlerine nazaran önemli ölçüde kısıtlanmış ve bu durum fikri hukuka ilişkin doktrin ve yargı içtihatlarında ittifakla kabul edilmiştir.¹⁰⁰ Gerçekten de hukuki uygulamayı belirleyen Yargıtay kararlarına göre; kullanım ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir mimari eserin (yapının) değiştirilmesi, diğer güzel sanat eserlerinin değiştirilmesine nazaran daha gevşek bir rejime tabidir.

Bu anlamda mimarın, eser sahibi olarak haiz bulunduğu fikri haklar ile, bina sahibinin özel hukuktan doğan hak ve yetkilerini ve ayrıca kamu hukukundan doğan imar düzenine ait mülkiyet tahditlerini dengede tutmak zorunluluğu vardır. Zira aşağıda da inceleneceği üzere, bina sahibi Medeni Kanun'un 683. maddesi uyarınca mülkü üzerinde kanun dairesinde dilediği gibi tasarruf edebilirken, mimar diğer güzel sanat eseri sahipleri gibi eserde her türlü değişikliği yasaklayamaz; sadece mesleki şeref ve itibarını yahut eserin mahiyet ve özelliğini bozan değişikliklere muhalefet hakkını muhafaza eder.¹⁰¹

Mimar, mimari eseri vücuda getirirken, plan ve projeleri yaparken, bunun belirli kullanım ihtiyaçlarına cevap vermek üzere yapıldığını bilir ve ona göre hareket eder. Yukarıda da belirtildiği gibi, diğer güzel sanat eserlerinden farklı olarak mimari eserlerde kullanım amacı estetik mülahazalardan önce gelir. Bu yüzden eser vücuda getirildiği sırada hakim olan kullanım amacı zaman içinde değişir, hatta tamamen ortadan kalkarsa, mimarın da bu yapının yeni ihtiyaçlara göre tadiline veya yıkılarak tamamen ortadan kaldırılmasına katlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur. O halde daha mimar proje aşamasında, malike mülkiyet hakkı ve imar mevzuatı çerçevesinde ileride o yapıyı tadil etmek hususunda, mesleki şeref ve

¹⁰⁰ Martin J. LUTZ: Über das Urheberrecht des Architekten bei der Änderung von Bauwerken, Festschrift für M. PEDRAZZINI, Bern, 1990, s. 617 vd.; Alois TROLLER: Das Urheberrecht an Werken der Architektur, ZBJV., Band 81, Heft 9, Sept. 1945 Naklen EREL, age., s. 125.

¹⁰¹ EREL, age., s. 126.

itibarını gözetmek kaydıyla yetki vermiş sayılmalıdır. Bu husus doktrin ve yargı içtihatlarında uzun zamandan beri kabul edildiği gibi, Avrupa ülkelerindeki modern telif hakları kanunlarında da hükme bağlanmıştır.¹⁰²

Fikri hukuk doktrininde eser sahibi olarak mimara tanınan hi-mayenin, onu sadece malikin keyfi tasarruflarına karşı korumak amacına yönelik olduğu kabul edilmektedir. FSEK madde 16/III hükmü genel olarak eser sahiplerine, eserde şeref ve itibarını zedeleyecek de-ğişiklikler yapılmasına engel olma hakkı tanımıştır. Ancak mimari eserlerde kullanım amacı estetik mülahazalardan önce geldiğinden, hiçbir hukuk düzeni mimarın sübjektif estetik değerlerinin korunması uğruna, kullanım amacından uzaklaşmış yahut yetersiz kalmış bir yapının orijinal haliyle muhafaza edilmesine veya malikin yine bu estetik değerleri korumak uğruna ağır mali külfetler altına sokulmasına izin vermez.¹⁰³

Yargıtay'ın mimari eserlerin değiştirilmesine ilişkin verdiği karar-lara göz attığımızda bu görüş desteklenmektedir.

Yargıtay'ın 2004 yılındaki bir kararında; “bir projede değişiklik ya-pılarak hak ihlal edildiğinin ileri sürülmesi her somut olaya bağlı olarak MK madde 2 anlamında “hakkın kötüye kullanımı” da teşkil edebilmekte-dir. Bu nedenle özellikle proje sahiplerinin, kendi projelerinde değişikliği bizzat kendisinin yapması veya **teknik zorunluluklar nedeniyle yapılan izinsiz değişiklikler halinde**, eser sahibinin eserde değişiklik yapıldığı iddiasını hukuken haklı bulmaz.”¹⁰⁴

Yargıtay, eser sahibinden izin alınmadan yapılan ve zorunluluğu aşan değişiklikler konusunda, eğer yapılan değişiklik mimari eserin özelli-ğini bozuluyorsa veya eser sahibinin şeref ve itibarına zarar veriyorsa; davacı mimarın, mimari eserle ilgili olarak eski hale iade talebiyle birlikte manevi tazminat istemini de kabul etmektedir.¹⁰⁵ Ancak Türk Hukukunda

¹⁰² Belçika Hukuku için bkz.: Revue de droit Intellectuel 1946, s. 22; Finlandiya Kanunu (1961) § 13; İtalya Kanunu (1941) md. 10/II; Japonya Kanunu (1970) § 20; Hollanda Kanunu (1912) md. 25/I,b; Norveç Kanunu (1961) § 12; Avusturya Kanunu § 83/III; İsveç Kanunu (1960) § 13; SSCB Medeni Kanunu (1964) md. 492-494 Naklen EREL, age., s.126.

¹⁰³ A. TROLLER, Bedenken zum Urheberpersönlichkeitsrecht, UFITA, Cilt 28, 1959 II, s. 385 Naklen EREL, age., s.126.

¹⁰⁴ 11. HD., 14.10.2004, E.2004/9774, K.2004/9844. (Yargıtay Kararları No: 55)

¹⁰⁵ “ Davacı şirket tarafından plan ve projesi yapılarak uygulanan fabrikanın atık su arıtma tesisleri davacı şirketin eseri olarak FSEK kapsamında korunmaktadır. Ancak

manevi tazminatın miktarı konusunda Yargıtay'dan kaynaklanan sorun var. Yargıtay'a göre manevi tazminatın miktarı zenginleşmeye neden olamaz. Bu yüzden Yargıtay 5.000 – 10.000 YTL'nin üzerinde belirlenen manevi tazminat miktarlarını fazla bulmakta ve yerel mahkemeleri düşük tazminat belirlemeye zorlamaktadır. Düşünün bir milyon dolarlık bir iş yapıyorsunuz, projeniz ve eseriniz beş yıl sonra perişan ediliyor ve siz 5.000 YTL tazminatla yetiniyorsunuz. Yargıtay, ne yazık ki kararları ile bu sonuca yol açıyor. Umarım değişir.

Mimari eserlerde değişiklik yapılmasını önlemeye yönelik davalar eser sahibi tarafından hayatı boyunca açılabilceği gibi, ölümünden sonra 70 yıl içinde vaki tecavüzlere karşı FSEK madde 19/I' de belirtilen şahıslar tarafından kendi namlarına da açılabilir. Ayrıca eser sahibi veya haleflerinden mali bir hakkı devir almış olup, meşru bir menfaati bulunduğunu ispat eden şahıslar da bu mali hakkın koruma süresi içinde dava açabilirler. Keza memleket kültürü bakımından önemli görülen eserlerde koruma süreleri dolmuş olsa bile, Kültür Bakanlığı dava açma yetkisine sahiptir.¹⁰⁶

Başlamış ve devam etmekte olan bir tecavüz sebebiyle açılacak "*tecavüzün ref'i*" davasıyla; eserin değiştirilmiş şekliyle çoğaltılmasının yasaklanması ve tecavüz edenin piyasada dolaşımda bulunan çoğaltılmış kopyalardaki değişiklikleri düzeltmesi veya eseri eski haline getirmesi talep edilir. Değişiklik; mimari yapının gazete, dergi veya diğer iletişim araçlarıyla yayımı sırasında yapılmışsa, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayım(n)lamış olan bütün gazete, dergi ve diğer iletişim araçlarında değişikliğin ilan yoluyla düzeltilmesi istenebilir (FSEK madde 67/bent 1).

Mimari yapıda değişiklik yapılması konusunda karar verme ve gerekirse yapılan değişikliği menetme yetkisi eser sahibi mimara tanınmakla birlikte, bunun istisnası mimarın işverene değişiklik konusunda yetki ver-

daha sonradan fabrikaya yeni kurulan boya imalat ünitesinin arıtma tesislerinin (davalı isteğiyle başkası tarafından) yapılarak davacının eserinin mahiyetinin bozulduğuna ve davacı şirketin tabelasının çıkarılarak tüm tesislerin davalıca yapılmış izlenimi verildiğine dayanarak açılan davada, yapılan eylemlerin FSEK kapsamında tecavüz niteliğinde olduğu sonucuna varılmıştır. Davalıların tecavüzünün önlenmesine, eserin eski hale getirilmesine ve davalının levhasının kaldırılmasına ve manevi tazminata hükmedilmesine karar verilmiştir. Ancak maddi tazminata yer olmadığı sonucuna varılmıştır." 11. HD., 1.7.1996, E. 1996/2451, K. 1996/4820. (Yargıtay Kararları No: 13)

mesidir. Fakat mimar değişiklik konusunda işverene yetki vermediyse, işveren de sanki kendisinde bu yetki varmış gibi başkasına bu konuda değişiklik yetkisi vermişse; eser sahibi, FSEK madde 54'e göre değişikliği yapandan ve işverenden yetkisiz değişiklik nedeniyle, tazminat isteminde bulunabilir ve hakkaniyet gerektiriyorsa; mahkeme daha geniş bir tazminata hükmedebilir. FSEK 54'e dayanan bu yolun pek denendiğini görmedim, ama daha geniş tazminat için eğer yetkisiz değişiklik izni verilme söz konusu ise bir davada bu mücadele verilmelidir.

Mimari yapılarda değişiklik yapılmasına ilişkin bir hüküm de Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 19. maddesinde yer almaktadır. Buna göre, binanın ortak yerlerinde özellikle dış görünüşe ve ortak kullanım alanlarına yönelik değişiklikler yapılması, bütün kat maliklerinin oy birliği ile mümkündür.¹⁰⁷ Örneğin balkonun kapatılması veya binanın bir cephesini kaplayacak şekilde reklâm alınması gibi.¹⁰⁸ Buna karşılık binanın iç kısımlarında değişiklik yapılması sadece, değişiklikten etkilenebilecek komşu kat malikinin izin vermesiyle yapılabilir. Buna örnek olarak, mutfakla salon arasında servis penceresi açılması veya dairenin iki odasının birleştirilmesi gösterilebilir. Böyle bir durumda tüm kat maliklerinin izninin alınmasına gerek yoktur. Tabii bu hallerde imar mevzuatı açısından bir sakınca olmamalı, binanın statüğü tehlikeye düşürülmemelidir.¹⁰⁹

4. Eserin Aslına Varma Yetkisi

FSEK madde 17 bu konuda; *“eser sahibi, gerekli durumlarda, aslın maliki ve zilyedinden, koruma şartlarını yerine getirmek kaydıyla, ... eserlerinin asıllarından geçici bir süre için yararlanmayı talep etme hakkına sahiptir. Eser sahibinin bu hakkı, bu eserlerin ticaretini yapanlar tarafından, eseri satın alan veya elde eden kişilere müzayede ve satış*

¹⁰⁷ Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/ Ar. Gör. K. Emre GÖKYAYLA, Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah EDİS'e Armağan, İzmir, 2000, s. 413.

¹⁰⁸ Bu konu hakkında bkz. Şeref ERTAŞ, Eşya Hukuku, İzmir, 1997, s.394; M.Kemal OĞUZMAN/ Özer SELİÇİ/ S.Oktay ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, İstanbul, 2006, s.503; Kemal T GÜRSOY/ Fikret EREN / Erol CANSEL, Türk Eşya Hukuku, Ankara, 1978, s.483., Hüseyin HATEMİ/ Rona SEROZAN / Abdülkadir ARPACI, Eşya Hukuku, İstanbul, 1991, s.177 Naklen Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/ Ar. Gör. K. Emre GÖKYAYLA, Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah EDİS'e Armağan, İzmir, 2000, s. 413.

¹⁰⁹ Prof. Dr. Şeref ERTAŞ/ Ar. Gör. K. Emre GÖKYAYLA, Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah EDİS'e Armağan, İzmir, 2000, s. 413.

katalogu veya ilgili belgeler ile açıklanır. Aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez. Eserin tek ve özgün olması durumunda eser sahibi, kendisine ait tüm dönemleri kapsayan çalışma ve sergilerde kullanmak amacıyla, koruma şartlarını yerine getirerek iade edilmek üzere eseri isteyebilir.” hükmüne yer vermiştir.

Bu madde hükmünü açıklayabilmek için öncelikle şu hususa değinmek gerekmektedir. Fikir ve sanat eserleri, üzerinde cisimlendikleri maddi maldan ayrı bir hukuki varlığa sahiptirler. Maddi mal her türlü hukuki işleme serbestçe konu olabilir, üzerinde başka şahıslar lehine şahsi veya ayni haklar tesis edilebilir. Bu durum maddi mal halinde cisimlenmiş bir eser üzerindeki fikri hakları kural olarak¹¹⁰ etkilemez. Mesela bir ressamın sattığı resmi üzerinde bütün manevi hakları ve mali haklarından da bir kısmı devam eder.¹¹¹

Mimari eserler açısından bu madde projelerin veya maketlerin korunmasına ilişkindir. Bir mimari proje yarışması sonunda veya herhangi bir yapının bitiminde, yatırımcı kuruluş veya mal sahipleri, tüm projeleri, tasarımları, maketleri ve çalışmaları mimardan almaktadır. Daha sonra bu çalışmaların akıbeti yani satın alan tarafından saklanıp saklanmadığı belli olmamaktadır. Oysa mimarın bunlar üzerindeki yararlanma hakkı hâlâ devam etmektedir. İşte Kanun’un bu maddesiyle mimarlar gerek sergilerde kullanmak, gerekse yarışmalara katılmak veya yayın yapmak gibi amaçlarla bu çalışmaları geri isteyebilme hakkına sahip olmaktadır.

FSEK madde 17/II hükmünde “*aslın maliki, eser sahibi ile yapmış olduğu sözleşme şartlarına göre eser üzerinde tasarruf edebilir. Ancak eseri bozamaz ve yok edemez ve eser sahibinin haklarına zarar veremez*” şeklinde belirtildiği üzere; eser sahibinin eserde değişiklik yapılmasını men etmek hususunda FSEK madde 16’da belirtilen manevi hakkının özel bir uygulaması gösterilmektedir. Eser sahibi mali hakları devrettiği kimselerin eserde kendi şeref ve itibarını yahut eserin nitelik ve özelliğini bozan değişiklikler yapmalarını nasıl yasaklayabiliyorsa; aynı yetkiyi maddi malın malikine, hatta esere tecavüz eden üçüncü şahıslara karşı da haizdir.¹¹²

¹¹⁰ Maddi mal üzerindeki tasarrufların bazı hallerde fikri hakları da etkileyeceği karine olarak kabul edilmiştir. Bu hususta bkz.: FSEK md. 57/II ve III.

¹¹¹ EREL,age., s.130.

¹¹² EREL,age., s.132.

Malik, zilyed veya üçüncü şahıslar tarafından eserin maddi veya manevi bütünlüğüne, eserin bozulması veya yok edilmesi şeklinde yapılacak tecavüzlere karşı eser sahibi; tecavüzün ref'i, tecavüzün men'i, tazminat ve ceza davalarıyla korunmuştur. Bu yasal olanaklara eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı sebebiyle değinildiği için, oraya atıfla yetiniyoruz.

Ancak bu kuralın istisnasını yeniden hatırlatmakta yarar görüyoruz. Mimari bir eserin tadili halinde, binada malikin ihtiyaçlarına göre bazı değişiklikler yapılması durumunda ve bu değişikliklerin eserin estetik nitelik ve özelliğini bozmaması şartıyla, malik eser sahibinden izin almaksızın gerekli tadilatı yapmaya yetkili olmaktadır.¹¹³ Bunun dışında mülkiyet hakkının kullanılması eserde estetik niteliği ve özelliğini bozacak şekilde değişiklik yapmaya izin vermemektedir.

Tüm bu açıklamalar neticesinde mimari eserlerdeki “eserin aslına ulaşma yetkisi” konusunda şunu söyleyebiliriz: Mimar, daha proje aşamasında malike mülkiyet hakkı ve imar mevzuatı çerçevesinde sonradan o yapıyı tadil etmek hususunda, şeref ve itibarını gözetmek kaydıyla, yetki vermiş sayılmaktadır.¹¹⁴ Mimari eserin sonraki malikleri de, eser sahibinin şeref ve itibarını korumak ve mimari eserin mahiyetini değiştirmemek kaydıyla, eserde değişiklikler yapabilecektir. O kadar ki; yapı maliki işlevini görmeyen bir yapıyı yıkmaya dahi yetkilidir.¹¹⁵

B. MİMARİ ESER SAHİPLERİNİN MALİ HAKLARI

Daha öncede ifade ettiğimiz gibi; mali haklar, eser sahibine eserden ekonomik olarak yararlanma yetkisi verir. Bazı diğer ülke kanunlarının aksine FSEK; mali hakları; eserden ekonomik olarak her türlü yararlanmayı kapsayan bütün bir hak değil, fakat sınırlı şekilde sayılmış beş hak kategorisi halinde düzenlenmiştir. EREL, bu sınırlı sayıda belirtilen mali haklara “pay ve takip hakkı”nın da eklenmesi görüşündedir.¹¹⁶ Biz de, bu hak Kanun’un başka bir faslında düzenlenmiş olsa da, Ülkemizde

¹¹³ ARSLANLI, age., s. 87 Naklen EREL, age., s. 132.

¹¹⁴ EREL, age., s. 126.

¹¹⁵ HIRSCH, Fikri Say II, s. 149; AYİTER, age., s.123-124; EREL, age., s.128 Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 352.

¹¹⁶ EREL, age, s.133.

henüz uygulama alanı bulmamış olan pay ve takip hakkının mali haklara eklenmesi düşüncesindeyiz.

Mali hakların kullanılması konusunda, eserin alenileşmiş olup olmamasına göre bir ayırım yapılmaktadır. Henüz alenileşmemiş bir eser fikri hak düzeni içinde sınırlı biçimde korumaya konu olmaktadır. Daha önce verdiğimiz bir örnekte olduğu gibi incelenmesi için işverene verilen bir “fikir projesi” ya da “ön proje” mimar tarafından açıkça belirtilmiş olmadıkça alenileşmiş olmayacağı için fikri hakların korumasından etkin olarak yararlanamaz.

Ayrıca FSEK madde 20’ye göre mali haklar; manevi haklardan farklı olarak, birbirinden bağımsızdırlar ve bunlardan biri üzerindeki tasarruf ve kullanımlar diğerlerini etkilememektedir.

Tüm mali hakların devri FSEK madde 52 de olduğu gibi muhakkak; yazılı şekilde yapılmalı ve hangi mali hakların devredileceği ayrı ayrı yazılarak özellikle belirtilmelidir.

Yapılan bu kısa açıklamanın ardından mali hakları mimari eserler açısından tek tek inceleyelim.

1. İşleme Hakkı

FSEK 6. maddesinde; *“diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip te bu esere nispetle müstakil olmayan ve aşağıda başlıcaları yazılı fikir ve sanat mahsulleri işlenmedir”* şeklinde bir tanım vermiştir. FSEK’de sayılan işleme türleri çok çeşitli olmakla birlikte, mimari eserleri ilgilendiren işleme biçimlerini şu şekilde sıralayabiliriz.

- *Musiki, güzel sanatlar, ilim ve edebiyat eserlerinin filim haline sokulması veya filime alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir şekle sokulması;*

- *Güzel sanat eserlerinin bir şekilden diğer şekillere sokulması;*

- *Bir eser sahibinin bütün veya aynı cinsten olan eserlerinin külliyat haline konulması;*

- *Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde seçme ve toplama eserler tertibi;*

- *Henüz yayımlanmamış olan bir eserin ilmi araştırma ve çalışma neticesinde yayımlanmaya elverişli hale getirilmesi (ilmi bir araştırma ve çalışma mahsulü olmayan alelade transkripsiyonlarla faksimileler bundan müstesnadır);*

- *Başkasına ait bir eserin izah veya şerhi yahut kısaltılması.*

Bir eserden yararlanılarak başka bir eser oluşturulması şeklinde kısaca tanımlayabileceğimiz işleme için FSEK'in 6. maddesi iki şart öngörmektedir.

* İstifade edilen eserin sahibinin haklarına zarar getirilmemelidir.

* İşleme işleyenin özelliğini taşımalıdır.

Bu iki şart yoksa ortaya çıkan yaratıcı çalışma "eser" sayılmaz.

Bern Sözleşmesi'nin 12. maddesi; *"edebiyat ve sanat eseri sahipleri eserlerinin uyarlanması, düzenlenmesi ve diğer değişikliklerine izin verme konusunda inhisari hak sahibidir"* demektedir.

FSEK madde 21 de işleme hakkı konusunda; *"bir eserden, onu işlemek suretiyle faydalanma hakkı münhasıran eser sahibine aittir"* denmektedir.

FSEK'nun bu maddesi, eserin işleme hakkını başkalarına kullan-dırma yetkisini sadece eser sahibine verdiğini açıkça ifade etmektedir. FSEK madde 20/4'e göre; bir işlemenin sahibi, işleme eserden doğan mali haklarını asıl eser sahibinin verdiği izin ölçüsünde kullanabilecektir.

İşleme faaliyeti, asıl esere bağımlı olan fakat ekonomik olarak ondan bağımsız şekilde değerlendirilmeye elverişli yeni bir eser oluşturmaktır. Bir mimarın bir iş merkezi olarak oluşturduğu yapı projesinden yararlanarak, benzer sanatsal çizgileri taşıyan bir kültür merkezi yapması, mimarın kendi eserini işlemesi yoluyla başka bir işleme eser oluşturmastır. Mimarın çizdiği bir avan projeden yararlanarak başka bir mimarın bunu uygulama projesine çevirmesi ve bir yapı oluşturmada işleme eser üretimi örneğidir. Ancak avan projenin başka bir mimar tarafından uygulama projesine dönüştürülmesi, avan proje müellifi mimarın bu konuda izin vermesine bağlıdır. Uygulama projesi mimarı, eğer eser sahibinden izin almışsa, temel olarak işleme hakkını ve işlemeden doğan mali hakları kazanmış olacaktır. Yargıtay'ın bir kararında; *"davacı tarafından çizilen iki projenin halen yapılmış olan iş merkezindeki binada kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmışsa ne ölçüde kullanıldığı, iş merkezinin ortaya çıkmasındaki görünüm ve sonucun, özgün olup olmadığını araştırırken işlenme niteliğine haiz olup olmadığının da incelenmesi gerektiği"* üzerinde durulmuş ve izinsiz bir işleme olup olmadığı araştırılmıştır.¹¹⁷

¹¹⁷ 4. HD., 23.11.1999, E.1999/6241, K.1999/10212. (Yargıtay Kararları No: 29-30)

Eser sahibine, eserinden işleme yoluyla elde edilecek yeni eserin kamuya sunulması ve ekonomik olarak değerlendirilmesi hususunda bağımsız bir yetki verilmiştir. İşleme hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanılabilceği, yani eser sahibi kendi eserini yine kendisi işleyebileceği gibi, bu hakkı başkalarına da devredebilir. Üçüncü şahıslara işleme hususunda izin verme yetkisi, ancak işleme eserin kamuya sunulacak veya ekonomik olarak değerlendirilecek olması halinde söz konusudur. Bunun dışında kalan hallerde FSEK madde 38/II hükmü gereğince musiki, ilim ve edebiyat eserleri; yayımlanma veya kâr amacı güdülmeksizin, *şahsen kullanmaya mahsus* belli sayıda olmak şartıyla üçüncü kişilerce serbestçe veya başkalarınca işlenebilir.¹¹⁸ Ancak, bu serbestiden yararlanabilmek için şahsen kullanmanın şartlarına uymak gerekmektedir. Bu şartlardan birincisi; kişisel kullanım amacıyla gerçekleştirilecek çoğaltmanın, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar vermemesidir. Örneğin bir mimari projenin belli kısımlarının bir öğretim üyesi tarafından derslerde kullanılmak üzere fotokopi yöntemiyle çoğaltılarak öğrencilerine dağıtması bu kapsamdadır. Fakat bu çekilen fotokopilerin ücret karşılığı satımı “hak sahibinin meşru menfaatlerine zarar vermeme” şartına ayrılık oluşturmaktadır. Yine şahsen kullanma için çoğaltılan bir projenin eser sahibi mimardan izin alınmadan üçüncü kişi tarafından kendi evinin yapımında kullanılması hak sahibi mimarın meşru menfaatine zarar verir, zira mimarın kendi projesini kullanacak ve uygulayacak kişiden normalde ücret alması gerekir. İkinci şart ise; normali aşan bir yararlanmanın olmamasıdır. Yani yararlanmanın sadece sınırlı ve belli bir çevrede kalması gerekmektedir. Projenin bir üçüncü kişi tarafından şahsen kullanma için çoğaltıldıktan sonra internette yayınının sağlanması normali aşan bir yararlanmadır.

İşleme eser türleri FSEK madde 6 da örnekleme kabilinde sayılmıştır. FSEK madde 6 da sayılan örneklerin dışında, bir eserin başka şekillere dönüştürülmek üzere işleme hakkı ve bu hakkın devri yine sadece eser sahibine ait bir haktır.

İşleme hakkını (eser sahibinden) devralan şahıs, o işleme türüne münhasır kalmak şartıyla, kendi işlemesi üzerinde eser sahipliğinden doğan bütün hak ve yetkileri haizdir.¹¹⁹ Burada devir almak yerine süre veya

¹¹⁸ EREL, age., s. 135.

¹¹⁹ ÖZTRAK, age., s. 32, Naklen EREL, age., s. 136; Bern Sözleşmesi md. 2/II ve 2/III hükümlerinde; edebiyat ve sanat eserlerindeki değişimlerin, özgün eser üzerindeki haklara zarar vermeksizin, özgün eser olarak korunacağı kabul edilmiştir.

yerle kısıtlı bir lisans da alınabilir. İşleme eserin sahibi; işleme eseri kamuya sunmak, asıl eser sahibininkiyle birlikte kendi adını belirtmek, işlemede değişiklik yapılmasını men etmek gibi manevi haklar yanında, işlemeyi ekonomik olarak değerlendirmek için gerekli mali haklara da sahiptir. Bu hakların kullanılabilmesi için, işleme izni veya lisansının FSEK 52. maddeye uygun yazılı olması yeterlidir.

İşleme hakkıyla birlikte devredilmiş kabul edilen bu mali haklar sadece iki açıdan sınırlanmıştır. İlk olarak işleme hakkı özel olarak hangi işleme türü için tanınmışsa, onunla sınırlıdır. Mesela mimari bir eserin sadece takvime basılması için izin verilmesi halinde bunun ayrıca kitap kapağı olarak kullanılması mümkün değildir. İkinci olarak da, işleme eser üzerinde yeniden bir işleme yapılması, işleyenden başka asıl eser sahibinin de iznine tabidir. İşleyen kendi meydana getirdiği işleme eseri, tekrar işlemek veya başkasına işletmek istiyorsa, yine asıl eser sahibinin iznine ihtiyacı duymaktadır.

Yani diğer mali hakların devrinden farklı olarak, FSEK madde 49/II ve 55 gereğince, eserin her yeni işleminde veya işleme hakkını devir alanın bunu bir başkasına devretmesinde, asıl eser sahibi veya mirasçılarının izni gerekmektedir.

İzin alınarak yapılmış bir işleme, gerek asıl eser sahibine, gerek üçüncü şahıslara karşı korunmaktadır. Örneğin bir mimari esere dayanarak film yapmak, mimari bir projenin maketini yapmak veya perspektifini çizmek için asıl eser sahibi olan mimardan izin alınması halinde, ortaya çıkan yeni eser hem asıl eser sahibine hem de diğer üçüncü şahıslara karşı korunmaktadır.

İşleme konusundaki izin verme hakkı, yukarıda da belirttiğimiz gibi bazı hallerde kamu yararı bakımından sınırlandırılabilen, bu tip durumlarda eser sahibinin iznine gerek olmamaktadır. Örneğin şahsi ihtiyaçlarla sınırlı kalmak ve kâr amacı gütmemek şartıyla mimari eser niteliğini taşıyan bir köprü'nün fotoğrafı çekilebilir. Hatta FSEK madde 40/I, III ile umumi yerlerde temelli kalmak üzere inşa edilmiş olan bir binanın resim, fotoğraf veya filme alınması yollarıyla işlenmesi, yayımlanma ve kâr amacıyla olsa dahi serbest bırakılmıştır.

FSEK madde 34'e göre de, eğitim ve öğretim gayesine tahsis etmek şartıyla, yayımlanmış musiki, ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden maksadın haklı göstereceği ölçüde iktibaslar yapılarak seçme ve toplama eserler meydana getirilmesi (yani bun-

ların FSEK madde 6 bent 7 hükmünde belirtilen şekilde işlenmesi) serbesttir.¹²⁰ Örneğin mimarlık fakültesindeki bir derste bir öğretim üyesinin öğrencilerine belli tip yapılarla ilgili bilgi vermesi için projeksiyon veya benzeri vasıtalarla öğrencilerine bir mimari eseri göstermesi.

Mimari eserlerin işlenmesi konusunda FSEK madde 6'nın içinde getirilen özel bir örnek bulunmamaktadır. Ancak FSEK madde 6 bent 3 te güzel sanat eserlerinin veya ilim ve edebiyat eserlerinin film haline sokulması veya filme alınmaya ve radyo ve televizyon ile yayıma müsait bir hale sokulmasından bahsetmektedir. Ayrıca yine FSEK madde 6 bent 5 te güzel sanat eserlerin bir şekilden diğer şekle sokulmasından bahsetmektedir. Mimari eserlerin işlenmesi ile ilgili verilecek örnekler şu şekilde olabilir. Bir mimari eser niteliğindeki yapının, resme konu olması; birçok projenin kitap haline getirilerek basılması. Bir heykelin otel haline getirilmesi gibi, bir başka eser türünden yararlanarak işleme yapılmak suretiyle bir mimari eser de oluşturulabilir. Tüm bu örneklerin yanında, daha öncede bahsettiğimiz şekilde bir avan projeden yararlanılarak uygulama projesinin hazırlanması işleme kabul edilmektedir. Yine aynı şekilde, tıpkı bir tiyatro eserinin sinema eseri dönüştürülmesi gibi bir mimari yapının proje ve uygulama aşamalarının belgesel niteliğinde yayınlanmak üzere filme konu edilmesi ve senaryonun temel taşı oluşturması da bir işlenme olarak kabul edilmelidir.

2. Çoğaltma Hakkı

Bern Sözleşmesinin 9. maddesi; *“bu Sözleşme ile korunan edebiyat ve sanat eseri sahipleri, hangi biçim ve yöntemle olursa olsun eserlerinin çoğaltılmasına izin vermek hususunda inhisari hak sahibidirler”* demektedir.

FSEK madde 22 hükmüne göre de; *“bir eserin aslını veya işlenmelerini kısmen ya da tamamen çoğaltma hakkı, münhasıran sahibine aittir.”*

Çoğaltma, eserin aynen tekrarlanmasını ve maddi bir varlık olarak tekrarlanacak şekilde nesnelleştirilmesini sağlayan teknik bir işlemdir.¹²¹ Bu işlem mimari eserler açısından FSEK madde 22/2 de;

a. Eserin aslından ikinci bir kopyanın çıkarılması,

b. Eserin işaret, ses ve görüntü nakline yarayan her türlü araca kayıt edilmesi,

¹²⁰ EREL, age., s.137.

¹²¹ TEKİNALP, age., s.170.

c. Mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması olarak sayılmıştır.

Kanun koyucu çoğaltma tekniklerini bu şekilde sayarak bu teknikler bakımından sayma yöntemini tercih etmiş bulunmaktadır. Ancak her geçen gün yeni çoğaltma araçları ile karşılaşmak söz konusu olacağı için çoğaltma araçlarının sayma yöntemiyle belirlenmesi pek doğru değildir. Nitekim bu sayılanlar dışında internet ortamında da çoğaltmak mümkündür. İşte bu sebeple FSEK madde 22 de yer alan "...bilinen ya da ileride geliştirilecek olan her türlü araca kayıt ... çoğaltma sayılır" ifadesi bu açıdan yeni gelişmelere uygundur.

Bu çoğaltma biçimlerinin içinde bizim konumuzla ilgili olan "mimari eserlere ait plan, proje ve krokilerin uygulanması" diğer yöntemlere göre özellik taşımaktadır. Bu özellik sadece mimari eserler ile kabartma ve delikli kalıplar bakımından sınırlanmıştır.

Güzel sanat ve mimari eserlerinde, bu eserlere ait plan ve projenin kopya edilmesinin çoğaltma olduğunda şüphe yoktur. Ancak anılan FSEK madde 22/II hükmü bu plan ve projelere dayanılarak, bunların uygulanması suretiyle bir eser meydana getirilmesini, mesela bir bina inşasını da çoğaltma saymıştır. Özellikle güzel sanat eserlerinde, eserin aslına ihtiyaç hissettirmeden yararlanmayı sağlayacak olan, eserin kopya edilmiş plan ve projeleri değil, bunlara göre yapılacak eserdir. Bu yüzden sadece plan ve projeleri çoğaltma hakkının devri, eser fiilen bunlara göre inşa edilmedikçe bir anlam taşımaz.¹²²

Ayrıca mimari proje aslından (orjinalinden) ozalit çıkarılması da çoğaltmadır ve mimarının iznine tabidir. Hiçbir mal sahibi veya işveren, mimara "hazırladığın projeyi para vererek senden satın aldım, onu dilediğim şekilde çoğaltırım" diyemez.

4110 sayılı Kanunla değiştirilmeden önce FSEK madde 38/III hükmü; güzel sanat eserlerine ait plan, proje, kroki vs. yayımlanmış olsalar bile, bunların eser sahibinin izni olmadan icra ve tatbik edilemeyeceklerini öngörmekteydi. Özellikle mimari eserlere ait plan ve projelerde eser sahibinin (mimarın) korunması bu hükümle sağlanmaktaydı.¹²³ Şimdi ise bu hüküm kaldırılmıştır. Diğer yandan güzel sanat eserlerinin özelliği ve değeri, bunların parça halinde ve tek olmalarındandır. Mekanik araçlar

¹²² EREL, age., s.138-139.

¹²³ TOPÇUOĞLU, age., s. 88-89; AYİTER, age., s. 129 Naklen EREL, age, s.138-139.

yardımıyla bir güzel sanat eserlerinin kopyasının çıkarılması, gerçek anlamda bir çoğaltma değil, bir taklittir. Mekanik araçların yardımı olmaksızın eserin bir benzerinin yapılması, mesela bir resim öğrencisinin ünlü bir ressamın tablosunu model alarak yaptığı resim ise ne taklit, ne de çoğaltmadır.¹²⁴ Duruma göre yeni yapılan ya orijinal veya işleme eser sayılabilir. FSEK madde 40/I hükmünde “güzel sanat eserlerinin resim, fotoğraf vs. ile çoğaltılmasından” söz edilmekte ise de, bu hallerde de çoğaltmadan ziyade işleme mevcuttur.¹²⁵

Çoğaltma hakkı konusunda eser sahibinden izin alma zorunluluğu; Bern Sözleşmesi’nin 10. maddesinde bulunan basında haber verme, eğitim amacı gibi bazı sebeplerle sınırlanmış veya ortadan kaldırılmıştır. Benzer sınırlamalar ve eser sahibinden izin alma gerektirmeyen yararlanma biçimleri FSEK’de de bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. FSEK madde 26 ve 27’de yer alan zaman bakımından sınırlamalar; FSEK madde 30 uyarınca kamu düzenini koruma gerekçesiyle sınırlandırma; FSEK madde 31 ve 37 arasında belirtilen genel menfaat gerekçesiyle sınırlandırılma (mevzuat ve içtihatlar, nutuklar, iktibas, gazete münderecatı ve haberler); FSEK madde 38’de yer alan şahsen kullanma ve FSEK madde 40 gereğince kopya ve teşhir gerekçeleriyle sınırlandırılma. Bu sınırlandırma durumlarında koruma süreleri henüz dolmamış olsa dahi eser sahibinin izni alınmadan eserin serbestçe çoğaltılması mümkündür. Mimari eser maketlerinin yapılması ve bunların fotoğraflarının çekilip, çoğaltılması da rastlanan bir durumdur. Fotoğraf için izin almak gerektiği gibi bu fotoğraflarında çoğaltılması artık fotoğrafı çekene ve mimari eser sahibine bağlıdır. Fotoğraf eserleri genel güvenlik sebebi veya adli amaçlar için sahibinin rızası alınmaksızın, resmi makamlar veya bunların emriyle başkaları tarafından her şekilde çoğaltılabilir (FSEK madde 30/I).

Mimari eserleri kapsayan bir diğer çoğaltmaya ilişkin serbesti de; FSEK madde 40/I gereğince; umumi yollar, caddeler ve meydanlara temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerinin resim, fotoğraf vs. ile çoğaltılabilmeleridir. Aynı şekilde, umumi yerlerde teşhir edilecek veya açık arttırmayla satılacak güzel sanat eserlerinin fotoğraf veya resimlerinin katalog, kılavuz, broşür vb. ile basılıp çoğaltılması da (FSEK madde

¹²⁴ ÖZTRAK, age., s. 24-25; bu taktirde model olarak kullanılan eserin sahibinden izni alma zorunluluğu yoktur.

¹²⁵ AYİTER, age., s. 131 Naklen EREL, age, s.138-139.

40/III) gerçekte çoğaltmadaki eser sahibinin izin hakkının sınırlandırılması şeklinde bir işlemdir.

Bir mimari eserin fotoğrafının çekilmesi aslında daha öncede bahsettiğimiz gibi bir eserden başka bir esere dönüştürülme olarak kabul edilirse, bir işlenmedir. Bu anlamda ortaya çıkan yeni bir eser vardır.

Mimari esere ilişkin yapılan değişikliklerin çoğaltma mı yoksa işleme mi olduğu konusu oldukça tartışmalıdır. Bu itibarla, mimarlık projelerinin uygulanması suretiyle bir mimarlık eseri oluşturulmasını, eğer bu mimarlık eseri, mimarlık projeleri değiştirilerek yapılmışsa, çoğaltma olarak değil, işleme olarak kabul etmek gerekmektedir.¹²⁶ ARIDEMİR¹²⁷, “*bu konuda mimari eserlere ait plan, proje ve krokilerin uygulanması sırasında zorunlu işlevsel faktörler nedeniyle yapılacak değişiklikleri, FSEK madde 16/II gereğince, çoğaltma tekniği icabı yapılması zorunlu değişiklikler olarak*” nitelendirmekte ve “*planların uygulanmasını, mimari eserin çoğaltılması olarak*” kabul etmektedir. Ancak “*bu sınırı aşan değişiklikler ile değişik estetik ihtiyaçlar nedeniyle yapılan değişiklikleri, işleme olarak*” değerlendirmektedir.

Yine diğer bir maddeye göre; röportaj niteliğinde olmak üzere, günlük olaylara bağlı olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaları işaret, ses ve resim nakline yarayan vasıtalarla alınması, bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması serbesttir (FSEK madde 37/I). Ev dekorasyonu veya mimarlık meslek dergileri, tv programları veya röportaj niteliğine bağlı olarak bazı web siteleri gibi çeşitli yayıncılık ortamlarında mimari ve iç mimari eserleri ve uygulamalarının fotoğrafları veya görüntülerinin yayını çoğunlukla bu kapsamda değerlendirilir.

FSEK madde 38/I’e göre; bütün fikir ve sanat eserlerinin, yayımlanma veya kâr amacı güdülmeşizsin şahsen kullanmaya mahsus belli sayıda nüshalara münhasır kalmak şartıyla çoğaltılması mümkündür. Çoğaltma hakkı iktibas hakkıyla da sınırlandırılmıştır. İktibas, bir eserin bazı parçalarının başka bir eser içinde kullanılması olduğundan, iktibas serbestisi bulunan hallerde (Bkz. FSEK madde 35, 36) eser parçalarının, iktibasın haklı göstereceği ölçüler içinde serbestçe çoğaltılması mümkündür.¹²⁸ Örneğin mimarlık öğrencilerine, yapılan binanın özelliklerini açıklamak

¹²⁶ Gürsel ÜSTÜN, “Yargısal Uygulamada Fikri Haklar”, İBD., C.73; 1999, s.965.

¹²⁷ ARIDEMİR, age., s.67-68.

¹²⁸ AYİTER, age., s. 132 Naklen EREL,age., s. 141.

ve dersi aydınlatmak amacıyla, başkasına ait bir mimari yapının fotoğrafının veya projesinin bir bölümünün hazırlanan ders kitabına koyulması ya da başka bir mimari eserler kitabında o dönem mimarlık eserlerinin çizim ve planlarının veya o mimarların kendi kitaplarında bulunan görüşlerinin aktarılması hukuka uygun yararlanmalardır.

Günümüzde bir çok mimari firma ve mimar eserlerini ve çalışmalarını internet ortamında sergilemektedir. İnternet ortamı birçok haksız çoğaltma için ortam hazırlamaktadır. Bu açıdan; internet ile ulaşılan ancak üçüncü kişilere nakledilmesi yasaklanmış olan bir mimari projenin, ileride üçüncü kişilere ulaştırılmak amacıyla, bilgisayarın hard-diskine kaydedilmesi çoğaltma hakkının ihlali sayılmaktadır.

3. Yayma Hakkı

FSEK madde 23 ; *“Bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, kiralamak, ödünç vermek, satışa çıkarmak veya diğer yollarla dağıtmak hakkı münhasıran eser sahibine aittir”* şeklinde yayma hakkını düzenlemiştir.

Bu düzenleme yayma hakkını, bir eserin aslında yahut işlenmesinden çoğaltma ile elde edilen nüshaların dağıtılması, kiralama, satışa çıkarılması yahut diğer bir şekilde ticaret konusu yapılması şeklinde tanımlamakta ve bu hakkı eser sahibi için saklı tutmaktadır. Yayma hakkı, çoğu kez ticaret mevkiine koyma anlamına gelmektedir. Aslında gerçekte yayma hakkı, *“yayım”* (FSEK madde 7/II) denilen fiili durumun fikri hukuk bakımından muteber şekilde gerçekleşmesi için, eser sahibinin göstereceği iradeyi, kullanacağı yetkiyi ifade eder.¹²⁹

Yayma hakkının mimari eserler açısından özellikle plan, proje, kroki ve maketler açısından kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Mimari projelerin ve tasarım unsurlarının kitaplarda yer alması, bir web sitesi kurularak çeşitli ev tiplerine yönelik olarak projelerin satılması veya bir prefabrik ev yapan şirketin bir mimarla anlaşarak onun projelerine uygun evler üretmesi ve bunları satması ya da bir uygulama projesinin 49 yıllık bir tapu tahsisine paralel olarak aynı süreyle bir yapı için kiralama yayma hakkının örnekleri olabilir. Yine bir mimarın yaptığı projelerin veya maketlerin bir sergi kapsamında sınırlı bir süre bir kuruluşa ödünç verilmesi örnek verilebilir. Burada plan, proje ve uygulama projeleri açısından eserin aslı

¹²⁹ AYİTER, age., s. 133 Naklen EREL, age., s. 145.

veya (bir derginin ekinde verilmesi örneğinde olduğu gibi) çoğaltılmış nüshaları da yayma hakkının konusu olabilir.

Yayma hakkını kullanmak için eser sahibinden izin alınmasını gerektiren kuralın istisnası olan FSEK madde 40/I hükmüne göre; umumi yollarda caddelerde, temelli kalmak suretiyle yapılan mimari yapıların; eser sahibinden izin alınmadan resim, grafik, fotoğraf vs. ile çoğaltması, yayması ve yine umumi mahallerde projeksiyonla gösterilmesi hukuken mümkündür. Mimari eserler için bu durum yalnızca yapının dış şekli için geçerli olmaktadır. *Buna göre, bir kroki, plan veya projenin kopyası çıkarılabilir veya bir binanın resmi çekilebilirse de, bu kroki, plan, proje veya resmin konusu olan binanın inşa edilmesi caiz değildir. Sonuç olarak mimari eserlerin taklit edilerek inşa edilmesi suretiyle çoğaltılıp yayımlanması hakkında “hususî menfaat” dahi olsa bir serbesti söz konusu değildir.*¹³⁰

Çoğu zaman karıştırılan yayma hakkı ile kamuya sunma (umuma arz) anlamına gelen yayımlama hakkı birbirinden farklı kavramlardır. Yayma hakkı; FSEK madde 23’e göre eser sahibinin mali haklarından birisidir ve eser sahibi, maddede belirtilen yetkilere sahiptir. FSEK madde 7’de düzenlenen yayımlama ise; eser sahibinin yayma hakkını kullanması ile eserin kamuya sunulması olayıdır.¹³¹ Yayınlama veya yayımlama eserin alenileşmesini de sağlar.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki; yayma hakkı çoğaltma hakkının bir uzantısıdır. Çoğaltılmış eserler amacını gerçekleştirmek için ticarete konu olmaktadır. Bu nedenle çoğaltma hakkı devredildiği çoğu zaman yayma hakkı da devredilmiş olmaktadır. Ancak netice olarak bu iki hakkın konuları birbirinden farklıdır ve bazı durumlarda bu haklar birbirinden ayrı ayrı devredilmek durumunda kalabilirler. Bu nedenle FSEK madde 52 gereğince çoğaltma ve yayma haklarının devredildiği yazılı sözleşmede ayrı ayrı belirtilmelidir. Ayrıca yayma hakkı FSEK madde 33¹³² uyarınca çoğaltma hakkına nazaran daha büyük sınırlamalara tabidir. Bu sınırlama sadece yayımlanmış eserler için söz konusudur.

¹³⁰ ATEŞ, age., s.401.

¹³¹ ARIDEMİR, age., s. 94.

¹³² FSEK md. 33; “Yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kar amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutlak şekilde açıklanması şartıyla serbesttir.”

Yayma hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanılabileceği gibi, süreli veya süresiz, ivazlı veya ivazsız, belirli bir memleket için veya böyle bir tahdit olmaksızın uluslararası olarak devir veya lisans sözleşmesi sonucu üçüncü kişilerce kullanılabilmektedir. Yayma hakkı ilim ve edebiyat eserleri için uygulamada “*neşir mukavelesi*” (BK. madde 372 vd.) ile devredilmekte ve yayımlayan (naşir) eseri hem çoğaltma, hem de yayma tahhüdü altına girmektedir. Ancak yayım sözleşmesi hakkın devrinden farklı olarak, yalnız yayımlayan bakımından bir *hak* doğurmakla kalmaz, aynı zamanda onu eser sahibine karşı eseri çoğaltma ve yayma *borcu* altına da sokar.¹³³

Kanun yayma hakkını eser nüshalarının dağıtılması, kiralınması, satışa çıkarılması veya herhangi bir biçimde ticaret konusu yapılması şeklinde belirttiği için, yayma hakkının mutlaka “*kâr amacı*yla” kullanılmasının gerekip gerekmediği akla gelebilir. Bizim de katıldığımız fikre göre, yayma hakkının kullanılmasındaki ticari gaye geniş şekilde yorumlanmalı ve eserin kâr amacı olmaksızın dağıtılması da bu kapsamda sayılmalıdır¹³⁴. Zira yayma hakkının amacı çoğaltılmış eser nüshalarının her hangi bir yoldan kamuya sunulmasıdır ve diğer mali haklar nasıl kâr amacı olmaksızın veya karşılıksız olarak başkalarına devir edilebiliyorsa, yayma hakkı da bu yolla devredilebilir. Yayma hakkının kâr sağlamak amacıyla kullanıldığı hallerde de, bu kârın fiilen gerçekleşmiş olup olmaması önemli değildir.

Yayma hakkının kullanılarak ticari hayata geçirilmesi halinde, üçüncü şahıslar satın alma yoluyla eline geçen nüshalar üzerinde mülkiyet hakkı elde etmektedirler ve bu üçüncü şahıslar eline geçen eser örneklerini başkalarına kiralayabilir veya ödünç verebilirler. Mesela bir kitap satın aldıktan sonra, eser sahibinin manevi haklarını ihlal etmemek şartıyla bunun istenilen yer, zaman ve fiyat üzerinden tekrar satılması, kiralınması, ariyet verilmesi mümkündür. Ancak nüshayı satın alan doğal olarak bunu çoğaltma hakkına sahip değildir. Yayma hakkının bu şekilde tahditsiz olarak devri, hakkın eser sahibi bakımından tükenmiş olmasını ifade eder.¹³⁵ Alman Hukukunda “tükenme ilkesi” (Erschöpfungsgrundsatz)¹³⁶ olarak adlandırılan bu esas, FSEK madde 23/II tarafından hükme bağlanmıştır:

¹³³ AYİTER, age., s. 242 Naklen EREL, age., s. 145.

¹³⁴ ARSLANLI, age., s. 102 Naklen EREL, age., s.147.

¹³⁵ EREL, age., s. 147.

¹³⁶ AYİTER, age., s. 135 Naklen EREL, age., s.147.

“Belirli nüshaların hak sahibinin yayma hakkını kullanması sonucu mülkiyeti devredilerek ülke sınırları içinde ilk satışa ya da dağıtım yapıldıktan sonra bunların yeniden satışı ya da kiralanması biçiminde yayımı, kiralama ve kamuya ödünç verme hakkı saklı kalmak şartıyla, eser sahibine tanınan yayma hakkını ihlal etmez.”

Öte yandan FSEK 23/III’e göre, bir eserin veya çoğaltılmış kopyalarının kiralanması veya ödünç verilmesi yoluyla yayma hakkı kullanımı, eser sahibinin çoğaltma hakkına zarar verecek şekilde eserin yaygın kopyalanmasına yol açamaz. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kültür Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. Mimari eserler açısından, bir projenin, planın veya çizimin birisine satılmasının ardından, satın alan kimsenin “bunu istediğim yerde ve miktarda uygulamam” şeklindeki davranışları yayma hakkı kapsamında olmayıp, bir tür çoğaltma olduğundan hukuki himaye görmez.

Mimari eserlerin yaptırılmasının esas amacı kullanmadır. Bu durumda mimarlık eseri olan bir binanın kiralanması veya bir otel odasının müşterinin kullanımına sunulması FSEK madde 23 anlamında kiralama kapsamına dahil edilecek midir? Tekinalp¹³⁷, yapılan sözleşme kira olarak adlandırılmasa veya kira olarak yapılandırılmasa bile, eserin veya çoğaltılmış nüshaların üçüncü kişilerin yararlanmasına ekonomik bir menfaat karşılığında bırakılması halinde (mal sahibi ile kiracı açısından) bir kiralamanın olduğundan bahsetmekte ve Alman Hukukundan hareketle yukarıda belirttiğimiz bir binanın kiralanması veya otelin müşterilere kullandırılmasının eseri yapan mimar açısından yayma hakkının kapsamındaki kiralama veya ödünç verme olmayacağını savunmaktadır. Alman Hukuku; mimari eserler ile uygulamalı sanata konu olan eserlerin (el işleri ve küçük sanat eserleri) çoğaltılmış nüshalarının, esas amaçlarının “kullanmak” olması sebebiyle Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku anlamında eser sahibi açısından kiraya verme veya ödünç verme kapsamına girmeyeceğini hükme bağlamıştır.¹³⁸ Tekinalp işte bu noktadan hareketle mimari eserler konusunda; “kullanma” ve “yararlanma” işveren açısından binanın yaptırılmasındaki esas amaç olduğu için, haklılık temeli sağlam olan bu istisnanın mimari eserler açısından işverenin hakları olarak yayma hakkına getirilmesi gerektiği üzerinde durmaktadır. Kanaatimizce, mal sahipleri veya işverenlerin yapıyı üçüncü kişilere kiralaması ve kullandırması; mimarın

¹³⁷ TEKİNALP, age., s.175.

¹³⁸ TEKİNALP, age., s.175.

yayma hakkının olmadığı bir istisna olarak açıkça düzenlenmelidir, yoksa yanlış anlamalara neden olması kaçınılmazdır.

4. Temsil Hakkı

FSEK madde 24'te temsil hakkını “*bir eserden doğrudan doğruya yahut işaret, ses veya resim nakline yarayan aletlerle umumi yerlerde okumak, çalmak, oynamak ve göstermek*” şeklinde tanımlamakta ve bu hakkı eser sahibi için saklı tutmaktadır. Burada iki tip temsil söz konusudur. İlki “*doğrudan temsil*”dir ve mimari eserler için uygulaması çok azdır, ancak hayal gücümüzü zorlama ile bir mimarın ekibi ile beraber bir modüler binanın yapımını bir meydanda sergilemesini örnek verebiliriz. İkinci tür temsil ise “*dolaylı temsil*” olup, televizyon yada internet gibi yayın araçları ile bir mimari eserin gösterimidir. Ancak zamanla dolaylı temsilin içinde olan kitle iletişim araçlarıyla (radyo, televizyon ve günümüzde internet) yayın FSEK de ayrıca “*umuma iletim*” olarak düzenlenmiştir. Kitle iletişim araçlarıyla umuma iletimde yayın, umumi yerde veya bireysel bir yerde olabilir. Temsil hakkında ise yapılan yayının (okuma, çalma, oynama, gösterme) umumi yerde olması gereklidir. Kitle iletişim araçlarıyla yapılan umuma iletim belirli bir kişi veya yere yönelik olmayan genel yayın araçları kullanılarak yapılır. Temsilde ise belirli bir yere özgü olarak işaret, ses veya resim nakline yarayan “aletler” kullanılır. Umuma iletimde hedef umum yani bir hak topluluğudur, temsilde ise hedef “*umumi yer*”dir. Özellikle FSEK 25. maddesi ile kitle iletişim araçlarıyla umuma iletim ayrı bir hak olarak düzenlendiğinden, “umumi yer” kavramı ve “belirli bir topluluğa yönelik yayın aleti kullanımı” temsil hakkını umuma iletim hakkından ayırır. Dolaylı temsil olarak, bir şehir meydanında veya gösteri salonunda bir mimari projenin çizimi aşamalarının veya bir uygulama projesi doğrultusunda bir yapının yapılmasının önceden banda alınmış görüntülerinin izletilmesini örnek verebiliriz.

Kanun'un açıklaması dahilinde; temsili “*eserin yayım (yayınlama) dışında kalan yollardan halka hitap edecek şekilde kamuya sunulmasıdır*”¹³⁹ diye tanımlayabiliriz. Kanun eserin okunması, çalınması, oynanması ve gösterilmesinden söz etmekle beraber, bu sayma temsil hakkını tarif bakımındandır ve sınırlayıcı değildir. Eseri bunlar dışındaki yollardan da duyularla algılanmaya uygun hale getiren her fiil temsil sayılır.¹⁴⁰ Mi-

¹³⁹ AYİTER, age., s. 136 Naklen EREL, age., s.

¹⁴⁰ ARSLANLI, age., s. 108; AYİTER: s. 136-137 Naklen EREL, age., s. 150.

mari yapının tepegöz vasıtasıyla bir tiyatrodan gösterilmesi gibi. FSEK 24/II gereğince “*temsilin umuma arz edilmek üzere vukubulduğu mahalden başka bir yere her hangi bir teknik vasıta ile nakli de eser sahibine aittir*”. Bu düzenlemeden yola çıkarak mimari bir proje yapımının veya yapı yapılmasının telekonferans yoluyla bir başka yerde bulunan seyircilere aktarılması da temsil hakkı örneğidir.

Temsil hakkı eser sahibi tarafından bizzat kullanabileceği gibi, üçüncü şahıslara devir de edebilir veya lisans verilebilir. FSEK madde 24/I hükmü eser sahibinin temsil hakkını, eserin gerek aslını ve gerekse işlemlerini kapsar şekilde düzenlenmiştir. Mesela işleme suretiyle meydana getirilen bir güzel sanat eserinin umuma teşhiri, yani doğrudan doğruya temsili caizdir. Buna karşılık işleme eserin başka türlü, örneğin yayım yoluyla değerlendirilmesi mümkünken, izinsiz gösterilmesi hukuka aykırıdır.¹⁴¹

Temsilde iki temel unsur bulunmaktadır;

- Eserden yararlanma, geçici olmalı ve yararlanma anıyla sınırlı kalmalıdır.
- Temsil, kamunun istifadesine elverişli umumi bir yerde gerçekleşmelidir.

Öğretide, umumi sayılmayacak bir yerde yapılan temsile rağmen, eserin burada kamuya sunulmak niyetiyle temsil edildiği anlaşılıyorsa; umumi yer unsuru gerçekleşmiş kabul edilmektedir.¹⁴² Yine eserin tek bir şahsa veya dar bir şahıs topluluğuna icra edilmesi temsil sayılmamaktadır. 4630 sayılı ve 2001 tarihli değişiklik sonucu FSEK madde 33 ile temsil hakkı sınırlanmıştır. Bu düzenleme “*yayımlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüzyüze eğitim ve öğretim maksadıyla doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eserin adının mutlak şekilde açıklanması şartıyla serbesttir*” şeklindedir. Buna göre; bazı hallerde gerek özel yararlar gerekse kamu yararı bakımından eser sahibinden temsil için izin almaya ve telif ücreti ödemeye gerek yoktur. Yüz yüze eğitim öğretim amacıyla öğrencilere yahut doğrudan veya dolaylı olarak kâr amacı güdülmeksizin bir konferans veya oyun esnasında bir mimari eserin projeksiyon yöntemiyle ilgililere gösterilmesi bu düzenlemeye ör-

¹⁴¹ Bkz. EREL, age., s.150.

¹⁴² SULUK/ORHAN, age., s. 399; EREL, age., s. 151.

nek kullanım biçimleridir. Burada ihmal edilmemesi gereken eser sahibinin ve eserin adının verilmesidir, yoksa eylem hukuka aykırı olur.

Ayrıca FSEK madde 35/4 de iktibas serbestisi kavramıyla temsil hakkı için eser sahibinden izin alınması gereğine bir başka istisna tanımıştır. Bu düzenlemeye göre, “alenileşmiş” güzel sanat eserlerini ilmi konferans veya derslerde konuyu aydınlatmak için projeksiyon gibi cihazlarla göstermek serbesttir. Burada temsil hakkına getirilmiş bir sınırlamadan söz edebilmek için göstermenin “umumi yer”de yapılması gerekir; zira eserin umumi olmayan bir yerde gösterilmesi zaten temsil kapsamına girmez. Öte yandan; alenileşmemiş bir eserin nerede olursa olsun izinsiz gösterilmesi ise “eseri kamuya sunma / umuma arz” hakkının ihlali niteliğindedir.

Bundan başka FSEK madde 40/I gereğince; güzel sanat eserleri türüne giren “mimarlık eserleri” olan yapılar zaten yol, cadde, meydan gibi umumi yerlerde sürekli kalmak üzere konulmuş olduğundan ve sergilendiğinden, bunların resim, fotoğraf, projeksiyon, televizyon, internet yoluyla umumi yerlerde yapılan gösterimi serbesttir. Ayrıca FSEK madde 40/II’ye göre, mimari eserlerin projeleri ve maketleri; eser sahibi tarafından üzerlerine temsili yasaklayıcı bir kayıt konulmadan satılmış ise satın alanlar veya bunların izniyle başkaları tarafından umumi yerlerde sergilenebilirler.

Temsil hakkı, eserin içeriği hakkında bilgi verme yetkisiyle de sınırlandırılmıştır. FSEK madde 14/II gereğince; bütünü veya esaslı bir kısmı henüz alenileşmemiş bir eserin içeriği hakkında sadece eser sahibi bilgi verebilir. Köprü, tren garı, metro binası veya otel yada iş merkezi, avan proje ve maketleri hakkında bu düzenleme uygulanabilir. Eser alenileştikten sonra bu yetkiye üçüncü şahıslar da sahiptir. Şayet alenileşmiş bir eserin muhtevası hakkında bilgi verme eserin temsili gerektiriyorsa, mesela umumi yerde verilen bir konferansta bilgi vermek amacıyla eserin gösterimi söz konusu olursa, eser sahibinin izni olmadan gerçekleşen bu temsil, temsil hakkının sınırlaması sayılabilir.¹⁴³

5. Yayın ve Umuma İletim Hakkı

FSEK madde 25 *“bir eserin aslını veya çoğaltılmış nüshalarını, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlanması ve yayınlanan eserlerin*

¹⁴³ Bkz. ARSLANLI, age., s. 109 Naklen EREL, age., s. 155.

bu kuruluşların yayınlarından alınarak başka yayın kuruluşları tarafından yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletilmesi hakkı münhasıran eser sahibine aittir.

Eser sahibi, eserin aslı ya da çoğaltılmış nüshalarının telli veya telsiz araçlarla satışı veya diğer biçimlerde umuma dağıtılmasına veya sunulmasına ve gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda eserine erişimini sağlamak suretiyle umuma iletimine izin vermek veya yasaklamak hakkına da sahiptir.

Bu madde ile düzenlenen umuma iletim yoluyla eserlerin dağıtım ve sunumu eser sahibinin yayma hakkını ihlal etmez” diyerek iki ayrı hakkı düzenlemektedir.

Maddenin 1. fıkrası “**yayın**” hakkını (bu hak daha öncede bahsettiğimiz gibi yayma ve dolaylı temsil hakkından farklıdır) ve 2. fıkrası ise; “**umuma iletim**” hakkını irdelemektedir. Yayınlanma; eserin radyo- TV veya dijital vasıtalarla umuma iletilmesiyken; FSEK madde 7 de yer alan yayma hakkı, bir eserin aslının veya çoğaltılmış nüshalarının ticarete sunulması anlamına gelmektedir. Bir mimari projenin internete verilmesi FSEK madde 25 kapsamında yayınlamadır ancak; bu projenin kiralanarak bina haline getirilmesi yaymadır.

Bu madde kapsamında umuma iletim hakkı, önceden 24. madde de yer alan temsil hakkının bir türü olarak görülmekte iken, sonraları teknolojik gelişmeler paralelinde temsil hakkından çok daha geniş bir perspektife ulaşmıştır.

Tüm bu açıklama dahilinde bu maddede ki eserin kullanım biçimlerini şu şekilde özetleyebiliriz;

Fikir ve sanat eserlerinin,

- Aslı veya kopyalarının diğer radyo-tv, uydu kablo gibi telli ve telsiz araçlarla ve dijital iletim araçları ile yayını,
- Yukarıdaki kuruluşlarının yayınının yeniden yayını.
- Aslı veya kopyalarının satış ve diğer biçimde umuma dağıtılması,
- Gerçek kişilerin seçtikleri yer ve zamanda esere erişimi veya ulaşımı,

Bu maddedeki düzenleme, eskiden temsil hakkı içinde değerlendirilen radyo yayını ile başlayan teknolojik gelişmeler, temsil hakkındaki yayının “**umumi yer**” ile sınırlı olması karşısında temsil hakkından ayrı yeni bir düzenleme gereksinimini ortaya çıkarmış ve Kanun değiştirilerek

önce radyo, sonra televizyon ve daha sonra da interneti de kapsar biçimde “umuma iletim” adı verilen bir başlık altında yeni bir mali hak meydana getirilmiştir. 25. madde internetin ve bilgisayarda dosya saklamanın gelişmesi paralelinde, internet ortamında; web siteleri veya kişisel bilgisayarların hard diskinde diğer kişilerin paylaşımına açık olarak tutulan dosya şeklinde ortaya çıkan yeni bir yayıncılık türünü de düzenlemektedir. Burada sanal ortamda bir eser interaktif kullanıma yani gerçek kişilerin dilettiği yer ve zamanda erişimine veya ulaşımına açık olarak tutulmaktadır. İnternet web sitesinde veya herhangi bir kişinin bilgisayarında bulunan bir esere, kişiler kolayca erişebilmekte ve özel olarak çeşitli dijital tekniklerle önlenmemişse kolayca çoğaltabilmektedirler.

Maddede yayınlanma için kullanılacak araçlar sınırlanmamıştır. Değişen şartlar dahilinde oluşacak yeni teknolojik gelişmelerle umuma iletime sınır koyulması olanaksızdır. Zaten bir Kanun’un uzun soluklu olması ve maddenin teknolojik gelişmeler sonucu işlerliğini kaybetmemesi için bu şekilde düzenlenmesi bir zorunluluktur.

Maddenin son fıkrasında belirtildiği gibi, eğer bir kişi bir eserin umuma iletim hakkına sahipse, bu hakkın kullanımı eser sahibinin yayma hakkının ihlali anlamına gelmeyecektir. Mimari bir projenin internette yayını veya televizyon programına konu edilmesi konusunda bir şahsa yetki verildiyse, eser sahibinin dijital satışı da içeren yayma hakkının ihlali söz konusu olmayacaktır.

Bu mali hak doğrultusunda eser sahibinden bir mimari projenin umuma iletim hakkını almış olan kişi, o eseri karasal vericili televizyonda veya bir uydu kanalında yayınlayabilir, internette bir web sitesinde erişimine izin verebilir veya herhangi bir bilgisayarda bulunan bir dosyanın içindeki bu projeyi insanların bir link ile ulaşip açıp incelemesine ve beğenirlerse kendi bilgisayarlarına bir kopyasının yapılmasıyla dağıtılmasına olanak tanıyabilir. FSEK 52. maddeye göre yazılı olarak ve açıkça umuma iletim hakkı eser sahibi tarafından üçüncü kişilere devredilebilir veya sınırlı bir süre ile lisans verilebilir. Ama hakkı devir almadan veya umuma iletim konusunda bir lisans almadan mimarın internet sitesinde yayınlanan projelerini bir üçüncü kişi alıp kendi web sitesinde yayınlayamaz veya link veremez.

Bu hak konusunda eser sahibinden izin alınmadan yayın yapılabilmesi konusundaki istisnalar; FSEK madde 26 ve 27’de yer alan zaman bakımından istisnalar; FSEK madde 30 uyarınca kamu düzenini koruma gerekçesiyle istisnalar; FSEK madde 31 ve 37 arasında belirtilen genel

menfaat gerekçesiyle istisnalar (mevzuat ve içtihatlar, nutuklar, iktibas, gazete münderecatı ve haberler); FSEK madde 38’de yer alan şahsen kullanma ve FSEK madde 40 gereğince umuma açık yerlerde bulunan mimarlık eserlerinde dış şeklin yayınlanması için istisnalar şeklinde düzenlenmiştir. Bu istisna durumlarında koruma süreleri henüz dolmamış olsa dahi eserin serbestçe umuma iletilmesi mümkündür.

6. Pay Alma (İzleme) Hakkı

Bir eserin eser sahibi tarafından satıldıktan sonra değerinin artması ve çok yüksek para ile tekrar satılması rastlanan durumlardandır. Bu takdirde eser sahibine veya ölmüşse mirasçılara, eserde meydana gelen değer artışından bir pay verilmesi hakkaniyet ve FSEK madde 45 hükmü gereğidir. Ancak FSEK madde 45 pay alma hakkını bazı şartlara bağlamış ve her eser türü için değil; sadece güzel sanat eserlerinin asılları ile eser sahibinin kendisinin sınırlı sayıda meydana getirdiği veya eser sahibinin kontrolünde ve izniyle meydana getirilmiş ve eser sahibi tarafından imzalanmış veya başka bir şekilde işaretlenmiş olmaları nedeniyle özgün eser olduğu kabul edilen kopyaları, yazarlarla bestecilerin el yazısıyla yazılmış eserlerinin asıllarından biri için bu hakkın uygulama alanı bulacağını belirtmiştir.

Pay almaya konu olacak eser türleri de sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar arasında mimari eserler ve mimari proje ve planlar yoktur.¹⁴⁴ Maddenin ilk kısmında açıkça mimari eserler bu madde dışında tutulmuştur. Ancak pay ve takip haklarının kapsamına FSEK madde 2’nin 1. bendinde “herhangi bir şekilde dil ve yazı ile ifade olunan” eserler girmektedir. Mimari proje ve planların da “dil ve yazı” ile ifade edilebileceği düşünülürse, maddenin başındaki “*mimari eserler hariç olmak üzere*” ibaresi değiştirilerek, bazı mimarlık eserleri bu kapsama girebilir ve özellikle mimari plan ve projelerin orijinal kopyaları veya maketler bu hakkın konusu yapılabilir. Zaten Kanun bu düzenleme ile resim, heykel gibi eserleri ve el yazısı kopyaları ve ilk baskıları hedeflemektedir.

Sonuç olarak; maddede bir değişiklik yapılmadığı sürece mimari eser sahiplerinin bu haktan yararlanmaları olanaksızdır.

¹⁴⁴ SULUK/ORHAN, age., s. 413.

VI. YAPI MALİKİNİN HAKLARI

T.C. Anayasası'nın 35. maddesine göre; herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Bir mimari eserin maliki, ister bu eseri istisna sözleşmesi gereği mimara bizzat sipariş vererek yaptırınsın, ister sonradan iktisap etsin, onu kendi ihtiyaçlarına göre kullanmak hak ve yetkisine sahiptir. Bu yetki malikin Türk Medeni Kanunu'nda yer alan “**mülkiyet hakkı**”ndan ileri gelmektedir. Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesi olan 683. maddeye göre mülkiyet hakkının içeriği şu şekilde belirlenmiştir: “*Bir şeye malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız el atmanın önlenmesini de dava edebilir.*”

Malik, İmar Mevzuatı'nın izin verdiği sınırlar içinde ve ekonomik olarak en verimli şekilde yapıyı tadil ve tevsi edebilir. Hatta değişen imar mevzuatına göre, değişiklik yapması malik için bir hak olduğu kadar aynı zamanda bir mükellefiyettir. Böyle bir durumda eser sahibi olan mimarın karşı çıkması da söz konusu olamaz. İsviçre Hukuku doktrininde, yapının iktisadi fonksiyonunu idame ettirebilmesi için esaslı surette tadili gerekiyorsa, bu durum yapının yıkılıp yeniden yapılanmasına eş tutulmuş ve mimara herhangi bir talep hakkı tanınmamıştır.¹⁴⁵

Ancak Medeni Hukuk bu geniş olanakları malike tanısa da, Fikri Mülkiyet Hukuku açısından bazı sınırlamalar söz konusudur. Malik yapacağı değişiklik ve genişletmelerde mimarın mesleki şeref ve itibarına aykırı hareket etmemelidir.¹⁴⁶ Buradan çıkacak anlam yapının orijinal şeklini aynen muhafazadan ziyade, onun fikri yaratıcılığını gösteren mimari un-

¹⁴⁵ H. BÜHLMANN: Schweizerische Juristenzeitung 1991, Heft 8, s. 139; Troller: ZBJV 1945, s. 385; BGE 117/II s. 466-479 Naklen EREL, age., s. 128.

¹⁴⁶ Mario M. PEDRAZZINI: Neuere Entwicklungen im Urheberrecht des Architekten, Droit de la Construction BR/DC/1-93, s. 6-7; TROLLER, age., s. 384 vd.; Lutz: s. 624 Naklen EREL, age., s.127

surların muhafazasıdır.¹⁴⁷ Aksi takdirde malik sırf fonksiyonel amaçlarla mimarın özgün yapısına ve fikri emeğine tecavüz etmiş sayılacaktır.

Hukuk öğretisine göre; mimarın mesleki şeref ve itibarının gözetilmesi, malike yapıyı tadil ve tevsî ederken keyfî tasarruflardan kaçınmak ve mümkün olduğu ölçüde eserin aslına sadık kalmak mükellefiyeti bulunmaktadır. Ancak bu mükellefiyet maliki aşırı bir mali külfet altına sokacak mertebeye varmamalıdır.¹⁴⁸ Bilindiği üzere, mimari yapıların iktisadi fonksiyonlarını muhafaza etmek üzere restorasyonu, bazen yıkılıp yeniden yapılmasına nazaran daha fazla bir mali yük getirmektedir. Anıtlar ve memleket kültürüne mal olmuş eski eserler dışında, hiçbir mimari eserin maliki, mimara karşı böyle bir mükellefiyet altına sokulamaz.¹⁴⁹

Erel, 1998 yılında kaleme aldığı eserinde; mimari eserlerin, kullanım amacı ve ihtiyaçların değişmesiyle tadil zorunluluğunun ortaya çıkmasında, malik ve mimarın karşılıklı hak ve menfaatlerini dengelenmesini gerekeceğini belirtmektedir. Erel'e göre; Fikri Hukuk açısından bu konuda önem taşıyan noktalar ve özel durumlar aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır.¹⁵⁰ Ancak Erel tarafından yapılan bu sıralamalarla ilgili Yargıtay'ın kimi konuda farklı kararları bulunmaktadır. Bu farklı görüşler Erel'e ait maddeler arasında verilmiştir:

1. Mimari eserde yapılan tadilat fevkalade cüz'i olabileceği gibi, mimar ile eseri arasındaki her türlü bağlantıyı ortadan kaldıracak ve artık eserin o mimara izafe edilmesini imkansız kılacak kadar külliyette de olabilir. Her iki halde de yapılan tadilat sonucu mimarın mesleki şeref ve itibarının ihlal edildiği söylenemez; zira artık eserdeki değişiklikler ya ihmal edilebilir ölçülerdedir yahut eser ile mükellefi arasındaki her türlü bağ kopmuştur.

Burada Erel'in görüşündeki önemli problem, küçük değişikliğin mimarın şeref ve itibarının ihlal edildiği anlamına gelmeyeceğini belirtmesidir. Halbuki eserin mahiyet veya özelliğini etkileyecek küçük bir değişiklik bile mimarın estetik görüşü veya onun kişiliği ile bütünleşmiş sanatsal çizgisine aykırı ağır bir durum ortaya koyabilir. Bu halde mimarın itibarı kesinlikle zarar görmektedir. Burada dikkat edilecek olan; değişikli-

¹⁴⁷ EREL, age., s. 128.

¹⁴⁸ TROLLER, age., ZBJV 1945, s. 385 Naklen EREL, age., s. 128.

¹⁴⁹ EREL, age., s.128.

¹⁵⁰ EREL, age., s. 128-129.

ğin büyük yada küçük olması değil, değişikliğin eserin mahiyet ve özelliğini yada mimarın şeref ve itibarını ağır olarak ihlal etmemesi gereğidir. Yine yapılan çok büyük değişiklik aynı ağırlık içeren sonucu doğurmaktadır. Bu yüzden küçük veya büyük değişikliğin yapının mahiyet ve özelliğini yada mimarın şeref ve itibarını bazı durumlarda ağır olarak ihlal edeceğini, ancak bunun ortadan kaldırılması için ya binadaki ilk mimarın yaptığına ilişkin tabelanın kaldırılması veya bu değişikliklerin başkası tarafından yapıldığının belirtilmesi ile mimarın isminin kaldırılması ve ilk mimara manevi tazminat ödenmesi gerektiğini söyleyebiliriz.

2. Eserdeki tadilatın mimar tarafından sözleşmeyle üstlenilmesi halinde zaten kendisinin hakları korunmuş olacaktır. Ancak bunun için mimarın makul bir ücretle çalışmayı kabul etmesinden başka, getirdiği önerilerin malikin ihtiyaçlarını tam olarak karşılaması ve aşırı bir mali külfet yüklememesi de gerekir. Tabiidir ki, mimara böyle bir görev vermek de malikin tercihindedir.

Burada taraflar arasında sözleşme ilişkisi belirleyici olmaktadır. Çizilen projenin işverence çeşitli safhalardaki onayları sonucu belirleyecektir. İşin sonunda mimar onaylara uygun projesini tamamlamakla işi tamamlamış olacak, ancak mimarın projesini uygulayıp uygulamamak işverenin tercihinə kalacaktır.

Mimarın üstlendiği projenin genişletilmesi eğer sözleşmede özel bir düzenleme yoksa ona mutlaka ek ücrete hak kazandıracaktır. Yargıtay'ın mimari eserlere yapılan ilaveler için proje veya yapı mimarının, ek telif ücreti isteyebileceğine ilişkin 1996 tarihli bir kararı şöyledir.¹⁵¹ Dava, davacı mimarın 2,5 kat olarak yaptığı bir okulun mimari ve statik projelerinin yapımı sırasında davalı tarafın isteği üzerine aplikasyon ve kalıp planlarının yapılarak iki kat daha ilave edilmesi istemi ve ek telif bedelini ödememiş olması üzerine açılmıştır. Yerel mahkeme kararında; statik projelerin FSEK ve Bern Sözleşmesi'yle telif hakları kapsamına alınmadığını belirtilerek dava reddedilmiştir. Ancak davacı tarafın temyiz itirazları Yargıtay tarafından kabul edilerek statik projelerinin de telif hakları kapsamında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu karar ile davacıya ek telif bedeli ödenmiştir.

3. Eserde yapılan tadilat ve değiştirmeler yapının önceki halinin yanı sıra farklı bir mimari stili yansıtıyorsa, o takdirde bu ekleme ve de-

¹⁵¹ 11. HD., 1.3.1996, E. 1996/982, K. 1996/1263. (Yargıtay Kararları No: 12)

ğiştirmelerin de kendi başlarına "eser" niteliği taşımaları kaydıyla, ortaya "iştirak halinde eser sahipliği" veya "müşterek eser sahipliği" denilen durumlar çıkabilir (FSEK madde 9, 10). Her iki halde de yapının önceki durumuna ait ve ilk mimara izafe edilebilecek özellikler korunduğu ve bütün içinde ayırt edilebildiği sürece, mimarın mesleki şeref ve itibarının zedelediği söylenemez.

2001 tarihli bir Yargıtay kararı bu konuda örnek verilebilir.¹⁵² Dava, Büyük S... Oteli'nin proje müellifi olan mimar tarafından, davalı İl Özel İdaresinin Oteli diğer davalıya kiralanmasından sonra kiracı tarafından eser sahibinin izni olmadan Otelin mimari yapısını bozacak şekilde ilave ve tadilatlar yapılması nedeniyle açılmıştır. Yargılama sonunda, eser sahibinin izni olmadan yapılan değişiklik ve eklemelerin yapının mimari özelliğini bozduğu anlaşıldığından; eski hale iadesi mümkünse ve değişikliğin izalesi ammenin ve malikin menfaatlerine esaslı surette haleldar etmiyorsa, eserin eski hale getirilebileceği, ama eski hale getirmenin ne şekilde olacağının Mahkemece, karar kısmında ayrıntılı şekilde belirlenmesi gerektiği kararı verilmiştir. Görüldüğü gibi Yargıtay burada Erel'in görüşüne uygun olarak mimari özelliği bozan uygulamalar sebebiyle eski hale iade kararı vermiştir.

4. Eserin münferit ve özellik taşıyan unsurları üzerinde bilinçli şekilde yapılan bir tadilatın ilk mimara ait olmadığına yine eser üzerinde belirtilmesi, mimarın şeref ve itibarının korunması için yeterli olacaktır. Bu husus FSEK madde 67/son fıkrayla hükme bağlandığı gibi, 1973 tarihli Brezilya Kanunu madde 27, 1956 tarihli İngiltere Kanunu madde. 43/4 ve 1966 tarihli Portekiz Kanunu madde 56 tarafından da öngörülmüştür. Ayrıca FSEK madde 67/son fıkra hükmüne göre, mimar eserdeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığının tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini de isteyebilir. Şayet eserin eski haline iadesi mümkünse ve bunun yapılması kamunun veya malikin menfaatlerini esaslı şekilde zedelemeyecekse, mimarı eseri eski haline de getirebilir.

Yargıtay'ın 1998 tarihli bir kararında¹⁵³ "güzel sanat eserinin haksız ve eser sahibinin rızası olmadan değiştirilmesi halinde, eski hale iadesi mümkünse ve değişikliğin izalesi kamunun ve malikin menfaatlerini haleldar etmiyorsa, eserin eski hale getirilebileceğini, aksi halde eser sahibinin özgün eserdeki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığının tanıtıl-

¹⁵² 11. HD., 29.3.2001, E. 2001/143, K. 2001/2548. (Yargıtay Kararları No: 40)

¹⁵³ 11. HD., 6.7.1998, E. 1998/3202, K. 1998/5147. (Yargıtay Kararları No: 22)

masını veya eserdeki adının kaldırılmasını isteyebileceği” vurgulanmıştır. Burada da Yargıtay Erel’in görüşüne paralel karar vermiştir.

5. *Mimarın mesleki şeref ve itibarı, eserin orijinal mimari tarzından açıkça farklı olan ilave ve değişikliklerden başka, onun mimari tarz ve üslubunun taklit olunmasıyla da ihlal edilebilir. Bu halde de eserin (değişiklik yapılan kısımlarının) başka bir mimara ait olduğunun uygun vasıtalarla belirlenmesi, mimarın şeref ve itibarının korunması için yeterli olacaktır.*

Bu yönde bir Yargıtay kararına rastlamamakla birlikte şu değerlendirmeyi yapabiliriz. Genelde güzel sanat eserlerinde “esinlenme” adı verilen, daha önce yapılmış eserlerden kısmen yararlanmanın bazı koşullarla hukuka uygun olduğu kabul edilmektedir. Ancak burada esinlenme ile taklit etmek arasındaki ince çizgiyi iyi belirlemek gerekir. Zira “taklit” olursa Yargıtay kararları “taklit”i hukuka aykırı bulmaktadır. Yargıtay bu konuya ilişkin vermiş olduğu bir kararında¹⁵⁴; yarattının “eser” sayılıp sayılmaması açısından, “somut şekilde bağımsız bir çalışma ve emek unsuru varlığını barındırıp barındırmadığı ve özgünlük taşıyıp taşımadığı” hususlarının belirleyici olacağını söylemektedir.

Yapılan yeni eserin taklit olmaması açısından, eserin ilk bölümde söylediğimiz subjektif şarta sahip olmasını; eser sahibinin kendi emeği sonucunda, varolanlardan önemli ölçüde değişik bir ürün yapılması ve bu yapılan ürünün eser sahibinden izler taşıması gerektiğini söyleyebiliriz. Nitekim bazı eserlerde, eser sahibinin özelliği; kullanılan bilimsel ve teknik malzeme arasında belirgin şekilde fark edilmeyebilir. Buna rağmen bu tarz çalışmalarda bile fikri emeğin korunması gerektiği şüphesizdir ve yukarıda açıklandığı anlamda “sahibinin özelliğini taşıma” şartı var olduğu ölçüde, bunlar da eser sayılırlar.¹⁵⁵ Ancak taklitçilikte bu subjektif şart bulunmaz.

6. *İspat yüküne değinmek gerekirse, mimarın fikri haklarını ihlal edecek ölçüde yapının orijinal mimari tarz ve üslubundan ayrılmayı gerektiren değişiklik ve ilavelerin hangi zorunlu teknik yahut kullanım ihtiyaçlarından kaynaklandığı, menfaatler dengesine uygun olarak malik tarafından ispat olunmalıdır.*¹⁵⁶

¹⁵⁴ 11. HD., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672. (Yargıtay Kararları No: 58)

¹⁵⁵ EREL, age., s.34.

¹⁵⁶ BÜHLMANN: SJZ 87, s. 140-141 Naklen EREL, age., s. 129

Genel itibariyle davalarda malik; yapılan değişikliklerin gerçekten zorunluluktan kaynaklandığını ispat etmek durumundadır. Aksi halde keyfi değişiklikler FSEK anlamında korunmamaktadır.

*Belirtilmelidir ki, birçok modern telif hakları kanunu mimari eserleri tadil özgürlüğünü, ancak mimarın şahsiyet hak ve menfaatlerinin ağır bir şekilde ihlali halinde kısıtlama yoluna gitmiştir.*¹⁵⁷

Burada üzerinde durmamız gereken bir başka nokta da; mimarın mükellefiyetlerini yerine getirmemesi veya imar kanunlarının ek inşaat hakkı tanınması halinde, yapı malikinin mimarı bu işleri yapmaya zorlama imkanın veya başka biriyle işe devam etme olanağının olup olmamasıdır. Bu olanak Borçlar Kanunu madde 358/II de açıkça düzenlenmiştir. Yapı maliki sözleşmeye aykırılık halinde ifaya zorlama davası açarak mimara mahkeme kararı ile işi tamamlama zorunluluğu getirebilir. Ayrıca FSEK madde 16/II düzenlemesine göre, imar kanunlarının ek inşaat hakkı tanınması hali, “çoğaltma tekniği icabı zaruri görülen değiştirmeler” kapsamında görülerek, eser sahibinin özel bir izni olmaksızın yapı maliki tarafından yapılabilir. Bu düzenleme doğrultusunda, aşağıdaki mahkeme kararında görüleceği gibi, eser sahibi mimarın izin vermemesine rağmen bir başka kişiye işi tamamlatabilmektedir.

Yargıtay’ın 2004 tarihli bir kararında¹⁵⁸; “söz konusu dava, kooperatif inşaatlarının mimari projeleri davalılardan A.B, statik projeleri ise diğer davalı ve kontrol mühendisi N.B tarafından yapılmakta iken, A.B. ve N.B.’nin görevine son verilmesi nedeniyle inşaatın devam edebilmesi için temel tadilat projesinin N.B.’nin bilgisi dahilinde bir başkasına çizdirildiği ve belediyece onaylandığı ancak N.B’nin çatı tadilat projesini imzalamamış olması nedeniyle belediye onayı alınamamış, kooperatif üyelerinin bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesi için başka bir mühendise imza yetkisi verilmesi” talebiyle açılmıştır. Yargılama sonunda A.B.’nin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiş olması nedeniyle onun açısından davanın reddine, ancak N.B.’nin sorumluluğunu yerine getirmemiş olması nedeniyle davacıların, imza yetkisine ilişkin talepleri yerinde bulunulmuştur. Sebep olarak da FSEK madde 16/2 uyarınca zaruri görülen değişikliklerin eser sahibinin izni olmadan yapılabileceği gösterilmiştir.

¹⁵⁷ Mesela İsviçre Telif Hakları Kanunu (Eidgenössische Urheberrechtsgesetz) Art. 12, Abs. Naklen, EREL, age., s.129.

¹⁵⁸ 11. HD., 18.5.2004, E. 2004/5177, K. 2004/5598. (Yargıtay Kararları No: 50)

VII. HAKLARIN KULLANILMASI VE DEVRİ

Kural olarak, telif hakları eser sahibine aittir. Ve esere ait mali ve manevi hakları kullanma yetkisi münhasıran eser sahibinindir. Ancak FSEK 18. ve 19. maddeleri, eser sahibinin menfaatlerini göz önünde bulundurarak bu hakların üçüncü kişilere bırakılabileceğinden bahsetmektedir.

Bu anlamda sadece mali değil; manevi haklara özgü bir durum da bulunmaktadır. Manevi haklar bilindiği gibi; eser sahibinin şahsına bağlı haklardandır.

Kullanılabilecek manevi hak türleri FSEK madde 19’da belirtilmiştir.

- FSEK madde 14/1’e göre; eserin umuma arz edilip edilmeme, yayımlanma zamanını ve tarzını tayin etme yetkisi,

- FSEK madde 15/1 gereğince; eseri, sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak umuma arz etme veya yayımlama yetkisi,

- FSEK madde 14/3’deki; eserin umuma arz edilmesinin veya yayımlanma tarzının eser sahibinin şeref ve itibarı zedeleyecek şekilde olması halinde, eser sahibi başkasına yazılı izin vermiş olsa bile gerek aslının gerek işlenmiş şeklinin umuma tanıtılmasını veya yayımlanmasını menetme yetkisi,

- FSEK madde 15/3 gereğince; eserin kimin tarafından vücuda getirildiğinin ihtilaflı olması veya herhangi bir kişinin eser sahibi olduğunu iddia etmesi halinde, eser sahibinin hakkının tespitini mahkemeden isteme yetkisi,

- FSEK madde 16/3 uyarınca; eser sahibi kayıtsız şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile şeref ve itibarını zedeleyen veya eserin mahiyet ve hususiyetini bozan her türlü değiştirmeleri men etme yetkisi.

Eser sahibi, saydığımız bu hakların kullanılmasını sağlar arası veya ölüme bağlı tasarrufla başka birine de bırakabilir.¹⁵⁹ Bu şekilde bir tasarruf işlemiyle hakların devri söz konusu değilse, FSEK madde 19’a göre; eser sahibinin ölümü sonrasında bu hakları kullanma yetkisi; vasiyeti tenfiz memuru; memur tayin edilmemişse, sırasıyla eser sahibinin sağ kalan eşi,

¹⁵⁹ SULUK/ORHAN, age., s .415.

çocukları, mansup mirasçılar, ana babası ve kardeşleri tarafından kullanılır. Bu kimseler eser sahiplerinin yakınları kavramı içindedirler.

Mali hak sahipleri ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da manevi hakların kullanımına belli şartlar altında (mevcut hakları kullanacak kişilerin bulunmaması veya bulunup da yetkilerini kullanmazlarsa yahut öngörülen koruma süreleri bitmişse ve eser memleket kültürü için önemli gözüküyorsa) yetkili olmaktadır. Mali hak sahipleri mali haklarını korumak için; Bakanlık da, kültür mirasını korumak için bu hakları kullanabilecektir.

Manevi hakların kullanımı yetkisinin eser sahibi sağken başkasına tanınabileceğini söylemiştik. Hatta mali haklara sahip kişiler de bu hakları kullanabilmektedirler. Bu arada belirtmekte fayda vardır ki; manevi hakların kullanılması ile manevi tazminat ikame edilmesi farklı kavramlardır. Örneğin eser sahibinin (mimarın) mirasçılara sadece esere saldırı halinde dava açma hakkı tanınmıştır.¹⁶⁰ Bu davayı ikame edenler manevi hakları kullanmamaktadırlar.¹⁶¹

Yine daha öncede bahsettiğimiz gibi mali hakları kullanma yetkisi eser sahibine aittir (FSEK madde 18/1). Ancak sözleşmeden veya işin mahiyetinden aksi anlaşılmadıkça çalışanların (işçi, memur veya hizmetlilerin) işlerini görürlerken meydana getirdikleri eserlerin üzerindeki haklar, bunları çalıştıran veya tayin edenler tarafından kullanılmaktadır. Bünyesinde mimar çalıştıran bir kuruluş, mimarın hizmet akti gereği oluşturduğu projelere ilişkin hakları kullanabilmektedir. Ancak o projenin eser sahibi, projeyi meydana getiren mimardır. Aynı şekilde tüzel kişilerin organları hakkında da bu kural geçerlidir. Belli şartlar altında eser sahibinin ölümünden sonra da Kanun'da gösterilen kişiler tarafından da bu haklar kullanılabilir.¹⁶²

FSEK 63. madde “*bu Kanunun tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder. Mali haklar üzerinde ölüme bağlı tasarruflar yapılması caizdir.*” demektedir. Bu sebeple mali hakların tamamı miras yoluyla mirasçılara intikal edebilme özelliğine sahiptir. Fakat mirasa konu olacak mali haklar, yalnızca mirasçı olabilecek kişiler tarafından kullanılır. Mali haklar bu şekilde mirasla geçtiği takdirde, FSEK 65. maddesine göre; MK madde 640 uyarınca miras kalan mallar için bir temsilci tayin edilmişse, temsilci bu haklar için yapacağı işlemler için mirasçıların kararını almak zorundadır.

¹⁶⁰ SULUK/ORHAN, age., s. 416.

¹⁶¹ TEKİNALP, age., s. 163.

¹⁶² SULUK/ORHAN, age., s. 415-416.

FSEK 64. maddesi birlikte yaratılan ama henüz alenileşmemiş mimari eserlere uygulanabilen bir düzenleme getirmektedir. Bu madde “Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri, eserin tamamlanmasından yahut alenileşmesinden önce ölürse hissesi, diğerleri arasında taksime uğrar. Bunlar, ölenin mirasçılarına münasip bir bedel ödemekle mükelleftirler. Miktar üzerinde uzlaşamazlarsa bunu mahkeme tayin eder. Eseri birlikte vücuda getirenlerden biri eserin alenileşmesinden sonra ölürse diğerleri, ölenin mirasçılarıyla birliği devam ettirip ettirmemekte serbesttirler. Devama karar vermeleri halinde, sağ kalan eser sahipleri mirasçılardan birliğe karşı haklarının kullanılması hususunda bir temsilci tayinini talep edebilirler. Devama karar verilmediği takdirde birinci fıkra hükümleri uygulanır” şeklindedir. Bu düzenleme sonucu eser sahiplerinden birinin ölümü sonucu diğer eser sahipleri ölenin mirasçılarına bir bedel ödeyerek eserin tamamlanmasını ve tamamlandıktan sonra da alenileşmesini sağlayabilmektedirler. Bu hüküm, her bir mimari eser aynı zamanda ülkenin kültürel zenginliği olduğu için, bu eserin tamamlanarak ülke zenginliğine katılmasını sağlamaktadır. Eğer eser tamamlanmış ve alenileşmişse ve bu aşamada eser sahiplerinden biri ölmüşse diğer eser sahipleri mirasçılarla bu eserin idaresini yapmak istemezlerse yine mirasçılara bir bedel ödeyerek bu eserin kendileri tarafından rahatça kullanımını sağlayabilirler.

FSEK madde 60 gereğince; Eser sahibi yahut mirasçıları, kendilerine kanunen tanınan mali haklardan, önceden yapılmış anlaşmaları ihlal etmemek şartıyla, bir resmi senet tanzimi ve bu hususun Resmi Gazete’de ilanı suretiyle vazgeçebilirler. Vazgeçme, ilan tarihinden başlayarak korumaya süresinin bitmesi halindeki hukuki neticeleri doğurur.

FSEK deki mali hakların **devir**, **ruhsat** ve **izin** şeklinde üç tip hak alımına konu olabileceğinden bahsetmemiz gerekmektedir.¹⁶³

Bunların ilki “**devir**”dir. Devir, devralanın devredilen mali haklara ait bütün hakları kullanabilmesi, sözleşme ile engellenmemişse başkalarına söz konusu hakları kısmen veya tamamen devredebilmesi ve devralının üzerinde haklar tanıyabilmesi demektir. **Devir’de devredilen hak artık devreden malvarlığından çıkmaktadır.** Bu hakkı devralan kişi

¹⁶³Yargıtay’ın ruhsat ve devir’in birbirinden farklı olduğuna ilişkin geniş görüşü için bkz. 11.HD. 26.04.1999, E. 1999/594, K. 1999/ 3250 (Yargıtay Kararları No: 24) Fikri haklarda devir, lisans ve izin açısından daha geniş bir değerlendirme için bkz. Gürsel ÖNGÖREN, İnternet Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2006.

“mutlak bir hak” almış olur.¹⁶⁴ Burada artık devredilen mali hak, devreden eser sahibinin malvarlığından çıktığından, bu hakkın bir biçimde kısıtlanması için mutlaka sözleşmede kısıtlamaya ilişkin özel bir düzenleme gereklidir. Eğer bir kısıtlama yoksa devralan kişi eser sahibi gibi bu hakları kullanabilir. Buradaki önemli şartlar FSEK 52. madde gereğince devir işleminin yazılı olması ve konuları olan hakların ayrı ayrı gösterilmesidir. Bu şekilde tek tek hakların belirtilmesinin sebebi, toplumda eser üzerindeki hakkın “telif hakkı” denilen tek bir mali haktan ibaret olduğu ve bunun bir defa devredilmesiyle, devralanın eser üzerinde istediği şekilde tasarruf edebileceği yolundaki yanlış kanaati bertaraf etmektir.¹⁶⁵ Şunu da belirtmek gerekir ki, bu maddedeki şart bir ispat şartı değil, geçerlilik şartıdır. Buna göre avan projesinin uygulama projesine dönüşebilmesi için uygulama projesi müellifine verilecek olan işleme yetkisi, muhakkak yazılı olarak ve bilhassa bu haktan bahsedilerek verilebilir. Çok istisnai olarak Yargıtay, Medeni Kanun (MK) 2. maddeye aykırı özel durumlarda yazılı sözleşme şeklini aramamaktadır.¹⁶⁶

Yargıtay kararları ve doktrinin üzerinde birleştiği konulardan biri mali haklara veya manevi haklara ilişkin verilen yetki ve izinlerin tek tek sayılması gerektiğidir.¹⁶⁷ “Mali hakları devrettim” ya da “bütün haklarımı devrettim” şeklindeki ibareler geçersizdir. Burada belirtilen saymanın yayma, temsil, çoğaltma veya umuma iletim gibi başlıklar halinde olması

¹⁶⁴ Mutlak haklar, hak sahibine hakkın konusu üzerinde doğrudan bir egemenlik sağlayan ve bu nitelikleri itibarıyla herkese karşı öne sürülüp, herkes tarafından da ihlal olunabilecek haklardır. Mesela mutlak hakların tipik bir örneğini teşkil eden mülkiyet hakkı, malik olan şahsa mülkiyet konusu olan mal üzerinde başka bir şahsın izin veya aracılığına gerek duymaksızın egemenlik kurma ve o maldan hukuk düzeninin sınırları içinde yararlanma yetkisi sağlar. Şafak EREL, Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Ankara, 1998, s.4., OĞUZMAN/ SELİÇİ/ OKTAY-ÖZDEMİR, Eşya Hukuku, İstanbul, 2006, s. 6 ve GÖKYAYLA, age., s.134.

¹⁶⁵ EREL, age., s.277.

¹⁶⁶ 11. HD. 19.03.2001, E.2001/226, K. 2001/2031 (Yargıtay Kararları No: 37) ve 26.6.1997, E. 1997/2854, K. 1997/5116 (Yargıtay Kararları No: 15)

¹⁶⁷ TEKİNALP; age., s.171 ve Yargıtay 11.HD., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338 “...sözleşmede video çekimi ve yayın hakkı devredildiği belirtilmiş ...televizyonda gösterim hakkının verildiğinden söz edilmemiştir... Sözleşmelerin tv yayın hakkını da kapsadığı yolunda daha geniş bir yoruma tabi tutulması mümkün değildir...” (Yargıtay Kararları No: 28)

yetmektedir.¹⁶⁸ Yoksa ayrıca çoğaltma için türleri kapsayan; fotokopi, inşaa, binanın fotoğrafının çekilmesi gibi bir sayma veya umuma iletim için televizyon ve internet gibi araçlara ilişkin bir sayma gerekmemektedir. “*Umuma iletim hakkını devrettim*” ibaresi tüm umuma iletim biçimlerini kapsar. Yargıtay bu açıdan 11. HD. 03.07.2000, E. 2000/5403, K. 2000/6334 sayılı kararıyla “...*hak sahibi mali hakkı her hangi bir sınırlama olmaksızın devredebileceği gibi... mali hakkın devrine ilişkin tasarruf işleminin herhangi bir sınırlama olmaksızın devri mümkündür*” demektedir.

Yargıtay’ın bu yöndeki kararları uzun bir süredir istikrar göstermektedir¹⁶⁹ ve devir’in hukuki sonucu konusunda Yargıtay, 11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246 sayılı kararıyla “... *davacının eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren mali hakları sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden* (davacının/**eser sahibinin** bu eserler üzerinde artık) **mali hakkı kalmadığı**” sonucuna varmaktadır.

Ancak “devir” hukuki işleminde, “çoğaltma” açısından genel ibare yerine “*projenin ozalitinin çıkarılması, planın uygulanması*” şeklinde tek tek çoğaltma biçimlerinin sayılması sistemi ile sözleşme yapılmışsa; sayılmayan kitap basımı veya cd’ler yoluyla çoğaltma ve diğer biçimlerde çoğaltma gibi diğer haklar devir kapsamında değildir (istisna edilmiştir) diye düşünmek gerekir. Bu görüşten yola çıkarak, “*mimari eserin planının fotokopi ve diğer yollarla çoğaltma haklarını devrettim*” gibi bir ibare varsa kitap, cd ve internet de dahil olarak çoğaltma kavramına giren tüm mali haklar devredilmiştir kanaatindeyiz. Yargıtay’ın da mali hakların bu

¹⁶⁸ 11. HD. 01.02.1999, E.1998/8794, K. 1999/311 “...ruhsatın.. tam ruhsat niteliğinde olduğu ve bu nedenle eser sahibinin **çoğaltma** ve **yayma haklarını** bu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe bir başka kişi ve kuruluşa devredemeyeceği...11. H.D., 08.12.1992, E. 1991/4907, K. 1992/11246 ... davacının eserleri üzerindeki kullanma, çoğaltma ve yayma haklarını içeren mali hakları sözleşme ve taahhütnameler uyarınca süre ve yer kısıtlaması olmaksızın davalıya devrettiğinden...” (Yargıtay Kararları No: 23).

¹⁶⁹ 11. HD., 04.05.1998, E. 1998/1096 K. 1998/3035 “....1981 tarihli anlaşma ile filmin dünya üzerindeki her türlü gösterim hakkının davacıya devredildiği, ... devrin FSEK 52. maddesine uygun olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne ...” (Yargıtay Kararları No: 18).

şekilde devredildiğine ilişkin kararları, kolaylıkla mimari eserlere uygulanabilir.¹⁷⁰

Burada diğer bir önemli nokta, işleme hakkının, diğer haklara ilişkin “*hakkın ismini sayarak devir sistemi*”nden farklı düzenlendiğidir. Yani “*çoğaltma, umuma iletim hakkımı devrettim*” ibaresinde olduğu gibi “*işleme hakkımı devrettim*” deyip her çeşit işleme haklarını devredemeyiz. FSEK 55. maddede “*aksi kararlaştırılmış olmadıkça mali bir hakkın devri veya bir ruhsatın verilmesi eserin tercüme veya sair işlenmelerine şamil değildir*” demektedir.¹⁷¹ Bu yüzden işleme biçimlerinin yapılan devir sözleşmesinde açıkça sayılması gerekir.

Mali haklar açısından ikinci tip hak alım yöntemi “**ruhsat**” veya “**lisans**”tır. Lisans/ ruhsat verme, hakkın; devreden malvarlığını bütünüyle terk etmeden devralana sadece kullanılması yetkisinin tanınmasıdır. Bunun “devir”den farkı sadece belli ve sınırlandırılmış hak veya haklarla ilgili kullanma yetkisi vermesidir. “*Bir inşaat projesinin sadece belirli bir arsada uygulanması*”, “*tasarım ve çizimlerin internette iki yıl umuma iletimi*”, “*üç yıl müddetle mimari bir projenin tüm teknik ve digital araçlarla çoğaltılması yada umuma iletimi*” veya “*sahibi olduğum bina maketinin web sitesinde başlangıç sayfası olarak kullanılması*” gibi hak yetkilendirmeleri yada kullanma yetkileri ruhsattır. **Ruhsat; mali hak sahibinin başkalarına da aynı ruhsatı vermesine mani değilse “basit ruhsat”tır.** Eğer çizilen proje veya yapılan tasarımlar için belirli bir arsada inşaat yapılması açısından ruhsat verilmişse, aynı tasarım mimar tarafından başka bir işveren için de projeye çevrilip, inşaatı için yeni bir lisans verilebilir. **Kanun veya sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça her ruhsat basit sayılır.** Basit ruhsatlar hakkında hasılat kirasına dair kurallar geçerlidir. Basit ruhsatların koşulları varsa feshi veya iptali mümkündür. **Eğer devredilen mali haklar, yalnız bir kimseye (yani devralana) mahsus olduğu takdirde “tam ruhsat”tır.** Tam ruhsat verme hukuki işlemi inhisaridir yani devredilen haklar artık devredilen kişinin tek elindedir ve eser sahibinden

¹⁷⁰ “...müzik eserlerinin yayın hakkı dava dışı M’de iken tüm hakların 1992 yılında ... devredildiği ve bu durumun müzik eseri işletme belgesine şerh edildiğini... dava konusu eserler üzerinde davacının komşu hak sahibi olarak mali ve manevi hakları bulunduğu ... maddi tazminatın davalıdan tahsiline...” 11. HD., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567. (Yargıtay Kararları No: 54).

¹⁷¹ 11.HD., 27.12.1999, E. 1999/9039, K.1999/10796 “...işleme hakkının tekrar devredilmesi için eser sahibinin muvafakatının zorunlu bulunduğu...” (Yargıtay Kararları No: 32).

de ayrılmıştır. Bu haliyle “tam ruhsat”, “devir” işlemine benzer sonuçları doğurur. Tam ruhsatlar hakkında intifa hakkına dair hükümler uygulanır.¹⁷²

Yargıtay’ın tam ruhsatın sonuçlarına ilişkin kararlarını şöyle sıralayabiliriz. 11. H.D. 11.03.1999, E.1999/9858, K. 1999/3423 “...*tam ruhsat verilmişse, ruhsat sahibinin fiilen mali hak sahibinden farkı yoktur...*” , 11. H.D. 26.04.1999, E.1999/594, K. 1999/3250 “...*Tam ruhsatta, mali haklara ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat sahibine devir edildiğinden....tam ruhsatta....devir alan.... Markalar kanunundaki inhisarı lisans sahibi gibi(dir)...Aksinin kabulü halinde, eser sahibi ve komşu hak sahibi tam ruhsatta mali hakkı kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine devir ettiğinden (ve devredenin artık hakkı kalmadığından), tam ruhsat sahibine dava hakkı tanınmaması halinde eser ve komşu hak korumasız kalacaktır.*”

Önemle belirtmek gerekir ki; FSEK madde 49’a göre, eser sahibi veya mirasçılardan mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma ruhsatını iktisap etmiş bir kimse, ancak bunların yazılı izniyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir. Yani eser sahibi ve mirasçıları, sonraki el değiştirmeleri engelleme yetkisine sahiptir. Buna göre bir mimar tarafından hazırlanan ön projenin iş sahibi tarafından alınmasının ardından, iş sahibi bu projeyi eser sahibinin veya mirasçılarının rızası olmadan bir başkasına uygulama projesi haline getiremez.

Buradan çıkan bir başka konu; televizyon ve internette yayın gibi mali haklar için devralanların veya ruhsat alanların bu hakları üçüncü kişilere devrederken sınırlamalar olup olmamasıdır. Eğer FSEK madde 48’in ilk fıkrasındaki “devir” hukuki işlemi yapılmışsa, hak; eser sahibinin malvarlığından çıkıp devralanın malvarlığına girdiğinden, bunun üçüncü kişilere devri için tekrar dönüp eser sahibinden izin almaya gerek yoktur. Sözleşmede üçüncü kişilere devir açısından hiçbir düzenleme yoksa yahut özellikle bir yasak koyulmamışsa böyledir. Ayiter’e göre de; “işleme hakkı”ndan başka bir mali hakkın devrinde, eser sahibi mali hakkını A’ya devretmişse A eser sahibinden izin almadan B’ye ve B yine eser sahibinden izin almadan C’ye devredebilir.¹⁷³

¹⁷² TEKİNALP, age., s.212 vd.

¹⁷³ AYİTER, age., s.209. ve 11.H.D., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199 “...dava konusu olan ...şiiiri tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda **davalı şirket en geniş bir biçimde bu hakları kullanabilir ve başkalarına**

Eğer FSEK 48. maddenin ikinci kısmındaki ruhsat işlemi yapılmışsa o zaman durumu ikiye ayırmak gerekir. FSEK 49. maddenin düzenlemesi “*eser sahibi veya mirasçılarından mali bir hak veya böyle bir hakkı kullanma **ruhsatını** iktisap etmiş olan bir kimse, ancak bunların yazılı muvafakatiyle bu hakkı veya kullanma ruhsatını diğer birine devredebilir*” demektedir. Burada 49. madde “**mali bir hak ... ruhsatı**” ve “**mali bir hakkı kullanma ruhsatı**” şeklinde iki tip ruhsat saymakta böylece, 48. maddenin ilk fıkrasındaki “devir” işlemini hariç tutmaktadır. Mali bir hakkı kullanma ruhsatına “*çoğaltma hakkını internet için alma*” verilebilir. Bu konuda çeşitli örnekler üzerinden düşünce üretilebilir. İlk örnekte eser sahibi sözleşmede ek bir madde ile çeşitli olasılıklar doğrultusunda üçüncü kişilere bu ruhsatı devir için izin vermiş olabilir, bu halde devir için sorun yoktur. Bu devir veya devirler için toptan bir izin veya her biri için tek tek düzenleme yapılabilir.¹⁷⁴ İkinci örnekte, sözleşmede üçüncü kişilere devir konusunda bir izin verildiği açıkça belirtilmiyorsa; eser sahibi veya mirasçısından A Şirketi ruhsat almışsa bunu B Şirketine devretmek için ayrıca eser sahibinin yazılı muvafakatını işlem öncesi alması gerekir. B Şirketi yine yazılı muvafakatla C’ye ve yine yazılı muvafakat varsa C’de D’ye devredebilir. Aksi takdirde A Şirketi, FSEK madde 49 gereği mali hakkı veya kullanma yetkisini B’ye devredemez. Üçüncü örnekte ise sözleşmede üçüncü kişiler için devir yasağı olmasıdır. Bu durumda devir imkanı bulunmamaktadır.¹⁷⁵

Özünde bu konuda FSEK madde 49 düzenlemesi hatalıdır. Maddede “*tam ruhsat mı yoksa basit ruhsat mı kastediliyor*” sorusunun cevabı açık değildir. Bizce 49. madde sadece basit ruhsatlar için bu kuralı getirmelidir. Zira yukarıda da açıkladığımız gibi “tam ruhsat”, “devir” hukuki sonucuna yakın hukuki sonuçları devralan için sağlamaktadır. Nitekim Yargıtay bu konudaki kararlarında tam bir kararlılık göstermese de görüşümüze uygun kararlar vermektedir. Yargıtay; 11. HD. 15.10.2001, E.2001/4951, K. 2001/7904 sayılı kararıyla, ölenin sağlığında eserle ilgili haklarını devralan kişilerin, bu hakları devrettiği kişilerin haklarının korunması gerektiğini ve bu hakların artık ölenin terekesinden çıktığını söylemekte ve bizim

devredebilir. Hal böyle olunca davacının...şiiiri için hiçbir hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır...” (Yargıtay Kararları No: 11)

¹⁷⁴ Burada bazı yazarlar eser sahibinden her bir devir için ayrı ayrı muvafakat alınmasını gerekli görmektedir ve toplu olarak alınmış devir iznini geçersiz bulmaktadır.

¹⁷⁵ 11. HD., 27.04.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748 (Yargıtay Kararları No: 17)

“devir” ve “tam ruhsat” için ileri sürdüğümüz mutlak hak görüşümüzü desteklemektedir. Yine 11. H.D. 15.10.2001, E.2001/4928, K. 2001/7866 sayılı kararıyla (ki kolayca mimari eserlere uyarlanabilir) “...1995 tarihli sözleşme ile...filmlerin SVMEK’den kaynaklanan hakları(nın) film ve ne-gatifleri ile birlikte Kanal ... A.Ş. ‘ne devredildiği, sözleşmenin 5. maddesi gereğince mülkiyet haklarının alınan şirkete gittiği,... işletme haklarının devir ve tescil işlemleri yapılmak üzere yetkilendirildiği, bu şekilde devralınan haklarının Kanal ... A.Ş. tarafından davalıya (bir başka yayıncı olan Y) verilmesi nedeniyle davacının (filmlerin Kanal ..’dan önceki hak sahibi olan X Şirketinin) tazminat talep hakkı bulunmadığı...” hüküm altına alınmıştır. Fakat 11.HD. 09.06.2003, E. 2003/499, K. 2003/6125 sayılı kararında “...sözleşmede... eserin tüm yayın haklarının bu davalıya ait olduğunu kabul etmişse de, yayın haklarının bu (bir başka) davalıya devretmesine muvafakati olduğuna dair sözleşmede bir hükme yer veril-memiştir. Oysa eser sahibinin, eserinin yayın hakkını vermiş olduğu aktinin bu hakkı bir başkasına devredilmesi için... FSEK 49. maddesi ge-reğince yazılı olarak muvafakatte bulunması gerekmekte olup...” ibare-siyle, tam ruhsata ilişkin devirde eser sahibinden izin alınması gereğini belirtmiştir. Kanaatimizce Yargıtay basit ruhsatlar hakkında 2003 tarihli kararını uygulamalı; ancak, tam ruhsatlar hakkında 2003 tarihli bu uygula-masını değiştirmelidir.

Alınan izin çok geniş kapsamlı olsa bile FSEK madde 52’deki “munzam koşul”un çağdaş yorumu çerçevesinde, devredilen mali hakların coğrafi alan, süre, medya türü gibi unsurlarla sınırlandırılması gerekecek-tir. Çünkü FSEK madde 52, Üstün’e göre “fikri mülkiyet tapu dairesi” gibidir¹⁷⁶. Bu nedenle mali hakların mutlaka ferdileştirilmesi gerekmekte-dir. Zira, FSEK 16. maddesi “*eser sahibi kayıtsız ve şartsız olarak yazılı izin vermiş olsa bile eserin mahiyet ve özelliklerini bozan her türlü de-ğiş-tirmeleri men edebilir, menetme yetkisinden bu hususta sözleşme yapılmış olsa bile vazgeçmek hükümsüzdür*” düzenlemesini içermektedir. FSEK madde 16/2’den çıkan sonuç esasen şudur; zaruri değişiklikler için eser sahibinden izin alınmasına gerek olmadığı belirlenmekle birlikte, bu izin hakkının eser sahibinin izniyle bir eseri işleyen, umuma arz eden, çoğal-tan, yayınlayan, temsil eden kişiye ait olduğu açıkça belirtilmesi gerekti-gidir. Bir mimarlık eserinin özgün projeye göre inşa edilmesi “çoğaltma”,

¹⁷⁶ ÜSTÜN, age., s.223.

tadilat projesi veya sözlü talimatla yapılan esaslı değişiklik ise “işleme” anlamındadır.

Dolayısıyla FSEK madde 16/2’yi mimari eserlerdeki işleme hakkının devri için şu şekilde değerlendirebiliriz; bir mimarlık eserinde yapılacak zaruri değişikliklere ilişkin izin muafiyeti için işleme hakkı sahibi olmak gerektiğine göre (eser sahibinin lehine yorum ilkesi gereğince), zaruri olmayan değişiklikler içinde işleme hakkına sahip olmak gerekmektedir. Buna göre yapılan değişiklik alelade bir değişiklik olsa dahi, değişikliği yapanın işleme hakkına sahip olup olmadığı FSEK madde 52 kapsamında saptanmalıdır.

Üçüncü ve son hak alımı ise; “**izin**”dir. FSEK madde 80. maddede yer alan izin; “komşu hak sahibinin izni ile” ve “icracı sanatçının izni ile” denilerek vurgulanmıştır. Bizim katıldığımız görüşe göre; FSEK madde 80’de yer alan müzik yapımcısının veya film yapımcısının eser sahibi veya icracı sanatçıdan ilk tespit hakkı için almış olduğu izin; yukarıda bahsettiğimiz “devir” veya “ruhsat” kapsamı dahilinde değildir. Bu hak alımı, alan kişi açısından “devir”e benzeyen hükümler taşıyan mutlak hak niteliğinde özel bir hukuki durumdur. Bahsettiğimiz bu üçüncü tür hak alımı olan “izin” ile; icracı sanatçı icrasını ve fonogram yapımcısı fonogramını oluşturmaktadır. Bu oluşumlar sonucunda; icracı sanatçı veya fonogram yapımcısının elinde bulunan yapımlar açısından; bunlara izin verenlerin dahi dokunamayacağı komşu haklar niteliğinde bağımsız ve müdahale edilemeyecek haklar oluşturulmaktadır. Bu nedenle de daha öncede bahsettiğimiz gibi FSEK madde 58’de bulunan cayma hakkı, “izin” hak alımı için geçerli değildir. İzin konusunu bu açıklamalarımızla kısaca kesiyoruz, zira bu hak kullandırma yöntemi mimari eserler için çok istisnai olarak uygulanabilir.

Devir veya ruhsatlar açısından önemli bir konu; işverenlerin veya kullanıcıların hak sahibi olmayan kimselerden hak aldıklarını zannederek birçok zararlara uğramalarıdır. FSEK madde 54 gereğince; mali bir hakkı yahut kullanma ruhsatını devre yetkili olmayan kimseden satın alan veya kiralayan kişi, iyiniyet sahibi olsa bile hak sahibi olamaz. İşveren bir projeyi çizmek için bir mimar ile anlaşır, fakat mimar projeyi arkadaşına veya başka bir mimara çizdirir ve sözleşmede belirtildiği tarihte işverene teslim eder. İşveren daha sonra bu projeyi uygulatmak için başka bir mimara uygulama projelerini çizdirmek ve binasını veya dekorasyonunu yaptırmak ister. İşte burada problem çıkar. Çünkü işverenin sözleşme yaptığı mimar hak sahibi değildir. Bu yüzden bu projenin uygulama projeleri veya bina

yapımı gerçek eser sahibi tarafından kolayca durdurulabilir. Bu yüzden de iş sahibi para ve zaman kaybına uğrar, hatta üçüncü kişilerle binadaki dairelerin satışı hakkında dahi anlaşmış olabilir yada işyerinin dekorasyonu bitmediği için anlaştığı bir mağaza zinciri ile yaptığı anlaşmanın bozulması ile karşılaşabilir. Bu durumda yetkisi olmaksızın mali bir hakkı başkasına devreden veya kullanma ruhsatını veren mimar aynı maddeye göre; yetkili bulunmadığına diğer tarafın bildiğini veya bilmesi gerektiğini ispat etmedikçe yapılan sözleşme ve sözleşmeden dönülerek işin hükümsüz kalmasından doğan menfi zararı ödemekle sorumludur. Kusur halinde mahkeme; hakkaniyet gerektiriyorsa sadece menfi zararı değil, ayrıca kâr kaybı gibi müspet zararı içeren daha geniş bir tazminata hükmedebilir.

Mali hakların devrini yukarıda genişçe anlattık. Şimdi de devir sonrası hakkında bilgi verelim.

FSEK madde 58 gereğince, mali bir hak veya ruhsat elde eden kimse, kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre belirlenmemişse duruma göre uygun bir zaman içinde hak ve yetkilerinden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin çıkarları önemli şekilde ihlal edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen eser sahibi sözleşmedeki hakların kullanılması için noter vasıtasıyla diğer tarafa uygun bir süre vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, elde eden kimse için imkansız olur veya tarafından reddedilir yahut bir süre verilmesi halinde eser sahibinin çıkarları önemli şekilde tehlikeye düşmekte ise süre verilmesine gerek yoktur. Verilen süre neticesiz geçerse veya süre verilmesine gerek yoksa noter vasıtasıyla yapılacak ihbar ile cayma tamamlanır. Cayma ihbarının tebliğinden itibaren 4 hafta geçtikten sonra caymaya karşı itiraz davası açılmaz.

Bir hakkı elde edenin mali hakkı kullanmamakta kusuru yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde hakkı elde eden, uygun bir tazminat isteyebilir.

Cayma hakkından önceden vazgeçme olanağı olmadığı gibi bu hakkın ileri sürülmesini iki yıldan fazla bir süre için yasaklayan sınırlamalar da hükümsüzdür.

Ruhsat sonrasında karşılaşılan diğer bir konu da anlaşmanın sonunda hakların eser sahibine geri dönmesidir. FSEK 59. madde gereğince; eser sahibi veya mirasçıları mali bir hakkı belirli bir amaç için yahut belirli bir süre için devretmişlerse amacın ortadan kalkması veya sürenin geçmesiyle ilgili hak, sahibine geri döner.

Mimari eserleri ilgilendiren bir başka bilinmesi gereken düzenleme de FSEK 57. maddesindedir. Bu hükme göre asıl veya çoğaltılmış nüshalar üzerindeki mülkiyet hakkının devri, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, fikri hakların devrini ihtiva etmez. Bu konuya örnek projenin sözleşme süresi sonunda iş sahibine teslim edilmesini verebiliriz. Orijinal imzalı proje kopyası elinde olan kişi mutlaka hakları devralmış değildir. Bunun için mimardan yazılı olarak bir anlaşma ile hangi hakları amaçlıyorsa onları devralması gerekir.

VIII. MİMARİ PROJE DÜZENLEME SÖZLEŞMESİ

A. TANIMI VE İÇERİĞİ

“Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesi”; işverenin oluşturulmasını talep ettiği yapının kullanım amacına göre, bir mimar ile yapının plan ve projelerin düzenlenmesi konusunda yaptığı hukuki sözleşmedir. Bu sözleşmeye göre; öğreti ve uygulama gereğince mimar, yapı sanatı ve tekniği ile İmar Hukuku kurallarına uygun, uygulanmaya elverişli bir mimari proje hazırlayacak, mimari proje onaylanıp yapı ruhsatı alındıktan sonra ise mimari projenin uygulanmasına geçilecektir.¹⁷⁷ Projenin hazırlanmasına ilişkin geçen süreçten sonra, uygulama süreci olan yapının meydana getirilmesi aşamasına gelinmektedir.

Mimari proje düzenleme sözleşmesi ile, mimarın üstlendiği borcunun konusunu oluşturan mimari proje hizmetleri; birbirini takip eden ve bütünleyen, biri tamamlanmadan bir diğerinin yapılamayacağı çeşitli iş aşamalarından oluşmaktadır.¹⁷⁸ Bu aşamalar sırasıyla hazırlık ve ön etüd çalışmaları, tasarım ile ön proje çalışmaları, kesin proje çalışmaları ve uygulama projesi gibi çalışmalardır.¹⁷⁹

Mimarın bu sözleşme çerçevesindeki yükümlülükleri içinde kimi zaman; yapı maliyet tavanının hesaplanması, ihale dosyalarının düzenlenmesi ve inşaatın kontrol edilmesi çalışmaları da bulunmaktadır.

B. KONUSU

Mimar ve yapı sahibi; BK madde 19/1’de öngörüldüğü üzere sözleşme serbestisi çerçevesinde tarafların isteklerine uygun olarak bireysel mimarlık sözleşmeleri düzenlemektedirler. Bu nedenle uygulamada tek tip bir mimarlık sözleşmesi bulunmamaktadır.¹⁸⁰ Ancak sözleşme tarafları,

¹⁷⁷ Göktürk UYAN, İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, İş Görme Sözleşmeleri Kuramına Bir Katkı, Beta Yayınları, 1. Bası, İstanbul, Şubat 2006, s. 3-4.

¹⁷⁸ UYAN, age., s. 4-5.

¹⁷⁹ Bkz. Mimari proje çalışmaları için II. MİMAR VE MİMARİ HİZMETLER adlı bölüm.

¹⁸⁰ GAUCH Peter, “Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und der SIA-Ordnung 102-in: GAUCH/TERCIER (hrsg.), Das Architektenrecht”, Freiburg 1995, N.9; İbra-

mimari proje düzenleme sözleşmesini BK madde 19/1’de öngörülen sözleşme serbestisi ilkesi¹⁸¹ çerçevesinde bireysel olarak düzenlenmek imkânına sahip oldukları gibi, sözleşmeyi uygulamada sıklıkla kullanılan Mimarlar Odası “Mimarlık Hizmetleri Tip Sözleşmesi”ni (MHTS) benimsemek suretiyle de oluşturabilmektedirler.

İsviçre uygulamasında ise, SIA tarafından hazırlanmış olan “*Mimarlık Hizmetleri ve Ücretlerine İlişkin Tip Sözleşme*” (SIA-Ordnung 102), taraflarca benimsenmek suretiyle sözleşmenin içeriğine dahil edilmektedir.¹⁸²

ABD’de “*tasarım – teklif – inşaat*” şeklinde özetlenen geleneksel yapı elde etme sürecinde “*işveren ve müteahhit arasında anlaşma, sözleşmenin genel şartnamesi, sözleşmenin özel şartnamesi, sözleşmeye esas proje, sözleşmeye esas teknik şartname, ilave konular ve zeyilnameler*” şeklindeki “sözleşme belgeleri” kullanılır.¹⁸³

him KAPLAN, Türk-İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarın Sorumluluğu, Ankara, 1983, s. 24, Naklen UYAN, age., s. 20.

¹⁸¹ SCHLUEP/SCHAUB, s. 903-904; KAPLAN, age., s. 26,83 Naklen UYAN, age., s. 22.

¹⁸² UYAN, age., s.22.

¹⁸³ **Uluslararası Mimarlar Birliği** (UIA) Mimarlık Pratiği İçin Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat Metni’nin Politikalarına İlişkin Öneri Kılavuzları, “**Kodlar, Standartlar, Üretim Bilgileri, Şartnameler Ve Diğer İnşaat Dokümanları**”(UIA Mesleği Uygulama Komisyonu’nun 4-5 Nisan 2003 tarihinde Tokyo’da yaptığı toplantıda gözden geçirilmiş 28 Şubat 2003 tarihli taslaktır.) Çeviren: Aykut Ülkütekin / Arif Şentek. (www.mo.org.tr adlı web sitesinden alınmıştır.) *Amerikan Mimarlar Enstitüsü*, sözleşmelere ilişkin özel formları ve diğer standart sözleşme belgelerini yayınlamaktadır. ABD’de yaygın olarak kullanılmakta olan bu belgeler arasında, mimarın işverenle ve belirli danışmanlarla yapılacağı sözleşme formları ile inşaat yönetimine ilişkin formlar da bulunmaktadır. Uygulama olanağı bulunan yerlerde bu formlar, ülke çapında etkin bir örgüt olan *Amerika Genel Müteahhitler Birliği* ile birlikte yayınlanmaktadır. İnternette, www.aia.org/documents/home.asp. adresinden AIA dokümanları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz. AIA’dan edinilen sözleşme dokümanlarına ek olarak, çok sayıda ABD mühendislik meslek kuruluşunun ortak girişimi olan **Mühendisler Ortak Sözleşme Dokümanları Komitesi** (EJCDC) de, tasarım ve inşaat projelerinde taraflar arasında kullanılmak üzere bir dizi sözleşme dokümanı formu yayınlamaktadır. EJCDC ile ilgili bilgileri internetteki <https://ascestore.aip.org> web sitesinden alabilirsiniz. **Uyumlu İşlerlik için Uluslararası İşbirliği** (International Alliance for Interoperability – IAI) 1994 yılında kurulmuştur ve mimarlık, mühendislik, inşaat, tesis yönetimi ve benzeri diğer faaliyetler ile ilgili olarak (CAD, maliyet analizi, yapı ruhsatları, inşaat programları, işletme - bakım, vb.) bilgisayar program ve uygulamalarına ilişkin uluslararası standartların geliştirilmesini ve kullanımını desteklemektedir. IAI konseyleri, mimarlık ve

Mimarlık hizmetleri, birbirini takip eden bütünleyen, biri tamamlanmadan bir diğerrinin yapılmayacağı çeşitli aşamalarından oluştuğu için Mimarlar Odası bu sözleşmeleri “*Mimarlık Hizmetleri Tip Sözleşmesi*” (MHTS) madde 5.1 ve madde 5.2’de sayılan “standart mimarlık hizmetleri” şeklinde değerlendirerek; bir yapının gerçekleştirilmesine özgülenmiş mimarlık hizmetlerinin, tamamına yakın bir bölümünü yansıtmayı amaçlamıştır. Yine Mimarlar Odası, MHTS’nin içinde yer alabilen mimari uygulamayı kontrol hizmetlerini “*Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri Sözleşmesi*” adıyla ayrı bir sözleşme olarak düzenlemiştir. Ayrıca MHTS’nin eki olan “*Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi*” (Mim HŞEABT) madde. 2.3’te “diğer mimarlık hizmetleri”¹⁸⁴ kenar başlığı altında sayılan mimarlık hizmetleri de hesaba katıldığında, mimarlık hizmetleri kataloğu tamamlanmıştır. Ancak Mimarlar Odasının web sitesine¹⁸⁵ baktığımızda, bu çalışmanın yapıldığı dönemde bulduğumuz “Tip Sözleşme” örneği özellikle telif hakları konusunda mimarların haklarını yeterince koruma olanağı vermemektedir. Ancak Mimarlar Odasının hazırladığı yönetmelikler, şartnameler ve tarifelerde -Borçlar Hukuku konusuna giren- mimarın ve işverenin hak, yetki ve sorumluluklarının düzenlendiği çok ayrıntılı düzenlemeler bulunmaktadır. Tarafların hak, yetki ve sorumlulukları konusundaki bu düzenlemelerin incelenerek, uygun olan hükümlere; hazırlanan yeni sözleşmede ilgili yönetmelik, şartname yada tarife adı yazılarak madde olarak atıf yapılması uzun uzun ayrıntılı sözleşmeler yapma uğraşını kolaylaştıracaktır. Bu sözleşme yapma yöntemi uluslararası iş yapma yöntemlerine de uygun olacaktır. Bir başka yöntem de hazırlanan yeni sözleşmede işe özel düzenlemeleri yaptıktan

mühendislik firmaları, bilgisayar programcıları / satıcıları, malzeme üreticileri, meslek birlikleri ve kamu kurumlarını temsil eden üyelerden oluşmaktadır. IAI’nın Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya’da faaliyet gösteren şubeleri bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgiyi IAI’nın internetteki www.iai-international.org sitesinden alabilirsiniz.

¹⁸⁴ “Mim HŞEABT md. 2.3’te sayılan “diğer mimarlık hizmetleri”, 2.3.1: program hazırlığına katılmak, 2.3.2: özel araştırma ve çalışmalar, dosya hazırlanması ve işlem takibi gerektiren işlerin yapılması, 2.3.3.: yapılabirliklik (fizibilite) çalışmaları, 2.3.4: genel yüklenicisi olmayan yapılarda şantiye koordinasyonu ve planlanması, 2.3.5: inşaat yönetimi, 2.3.6: karşılaştırmalı keşif hazırlanması, 2.3.7: röleve, restorasyon ve restitüsyon çalışmaları, 2.3.8: sanat eseri seçimi, 2.3.9: iç mekan düzenlemesi ve mobilya tasarımı, 2.3.10: çevre düzenleme, 2.3.11: kentsel tasarım hizmetleri, 2.3.12: maket çalışmaları ve 2.3.13: bilirkişilik-hakemlik hizmetlerinden oluşmaktadır.” Naklen UYAN, age., s. 20.

¹⁸⁵ <http://mo.org.tr/mevzuatdocs/1.tipsozlesme.doc>

sonra “işbu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde UIA, TMMOB ve Mimarlar Odasının çıkardığı yönetmelik, şartname ve tarifelerdeki hükümler geçerlidir” şeklinde atıf yapılmasıdır. Fakat bu durumda hangi maddedeki düzenlemenin işe uygun olup olmadığı öngörülemez olduğundan aleyhe olan birçok hükmün taraflara uygulanmasına seyirci kalınabilir.

MHTS’de belirtilen standart mimarlık hizmetleri incelendiğinde; mimarlık hizmetlerinin “mimari proje hizmetleri”¹⁸⁶ (madde 5.1) ve “uygulama denetimi hizmetleri”¹⁸⁷ (madde 5.2) olmak üzere iki ana gruba ayrıldıkları görülecektir. Buna göre; mimar ile yapı sahibi arasında yapılan mimarlık sözleşmesi, standart mimarlık hizmetlerinin tümünü kapsayabileceği gibi, her iki grup mimarlık hizmetleri için ayrı birer sözleşme yapılarak yapı sahibi, mimarlık hizmetlerini ayrı mimarlara devredebilir yada tüm mimarlık hizmetlerini tek bir mimara da yaptırabilir. Buna göre, her somut yapı faaliyetinde mimarlık sözleşmelerinin konuları birbirinden farklı olabilmektedir.¹⁸⁸

C. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE KURULMASI

Bir nevi iş görme sözleşmesi niteliğinde olan mimar ve yapı sahibi arasındaki mimari proje düzenleme sözleşmesinde BK madde 11/1 uyarınca şekil serbestisi bulunmaktadır. Taraflar istekleri doğrultusunda sözleşmeyi yazılı veya sözlü olarak kurabileceklerdir. Sözleşmenin geçerli olup olmaması açısından bir şekil şartı aranmamaktadır. Ancak mimar ile yapı sahibi kendi aralarında BK madde 16¹⁸⁹ çerçevesinde yapacakları

¹⁸⁶ “MHTS Md. 5.1’de sayılan “mimari proje hizmetleri”, A: hazırlık ve ön etüd çalışmaları, B: ön proje çalışmaları, C: kesin proje çalışmaları, D: uygulama projesi çalışmaları (D-1: uygulama projeleri, D-2: sistem detayları, D-3: imalat detayları, D-4: teknik şartnameler, D-5: metraj, keşif, maliyet etüdü ve E: ihale çalışmalarından (E-1: ihale belgelerinin hazırlanması, E-2: ihalenin yapılması) oluşmaktadır.” Naklen UYAN, age., s. 20.

¹⁸⁷ “MHTS Md. 5.2’de sayılan “uygulama denetimi hizmetleri”, E-1: mesleki kontrollük hizmetleri, E-2: fenni mesuliyet hizmetleri (TUS), E-3: yapıldı projesi-orijinallerinin teslimi, E-4: kesin hesaplar ve F: kabul – teslim hizmetlerinden oluşmaktadır.” Naklen UYAN, age., s. 20.

¹⁸⁸ KAPLAN, age., s. 24.

¹⁸⁹ Borçlar Kanunu md. 16: İki taraf kanunen hususi bir şekle tabi olmayan bir akdin hususi bir şekilde yapılmasını kararlaştırmışlar ise, akit takarrür eden şekilde yapılmadıkça iki taraf bununla ilzam olunamaz.

sözleşmeyi özel bir şekil şartına bağlayabilirler. Bu kararlaştırılan şekil şartı ispat şartından daha çok bir geçerlilik şartıdır. Ayrıca ispat açısından, ileride çıkabilecek uyuşmazlıkları göz önünde tutarak tarafların işbu sözleşmeyi yazılı olarak yapmaları en isabetli yoldur. Hem bu şekilde sözleşme dahilinde olan belirsizlikleri de ortadan kaldırmış olacaklardır. Örneğin bir çok yapı türü bakımından düzenlenmesi zorunlu olmayan kesin projenin, somut sözleşme içeriğine dahil olup olmadığı konusundaki belirsizlik ortadan kaldırılabilir.¹⁹⁰

Mimar ile yapı sahibi arasında kurulan bu sözleşme tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerden olduğu için BK madde 1’de belirtildiği gibi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile kurulmaktadır. Fakat mimari proje düzenleme sözleşmesinde sözleşmenin “ön görüşme” aşaması yaşanır. Ön görüşme aşamasından sonra çıkacak metin sonucu bir taraf “ıcap”ta bulunur ve diğer taraf “kabul” beyanında bulunur ve bu şekilde sözleşme kurulur. Mimari projenin düzenlenen sözleşme şartlarına uygun olabilmesi için; projenin, yapı sahibinin ileride gerçekleştirecek yapıya ilişkin talep, ihtiyaç ve imkanlarını doğru yansıtacak şekilde hazırlanması ve dolayısıyla mimari projeye ilişkin bu verilerin esas itibarıyla sözleşmede belirginleşmiş olması gerekmektedir.

Bu şekilde bir sözleşmenin kurulabilmesi için; öğreti¹⁹¹ ve mahkeme içtihatlarında¹⁹² kabul edildiği üzere, sözleşme görüşmeleri aşamasında taraflar arasında güven esasına dayalı bir hukuki ilişki kurulmalı ve taraflar bu ilişkide dürüstlük kuralına uygun davranmalıdırlar.¹⁹³ Buradaki dürüstlük kuralına uygun davranma borcu kapsamına; karşı tarafın hataya düşmesi halinde uyarma, aldatıcı davranışta bulunmama, gerekli bilgilerin karşı tarafa verilmesi girmektedir. Aksi halde sözleşme kurulmuş olsa da

İki taraf muayyen bir surette keyfiyeti izah etmeyerek tahriri şekilden bahsetmiş oldukları takdirde, kanun bu şekle riayet olunmasını emrediyorsa, iki tarafın ona riayet etmesi lazımdır.

¹⁹⁰ HESS Urs, “Der Architekten-und Ingenieurvertrag”, Zürich, 1986, s. 32. Naklen UYAN, age., s. 26.

¹⁹¹ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N. 948; SCHWENZER Ingeborg, “Schweizerisches Allgemeiner Teil” Berb 2000, s. 281-282; OĞUZMAN M. Kemal/ÖZ M. Turgut, “Borçlar Hukuku Genel Hükümler”, İstanbul 2000, s. 311 vd.; TEKİNAY/AKEREN Fikret, “Borçlar Hukuku Genel Hükümleri” İstanbul, 2001, s. 1116 vd.

¹⁹² BGE 105 II 79; 116 II 698; 120 II 336 Naklen UYAN, age., s. 27.

¹⁹³ UYAN, age., s. 27.

olmasa da; kusurlu davranış sergileyen taraf, karşı tarafın bu nedenle uğradığı zararı *culpa in contrahendo* (sözleşme görüşmesinde kusurlu davranış) sorumluluğunun bir gereği olarak tazmin etmek zorunda kalacaktır.¹⁹⁴ MHTS madde 5.1'deki “*standart mimarlık hizmetleri*” arasında yer alan ve mimar ile yapı sahibi tarafından birlikte gerçekleştirilecek olan hazırlık ve ön etüt çalışmaları,¹⁹⁵ uygulamada, sözleşme için görüşme ilişkisi aşamasına karşılık gelmekte ve mimarın bu kapsamda gerçekleştireceği hizmetler için bir ücret ödenmemektedir. Mimar, mimari sözleşme çerçevesinde yapı sahibine bir öngörü kazandırmak amacıyla yapı maliyet tabanını hesabı hariç olmak üzere eskiz çalışmaları (tasarım) yapacaktır. Bu eskiz çalışmaları fikir projesi niteliğindedir. Fikir projesi, estetik yapı yapma amacıyla olan mimar için yapı sahibine karar verme ve seçme özgürlüğünü verme açısından bir zorunluluk oluşturmaktadır.

Uygulamada genel itibarıyla; yapı sahibinin mimara bir icapta bulunması üzerine, kabul iradesiyle bir ön proje düzenleyip, yaklaşık yapı maliyetini hesaplayan mimar; proje yapı sahibince uygulamaya koyulsun veya koyulmasın, kararlaştırılan veya tarifelere göre tespit edilecek bir ücret istemek hakkına sahiptir.¹⁹⁶

TMMOB tarafından 22.12.2006 tarihinde kabul edilen “*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az (Asgari) Bedel*”¹⁹⁷ Tarifesi (Mim HŞEABT) madde 9 gereğince mimara yapılan ödeme şekilleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

¹⁹⁴ GAUCH/SCHLUEP/SCHMID/REY, N. 963 vd Naklen UYAN, age., s. 27.

¹⁹⁵ UYAN, age. s. 23-24.

¹⁹⁶ KAPLAN, age., s. 20 Naklen UYAN, age., s. 29.

¹⁹⁷ Mim-Müh HAÇDEY ve Mim HŞEABT¹⁹⁷ gereğince **Asgari Ücret**; her türlü mimarlık mühendislik hizmetlerinin, yürürlükteki kanun ve yönetmelikler uyarınca yapılabilmesi için TMMOB ve bağlı odalarca tespit ve ilan olunan ve 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 27 nci maddesinin 5 inci bendi uygulamalarına da esas en az ücretleridir. Mim HŞEABT gereğince **birim maliyet (BM)**; yapının, birim ölçüsünün (binalarda birim alanının), Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca her yıl mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetlere (birimi YTL/m²dir) denir. **Yapı yaklaşık alanı (YYA)**; mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin yapıldığı yapının ön proje, ihtiyaç programı, tapu, çap gibi ilgili belgelerden hesaplanan yaklaşık brüt alanıdır. **Yapı yaklaşık maliyeti (YYM)**; mimarlık ve mühendislik hizmetleri ücretlerinin hesabına temel olan ön kâbuldür. Yapı yaklaşık alanının, birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değerine (birimi YTL olarak hesaplanır) denir.

Sabit bedel olarak : Mimarın gerçekleştireceği hizmetlerin kapsamı, yapının programı ve niteliği (sınıfı) sözleşme aşamasında teknik, hukuki ve idari işlemler bakımından tam ve değişmeyecek şekilde belirlenmiş ise ve iş aynı yıl içerisinde yapılıyorsa mimarlık hizmetlerinin karşılığı Mimara "Sabit Bedel" olarak ödenir. Bu durumda mimarın yapacağı iş aşamalarının parasal karşılığı hesaplanarak sözleşmeye yazılır.

Mimara yapılacak ödemelerin "Sabit Bedel" olarak yapılmasının sözleşme ile belirlenmesinden sonra işin yapılması koşullarında değişiklik olması durumunda mimarın hizmet bedeli de aşağıdaki maddelere ve Mim HŞEABT madde 9-7 hükmüne göre değiştirilir.

Yapının maliyetine orantılı olarak : Yalnızca mimarın gerçekleştireceği hizmetlerin belirli olması ve yapacağı işin programının belirsiz olması durumunda mimarın hizmetlerinin karşılığı "*Yapı Maliyetine Oranlı*" belirlenerek ödenir. Bu durumda;

a- Mimarın her iş aşaması karşılığı hakedişi Yapı Maliyet Tavanı belirleninceye kadar, işin başında hesaplanan Yapı Yaklaşık Maliyeti üzerinden ödenir.

b- Yapı Maliyet Tavanı'nın belirlenmesi ile o ana kadar mimara her iş aşaması karşılığı yapılan ödemelerin tutarları hesaplanır ve farkları mimara hemen ödenir ya da müteakip hakedişinden düşülür.

c- Mimar ile işveren/iş sahibi; mimara ödenecek hizmet bedellerinin inşaatın tamamlanmasından sonra belirlenebilecek "Yapı Kesin Maliyeti"ne göre hesaplanmasında anlaşma yapabilirler.

Masraf Karşılığı + Kâr olarak : Mimarın gerçekleştirileceği hizmetlerin ve yapacağı işin programının belirli olmaması durumunda mimarın hizmetleri "Masraf Karşılığı + Kâr" olarak ödenir. Ayrıca, mimar tarafından yapılacak çalışmaların yapılan işin maliyeti ile kıyaslanamayacak olduğu durumlarda örneğin; mimarın önemli ve uzun süre çalışma yapmasını gerektiren düşük maliyetle yapılan bir tadilatla mimara hakedişi "masraf karşılığı+ kâr" olarak hesaplanarak ödenir. Bu durumda;

a- Mimarın kendisinin ve beraber çalıştığı diğer mimar ve teknik elemanların, uzmanların ücretleri çalışılan süre boyunca,

b- "a" maddesinde yazılı olanların sosyal hakları, vergileri vb. çalışılan süre boyunca,

c- Mimarın veya bürosunun genel giderlerinin bu işe düşen payı,

d- Bu işle ilgili yolculuk ve ikame masrafları,

e- Mimarın veya bürosunun karı,

f- Bu işle ilgili yapılan diğer çalışmalar Mim HŞEABT 9-4 ve 9-5 maddelerde yazılı esaslara göre ödenir.

Bu şekilde bedelin hesaplanmasında zorluk çıkarsa; a, b, c, d, e, maddesindeki bedellerin toplam karşılığı, a ve b maddesindeki bedellerin toplamının 5 katı olarak belirlenir.

Yevmiye bedeli olarak: İş sahibi, mimar'dan sözleşme dışında bazı çalışmalar yapmasını ya da iş ve işlemleri yerine getirmesini isteyebilir. Mimar bu çalışmaları yapmayı kabul ederse bu hizmetlerin karşılığı mimara "yevmiye" esasına göre ödenir. Mimara yevmiye esasına göre yapılacak ödemeler sürenin (saat olarak) yevmiye bedeli ile çarpılması şeklinde hesaplanır. Süre, mimarın kendisinden istenen işi yapmak üzere geçirdiği süredir. İş mimarın bürosu dışında yapılıyorsa, bu süreye o işi yapmak üzere işin yapıldığı yere ulaşım süresi ilave edilir. Geçirilen saatler tama tamamlanır. Yevmiye bedeli, Mimarlar Odasının yürürlükteki en az bedel tarifesindeki “*Yapı Birim Maliyetleri Tablosu*”ndan 4-C grubu m² bedelinin 1/10’u olarak hesaplanacaktır.

Mimara yapılacak ödemeler yukarıda yazılı şekillerden birkaçının birlikte uygulanması ile olabilir. Mimarın, üstlendiği mimarlık hizmetlerinin tam olarak yerine getirilmesi için yaptığı masrafları talep etme hakkı saklıdır.

Hizmetlerin artması : Mimarın sözleşme ve şartname ile belirlenmiş hizmetlerinde ya da üstlendiği sorumluluklarında, iş programının şartnamenin 17-1-d maddesinde yazılı belgelerin, iş sahibinin ya da onay ve izin veren mercilerin isteği üzerine, zorunlu nedenlerle yada yönetmelik değişikliği nedeniyle kısmen ya da tamamen değişiklik olması durumunda, bu hizmet ve sorumluluk artışı karşılığı bedel hesaplanarak sözleşme bedeline ilave edilir.

Hizmet bedellerinin güncelleştirilmesi : Mimarın hakedişleri hizmetin yapıldığı yılda geçerli ücret tarifi üzerinden hesaplanır.

K.D.V. Yasası'na uymak : Serbest meslek hizmeti olan mimarlık hizmetleri K.D.V. Yasasına tabidir. Mimara yapılan her türlü ödemeye bu yasanın öngördüğü K.D.V. bedeli ilave edilir.

“*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifi*” (Mim HŞEABT) madde 10’a göre; mimarlık hizmetleri karşılığı mimara yapılacak ödemeler aşağıdaki formüle uygun olarak hesaplanır :

Mimarlık	Yapı	Yapı	Yapı Alanı	Hizmet	Hizmet	İhtisas
Hizmeti	= Birim	X	Alanı X Sınıf Ücret	X	Bölüm X Dalı	X
Bedeli	Maliyeti		Oranı	Oranı	Oranı	Katsayısı X d X z

TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi Ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi Ve Ücret Tarifesi”nde madde 5’den itibaren içmimari hizmetleri, dekorasyon ve mobilya tasarımı için mimara ödenecek ücretler benzer şeklide düzenlenmiştir.

D. SÖZLEŞMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Mimarlık sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Çünkü tek bir mimarlık sözleşmesi tipi yoktur. Mimari proje düzenleme sözleşmesi ise; tüm mimarlık hizmetleri içinde sadece mimari proje düzenleme hizmetlerini konu edilen mimarlık sözleşmesi şeklindedir. Bu sözleşmenin içindeki hizmetler; ön proje ve kesin projenin tasarlanması, uygulama ve detay planlarının hazırlanması ile yapı maliyet tavanının hesaplanmasından oluşmaktadır.

Mimari proje düzenleme sözleşmesinin hukuki niteliği konusunda öğreti ve Yargıtay kararları doğrultusunda değerlendirme yaparak sonuca varmak en makul çözüm yoludur.

Hukuki niteliği belirlemek için Borçlar Kanunu’nda yer alan sözleşme tiplerine göz attığımızda; iş görme sözleşmesi ile mimari proje düzenleme sözleşmesinin özelliklerinin benzediğini görmekteyiz. Öyle ki iş görme sözleşmelerinde; borçlunun bağımsız olarak iş görmesi veya iş görme alacaklısının talimatı ile bağlı olması, bir takım iş görme edimlerinin özel bir güven ilişkisi gerektirmesi, iş görme ediminin belirlenebilir olması ve nesnel olarak incelenmesi imkanının bulunması, bir takım iş görme edimlerinin önceden planlanmayı gerektirmesi ve yine bir takım iş görme edimlerinin ifası bakımından zaman etkeninin önem taşıması, iş görme edimlerinin esas itibarıyla kişisel olarak ifa edilmesi ve belirli iş görme edimlerinin bir iş örgütlenmesi yoluyla ifayı gerektirmesi, belirli iş görme edimlerinin maddi bir iş görme sonucu oluşturmaya yönelik olması (kişisel borç niteliğindeki belirli iş görme borçlarının maddi bir borç ile bağlantısının bulunması) ve iş görme ediminin, ivazlı veya ivazsız olarak ifa edilmesi şeklindeki ölçütler; mimari proje düzenleme sözleşmesinin eser veya vekalet türünde bir iş görme sözleşmesi olduğunu ortaya koymaktadır.

Yapılan bu ön açıklamadan sonra konuyu daha önce bahsettiğimiz gibi öğreti ve Yargıtay kararları ışığında değerlendirelim.

Mimarlık projeleri bir “eser” olduğundan, mimarlık projeleri sözleşmeleri de “eser sözleşmesi”dir. Eser kavramının kapsamı ve eser sözleşmesi hakkındaki öğreti görüşleri gerçekten enteresandır.

Göktürk, “...eser, icabına göre bazen (yapılar, bir binanın veya tadili veyahut yıkılması, bir elbisenin dikilmesi, bir aletin veya herhangi maddi bir şeyin imali kabilinden) maddi bir şey olabileceği gibi, bazen de (bir duvar tezniyatı veya resimleri, bir binanın veya herhangi bir yapının planlarının veya hesaplarının yapılması, bir keşif veya ihtirada bulunulması veyahut bir yol veya sistem ve usul vazedilmesi, ilanlar basılması kabilinden) gayri maddi bir kıymet veya mahiyet arzedebilir.”¹⁹⁸ diyerek fikri bir iş görme sonucunun eser sayılabilmesi için maddi bir varlığa dönüşmesini şart koşturmaktadır.

Bilge ise; eser sözleşmesinin konusunu oluşturan eseri, “insan emeğinin mahsulü olup, hukuki bir bütün olan ve iktisadi değer taşıyan maddi ve manevi (fikir) her şey”¹⁹⁹ olarak tarif etmektedir. *Olgaç* da aynı görüştedir.²⁰⁰

20.5.1966 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararını izleyen ve günümüze kadar süregelen zaman dilimine bakıldığında, eser kavramının kapsamına ilişkin olarak öğretide farklı görüşlerin ileri sürüldüğü görülmektedir.²⁰¹ Buna karşın, Türk Hukuk öğretisinde hakim olan görüş, maddi olmayan iş görme sonuçlarının da eser sözleşmesinin konusunu oluşturacağı yönündedir. Öğretide, *Tunçomağ*, *Aral ve Zevkliler/Aydoğdu/Petek* eser kavramının, herhangi bir hukuki varlıkta cisimleşmemiş olan geçici

¹⁹⁸ Hüseyin Avni GÖKTÜRK, “Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri”, Ankara, 1951, s. 497.

¹⁹⁹ Necip BİLGE, “Borçlar Hukuku Dersleri- Hususi Borç Münasebetleri”, Ankara, 1958, s.176. Yazar, bu eserin son basısında da aynı görüşü tekrarlamaktadır. Bkz. BİLGE Necip, “Borçlar Hukuku Özel Borç Münasebetleri”, Ankara, 1971, s. 245-246.

²⁰⁰ Senai OLGAC, “İstisna Akdi-Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri (VI)”, İstanbul, 1966, s. 446.

²⁰¹ HGK E. 1966/161 K. 165, ABD. 1967, s. 1050 “bir şarkıcının konser verme taahhüdünü eser sözleşmesi olarak kabul edilmesi” Naklen UYAN, age., s. 84.

nitelikteki bütünsel fikir ve iş görme sonuçlarını da kapsayacak genişlikte olduğu görüşünü savunmaktadırlar.²⁰²

Tandoğan ise; daha önce maddi iş görme sonuçları yanında maddi olmayan iş görme sonuçlarının da eser kavramının kapsamına girdiğini ileri süren²⁰³ görüşünü terk etmiş ve eser sözleşmesinin konusunu yalnızca maddi iş görme sonuçlarının oluşturduğu görüşünü benimsemiştir. Yazara göre, Türk hukuku bakımından fikri eser sözleşmesinin kabulü isabetli değildir.²⁰⁴ *Hatemi* de, eser sözleşmesinin konusunun yalnızca maddi bir iş görme sonucu olabileceğini belirtmektedir.²⁰⁵

Türk hukukunda mimarlık sözleşmesi hakkında yayınlanmış olan incelemelere baktığımızda, mimari proje düzenleme sözleşmesinin hukuki niteliği hakkında iki ayrı görüşün ileri sürüldüğü görülmektedir. *Kötelî* ve *Çakalır*'a göre, mimari proje düzenleme sözleşmesi bir vekalettir.²⁰⁶ Buna karşın, *Kaplan* ve *Seliçi*, eser sözleşmesi görüşünü savunmaktadırlar.²⁰⁷

Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 20.9.1976 tarihli kararında²⁰⁸, davalı yapı sahibi Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davacı mimar M.G. arasında yapılan ve konusu Ayvalık'ta 1000 ton kapasiteli bir sabunhane projesinin düzenlenmesi olan mimari proje düzenleme sözleşmesi incelenmiştir. Mimari proje düzenleme sözleşmesinin bir eser sözleşmesi olduğunun ifade edildiği kararda, bu sözleşmenin neden bir eser sözleşmesi olarak nitelendirildiğine ilişkin ise hiçbir açıklamada bulunulmamıştır.

²⁰² Kenan TUNÇOMAĞ, *Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, C.2, İstanbul, 1977, s. 953-954; Fahrettin ARAL, *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri*, Ankara, 2000, s. 328; ZEVLİLİLER/AYDOĞDU/PETEK, *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi*, Ankara, 2001, s. 321-322, Naklen UYAN, age., s. 85.

²⁰³ Haluk TANDOĞAN, "İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayırt Edilmesi-İmran Öktem'e Armağan", Ankara, 1970, s. 318.

²⁰⁴ Haluk TANDOĞAN, *Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi*, C.2, Ankara, 1987, s. 9 v.d. Yazar; "maddi bir şeyde tecessüm etmeyen fikir, sanat veya spor çalışmalarına istisna akti değil, vekaletle ilişkin hükümler uygulansın,.. çalışma sonucunun maddi olarak biçimlendiği hallerde fikri istisna sözleşmesi mümkündür" demektedir.

²⁰⁵ HATEMİ /SEROZAN /ARPACI, "Borçlar Hukuku Özel Bölüm", İstanbul, 1992, s. 353

²⁰⁶ Mustafa Argun KÖTELİ, *Mimarlık Sözleşmesi*, 1985, İstanbul, s. 117; Yalçın ÇAKALIR, *Mimarlık Sözleşmesi*, Ankara, 1976, s.21.

²⁰⁷ KAPLAN, age., s.82; Özer SELİÇİ, "Mimarlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-Temsil ve Vekaletle İlişkin Sorunlar", İstanbul, 1977, s. 275 Naklen UYAN, age., s. 85.

²⁰⁸ 15. HD., 20.9.1976, E.1976/2108 K. 1976/3038, YKD. 1978, s.423 VD Naklen UYAN, age., s.86. (Yargıtay Kararları No: 2)

Ancak Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 22.11.1976 tarihli kararında²⁰⁹ proje düzenleme sözleşmesinin bir eser sözleşmesi olduğu görüşünü “*çalışmanın ilk kesiminde mühendis, geometri biliminin ve tekniğinin verilerinden yararlanarak bir tasarı yapmakta ve işverene kesinkes bağlı olmaksızın bir yapıt (eser) oluşturmakta, diğer bir deyimle yapının projesini çizmektedir. Bu proje, bilimsel ve tekniksel biçimde onu çizenin tüm özelliklerini taşıyan bir yapıt (eser) sayılmalıdır*” şeklinde gerekçelendirmiştir.

Mimar ve işveren/iş sahibi²¹⁰ arasındaki ilişkinin güvene dayalı nitelikte birden fazla edimi içeren bir ilişki olduğunu belirtmiştik. Mimarın edimleri içinde olan ön proje, kesin proje, mimari uygulama projesi ve her bir detay planı bize göre de bağımsız birer eser sözleşmesi niteliğindedir. Bu anlamda mimari proje düzenleme sözleşmesini de ardarda teslimler içeren kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olarak kabul edebiliriz.

İşveren veya yapı sahibi, mimara yaptığı bu işlerin karşılığında uygun bir bedel verme borcu altına girecektir.

Bazı durumlarda tarafların bu klasik asli yükümlülüklerinin haricindeki borçları sözleşmenin hukuki nitelendirilmesine bağlı olarak farklı sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Örneğin; mimarın proje düzenleme sözleşmesi gereğince düzenlenmiş olduğu yazılı ve çizili belgelerden biri, teslimden önce kaza sonucu yok olursa, mimar bakımından kusursuz ifa imkansızlığı ortaya çıkacak ve onun yok olan belgeye ilişkin bu borcu, BK madde 117/1 gereğince sona erecektir.²¹¹ Ancak, meydana gelen hasarın mimara mı yoksa yapı sahibine mi ait olacağı sorusunun çözümü, taraflar arasındaki borç ilişkisinin hukuki nitelendirmesine bağlı olarak belirlenecektir. Eser sözleşmesinin varlığı halinde; zarara, BK madde 117/2 c.1 ve BK madde 368/1 gereğince mimar katlanacak, yani yapı sahibine karşı bir ücret talebinde bulunmayacaktır.²¹² Vekaletin varlığı halinde ise, BK madde 394/2 gereğince, kazaen yok olan belgenin hasarına yapı sahibi katlanacak ve söz konusu hükme göre, mimar yok olan belgeye karşılık

²⁰⁹ 10 HD., 22.1.1976, E.1975/4935 K. 1976/1294, YKD. 1976, s.678 VD Naklen UYAN, age., s.86. (Yargıtay Kararları No: 1)

²¹⁰ MHDY, **iş sahibini**, serbest mimarla sözleşme yapan, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerle, kamu tüzel kişileri, kamu kurum ve kuruluşları olarak ifade etmektedir. Mim-Müh HAÇDEY gereğince **İşveren**; mimarlık mühendislik hizmetlerini yaptracak kişi, kurum ve kuruluşlarını ifade eder.

²¹¹ UYAN, age., s.159.

²¹² YAVUZ, age., s. 461.

gelen ücretini yapı sahibinden talep edebilecektir.²¹³ Genel itibarıyla aradaki nitelendirme farkı çok önemli değildir. Çünkü günümüzde mimarlar, düzenlemiş oldukları yazılı ve çizili belgeleri, bu gibi ihtimallere karşı çeşitli yöntemlerle düzenli olarak kopyalamaktadırlar. Diğer yandan, yok olmuş olan bir projenin ikinci kez düzenlenmesi, ilkinde nazaran daha az bir çabayı gerektirmektedir.²¹⁴

Sadakat borcu konusunda ise; vekalet sözleşmesi ya da eser sözleşmesinin tarafı mimar arasında bir fark bulunmamaktadır. Her ikisi de üstlenmiş oldukları işi sadakatle yürütmek zorundadırlar. Ancak vekilin (vekalet sözleşmesinin tarafı olan mimarın) sadakat borcunun bir uzantısı olarak; bilgi verme ve aydınlatma borcu da bulunmaktadır. Ayrıca borç ilişkisinin karşı tarafı olan işverenin menfaatini korumak ve bu menfaate zarar verecek davranışlardan kaçınma borcu da bulunmaktadır. Aynı borçlar eser sözleşmesi için de geçerlidir.

E. MİMAR VE İŞVEREN ARASINDAKİ İLİŞKİ VE ÇEŞİTLİ NEDENLERLE SONA ERMESİ

Borçlar Hukuku kapsamındaki mimar ve işveren arasındaki hak, yetki ve sorumluluklar açısından taraflar sözleşme koşullarını serbestçe düzenleyebilirler. Ancak uluslararası alanda olduğu gibi taraflar; işin konusunu, ücret ve süre gibi ana konuları düzenleyip diğer konularda Uluslararası Mimarlar Birliği'nin (UIA) Mimarlık Pratiği İçin Tavsiye Edilen Uluslararası Profesyonellik Standartları Konusunda UIA Mutabakat Metni'nin Politikalarına İlişkin Öneri Kılavuzları, Kodlar, Standartlar, Üretim Bilgileri, Şartnameler ve Diğer İnşaat Dokümanları gibi uluslar arası belgelere yada TMMOB ile Mimarlar Odası'nın çıkardığı yönetmelikler, şartnameler yada tarifelerdeki özel olarak yapılan düzenlemelere genel olarak veya belirli maddelere atıf yapabilirler. Eğer taraflar arasında bir uyumsuzluk olursa, uyumsuzluk atıf yapılan maddedeki düzenleme çerçevesinde çözülecektir. Şimdi bu açıklama doğrultusunda mimar işveren ilişkilerini düzenleyen Mimarlar Odasının dokümanlarına bakalım.

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği

²¹³ YAVUZ, age., s. 618.

²¹⁴ Daniel TRUMPHY, Architektenvertragsstypen, Zürich, 1989, s.23 Naklen UYAN, age., s.160.

(MHDY)” madde 15 de mimarların görev, hak ve sorumlulukları şöyle sıralanmıştır²¹⁵;

²¹⁵ Benzer şekilde TMMOB tarafından 22.12.2006 tarihinde kabul edilen “**Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi**”nde madde 16 da mimarın genel olarak görev, hak, yetki ve sorumlulukları şu şekilde sayılmıştır;

- a. Mimarlık mesleğinin uygulanmasında mimar toplum içinde meslek topluluğunun temsilcisi durumundadır ve yürürlükteki mimarlıkla ilgili tüm yasa, tüzük, yönetmelik, şartname ve standartlar ile Mimarlar Odası'nın mimarlık mesleğinin uygulanmasına ilişkin kararlarına uymak ve mesleki çalışmalarını Mimarlar Odası'nın mesleki denetimine sunmak zorundadır.
- b. Mimar, projenin Türk Standart ve normlarına, Mimarlar Odası Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartlarına, yürürlükteki şartnamelere, yönetmeliklere, yasalarla ön görülmüş hususlara uygun olarak yapılmasını ve yürütülmesini sağlamakla yükümlüdür.
- c. Mimar, serbest mimarlık hizmetleri ile ilgili olarak, hizmetin başlamasından önce iş sahibi ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Mimarlar Odası'na hazırlanmış tip sözleşmedeki asgari koşulları kapsar. Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve en az bedel tarifesi serbest mimarlık hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.
- d. Mimar, bir yapıyı "eser sahibi" olarak tasarlar ve yapımını denetler. Eserinin tam ve mükemmel olarak gerçekleştirilmesini gözetir, eksiksiz ve kusursuz olarak iş sahibine tesliminden sorumludur.
- e. Mimar, 5846 Sayılı "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası" hükümlerine göre ve mimarlık mesleğinin genel tanımı ve uygulaması çerçevesinde gerçekleştirdiği plan, proje, resim, her türlü tasarım ve maketin ve bunlara dayanılarak gerçekleştirilen yapıların telif haklarına sahiptir ve bunların ne şekilde çoğaltılacağına ve yayınlanacağına kendisi karar verir.
- f. Telif hakkını kazanmış olan mimar, iş sahibi tarafından onaylanan ön projeden sonraki geri kalan tüm iş aşamalarını yapmaya hak kazanır.
- g. Mimar, müellifi olduğu yapıyı imzalamaya hak kazanır. Bir yapıyı müellifinden başkası imzalayamaz.
- h. Telif hakkı, mimarların hazırladığı projelerin alenileşmesi ile kazanılır.
- i. Telif hakkı her ne koşulda olursa olsun, mimarın kendisi tarafından dahi bir başkasına devredilemez.
- j. Mimarın meydana getirdiği eserin koruma süresi mimarın yaşadığı sürece ve ölümünden sonra 70 yıl devam eder. Bu hak ölümünden sonra yasal varislerince korunur.
- k. Mimar, telif hakkını kazandıktan sonra, dilerse sözleşmede belirtilmiş iş aşamalarının bir kısmını ya da tamamını ve diğer mimarlık hizmetlerini yetkilendireceği yada vekil tayin edeceği bir mimar'a yaptırabilir. Bu durumda tayin ettiği vekilin ücretini mimar öder. Bunları başkasına yaptırmış olması Mimarı bu çalışmalarla ilgili mesleki sorumluluklarından kurtarmaz.

a) Mimar, bu Yönetmelik kapsamına giren tüm serbest mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odasının mesleki denetimine sunmakla yükümlüdür. Mimarın bu yükümlülüğü iş sahibinin, ilgili idarenin, inşaat ve kullanma izni veren mercilerin Mimarlar Odası mesleki denetimini istemesi durumunda da ortadan kalkmaz.

b) Mimarın kendisine tanınmış görev, hak ve sorumlulukları Mimarlar Odası dışında başka bir kuruluş tarafından sınırlanamaz ve kısıtlanamaz.

c) Mimar, bu Yönetmelik kapsamında olan serbest mimarlık hizmetleri ile ilgili olarak, hizmetin başlamasından önce iş sahibi ile sözleşme imzalamak zorundadır. Bu sözleşme; işin kapsamı, süresi, aşamaları, bedeli ve karşılıklı haklar konularında Mimarlar Odasınca hazırlanmış tip sözleşme-deki asgari koşulları kapsar. Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesini serbest mimarlık hizmetleri sözleşmesinin ayrılmaz eki sayılır.

d) Mimar, işvereni ile imzalayacağı sözleşme ve sunacağı serbest mimarlık hizmetlerini;

1) Bu Yönetmelik hükümlerine,

-
- l. Bir iş aşamasını başkasına devreden mimar, iş sahibine bilgi vermek ve onayını almak zorundadır.
 - m. İş aşamalarının bir kısmını yada tamamını devralan mimar, devreden mimarın talimatlarına uymak zorundadır.
 - n. Eser bir kaç mimar tarafından gerçekleştiriliyorsa, telif hakkı ortaktır. Ortak mimarlardan her biri yukarıdaki haklardan yararlanır. Ancak, ortak çalışan mimarların her birinin ayrı ayrı oluru ile telif hakkı ortaklardan birisine verilebilir.
 - o. Mimar tarafından yapılmış tasarım, çizim, yazılı belgelerin orijinaleri mimar'da kalır. Mimar uygun görmediği takdirde bunları teslim etmez.
 - p. Mimar, tasarımı ve uygulama denetimini yapmak üzere yardımcı mimarları, mühendisleri ve diğer uzmanları tayin etmek ve görevlendirmek yetkisine sahiptir ve bunların çalışmalarından sorumludur.
 - q. Bir işi birden fazla mimar üstlenmişse, bunlar mimarlık hizmetlerini ve ücretleri aralarında diledikleri şekilde paylaşmakta serbesttirler. Aralarından birisinin aczi yada ölümü nedeniyle, Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi feshedilemez; diğerleri çalışmaları tamamlar.
 - r. Mimar, ağır bir hastalık ve ölüm yada bir başka nedenle mesleki çalışmalarını yürütmeyecek duruma kalırsa, bu hizmetleri kendisinin yada mirasçılarının belirleyeceği bir başka Mimara devretmek hakkına sahiptir. Gerekğinde bu hak ve yetkiyi iş sahibine iade edebilir.

2) Mimarlar Odası Mimarlık Mesleğini Uygulama, Mimarlar Arası Dayanışma, Mimarlık Şeref ve Haysiyetini Koruma Yönetmeliğine,

3) Mimarlık hizmetleri şartnamesi ve ücret tarifesi hükümlerine,

4) Zorunlu standart ve normlara,

5) Genel olarak bilinen fen ve yapı sanatı kurallarına,

6) Mimari proje çizim ve sunuş standartlarına,

7) Mimarlar Odasının serbest mimarlık hizmetleri sunulması ile ilişkili kanunlar, yönetmelikler çerçevesinde belirlediği esaslara,

göre yürütmekle yetkili, yükümlü ve bundan dolayı sorumludur.

e) Tescile esas bilgi ve belgelerin Mimarlar Odasına verilmesi aşamasında gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları saptanan, serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi üzerinde herhangi bir değişiklik yapan ve bu Yönetmeliğe göre mesleği uygulama koşullarında değişiklik olan serbest mimarın büro tescil belgesi geçersiz kılınır, mührü geri alınır.

f) Mimar, serbest mimarlık hizmetleri için verilen evrak, belge ve hazırladığı yazılı ve çizili dokümanları, işin sona ermesinden sonra 5 yıl süre ile saklamak zorundadır. Mimar eserlerinin orijinallerini 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca, yaşamı boyunca ve ölümünden 70 yıl sonrasına kadar korunacağını bilerek hareket eder.

g) Mimar, eser sahibi mimarın oluru olmadan tadilat yapamaz.

h) Eser sahibi mimarın bulunamaması durumunda, mimar tadilat projesi üstlenebilmek için Odaya başvurmak ve iş sahibinin yasal tebligat ve ilan yapmasını talep etmekle yükümlüdür.

i) Mimar, mimarlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde işverene bilgi vermek koşuluyla projesinde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

j) Mimar, serbest mimarlık hizmetleri sonunda meydana gelen eserini teslim edecek ve kabul tutanağını gerektiği durumlarda ilgili mercilere verecektir.

k) Mimar, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7 ve 14 üncü maddeleri uyarınca eserini umuma arz etme yetkisine sahiptir. Bu nedenle mimar yapı üretim sürecinin tüm aşamalarında mesleki kontrol olarak eserin vücut bulmasını denetleyerek, eserin tamamlanıp kullanıma açılmasına izin vermek durumundadır.

TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi Ve Ücret Tarifesi”nde de ayrıca madde 3.2 de mimarın hak ve sorumlulukları şöyle düzenlenmiştir.

- Resmi işlemler: Mimar, işveren’in verdiği ihtiyaç programına ve istekleri doğrultusunda hazırladığı projelerin izin veren resmi merciler tarafından reddedilmesinden yada değiştirilmesinden dolayı sorumlu tutulamaz. Ancak tüm çalışmalarını yasa, yönetmelik, şartname ve standartlara uygun olarak yapmak ve izin yada onay veren mercilerin gerekçelere dayanan değişiklik isteklerine uygun olarak projelerinde gerekli değişiklikleri yapmak zorundadır.

- İşleri kontrol şekli: Mimar dekorasyonunu yaptığı işlerin atölyelerde yapılan imalatlarını ve şantiyede yapılan imalat ve montaj işlerini zamanını ve sıklığını kendi tayin edeceği sürelerde kontrol eder.

- İşte gecikme ve kalitesiz imalat: Yüklenici imalatçı yada satıcılar tarafından üstlenilmiş dekorasyon işlerinde bir kusur, niteliksizlik yada gecikme görüldüğü takdirde bunların mimar tarafından ilgililerine uyarılması ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının istenmesi gerekir. Mimar uyarılarına uyulmadığı takdirde işveren’e durumu, gereğini derhal hak ediş ödemeleri yada kesin hesap aşamasında yapabilmesi için bildirmek durumundadır.

- Ön projenin her iki tarafında kabulünden ve işveren tarafından imzalanıp onaylanmasından sonra mimar, işveren tarafından yapılan dekorasyon işlerinin estetiğinin kalitesini kullanım şeklini ölçülerini ve standartlarını etkileyecek şekilde talep edilen değişikliklerin sorumluluğunu üstlenmek istemezse sözleşmeyi feshedebilir. Bu durumda işveren mimarın o ana kadar doğmuş olan alacaklarının tamamını tarifelere göre mimara ödemek zorundadır.

- Mimarın çalışmalarını teslimi: Mimar işvereni ile yapacağı sözleşmede özel bir hüküm bulunmadıkça hazırladığı yazılı ve çizili evrakı işveren’e üç nüsha olarak teslim eder. İşverenin bu belgelerden ve projelerden daha fazla nüsha istemesi durumunda mimar bunları masrafları karşılanması koşuluyla çoğaltarak işveren’e verir.

- Mimarın sorumlu tutulamayacağı durumlar: Mimar işvereni tarafından kendisine verilen bilgi ve belgelerin hatalı eksik ve kusurlu olmasından dolayı oluşabilecek hata ve zararlardan sorumlu tutulamaz. mimar, işveren tarafından görevlendiriliş, yüklenici/yapımcı, taşeron (üstenci) imalatçı ve benzerlerinden, uyarısına rağmen, işveren bunları değiştirme-

mekte ısrar ederse bunların hatalarından ve bu hatalardan ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

- İç mekan düzenlemesi ve mobilya tasarımı hizmetleri konusunda işveren ile mimar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, işverenin işten vazgeçmesi veya sözleşmeyi durdurması durumunda mimarın tazminat hakları, sözleşmenin feshi ve sözleşmeden vazgeçilmesi ile zorunlu nedenler konularında taraflar mimarlık hizmetleri şartnamesinin 1-4 maddesi hükümlerine uygun olarak hareket ederler.

“*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)*” mimarın sorumlu tutulamayacağı durumları madde 16/3 de şöyle düzenlemiştir.

a. Mimar, iş sahibi tarafından kendisine verilen bilgi ve belgelerin hatalı, eksik ve kusurlu olmasından dolayı ve işveren'in hatalarından sorumlu tutulamaz.

b. İş sahibinin, proje ve uygulama aşamalarında, mimarın oluru ve talebi olmadan görevlendirdiği mühendis, uzman ve teknik elemanların çalışmalarından, hatalarından ve bunların sonuçlarından Mimar sorumlu tutulamaz.

c. Mimar, proje ve uygulama çalışmalarına katılmak üzere görevlendirdiği mühendis ve diğer uzmanların, çalışmalarını eşgüdüm içerisinde yürütmelerinden dolayı iş sahibine karşı sorumlu olsa dahi, bunların kendi ihtisas konuları ile ilgili çalışmalarında yapacakları hata ve kusurlardan sorumlu tutulamaz.

d. Mimar, iş sahibi tarafından görevlendirilmiş, yüklenici/yapımcı, taşeron (üstenci), imalatçı vb.den, uyarısına rağmen, iş sahibi bunları değiştirmemekte ısrar ederse, bunların hatalarından ve bu hatalardan ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.

“*Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)*” madde 16/2 de mimarın iş sahibine karşı görevleri ve sorumlulukları şöyle sıralanmıştır.

a. Mimar, üstlenmiş olduğu mimarlık hizmetlerinin eksiksiz ve kusursuz olarak yapılması ve tamamlanmasından sorumludur. Tasarımı ve denetimi altında gerçekleştirilen yapının sahiplerine ve kullanıcılarına kusursuz olarak teslim edilmesinden sorumlu tutulur.

b. Mimar, iş sahibine, yasa, yönetmelik, imar planı, tüzüklerde gösterilenlerden ve bu şartname ile belirlenmiş hususlardan başka özel haklar alacağını ve imtiyazlar elde edeceğini vaat edemez.

c. Mimar, yasalara, toplum yararına ve meslek kurallarına aykırı olmadığı sürece iş sahibinin yararları doğrultusunda hareket eder. İş sahibinin ihtiyaçlarını belirler ve değerlendirir, ona tavsiyelerde bulunur ve ona danışmanlık yapar.

d. Mimar, iş sahibi ile yaptığı görüşmelerde, ona bile bile yanıltıcı bilgiler veremez ya da yapacağı işi olduğundan farklı gösteremez, onun bu konudaki bilgi eksikliğini kötüye kullanamaz.

e. Mimar, yapı üretiminde kullanılacak yapı sistemini seçer, teknikleri tayin eder. Kullanılacak malzemeye karar verir.

f. Mimar, kendisinden istenmişse, inşaatın yönetimini üstlenebilir.

g. Mimar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar iş sahibi tarafından kontrol ettirilirse, mimar çalışmalarının her aşamasında hazırladığı çizili ve yazılı belgelerin bir nüshasını kontrole vermekle yükümlüdür.

h. Mimar, iş sahibi ile yapacağı sözleşmede özel bir hüküm bulunmadıkça, hazırladığı yazılı ve çizili evrakı iş sahibine 2 nüsha olarak teslim eder. İş sahibinin bu belgelerden ve projelerden daha fazla nüsha istemesi durumunda, mimar bunları masrafları karşılanması koşuluyla çoğaltarak iş sahibine verir.

i. Mimarın çalışmaları iş sahibi ile sözleşme imzalanması ile başlar, sözleşmede yer alan iş aşamalarının tamamlanması ve iş sahibi tarafından kabulü ile sona erer.

j. Mimar, sözleşme ile üstlendiği mimarlık hizmetleri, iş sahibi tarafından yeterince anlaşılabilmesi ve onun onayına esas olabilmesi için gerekli her türlü bilgiyi sunmalıdır.

k. Mimar, üstlendiği proje ile ilgili her iş aşamasına ait çizili ve yazılı belgeleri iş sahibinin onayına sunmakla yükümlüdür.

l. Mimar, iş sahibinin bilgisi ve onuru olmadan onaylanmış projesinde yada yapının bünyesinde herhangi bir arttırma yada eksiltme yapamaz. Öngörülmemiş bir harcamayı gerektiren her türlü kararında iş sahibinin olurlarını almak zorundadır.

m. Mimar, inşaat sürecinde ortaya çıkacak, daha önce projede öngörülmemiş inşaat zorunlulukları yada teknik zorluklar karşısında gerekli değişiklikleri yapar ve işvereni bunlardan haberdar eder.

n. Mimar resmi merciler ve kamu kuruluşları ile ilişkilerinde iş sahibince yardımcı olacaktır.

o. Mimar, yapının tasar çalışmalarına katılacak mühendisler ile diğer uzmanları tayin edebilir, çalışmalarını koordine eder ve bu çalışmalarının mimari proje ile uyumunu sağlar. İş sahibi, mimar'la yaptığı sözleşme konusu işle ilgili teknik danışmanların ve başka uzmanların hizmetlerinden de yararlanmak üzere ayrı sözleşmeler yapmışsa, Mimar bunların arasında mesleki bakımdan yeterli ve güvenilir bulmadıklarını iş sahibine bildirmek ve onu uyarmak durumundadır.

p. Mimar, yüklenici ve üstencilerin seçimine katılır ve iş sahibine tavsiyelerde bulunur. Yeterli mesleki deneyim ve bilgi birikimi olmayan, güven vermeyen ve üstlendiği işi tam olarak yapacağına dair güvence vermeyen yüklenicileri seçmemesini iş sahibine tavsiye etmek mimarın görevidir. Mimar, iş sahibinin yüklenici/yapımcılarla yaptığı anlaşmalarda taraf olamaz ve bu anlaşmalardan ve sonuçlarından sorumlu tutulamaz.

q. Mimar, iş sahibini yüklenicilerin yaptığı işlerden sürekli haberdar eder, hakedişlerini kontrol eder, gerektiğinde karşılaştırmalı keşif ile bütçe kontrolü yapar, yüklenicilere tam olarak yapılmamış hakediş ödemelerinden dolayı doğabilecek sorunlar konusunda iş sahibini uyarır, işlerin kabulünde ve teslim alınmasında hazır bulunur.

“Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)” madde 17 de ise iş sahibinin görev, hak, yetki ve sorumluluklarını belirlemiştir. Buna göre iş sahibinin genel olarak görev, hak, yetki ve sorumlulukları şunlardır.

a. İş sahibi mimarlıkla ve mimarlık hizmetleri ile ilgili yasalara, yönetmeliklere, uyar ve uyulmasını sağlar. Sözleşme yaptığı mimardan, Mimarlar Odası'nın koyduğu mesleği uygulama kurallarına aykırı davranışta bulunmasını isteyemez, mimarlık hizmetlerini Mimarlar Odası'nın mesleki denetimine sunulmasından alıkoymaz.

b. İş sahibi, mimarlık hizmetlerinin bir bütün olduğunu, yapının mimar tarafından en az zorunlu mimarlık hizmetlerin tümünün gerçekleştirilmesi ile meydana geleceğini kabul eder ve mimarlık hizmetlerinin tam olarak gerçekleştirilmesi için mimarla yaptığı sözleşmenin hükümlerine uyar, Mimarın oluru olmadan mimarlık hizmetlerini bir başkasına devre-demeyeceğini ve yaptıramayacağını kabul eder.

c. İş sahibi, yapının gerçekleştirilmesine ilişkin tüm mimarlık, mühendislik ve diğer uzmanlık hizmetlerinin Mimarın koordinasyonu altında yapılacağını kabul eder. İş sahibi, yapının gerçekleştirilmesine tasa-

rım ve uygulama aşamalarında katılan tüm kişilerinde mimarla yaptığı sözleşmenin hükümlerine uymalarını sağlar.

d. İş sahibi, mimara hukuki belge ve bilgileri (tapu, irtifak, ortaklık, şuyu, hisse, tapu şerhi, ipotek vb.), imar belge ve bilgilerini (imar planı, imar durumu belgesi, yol istikamet krokisi vb.), teknik belge ve bilgileri (halihazır harita, plankote, ağaç-yapı rölövesi, ölçülü kroki, çap, çevre planı, zemin etütleri, sondaj raporları, iklim ve coğrafi veriler vb) vermekle yükümlüdür.

e. Yapının kompozisyonunda yer alacak tüm elemanların ve bunların önem dereceleri ile özellikleri yapının işlevleri ve kullanma amaçları, ihtiyaçların belirlenmesi, tasarım aşamasında değerlendirilecek özel istekler, yapının kullanıcıları ile ilgili bilgiler, gerçekleştirilecek yapı özel normlara göre yapılacaksa belirtilmeli, işin gerçekleşmesi için ayıracağı bütçe ile ilgili bilgiler açıklanmalıdır.

f. İş sahibi, sözleşme yaptığı mimara, sözleşme konusu yapı ile ilgili olarak başka mimar yada mimarlar tarafından daha önce yapılmış çalışmalar var ise bilgi vermelidir.

g. İş sahibi tarafından mimara verilecek bilgi ve belgelerin tam, doğru ve geçerli olması zorunludur. İş sahibi, yukarıda gruplanmış bilgi ve belgeleri mimarın çalışmalarını aksatmayacak şekilde ve zamanlarda temin etmekle yükümlüdür. Bu belge ve bilgilerin eksik olması durumunda, işveren ücretini yevmiye esasına göre ödemek koşulu ile teminini Mimar'dan isteyebilir

h. Sözleşmede aksi belirtilmedikçe ve başkaca bir hüküm bulunmuyorsa, iş sahibi kendisine verilen çizili ve yazılı belgeleri en çok bir ay içerisinde incelemek ve onaylamak zorundadır. Onaylamaktan kaçınırsa, bunun nedenlerini mimara yazılı olarak bildirmek durumundadır. Bu sürenin sonunda mimara yazılı bildirimde bulunulmamışsa bu belgeler onaylanmış sayılır ve bu iş aşaması karşılığı ücret mimara ödenir.

i. İş sahibi, mimar tarafından hazırlanan çizili ve yazılı belgeleri inceledikten sonra onaylar, bunları imzalar ve ilgili mercilere başvuruda bulunur. Aynı şekilde iş sahibi, kamu ve kent yönetim örgütleri nezdinde yapacağı girişimlerden mimara bilgi vermek, bunların görüşlerini ve çalışmalarla ilgili olarak belirttikleri hususları mimara iletmek ve verdiği dilekçelerin ve aldığı cevap ya da onayların ve eklerinin birer suretini mimara vermek ile yükümlüdür.

j. İş sahibi, mimarla yaptığı sözleşmede belirtilen işle ilgili olarak mühendis, teknik danışman ve başka uzmanlarla, onların mimarın bilgisi ve onayı dahilinde bunlarla ayrı sözleşmeler imzalamakta serbesttir. Mimar kabul ederse bu danışman ve uzmanları kendi sözleşmesi kapsamına alabilir yada taşeron olarak çalıştırabilir.

k. İş sahibi yüklenici/yapımcıların rekabetine başvurup vurmayacağına karar verir. İnşaatını yaptıracığı yüklenici ya da yüklenicileri kendi özgür iradesi ile seçer.

l. İş sahibi uygulama aşamasında, mimarın bilgisi olmadan inşaatla ilgili yüklenicilere, taşeronlara ve imalatçı yada montajcılara doğrudan emir yada talimat veremez. Ancak, bunlarla ilgili yasal yollara başvurmak ve işlem yapmak hakkına sahiptir.

m. İş sahibi, uygulama sürecinde, yüklenicilere, yapımcılara yada anlaşma yaptığı diğer inşaatla ilgili 3. şahıslara hakedişlerini sözleşmelerinde belirlenmiş sürelerinde ödemek ve bu ödemelerden mimara bilgi vermek zorundadır.

n. İş sahibi proje ve şartnamelere uygun olarak tamamlanan yapıyı kabul etmek ve teslim almak durumundadır.

o. Projeden etkilenen yada inşaatla ilişkili diğer kişilerle uzlaşmak ve anlaşma yapmak yada anlaşmazlıkları çözümlmek yükümlülüğü iş sahibine aittir.

p. İş sahibi, mimarın "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası"na göre sahip olduğu müelliflik haklarına uymak zorundadır. İş sahibi, ön proje çalışmaları iş aşamasını onaylamış ise, mimarın proje müellifliği hakkını tanır ve bu hakkı korur. İş sahibi, mimar tarafından hazırlanan projeler üzerinde, mimarın olurluğunu almadığı hiç bir değişiklik yapamaz, bunları değiştiremez, devredemez, uygulayamaz, çoğaltamaz, dağıtamaz ve üzerinde hak iddia edemez. İş sahibi, kabulünün yapılmasından sonra yapıda yapılmak istenen değişiklikler yada ilaveler ile ilgili olarak da mimarın telif haklarını korumakla yükümlüdür .

q. İş sahibi, eserini kullanacağı her durumda mimarın adını belirtmek ve eseri ile ilgili yayınlacağı her belgenin içeriği ve şekli konusunda mimara bilgi vermek ve onu çoğaltmak, dağıtmak, yayınlamak için mimarın olurluğunu almak zorundadır.

r. İş sahibi, mimar'la yapmış olduğu "*Mimarlık Hizmetleri Sözleşmesi*" uygulanmasından üçüncü şahıslara karşı sorumludur.

s. İş sahibi, müelliflik hakkını kazanmış mimarın kesin proje çalışmaları, uygulama projesi çalışmaları, ihale belgelerinin hazırlanması ve mesleki kontrollük (MUS) iş aşamalarını, sorumluluğunu taşımak koşulu ile bir başka mimara devretmesine ya da vekil tayin ettiği mimara yaptırmasına itiraz edemez.

t. İş sahibi, çalışmalarının her aşamasında tüm masrafları kendisine ait olmak üzere, tayin edeceği kişi ya da kontrol bürosu aracılığı ile mimarın çalışmalarını kontrol etme hakkına sahiptir. İş sahibi, görevlendirdiği kontrolü ya da kontrol bürosunu, görüşlerini doğrudan mimara bildirmekle yetkilendirecektir.

u. İş sahibi, mimarlık hizmetleri sözleşmesini imzalamış olmakla, bu şartnamede belirlenmiş olan, mimarın görev, hak, sorumluluklarını ve yetkilerini kabul etmiş ve bunlara uygun davranmayı taahhüt etmiş sayılır.

TMMOB Mimarlar Odası, “İç Mekan Düzenlemesi ve Mobilya Tasarımı Hizmetleri Şartnamesi ve Ücret Tarifesi”nde de ayrıca madde 3.1 de İşveren’in hak ve sorumlulukları şöyle düzenlenmiştir.

- Giriş izni verilmesi: İşveren işlerin tamamlanabilmesi için işgal ettiği mahallere karşı giriş izni vermekle yükümlüdür.

- Uygulama sürecinde yapılan değişiklikler: İnşaat, imalat, montaj ve satın alma sözleşmelerinin imzalanmasından sonra işveren’in isteği yada mimarın önermesi ve işveren’in onayı ile yapılan değişiklikler işveren ve mimarın imzalayacakları tutanaklara kaydedilerek belirlenir. Bu değişikliklerin işin toplam keşfinde meydana getireceği artış yada eksilme şeklindeki değişikliklerin mimarın hak edişini ne şekilde değiştireceği sözleşmede belirlenir.

- Kabulden önce işgal: İşveren dekorasyonu yapılan mahalleri tamamlamadan ve kabulü yapılmadan önce işgal ederse mimar bu durumu işveren’inde imzalayacağı bir tutanakla belirlemek ve yüklenici imalatçı ve satıcılara bildirmek durumundadır. Bu durumda işveren işlerin tamamlanabilmesi için işgal ettiği mahallere girişe izin vermek zorundadır.

- Önemli proje değişiklikleri: İşveren onaylanmış projede ve bu proje kapsamındaki imalatlarda program değişikliği getirmese dahi mimarın yeniden etüt yapmasını gerektirecek imalat ve malzeme değişiklikleri şeklinde önemli değişiklikler yapılmasını isterse mimarın bu ilave çalışmaları karşılığı hak edişini işveren’den tahsil etme hakkı doğar. Bu değişiklikler, işveren tarafından işin toplam bedelinde indirim yapma amacıyla

yapılmışsa sözleşme şekli ne olursa olsun indirim miktarı dikkate alınmaz ve mimara hak edişleri sözleşme öngörüldüğü şekilde tam olarak ödenir.

- İşler mimarın talimatları doğrultusunda yürütülür. İşveren işlerin genel sorumluluğunu üstlenmiş olan mimarın haberi olmadan yüklenicilere, imalatçılara, satıcılara yada onların personeline talimat veremez yada onlarla anlaşmalar yapamaz.

Genelde sözleşmenin sona ermesi tarafların edimlerini yerine getirmesiyle olmaktadır. Bunun dışında BK 106-108 maddelerinde yer alan fesih koşulları ve sürelerine uymak yoluyla, taraflardan biri borçlarını yerine getirmiyorsa diğer taraf tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir veya akdin icrasından vazgeçebilir. Ayrıca taraflar karşılıklı anlaşarak da bu sözleşmeyi sona erdirebilirler.

“Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)” madde 16/4’e göre, mimar; aşağıdaki durumlarda gerçekleşmesi halinde sözleşmeyi feshedebilir yada işten vazgeçebilir.

a. Mimarın meslek kurallarına, Mesleki Davranış ve Ahlak İlkele-ri’ne, yasalara, yönetmeliklere uyması olanaksız duruma gelmişse,

b. İşveren/İş sahibi tarafından işini gerekli kalitede yapma güven-cesi vermeyen bir yüklenicinin seçilmesi ve sözleşmeye bağlanması duru-munda,

c. İş sahibinin güveni ortadan kalkmışsa,

d. Mimarı çıkar çatışmasına zorlayan ya da bağımsız davranmasını engelleyen bir durum ortaya çıkmışsa,

e. Mimarlık hizmetleri sözleşmesinin bir ya da bir kaç maddesine iş sahibi tarafından uyulmaması durumunda,

f. İş sahibinin mimara vereceği belge ve bilgilerin ve ödemelerin tesliminde gecikme olması durumunda,

Bu maddeye göre; iş sahibinin mimarın eksik ya da kusuru olmaksızın bir iş aşamasına ait çalışmalar sonucu hazırlanan belgelerin onaylan-masından kaçınması ve bu iş aşamasına ilişkin hakedişlerini mimara öde-memesi durumunda, işveren sözleşme hükümlerine aykırı davranmış sayılır ve mimarın sözleşmeyi fesih ve bakiye işlerden dolayı alacaklarının % 30’unu tazmin hakkı doğacaktır. Yine Ülkedeki genel yada kısmi sefer-berlik ilanı, mimarın çalışma yerlerini etkileyen, yangın, sel, deprem gibi doğal afetler meydana gelmesi veya bulaşıcı hastalık olması, iş sahibi'nin

yada mimarın iflası ve acz içerisine düşmesi halinde; bunların işe tesirleri oranında süre uzatımı yapılır yada sözleşme durdurulur veya feshedilir.

“Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi (Mim HŞEABT)” işverenin sözleşmeyi feshetmesi ve yada işten vazgeçmesi hallerine özgü şu düzenlemeleri yapmıştır.

a. Sözleşmenin uygulanmasından iş sahibi tarafından zorunlu bir nedene dayanılarak vazgeçilirse yada sözleşme tek taraflı olarak feshedilirse, mimarın o ana kadar tamamlamış olduğu iş aşamalarının bedelleri mimara ödenir. Ödemenin yapılması durumunda, mimar, o ana kadar gerçekleştirdiği işleri iş sahibine teslim eder. Yarım kalmış iş aşamalarının bedelleri tam olarak ödenir. İş sahibi, zorunlu bir neden olmaksızın sözleşmeyi fesheder ya da işten vazgeçerse, henüz tamamlamadığı iş aşamalarının toplam bedelinin % 30'u mimara tazminat olarak ödenir

b. Mimar zorunlu haller dışında, geçerli bir neden olmaksızın, sözleşmesinde yazılı mimarlık hizmetlerini yapmadığı ya da sözleşme hükümlerinde belirtilen hususlara uymadığı taktirde, iş sahibi, mimara 15 gün süreli bir bildirim göndererek sözleşme ve eklerinin hükümlerine uymasını ister. Mimar, bu bildirimde verilen süre içinde ve istenilen hususlara uymamakta ısrar ederse, başkaca bir ihtara ve karar almaya gerek kalmaksızın iş sahibinin sözleşmeyi fesih hakkı doğar. Sözleşme bu şekilde feshedildiği taktirde, mimarın hakedişleri ödenmez ve durum mimarın listesi'ne kayıtlı olduğu Mimarlar Odası'na bildirilir.

c. Zorunlu bir nedenle sözleşme durdurulursa, mimar, o ana kadar gerçekleştirdiği işleri iş sahibine teslim eder. Bu işler, iş sahibi ve mimar arasında değerlendirilerek, bunların değeri mimara ve o ana kadar yapılan ödemelerin üzerinde ise aradaki fark mimara defaten ödenir. Eksik ise, aradaki fark mimar tarafından iş sahibine ödenir.

d. İş geçici bir süre durdurulmuşsa, mimarın tamamladığı iş aşamalarının bedelleri tamamlandığı yılın tariflerine göre hesaplanarak ödenir.

e. Herhangi bir nedenle, mimarın işi yapmasına yada mesleğini icradan menine Mimarlar Odası'nca yada mahkemece karar verildiği taktirde, sözleşme feshedilmiş sayılır ve iş sahibinin alacak ve diğer hakları saklı kalmak koşuluyla, hüküm alınmasına ya da bildirimde bulunulmasına gerek kalmaksızın iş sahibinin kayıpları mimarın varlığından karşılanır.

f. Memlekette genel yada kısmi seferberlik ilanı, mimarın çalışma yerlerini etkileyen, yangın, sel, deprem gibi doğal afetler meydana gelmesi

yada bulaşıcı hastalık olması, iş sahibinin yada mimarın iflası ve acz içerisinde düşmesi halinde; bunların işe tesirleri oranında süre uzatımı yapılır yada sözleşme durdurulur veya feshedilir.

Yukarıda açıklanan olağan sona ermelerin dışında; mimar, üstlenmiş olduğu mimari proje düzenleme hizmetlerini henüz tamamlamamış olduğu sırada ölür veya bu hizmetleri tamamlama gücünü kaybederse, mimarlık sözleşmesini eser/istisna sözleşmesi olarak nitelendirirsek BK madde 371/1'e göre veya vekalet sözleşmesi olarak nitelendirirsek BK madde 397/1 gereğince, söz konusu mimari hizmet edimlerinin kişisel niteliğinden dolayı, mimari proje düzenleme sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. Vekalet sözleşmesi olarak niteleme durumunda, mimar veya onun ölümü halinde mirasçıları, ölüm veya acz haline kadar yerine getirilmiş olan iş görme edimine uygun düşen masraf ve ücreti talep edebilir.²¹⁶ Buna karşın eser sözleşmesi açısından, mimar veya onun ölümü halinde mirasçıları, tamamlanamamış olan eserin bitmiş kısmı için, ancak bu kısım yapı sahibi için kullanılabılır nitelikte ise, BK 371/II'ye göre bir ücret talep edebileceklerdir.²¹⁷

²¹⁶ Mustafa Argun KÖTELİ, Mimarlık Sözleşmesi, İstanbul, 1985, s. 240 vd.; TANDOĞAN, age., s. 466 vd.

²¹⁷ KAPLAN, age., s. 78; TANDOĞAN, age., s. 167 vd.

IX. ESER SAHİBİNİN HAKLARININ SINIRLANDIRILMASI

Eser sahibinin hakları ;

A. Kamu düzeni,

B. Genel menfaat ve

C. Özel menfaat

düşünceleriyle veya

D. Hükümete tanınan yetkilerle sınırlandırılmıştır.

Şimdi bu sınırlamaları mimari eserler açısından değerlendirerek inceleyelim;

A. KAMU DÜZENİ DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA

Eser sahibine tanınan haklarda kamu düzeni açısından getirilen sınırlamalar; eserin ispatı amacıyla mahkemelerde ve diğer resmi kurumlar önünde kanıt olarak kullanmak ve kolluk güçlerinin sanıkları teşhis etmeleri, izlemeleri veya suçun ortaya çıkarılmasında kolaylık sağlama gibi birçok sebeple olabilir. Mesela bir bankanın soyulması olayında mimardan banka binasına ait planları veya maketi güvenlik güçleri isteyebilirler, bu maketi işi çözmek için parçalara ayırabilirler ve ayrıca proje sözleşmesi aşamasında işveren ile mimar arasında düzenlenmiş olan gizlilik sözleşmesi bu noktada engel olmaz. FSEK madde 30’da konu; “*eser sahibine tanınan haklar, eserin ispatı maksadıyla mahkeme ve diğer resmi makamlar huzurunda ve aleliltlak zabıta ve ceza işlerinde bir muameleye konu teşkil etmek üzere kullanılmasına mani değildir. Fotoğraflar, umumi emniyet mülahazasıyla veya adli maksatlar için sahibinin rızası alınmaksızın, resmi makamlar veya bunların emriyle başkaları tarafından her şekilde çoğaltılabilir ve yayılabilir. Eserin her hangi bir suretle ticaret mevkiine konmasını, temsilini veya diğer şekillerde kullanılmasını meneden yahut müsaade veya kontrole bağlı tutan kamu hukuku hükümleri mahfuzdur*” şeklinde düzenlenmiştir.

Maddenin ikinci cümlesi gereğince, bir suçlunun yer aldığı bir mimari eserin veya bir binanın iç bölümünün fotoğrafı da mimardan izin

alınmadan resmi kurumlar veya güvenlik güçleri tarafından çoğaltılarak dağıtılabilir.

Maddenin son cümlesinin uygulaması açısından da çeşitli örnekler verilebilir. Yapılan bir projede, yapıda veya bir içmimarî objesinde çocuk pornosu veya cinsel ilişkinin pornografik unsurları bulunabilir ve savcılık bu eserlere ilişkin temsil veya satış yasağı koyabilir.

B. GENEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE SINIRLANDIRMA

Bu başlık altında incelenecek olanlar; mevzuat ve içtihatlardan herkesin yararlanması, kamuya açıklanması yararlı olan söz ve nutukların herkes tarafından bilinmesi olanağının yaratılması, hayır kurumlarına gelir sağlanması, kültür ürünlerinin eğitimin ve toplumun hizmetine sunulması, bilimin yaygınlaştırılması ve günlük olaylardan kamunun bilgi alabilmesi durumlarıdır.

FSEK madde 31 gereğince; hukuk kurallarının yer aldığı mevzuat ile mimari eserler konusundaki mahkeme kararlarının incelendiği yargıtay içtihatlarının adı geçen mimarından izin alınmadan çoğaltılması, yayılması, işlenmesi veya herhangi bir şekilde bunlardan faydalanma serbesttir.

FSEK madde 32, “*Büyük Millet Meclisinde ve diğer resmi meclis ve kongrelerde, mahkemelerde, umumi toplantılarda söylenen söz ve nutukların, haber ve malumat verme maksadıyla çoğaltılması, umumi mahallerde okunması veya radyo vasıtasıyla ve başka suretle yayımı serbesttir. Hadisenin mahiyeti ve vaziyetin icabı gerektirmediği hallerde söz ve nutuk sahiplerinin adı zikredilmeyebilir. Bu söz ve nutukları birinci fıkrada zikredilenden başka bir maksatla çoğaltmak veya diğer bir suretle yaymak eser sahibine aittir*” demektedir. Bu düzenlemeye göre, umumi olan bilimsel bir toplantıda bir mimarlık hocası veya mimar tarafından bir projenin, planın veya çizimin uygulanabilmesi için kullanılacak yöntem açıklanıyorsa, o kişinin adı açıklanmak suretiyle bu konuda yayın yapılabilir. Fakat konferans; nutuk ve sözden farklı olduğu için temsil hakkı içinde incelenmelidir.

Bunların dışında firmaların sözleşmelerindeki düzenlemeler ve genel işlem şartları, avukatların yazdıkları dilekçeler, bilirkişi raporları şayet eser niteliğini taşıyorlarsa eser olarak (korunmakta ve) değerlendirilmektedirler.²¹⁸

²¹⁸ HIRSCH, age., s. 38.

Yargıtay'ın bu konuya ilişkin 1999 tarihli bir kararında; Bayındırlık Bakanlığı'nın inşaat birim fiyat tarifelerinin kendine özgü biçimde bir araya getirilmesinin eser olduğunu ve bunların mevzuat ve içtihat sayılamayacağından FSEK madde 31'deki sınırlamalar kapsamına (eser sahibinden izin alınması gerekmeyen durumlara) girmeyeceğine ve FSEK'deki korumalardan yararlanacağına işaret edilmiştir.²¹⁹

FSEK 33. maddeye göre, yayınlanmış bir eserin, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında, yüz yüze eğitim ve öğretim maksadıyla, doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmeksizin temsili, eser sahibinin ve eser adının olağan şekilde açıklanması şartıyla serbesttir. Burada yüz yüze eğitimden bahsedildiği için televizyon veya internet yoluyla yapılan eğitimler bu istisnadan yararlanamaz. Bu nedenle televizyonda açık öğretim dersleri adlı bir yapımda; bir tasarımın veya projenin detaylarının açıklanması 33. maddedeki serbesti dahilinde değildir.

FSEK 34. maddeye göre, eğitim ve öğretim amacına yönelik olmak şartıyla, yayınlanmış mimari eserleri kapsayan ilim ve edebiyat eserleriyle alenileşmiş güzel sanat eserlerinden iktibaslar yapmak suretiyle toplama veya seçme eser meydana getirilebilir.

Kanun bedii nitelik taşımayan teknik ve bilimsel nitelikteki fotoğrafların, haritaların, plan, proje, kroki ve resimlerin; coğrafya ve topografyaya ait maketlerin, mimarlık ve şehircilik tasarımlarıyla sahne ve çevre tasarımlarının (FSEK madde 2/3), eğitim öğretim amacıyla meydana getirilen bir toplama esere iktibas yoluyla konmasına izin vermiştir. Ancak FSEK madde 34 gereğince, bu tür bir iktibas, söz konusu toplama eserin içeriğini aydınlatmak amacıyla yapılabilir. Yoksa içerikte hiçbir şey olmadan bunlar toplanamaz. Mesela bir coğrafya kitabında, başkası tarafından çekilmiş Sakar (Gökova) Geçidi'nin veya Keban Barajı'nın fotoğrafı, GAP'ın başka bir eser sahibince çizilmiş krokisi veya İzmir Körfezi'nin haritası yer alabilir.

²¹⁹ “Dava, davacı Bakanlık tarafından 1994 yılına ait inşaat birim fiyatlarına esas, işçilik, araç ve gereç listeleri ile yapı işleri birim fiyat tarifeleri eki fiyat listelerinin bastırılıp üzerine “para ile satılmaz” ibaresinin korunmasına karşılık, davalı tarafından izinsiz çoğaltılmak suretiyle satışa çıkarılması üzerine, davalının eylemini önlemeye yönelik olarak açılmıştır. Yargıtay'ın ilgili Dairesi ise, bu konudaki emsal kararlarında değindiği gibi, davacı İdare tarafından belirlenen inşaat birim fiyatlarının unsurları ile ilgili bilgi ve cetvellerin FSEK md.31'deki belgelerden sayılamayacağına ve bu nedenle davalı tarafından serbestçe çoğaltılamayacağına karar verilmiştir.” 11. HD., 16.12.1999, E. 1999/5797, K. 1999/10400. (Yargıtay Kararları No: 31).

Ancak yapılacak olan bu yararlanmanın maksadını haklı gösterecek ölçüde olması gerekmektedir, aksi şekilde birçok eser sahibinin eserini toplayıp hiçbir kişisel özellik ve bilgi katmadan toplama bir kitap yapılması hukuka aykırıdır. Ve yine bu serbestlik, hak sahibinin meşru menfaatlerine haklı bir sebep olmadan zarar verir veya eserden normal yararlanma ile çelişir şekilde kullanılamaz.

Yayımlanmış ilim ve edebiyat eserlerinden ve alenileşmiş güzel sanat eserlerinden, iktibaslar yapılmak suretiyle **eğitim ve öğretim gayesi dışında** seçme ve toplama eserler vücuda getirilmesi ancak eser sahibinin izniyle mümkündür.

FSEK 35. madde de bahsedilen **iktibas**; alenileşmiş bir eserden, bazı cümlelerin, paragrafların, motif ve tınların, hatta ezgilerin veya **alenileşmiş** güzel sanat eserinin resimlerinin **aynen**, **kaynak gösterilerek**, **başka bir esere konulmasıdır**.

İktibas serbestisi eğitimin, bilimin veya sanatın yararına konulmuştur. Örneğin bir sanat tarihçisi, bir mimarı anlatabilmek için onun eserlerine yer verebilir. FSEK madde 35'e göre mimari eserler açısından şu hallerde iktibas yapılması mümkündür;

a. Alenileşmiş bir eserin bazı cümle ve kısımların bağımsız bir başka bilim ve edebiyat eserine alınması. Bir mimarın eserlerinden bazı bölümlerin “yazlık evler” adındaki bir kitaba koyulması buna örnektir.

b. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin ve yayımlanmış diğer eserlerin, amacın haklı göstereceği bir oran dahilinde ve içeriğini aydınlatmak gayesiyle bir bilim eserine konulması. Örneğin; tarihi bir mimari eserin restorasyonu sırasında ortaya çıkan projelerin, sanat tarihi kitabı yazan bir yazar tarafından eserine alınması.

c. Alenileşmiş güzel sanat eserlerinin bilimsel konferans veya derslerde, konuyu aydınlatmak için projeksiyon ve buna benzer vasıtalarla gösterilmesi. “İSTANBUL’UN ÇAĞDAŞ MİMARİ YAPILARI” adlı bir konferansta, mevcut yeni mimari eserlerin slayt gösterisi halinde gösterilmesi gibi.

Burada özellikle dikkat edilecek konu; iktibasın belli olacak şekilde yapılması gereğidir. İlim eserlerinde (projelerde, planlarda) , iktibas yapılırken kullanılan eserin ve eser sahibinin adından başka ilgili kısmın alındığı yer belirtilir.

FSEK 36. madde gereğince, gazete içerikleri ve röportajlar da yararlanma serbestisi kapsamındadır. Gazete ve dergilerde çıkan toplumsal, siyasi ve ekonomik günlük meselelerle ilgili makalelerin “**iktibas hakkı**

açıkça saklı tutulmamışsa”, aynen veya işlenmiş şekilde diğer gazete ve dergiler tarafından alınması ve diğer iletişim araçlarıyla (televizyon, internet vb.) yayılması ve kısaltılarak kullanılması serbesttir. Mesela şehre yapılacak iddialı bir bina konusunda mimarın yaptığı röportajın (alenileşmemiş bir eser hakkında umuma arz veya eserin içeriği hakkında bilgi verilmesi manevi hakkı) bazı kısımlarının kullanılması bu madde kapsamındadır. Alıntı hakkı açıkça yasaklanmışsa başka yayın organları tarafından bu açıklama “aynen” kullanılamaz. Ancak diğer yayın organları kısaltarak bu bilgileri kullanabilir. Alıntı hakkı saklı tutulmamışsa aynen kullanılabilir.

Ancak her şekilde iktibas edilen gazete, dergi, ajansın ve diğer kaynakların adı ve sayısının yanı sıra eser sahiplerinin adının veya takma adının açıklanması gerekir.

FSEK 37. madde gereğince; “*haber mahiyetinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük hadiselerle ilgili olarak fikir ve sanat eserlerinden bazı parçaların işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla alınması mümkündür. Bu şekilde alınmış parçaların çoğaltılması, yayılması, temsil edilmesi veya radyo ve televizyon gibi araçlarla yayınlanması serbesttir. Bu serbestlik, hak sahibinin hukuki menfaatlerine zarar verecek şekilde veya eserden normal yararlanmaya aykırı biçimde kullanılamaz*”. Görüldüğü gibi haber niteliğinde olmak ve bilgilendirme kapsamını aşmamak kaydıyla, günlük olaylar kapsamında mimari eserlerin parçaları kitle iletişim araçlarıyla yapılan yayınlarda kullanılabilir, çoğaltılabilir, temsil edilebilir, yayınlanabilir. Örneğin, henüz yeni inşa edilen bir köprünün krokisinin ve eskiz çalışmalarının mimarın izni olmasa dahi belediyeden alınarak gazetede ve internette bir haber kapsamında yer alması.

C. ÖZEL MENFAAT DÜŞÜNCESİYLE GETİRİLEN SINIRLANDIRMA

Özel menfaat düşüncesiyle getirilen sınırlama, kişisel kullanım ile kopya ve teşhirdir.

FSEK madde 38’e göre; her türlü eser kâr amacı güdülmeksizin, şahsen kullanılmaya mahsus olarak çoğaltılabilir. Bu madde çoğaltma hakkı için eser sahibinden izin alma zorunluluğunun istisnasını oluşturmaktadır. 1995 yılında 4110 sayılı değişiklikle bu sınırlama güzel sanat eserlerini de içine almıştır. Bununla birlikte Kanun diğer eserlerden farklı

olarak güzel sanat eserlerinin çoğaltılması ile ilgili bazı özel düzenlemelere yer vermiştir. Bu açıdan Kanun'un 40. maddesine göre; güzel sanat eserleri, şahsi ihtiyaç çerçevesinde kullanılabilmeleri yönünden “mimari eserler” ve “diğer güzel sanat eserleri” olarak iki alt gruba ayrılmış ve bu yönden farklı düzenlemelere tabi kılınmıştır.²²⁰

Mimari eserlerin özel menfaat düşüncesiyle kullanımı şöyledir. FSEK madde 38/1 çerçevesinde çoğaltma hakkının tüm eserler yönünden geniş yorumlanması, eser sahiplerinin aleyhine bir durum doğurur. Örneğin bir kroki, plan veya projenin kopyası çıkarılabilir veya bir binanın resmi çekilebilir ise de; bu kroki, plan, proje veya resmin konusu olan binanın inşa edilmesi hukuka uygun değildir.²²¹ Sonuç itibarıyla, bir mimari eserin taklit edilerek inşa edilmesi suretiyle çoğaltılması konusunda “özel menfaat” düşüncesiyle de olsa bir serbestiden bahsetmek mümkün değildir. Çünkü ilgili madde şahsen kullanma açısından mimardan izin almadan onun haklı menfaati olan mali haklara zarar veremeyeceğini ve normal yararlanma olan parasını verip, izin alıp kullanma şekline aykırı olamayacağını düzenlemektedir.

Nitekim FSEK madde 40/1 hükmü ile getirilen kopya ve teşhire ilişkin eser sahibinden izin almadan kullanma olanağı veren serbesti mimari eserlerin yalnızca dış şekline aittir. FSEK'in bu ilgili maddesi şu şekildedir: “*Umumî yollar, caddeler ve meydanlara, temelli kalmak üzere konulan güzel sanat eserlerini; resim, grafik, fotoğraf ve saire ile çoğaltma, yayma, umumî mahallerde projeksiyonla gösterme, radyo ve benzeri vasıtalarla yayımlama caizdir. Bu salâhiyet mimarlık eserlerinde yalnız dış şekle münhasırdır.*

Üzerlerine, sahibi tarafından sarahaten men edici bir kayıt konulmuş olmadıkça güzel sanat eserleri malikleri veya bunların muvafakatiyle başkaları tarafından umumî mahallerde teşhir edilebilir.

Açık artırma ile satılacak eserler umuma teşhir olunabilir. Umumî mahallerde teşhir edilen veya açık artırmaya konulan bir eseri sergi veya artırmayı tertip eden kimseler tarafından bu maksatlarla çıkarılacak katalog, kılavuz veya bunlara benzer matbualar vasıtasıyla çoğaltma ve yayma caizdir.

²²⁰ ATEŞ, age., s. 400.

²²¹ ARSLANLI, age., s.148-149 Naklen ATEŞ, age., s. 401.

Bu hallerde, aksine yerleşmiş âdet yoksa, eser sahibinin adının zikrinden vazgeçilebilir”.

Bu düzenlemeden de görüldüğü gibi, açıkça eser sahibi tarafından bir yasaklama yapılmadıkça, eseri eser sahibinden satın alanlar veya satın alanlardan satın alan malikler tarafından yol, meydan, rıhtım ve diğer umuma açık yerlerde sergilenebilir. Bu düzenleme güzel sanat eserlerini kapsadığından sadece mimari eser olan yapılar açısından uygulanabilir.

Mimari eserlerden olan proje, plan veya maketler ile iç mimari unsurları, mobilya tasarımları ve mobilyalar açık arttırma gayesi ile eser sahiplerinden izin alınmadan sergilenebilir. Yine açık arttırmaya konu bu eserler ile umumi yerlerde sergilenen eserleri sergi ve açık arttırmayı düzenleyen kişiler katalog, broşür ve diğer tanıtıcı belgeler şeklinde ayrıca eser sahibinden izin alma gerekmeden çoğaltabilirler, satışa çıkarabilirler, kiraya verebilirler. Eğer mutlaka eser sahibinin adı da verilmelidir şeklinde özel bir gelenek yoksa bu katalog, broşür ve diğer tanıtım malzeme-lerinde eser sahibinin adı verilmeyebilir.

D. HÜKÜMETE TANINAN YETKİLERLE SINIRLANDIRMA

Hükümete tanınan yetkiler arasında; meslek birliklerinin kurulması, eser, icra, fonogram ve yapımların yayınlanmasına ve/veya iletilmesine ilişkin esasların tespiti, fikir ve sanat eserlerinin işaretlenmesi, güzel sanat eserlerinin (daha önce bahsettiğimiz gibi mimari eserler dışında) bedellerinden pay verilmesi, devletin yararlanma yetkisi ve kamuya mal etme hükümleri bulunmaktadır.

Mimari eserlerle ilgili olan hükümet sınırlamaları daha çok; Devletin yararlanma yetkisi ve kamuya mal etme hükümleridir.

• Devletin Yararlanma Yetkisi;

Çoğaltma ve yayma hakkı, eser sahibi tarafından men edilmemiş olan ve umumi kütüphane, müze ve benzeri yerlerde saklı bulunan henüz yayımlanmamış veya alenileşmemiş eserler; mali haklarla ilgili koruma süresi dolmuş olmak şartıyla, bulunduğu kamu kurumu ve kuruluşlarına ait olmaktadır.

FSEK madde 46 gereğince, bunlardan bilimsel ve benzeri amaçlarla yararlanmak isteyen kişi ve kuruluşların izin alacakları mercii ve bunlardan alınacak ücretlerle, bu ücretlerin hangi kültürel gayelerde sarf edile-

ceği ve diğer hususlar ilgili kuruluşların görüşü alındıktan sonra Bakanlıkça hazırlanacak tüzükle belirlenir.²²²

Bu sınırlama durumuna ilişkin mimari eserlerle ilgili verilecek olan ve mimarlık öğrencilerinin en sık olarak karşılaştıkları örnek şöyledir: Mimarlık fakültelerindeki yüksek lisans öğrencileri hazırladıkları tezleri fakülte kütüphanelerine vermektedirler ve bu tez ve çalışmalar daha sonra devletin yararlanma yetkisi kapsamında yukarıda değinilen şartlar altında başka tezlerin veya araştırmaların yapılması için kullanılmaktadır.

• Kamuya Mal Etme;

FSEK madde 47 hükmüne göre, ülke kültürü için öneme sahip görülen bir eser üzerindeki mali haklardan faydalanma yetkisi, hak sahiplerine uygun bir bedel ödenerek koruma süresinin dolmasından önce bir kararname ile kamulaştırılabilir.

Kamulaştırma yetkisinin doğması ve kullanılması için;

1) Eser memleket kültürü bakımından önemli görülmelidir. Bu husustaki takdir yetkisi kamulaştırma kararnamesini çıkaracak olan Bakanlar Kuruluna aittir.

2) Eser Türkiye’de veya Türk vatandaşları tarafından Türkiye dışında yayımlanmış olmalıdır. Bir yabancı tarafından Türkiye dışında yayımlanmış eser memleket kültürü bakımından önemli görülse bile kamulaştırılmaz.²²³

3) Eser nüshaları iki yıldan beri tükenmiş olmalı ve hak sahibinin uygun bir süre içinde bunun yenisini yayımlayacağı ihtimal dışı görülmemelidir. Eserin yayımlanma imkanı bulunduğu sürece, memleket kültürü bakımından önem taşısa bile kamulaştırma yapılamaz.²²⁴

4) Eserin mali haklara ilişkin koruma süreleri dolmamış olmalıdır. Mali haklar için belirtilen kanuni süreler dolmuşsa eserin herkes tarafından kullanımı serbest hale geleceğinden, kamulaştırmaya gerek kalmadan bütün üçüncü şahıslar gibi Devlet de eserden serbestçe yararlanabilir.

5) Kamulaştırma yetkisinin kullanılabilmesi için Bakanlar Kurulunun bir kararname çıkarması gerekir. FSEK madde 47/III’e göre bu kararnamede eser ve sahibinin adı, eser veya mali hak sahiplerine ödene-

²²² Bu konuda bir tüzük çıkarılmıştır. RG, 16.10.1986, S. 19253.

²²³ ARSLANLI age., s. 158 Naklen EREL, age., 238.

²²⁴ ARSLANLI age., s. 157 Naklen EREL, age., s. 238.

cek kamulaştırma bedeli, mali hakları kullanacak makam veya müessese, kamulaştırma bedelinin düşülmesinden sonra elde edilecek safi kârın hangi kültürel gayelere tahsis edileceği belirtilir.

Yukarıda açıklanan şartlar doğrultusunda, yayınlanan proje, plan gibi mimari eserlerin kültürel açıdan önem arz etmesi durumunda Bakanlar Kurulu'nun çıkaracağı bir kararname ile kamulaştırılması mümkündür.

X. HAKLARIN KORUNMA SÜRELERİ

Fikri mülkiyet haklarını Eşya Hukuku kapsamındaki maddi mülkiyet haklarından ayıran en önemli fark, fikri mülkiyete ilişkin hakların sınırlı süreli bir korumaya sahip olmalarıdır. Buradaki amaç; toplumun genel çıkarlarıyla eser sahibinin bireysel menfaatlerini dengede tutmaktır.²²⁵

Koruma sürelerinin dolmasıyla birlikte eser kamunun malı haline gelir ve eserin mali hakları, ister eser sahibinde bulunsun, ister başkalarına devredilmiş olsun sona erer ve artık bu eserler eser sahipleri, diğer hak sahipleri yada mirasçılarından izin alınmadan üçüncü kişiler tarafından serbestçe kullanılabilir. FSEK madde 26/I hükmünün yaptığı atıf uyarınca madde 46 ve 47 hükümlerinde öngörülen istisnai haller dışında²²⁶, artık herkes eseri serbestçe işlemek, çoğaltmak, yaymak ve temsil etmek imkânına kavuşur. Böylece bir mimari yapının bahsedilen koruma süresinin dolmasından sonra (örneğin; tarihi bir mimari eser olan Topkapı Sarayı gibi) kartpostallara basılarak çoğaltılması veya yayınlanması serbest hale gelmektedir. İşleme ve çoğaltmaya başka bir örnek, yakın zamanda İstanbul’da kurulan MİNİATÜRK’te yer alan tarihi yapıların minik maketlerinin yapılmasıdır.

FSEK madde 27/1’e göre; kural olarak fikir ve sanat eserleri üzerindeki mali haklar, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl süre ile korunmaktadır. 2001 yılındaki 4630 sayılı değişiklik ile birden fazla eser sahibi olması durumu da düzenlenmiş ve bu sürenin hayatta kalan son eser sahibinin ölümünden itibaren işleyeceği belirtilmiştir.

FSEK madde 27/2; sahibinin ölümünden sonra alenileşen²²⁷ (kamu- nun bilgisine sunulan) eserlerin koruma süresini, eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl olarak belirlemiştir. Sahibi belli olmayan eserlerde koruma süresi, aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Ancak eser sahibi ölümünden önce ismini açıklarsa, koruma süresi eser sahibinin ölümünden

²²⁵ SULUK/ORHAN, age., s. 521.

²²⁶ Bu istisnai durumlar; FSEK madde 46 “Devletin Faydalanma Salahiyeti” ve madde 47 de düzenlenen “Kamuya Maletme” halleridir.

²²⁷ Aleniyetin fikri hukuk bakımından sonuç doğurabilmesi için iki unsuru bünyesinde taşıması gerekir; a) Fiili Unsur; eserin fiilen umuma arz edilmesi, b) İradi Unsur; sahibinin eseri alenileştirme hususundaki niyeti.

itibaren 70 yıl olarak belirlenmiştir.²²⁸ Sahibinin adı belirtilmeden yayımlanan eserlerde aleniyet tarihinden itibaren 70 yıllık koruma süresinin dolmasından sonra eser sahibi adını açıklarsa da koruma süresi canlanmamaktadır²²⁹(FSEK madde 27/3).

Yapılan bu açıklamalar FSEK’de düzenlenen gerçek kişi eser sahiplerine ilişkin koruma süreleriydi. FSEK 27. maddenin son fıkrasında, tüzel kişilerin eser sahibi olmasına dair bir ibare bulunmaktadır. Bunun sebebi dava konusu eserin 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki kurallara bağlı olması halinde eser sahibinin tüzel kişi de olabileceğinin düşünülmesidir. Çünkü 1995 yılında 4110 sayılı değişiklikten sonra FSEK’e göre tüzel kişiler artık eser sahibi olamazlar. Bu halde de koruma süresinin aleniyetten itibaren başlayacağı belirtilmiştir.

Koruma sürelerinin sınırlı oluşu daha çok mali haklar bakımından öngörölmüş bir durumdur. Aynı sınırlamanın manevi haklar bakımından söz konusu olup olmadığı üzerinde fikir ayrılıkları mevcuttur.²³⁰

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda manevi hakların süreyle sınırlı olduğu belirtilmemiş olmakla beraber, eser sahibinin ölümünden sonra bu hakları kullanma yetkisinin kimlere intikal edeceği madde 19/2 sayılmış ve 70 yıllık bir süre getirilmiştir. Gerçekten burada hangi manevi hakların mirasçılara geçeceği ve geçen hakların ne kadar süre kullanılabileceği özellikle belirtilmiştir. Bu nedenle doktrinde kabul edilen ve manevi hakların hepsinin eser sahibinin ölümüyle son bulacağına ilişkin görüşlere katılmıyoruz.

Ancak manevi haklara ilişkin getirilen bu düzenlemenin iki istisnası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, eserin ülkenin kültürü bakımından önemli olduğu hallerde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın süreye tabi olmandan sayılan hakları kullanabileceğidir. İkincisi ise, mali bir hakkı devralmış olan külli ve cüzi haleflerin ilgili manevi hakları kullanabilecek olmalarıdır.

²²⁸ Eser sahibinin ölümünden sonra isim açıklama yetkisi FSEK madde 19 da belirtilen kimselere geçer. Bu kişilerin isim açıklama suretiyle koruma sürelerini eser sahibinin ölümünden itibaren daha 70 yıl süreyle uzatma imkanı doğacaktır. Ancak öğretide, gizli tutulan ismi açıklayarak koruma süresini uzatma yetkisinin 17. maddenin 3. fıkrası gereği, sadece eser sahibine tanınmış olduğu kabul edilmektedir. Bkz. EREL, age., s. 95; SULUK/ORHAN, age., s. 522; AYİTER, age., s. 152-153; ARSLANLI, age., s. 119.

²²⁹ SULUK/ORHAN, age., s. 522.

²³⁰ EREL, age., s. 94.

Söz konusu bu koruma süreleri hakkında, FSEK de ölüm veya ailenileşme tarihlerinin hangisinden itibaren başlayacağı kesin olarak seçilmemiş olup, bunlardan birinin gerçekleştiği yıldan sonraki yılın ilk günü 70 yıllık sürenin başlayacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.

XI. MİMARİ ESERLERE İLİŞKİN TECAVÜZLER VE DAVA YOLUYLA KORUNMASI

Hangi alanda olursa olsun; tecavüz eden (saldırgan), başkasının hukuken korunan hakkına müdahale etmektedir. Yapılan bu müdahale, haksız ve hukuka aykırı olduğu ve başkasına ait bir hakkı ihlal ettiği için, hukuken tecavüz haksız fiil olarak kabul edilmektedir.²³¹ Fikri Mülkiyet Hukuku’nda ayrıca; tecavüze yakın bir kavram olarak “intihal” kavramı kullanılmaktadır. İntihal sözlük anlamı itibariyle, “*aşırma, başkasına ait bir eseri kendisininmiş gibi gösterme*”²³²; *kaynak göstermeksizin başkasının eserinden parça alma*”²³³ anlamında olup, hukuk düzeninde bu anlam kabul edilmiş ve eylem yasaklanmıştır (FSEK madde 66 vd.).²³⁴

Fikri Mülkiyet Hukukundaki bir başka tecavüz yöntemi olan “iktibas”; sözlük anlamıyla “*bir yazıya başka bir yazarın yazısından alınmış parça*” veya “*aktarma*”dır. FSEK’de kullanılan anlamıyla ise, “*alenileşmiş bir eserden bazı cümle, paragraf, motif ve tınların, ezgilerin ya da güzel sanat eserlerinin aynen alınması*”dır. İktibas gerekli şartları taşıyorsa serbesttir ve hukuka uygun bir davranıştır. İktibasın şartlarından olan alenileşme şartı güzel sanat eserleri için de geçerlidir. İktibas serbestisi genel olarak; sanatın, bilimin, eğitimin ve kültürün gelişimi için getirilmiştir. Ancak bu serbestinin bazı sınırları bulunmaktadır. Örneğin; mimari eserler gibi güzel sanat eserlerinden yapılan iktibaslar sadece o konuyu ilmi bakımından incelemeye yönelmiş metodik ve sistematik eserlerde kullanılabilir. Bu iktibaslar edebiyat, sinema yahut başka güzel sanat eserlerine konulamazlar; mesela tersi bir olayda bir rölyefin iktibas olunarak bir mimari eserde kullanılması mümkün değildir.²³⁵

Kanun ilmi konferans veya derslerde yapılacak iktibasların projeksiyon vb. vasıtalarla gösterme suretiyle olacağını belirtmektedir. Kanaati-

²³¹ HGK,17.12.1997, E.1997/11-836,K. 1997/1075. (Yargıtay Kararları No: 16)

²³² Ferit DEVELİOĞLU/Neval KILIKÇINI, Osmanlıca – Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler Kitapevi, İstanbul, 1983, Cilt 5, s. 161.

²³³ Ejder YILMAZ, Hukuk Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara 1976, s. 72.

²³⁴ HGK, 29.1.2003, E. 2003/4-47,K.2003/37.

²³⁵ AYİTER: age., s. 165 Naklen EREL, age., s.216.

mizce bu emredici değildir ve eserin aslının gösterilmesi suretiyle temsil de mümkün sayılmalıdır.²³⁶

Yapılan bu kısa tanımlardan sonra tekrar konuya dönersek; mimari eserler üzerindeki mali ve manevi hakların ihlalleri halinde bir tecavüzün varlığından bahsedilebilmektedir ve buna ilişkin Kanun'da sayılan davalara (hukuk ve ceza davalarına) müracaat edilerek korunmadan yararlanılır.

Söz konusu bu tecavüz ve korunma yöntemlerinden bahsederken; bu çalışmada konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve somut örneklerle güçlenmesi için, Yargıtay kararları kullanılacaktır.

A. HUKUK DAVALARI

Kanun koyucu eser sahiplerini korumak için değişik dava ve talep hakları tanımıştır. Bu anlamda hak sahibine tanınan hukuk davaları şu şekildedir.

1. Eser Sahibinin Tespiti Davası:

FSEK madde 15'e göre; eser sahibini belirlemek için açılan bir davadır. Bu dava eda niteliğine sahiptir. Çünkü dava sonunda sadece eser sahibi ortaya konmamakta aynı zamanda eserin sahipliği davayı kazanana verilmektedir. Bu dava iki halde açılmaktadır;

a) Eserin kimin tarafından vücuda getirildiğinin ihtilaflı olduğu durumlarda veya

b) Herhangi birinin eserin sahibi olduğunu iddia ettiği hallerde.

Açılan davayı sonuçlandırabilmek için öncelikle mevcut eserin gerçekte kime ait olduğunun ispatlanması gerekmektedir.

Yargıtay'ın bu konuya ilişkin verdiği kararlardan birinde²³⁷; davacılar, kendilerine ait mimari projenin 4.3.1991 tarihli sözleşme ile İstanbul Bahçeşehir 1. Etap 1-2 Kısım inşasında kullanıldığını, ancak davalının İzmir Mavişehir'de inşa ettiği konutlarda da bu projeyi izinsiz olarak kullandığını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuşlardır. Yargıtay bu olayda, uygulanan mimari projelerin kime ait olduğunun tespiti için yerinde keşif yapılarak eser sahibinin kim olduğunun belirlenme-

²³⁶ EREL, age., s. 215.

²³⁷ 11.HD.1.6.2004, E. 2003/10569, K. 2004/6137. (Yargıtay Kararları No: 51)

sini gerekli görmüş, yerel mahkemenin eksik inceleme yapmış olduğunun belirterek davayı yerel mahkemeye geri yollamıştır.

Yargıtay bir başka olayda²³⁸ ihtilafın, yapıda kullanılan mimari projenin kime ait olduğu noktasında düğümlendiğine dikkat çektikten sonra yapıda kullanılan projenin davacıya ait olup olmadığının belirlenmesi gerektiğine hükmetmiştir.

Doktrinde²³⁹ genel kabul edilen görüşe göre; eser sahibinin tespiti davası, intihali (eser hırsızlığını) kapsamamaktadır. İntihalde mimari eser zaten sahipli olup, sahipliği çekişmesiz bulunan aleniyete kavuşmuş veya yayımlanmamış bir eserden, eser sahibinin adı zikredilmeden **uygun görülmeyecek ölçüde** aktarma, yani çalma vardır. İntihalde bulunan kimse, başkasının eserini kendi eseri gibi göstermektedir.²⁴⁰

Tespit davası somut olayın özelliğine göre; hasımlı veya hasımsız açılabilir. Hasımlı ise, davalı duruma göre belirlenmektedir. Davacı ise, eser sahipliği iddiasında bulunan kimsedir. FSEK madde 19'daki kişiler (eser sahibinin ölmeden önce manevi hakları kullanma konusunda yetkilendirdiği kişiler, böyle bir yetkilendirme yoksa vasiyeti tenfiz memuru, vasiyeti tenfiz memuru tayin edilmemişse sırasıyla; sağ kalan eş ve çocuklar, mansup mirasçılar, ana-baba, kardeşler, mali hak sahipleri) eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl içinde bu davayı açabilmektedirler. Kültür ve Turizm Bakanlığı da FSEK madde 19'daki şartların varlığı halinde bu davayı açabilmektedir.

Bu davadan önceden feragat mümkün değildir. Bu davada zamanaşımı cereyan etmemektedir. Çünkü tecavüzün devamı süresince; tespit, durdurma ve önleme davaları açılabilir. Yargıtay²⁴¹ koruma süresi

²³⁸ “ Davacı tarafından davalı... ya ait arsa üzerinde yapılacak iş merkezi için bir anlaşma yapılmıştır. Bunun sonucunda davacı tarafından yapılan çizim ve çalışmalar davalıya sunulmuştur. Uyuşmazlık konusu; davacının yaptığı çalışma sonucu meydana getirdiği projelerin hazırlık çalışması mı, yoksa uygulama projesi niteliğinde mi bulunduğu ve bu projelerin yapılan iş merkezinde ne ölçüde uygulandığı, diğer bir anlatımla binanın yapılışında kullanılan projenin davacının yaptığı projelerin ne ölçüde özelliklerini taşıdığı ve davacının yaptığı projeye göre halen binanın yapılışındaki projenin ayrı bir özellik taşıyıp taşımadığı noktasında toplanmaktadır.” 4.HD.23.11.1999, E. 1999/6241, K.1999/10212 Yasa Hukuk Dergisi, C.XIX, S.226/2000, s. 1227-1228 (Yargıtay Kararları No: 29-30)

²³⁹ EREL, age., 121

²⁴⁰ TEKİNALP, age., 292.

²⁴¹ 11.HD. 13.3.1995, E. 1994/6106, K. 1995/1880. (Yargıtay Kararları No: 9)

dolan eserler bakımından da eser sahipliğinin tespiti davasının açılabilmesine haklı olarak karar vermiştir. Zira eser sahibi olarak tanıtılma hakkı manevi bir hak niteliğindedir.

2. Tecavüzün Ref'i Davası:

FSEK madde 66 ve 68'e göre; ref davası, bir tecavüz gerçekleşmiş ve sonuç doğurmuşsa açılmaktadır. Bu dava ile, tecavüzün giderilmesiyle birlikte ortaya çıkan sonuçların kaldırılması talep edilmektedir. Davalıların kusuru şartı aranmamaktadır.

Bu davalar FSEK 66. maddesinde şöyle düzenlenmiştir.

“Henüz alenileşmemiş bir eser, sahibinin rızası olmaksızın veya arzusuna aykırı olarak umuma arz edildiği takdirde tecavüzün ref'i davası, ancak umuma arz keyfiyetinin çoğaltılmış nüshaların yayımlanması suretiyle vakı olması halinde açılabilir. Aynı hüküm, esere, sahibinin arzusuna aykırı olarak adının konulduğu hallerde de caridir.

Eser üzerinde sahibinin adı hiç konulmamış veya yanlış konulmuş yahut konulan ad iltibasa meydan verecek mahiyette olup ta eser sahibi 15 inci maddede zikredilen tespit davasından başka tecavüzün ref'ini talep etmişse, tecavüz eden gerek aslına, gerek tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalar üzerine eser sahibinin adını derç etmeye mecburdur. Masrafı tecavüz edene ait olmak üzere, hükmün en fazla 3 gazetede ilanı talep edilebilir.

FSEK Madde 32 (söz ve nutukların Kanun'daki istisnalar dışında çoğaltımı), 33 (yayınlanmış eserlerin eğitim ve öğretim gayesi ile kullanılması) , 34 (eğitim ve öğretim amacıyla seçme ve toplama eserler oluşturulması), 35 (bilimsel eserlerde ve konferanslarda iktibas yapılması), 36 (basında yer alan eserlerden haber amaçlı alıntılar yapılması), 39(kalktı) ve 40 ıncı (güzel sanat eserlerinin umuma açık yerlerde temsili, umuma açık yerlerdeki eserlerden çoğaltma yapılarak yararlanılması, açık arttırma konusu eserlerin katologa basılması) maddelerde sayılan hallerde yanlış veya kifayetsiz kaynak tasrih edilmiş veyahut hiç kaynak gösterilmemişse ikinci fıkra hükmü uygulanır.

Eser haksız olarak değiştirilmiş ise hak sahibi aşağıdaki taleplerde bulunabilir:

1. Eser sahibi, eserin değiştirilmiş şekilde çoğaltılmasının, yayım ve temsilinin, radyo ile yayımının menedilmesini ve tecavüz edenin, tedavülde bulunan çoğaltılmış nüshalardaki değişiklikleri düzeltmesini veya bunların

eski haline getirilmesini talep edebilir. Değişiklik, eserin, gazete, dergi veya radyo ile yayımı sırasında yapılmışsa eser sahibi, masraflı tecavüz edene ait olmak üzere, eseri değiştirilmiş şekilde yayımlanmış olan bütün gazete, dergi ve radyo idarelerinden değişikliğin ilan yolu ile düzeltilmesini talep edebilir;

2. Güzel sanat eserlerinde eser sahibi asıldaki değişikliğin kendisi tarafından yapılmadığını veya eserdeki adının kaldırılmasını yahut değiştirilmesini talep edebilir. Eski halin iadesi mümkün ise değişikliğin izalesi ammenin veya malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser sahibi eseri eski hale getirebilir”

Doktrinde bu davayı eser sahibinin yanında izin (lisans) sahibinin de açıp açamayacağı konusunda tartışmalar bulunmaktadır. Bir görüşe göre²⁴²; lisans sahibi davayı açabilmektedir. Diğer görüşe göre ise²⁴³; lisans sahibi sadece sözleşme çerçevesinde izin verene başvurarak, ondan ref davasının açılmasını isteyebilir. Tekinalp²⁴⁴, mali hakları devralanın bu davayı açabileceğini, ancak izin (lisans alanın) sahibinin sadece maddi tazminat davası açabileceğini, ref davasını açamayacağını savunmaktadır.²⁴⁵

İşbu dava mimari eserler açısından özellik arz etmektedir. FSEK madde 67/son’a göre mimari eserlerde bir değişiklik söz konusuysa, yasa da öngörülen şartların varlığı halinde eski hali iade talep edilebilecektir. Bu durum tüm güzel sanat eserleri için de geçerlidir.

Mimari eserler olan yapıların estetik özelliklerinin yanında fonksiyonel özelliklerinin de bulunması nedeniyle; Yargıtay’ın mimari eserlere ilişkin tecavüzün ref’i davasına dair birçok kararı bulunmaktadır. Yargıtay bu konudaki bazı kararlarında mimari eserle ilgili olarak eski hale iade talebini kabul etmekte, ancak maddi zarar oluşmadığı gerekçesi ile maddi tazminat istemini reddetmektedir.²⁴⁶

Yargıtay; mimari eserlerin renginde değişikliğe gidilmesi halini, eserde izinsiz değişiklik ve hak ihlali olarak kabul etmiştir. Bu karar so-

²⁴² EREL, age., s. 294.

²⁴³ AYİTER, age., s. 254 Naklen SULUK/ORHAN, age., s. 784.

²⁴⁴ TEKİNALP, age., s. 278.

²⁴⁵ Mali haklar açısından izin ve devir arasındaki farklar açısından sayfa 40’daki açıklamalarımıza bakınız.

²⁴⁶ 11. HD., 1.7.1996, E. 1996/2451, K. 1996/4820. (Yargıtay Kararları No: 13)

nucu, mimari eserin renginin bozulmasının eser sahibinin özelliğini ve eserin orijinallliğini bozduğunu belirtilerek tecavüz olarak nitelendirmiştir. Ve yapılan değişikliğin eski hale getirilmesi amacıyla orijinal rengine boyatılması suretiyle tecavüzün önlenmesine ve manevi tazminata hükmedilmiştir.²⁴⁷

Yargıtay'ın mimari eserlerde yapılan değişikliklerle ilgili olarak verdiği bir başka karar şöyledir²⁴⁸; Davacı, proje müelifi olduğu bir otelin davalı tarafından diğer davalıya kiralandığını ve kiracı tarafından davacının onayı olmadan otelin mimari yapısını ortadan kaldıracak şekilde eklemeler ve tadilatlar yaptığını ileri sürerek, eserin eski hale iadesini ve maddi-manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Otel sahibi davalı, sorumluluk ve giderlerin kiracı davalıya ait olmak üzere, kullanım amacına uygun zorunlu tadilatlar yapıldığını belirterek sorumluluğunun olmadığını savunmuştur. Bu iddia ve savunmalar üzerine Yargıtay; *“güzel sanat eserleri, haksız ve eser sahibinin rızası olmadan değiştirilmişse, eski hale iadesi mümkünse ve değişikliğin ortadan kaldırılması kamunun ve malikin menfaatlerini esaslı suretle zarara uğratmıyorsa, eserin eski hale getirilebileceğini, aksi halde eser sahibinin eserdeki adının kaldırılmasını isteyebileceğini”* karar altına almıştır. Dikkat edersek Yargıtay bu kararda, değişikliklerin tam olarak ortadan kaldırılması için gerekli şartların bulunması gerektiğini vurgulamıştır. Bu şartlar; eski halin iadesinin mümkün olması, (bu şart kanunun öngördüğü bir şart olmayıp, eşyanın tabiatından doğmaktadır) ve değişikliğin kaldırılması kamunun yada malikin menfaatlerin önemli biçimde ortadan kaldırmamalıdır. Ayrıca Yargıtay, eski hale iadesine karar verilmesi halinde infazın ne şekilde yapılması gerektiği konusunda da gerekçeli kararı yazan hakimlerin ayrıntılı bir açıklama yapması gerektiğini belirterek, nasıl uygulanacağını, nelerin düzeltileceğini belirtmeden soyut olarak eski hale getirme kararı verilmesini uygun bulmamıştır.

Başka bir kararda ise; zaruri hallerde mimari projede değişiklik yapılabileceğine hükmedilmiştir.²⁴⁹ Yargıtay'ın bu kararında olan “eserdeki değişikliğin ve yapanın tanıtılması” ve “ilk ve eser sahibi mimarın isminin kaldırılması” çözümleri büyük önem taşımaktadır. Zira uygulamada bazı eserlerde bu tür değişikliklerin yapılması, çıkacak olan daha büyük problemleri engellemektedir.

²⁴⁷ 11. HD., 22.6.1998, E. 1998/3246, K. 1998/4717. (Yargıtay Kararları No: 20)

²⁴⁸ 11. HD., 29.3.2001, E. 2001/143, K. 2001/2548. (Yargıtay Kararları No: 40)

²⁴⁹ 11. HD., 18.5.2004, E. 2004/5177, K. 2004/5598. (Yargıtay Kararları No: 50)

Yargıtay'ın FSEK madde 68/2 hükmünü göz önüne bulundurarak verdiği bir karara göre; davacıya ait projelerin biraz değiştirilmesi suretiyle davalı şirkete ek binalar yapılması sonucu, tarafların aralarında (yeni işe ilişkin) bir sözleşme olmaması ve eser sahibinin de izni olmaması sebepleri ile maddi tazminat olarak eser sahibinin yeni yapılarda kullanılan proje için (farazi bir sözleşme varolsaydı) isteyebileceği normal bedelin 3 kat fazlasını isteyebileceği sonucuna varılmıştır.

Farazi bir sözleşme varlığı konusundaki Yargıtay'ın ilk kararı 1958 tarihinde verilmiştir. Önemle belirtmek gerekir ki; Yargıtay'ın farazi sözleşme görüşünün bazı hukuki sonuçları bulunmaktadır. Çünkü bu görüş ile uyuşmazlıkta haksız fiil hükümleri yerine sözleşmeye ilişkin hükümler uygulanacaktır. Bunun hukuki sonuçlardan biri, zamanaşımı süresiyle ilgilidir. Haksız fiillerde bir ve on yıllık zamanaşımı süreleri uygulanmaktayken; FSEK madde 68'e göre (yani projesini bir bedel karşılığı yapmış gibi) maddi tazminat istemine dayanılarak açılan davalarda, bu süre on yıla çıkmaktadır. Ayrıca davacı artık FSEK madde 68'e dayandığı için tecavüzün menî gibi haksız fiile dayanan veya tecavüzün ortadan kaldırılmasını isteyen taleplerde bulunamayacaktır. Çünkü neticede mimar parasını fazlasıyla almakta ve Yargıtay hizmete bedel ödendiğinden yasaklama ve engelleme yapmanın iş sahibini aşırı zarara uğratacağını düşünmektedir.

Yapılan bu açıklamalardan sonra kanaatimizce, tecavüzün ref'i davasının hukuki niteliğinin çoğu kez haksız fiil olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle BK madde 41 ve devamındaki tamamlayıcı hükümler uygulanmaktadır. Tecavüz devam ettiği sürece zamanaşımı devam etmemektedir. Aksi halde BK madde 60 uygulanmaktadır. Fakat tecavüz bir sözleşmenin ihlali niteliğini taşımaktaysa; BK madde 125 deki on yıllık zamanaşımı uygulanmaktadır.

Tecavüzün refi davası FSEK madde 66/son hükmüne göre; eser sahibinin ikametgahında açılabilir.

3. Tecavüzün Menî Davası:

FSEK madde 69'a göre; tecavüz (saldırı) veya tecavüz tehlikesinin bulunduğu zamanlarda tecavüzü veya tecavüz tehlikesini ortadan kaldırmak için açılan bir davadır. Davalının kusurunun olması şartı aranmaktadır. Yine aynı şekilde, mevcut bir tecavüzün devamını önlemek için de bu dava açılabilir. Ref davasından en önemli farkı; tecavüzün sonuçlarını ortadan kaldırma gayesinin olmamasıdır. Men davasındaki

amaç; tehlikenin somut bir eyleme dönüşmesinin önlenmesidir. Ayrıca ref ve men davaları birlikte de açılabilirler. FSEK madde 66 bu davanın da tıpkı ref davasında olduğu gibi; eser sahibinin ikametgahı mahkemelerinde açılacağını vurgulamıştır. FSEK 66. maddenin iki, üç ve dördüncü fıkraları bu davalar hakkında da uygulanır.

Men davasının zamanaşımı yoktur. Çünkü tecavüz devam ettiği müddetçe bu dava açılabilir.

Bu davanın davacısı, ref davasında olduğu gibi, eser sahibi ve FSEK madde 19’da sayılan kimselerdir. Ancak madde 69/1 hükmünde bulunan *“mali ve manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibi muhtemel tecavüzün önlenmesini dava edebilir. Vaki olan tecavüzün devamı veya tekrarı muhtemel görülen hallerde de aynı hüküm caridir.”* şeklinde ifade ile yalnızca “eser sahibi”nin bu davayı açabileceğine ilişkin bir sınırlama olduğunu düşünmemek gerekir. Çünkü ref davası, men davasına göre daha engelleyici olmasına karşılık, onda dahi FSEK madde 19’daki kişiler bu davayı açabilirler. Ayrıca madde 69/1 metnini yorumlarken kapsamını dar düşünmek; Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun “eser ve diğer hak sahiplerini haklara saldıranlara karşı koruma” amacı ile çelişki oluşturur.

4. Tecavüzün Tespiti Davası:

FSEK tecavüzün tespiti davasını, saldırılara karşı açılacak davalar arasında düzenlenmemektedir. Bu dava şartlarının varlığı halinde Türk Ticaret Kanunu madde 57 ve Medeni Kanun madde 25’e dayanarak da açılabilir. FSEK madde 19’da sayılan kimseler bu davaları açabilir kanaatindeyiz. Bu davada tecavüzün varlığı ve hukuka aykırı olduğu mahkeme kararı ile saptanır.

Bu davanın açılabilmesi için kusur şartı aranmamaktadır. Yalnızca fikinsel ve sanatsal haklara saldırının bulunması yeterlidir.

Tazminat veya eski hale getirme gibi davalı tarafından bir eylemin yapılmasını gerektiren eda davasının açılacağı hallerde, sadece soyut olarak saldırının veya saldırganın mahkemece belirlenmesini isteyen ve bir eylem talep edilmeyen tespit davası açılmamaktadır. Bununla ilgili bir Yargıtay kararında, *“davacıların tespitini talep ettikleri hususların derhal tespiti gereken hususlardan olmadığı, bunların açılacak bir eda davasında*

*incelenecek ve değerlendirilecek konulardan olduğu” sonucuna varılmış ve dava reddedilmiştir.*²⁵⁰

Tespit davasındaki zamanaşımı için her ne kadar TTK madde 62’deki bir ve üç yıllık zamanaşımının uygulanacağı belirtilse de; yapılan eylemin fikirselsel ve sanatsal haklara bir saldırı olup olmadığına ilişkin bir dava olduğu için, yani tecavüz veya tecavüzün etkileri devam etmekte olduğundan davada zamanaşımı işlemeyecektir. Sona ermiş bir tecavüzün tespiti davasının açılmasına -eğer tecavüzün etkileri artık devam etmiyorsa- hukuk sistemimiz izin vermemektedir. Ancak istisnai olarak böyle bir davanın açılabilmesi olasılığı varsa, TTK madde 62’deki kural gereğince, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren bir ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıllık sürede davasını açıp açmadığı dikkate alınmalıdır²⁵¹.

5. Tazminat Davaları:

a. Manevi Hakların İhlali Halinde Tazminat Talebi;

FSEK madde 70’de manevi haklara saldırının varlığı halinde manevi tazminat isteminde bulunulabileceği belirtilmektedir. Bunun için davalının kusuru şartı aranmaktadır, ancak kusurun ağırlığı bu tazminat isteminde bulunmak için önem taşımamaktadır. Hatta uygulamada Yargıtay kararlarının geneline bakıldığında manevi bir hakkın ihlali halinde hemen hemen her durumda tazminata hükmedilmekte; kusurun varlığının araştırılmasına gerek görülmemektedir.

FSEK de madde 14 (ilk defa kamuya sunuş hakkı), madde 15 (eser sahibinin adının belirtilmesi hakkı), madde 16 (eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı) ve madde 17’de (eser sahibinin eseri elinde bulunduran ve sahip olana karşı engelleme hakkı) sayılan manevi haklardan biri çiğnenmişse ve bu eylem kusurlu olarak işlenmişse, ilgilinin dava açması halinde manevi tazminata hükmetmek gerekmektedir.

Bazı durumlarda; manevi hakların ihlali sonucunda ortaya çıkan zararın büyüklüğü ve hak sahibinin mali durumu tazminat miktarını etkilemektedir. Bazen oluşan zararı gidermek için, manevi tazminat isteminin yanında maddi tazminat isteminde de bulunmaktadır. Örneğin izinsiz olarak yapılan ve eserin özgünlüğünü bozan bir değişiklik sonucu, bu ey-

²⁵⁰ 11. HD., 4.4.2005, E. 2004/6683, K. 2005/3135. (Yargıtay Kararları No: 60)

²⁵¹ TEKİNALP, age., s.307.

lemin eser sahibi mimar tarafından yapıldığının sanılması, o mimar için kötü bir şöhrat yaratarak, yeni işler alamamasına veya elindeki başka bir işin işveren tarafından iptal edilmesi sonucu maddi zarara neden olabilir. FSEK madde 70; sadece Kanun'da sayılan manevi hakların ihlali halinde manevi tazminat talebinde bulunulabileceğini düzenlemektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun verdiği 18.12.1981 tarihli kararda; eser sahibinin eseri üzerindeki manevi hakları ile kişisel menfaatlerinin birbirinden ayrı olduğu belirtilmiş, eser sahibinin FSEK'te sayılan manevi haklarının ihlali halinde isteyebileceği manevi tazminatın FSEK'te düzenlendiği, ancak FSEK'te yazılmayan şekillerdeki kişisel menfaat ihlallerinde isteyebileceği tazminatın ise BK madde 49'a bırakıldığı açıklanarak, ilgilinin genel olarak mülkiyet veya mesleki onur ihlallerinde Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu'nun kişilik hakkı ihlallerine ilişkin manevi tazminat hükümlerinden yararlanılacağı söylenmiştir.²⁵²

FSEK uygulaması açısından; manevi tazminat davasının açılması için eser sahibinin herhangi bir manevi hakkının ihlali yeterli olmaktadır.²⁵³ Ancak, 29.3.2001 tarihli ve 493/2537 sayılı yayımlanmamış bir karara göre; hangi manevi hakların ihlal edildiğinin özellikle davada belirtilmesi gerektiği üzerinde durulmuştur. Buradaki Yargıtay'ın kararına göre; sadece manevi hakların hangilerinin ihlal edildiğinin davada belirtilmesi yeterli bulunmuş, sebep-sonuç ilişkisi ve bu ihlal nedeniyle bir zararın bulunduğu ispatlanması şartı getirilmemiştir.

Yine Yargıtay²⁵⁴, davacı mimarlardan izin alınmadan onların mimari projelerinin kullanılmasına ve kopyalanmasına ilişkin olarak; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, dava konusu projenin önem ve değeri ve kopyalama biçimine bakarak FSEK madde 70/1-2 nci maddeleri gereğince uygun bir manevi tazminatın verilmesine karar vermiştir.

Yargıtay, manevi zararın tazmini için bir miktar paranın verilmesinin yanında, paraya ek olarak kararın gazetelerde ilanı gibi başka yaptırımları da karara bağlayabilmektedir.

Manevi hakların ihlali halinde bu davanın davacısı eser sahibidir. Mirasçılarının ise bu davayı açıp açamayacakları Türk Hukuku'nda tartışmalıdır.²⁵⁵ FSEK madde 19 gereğince eser sahibine ait manevi hakların

²⁵² HGK., 18.12.1981, E. 1980/1, K.1981/2.

²⁵³ 11. HD., 4.06.2001 tarihli kararında kabul edilmiştir. Naklen TEKİNALP, age., s. 308.

²⁵⁴ 11. HD., 19.3.2002, E. 2001/10702, K. 2002/2515. (Yargıtay Kararları No:44)

²⁵⁵ TEKİNALP, age., s.309.

mirasla mirasçılara geçmesi mümkün olmadığı için; ancak eser sahibinin mirasçıları veya vasiyeti tenfiz memuru açısından saldırganlar tarafından yapılan eylem, onların eser sahibinin yakınları olmaları sıfatıyla kişisel bir zararlarına yol açıyorsa bu davayı açabilecekleridir. Yargıtay'ın aksi sonucunu doğuran bir kararına göre²⁵⁶; “... 19/2. madde, aynı yasanın 19/1. maddesinde sayılan kimselerin, eser sahibinin ölümünden sonra, eser sahibinin 14, 15 ve 16. maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kullanabilecekleri öngörüldüğünden, manevi zararın giderilmesini isteme haklarının da bulunduğu kabulü gerektiği” belirtilerek, “davacılar yararına münasip bir manevi tazminata” hükmedilmiştir. Yargıtay'ın verdiği bu karar; manevi tazminat davasını, eser sahiplerinin yanında mirasçılar hatta mali hak sahiplerinin de açabileceğine ilişkin HGK'nun verdiği, 1983 tarihli kararına dayanmaktadır.²⁵⁷ Ancak HGK'nun verdiği karar FSEK hükümlerine uygun düşmemektedir. Nitekim Yargıtay verdiği yeni tarihli başka bir kararda, mali hakları devralan kimsenin manevi tazminat isteyemeyeceği sonucuna varmıştır.²⁵⁸

Yargıtay'ın bu konuya ilişkin bir başka kararı ise şöyledir.²⁵⁹ “Dava-cılar miras sonucu elde ettikleri eserin, davalı yayıncı şirket tarafından kendilerinden izin alınmadan yayınladığını belirterek maddi ve manevi tazminat ödenmesini ve verilecek kararın gazetede ilanını talep etmişlerdir... 5846 sayılı FSEK'in 63. maddesi gereğince, bu Kanun ile tanınan mali haklar miras yolu ile intikal etmektedir. Eser sahibinin aynı Kanun'dan doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılara intikal etmemekle birlikte, eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek olanlar; tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru, tayin edilmişse sağ kalan eşi, çocukları, mansup mirasçıları, ana babası ve kardeşidir. Görülen davada, işleme eser sahibinin mirasçısı olan davalıların istemi, eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK'in 14. maddesi yoluyla aynı Yasa'nın 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduğuna göre, FSEK'in 19/1. maddesi uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olamayacağı için istem reddedilmiştir.”

²⁵⁶ 11. HD., 3.7.2000, E. 2000/4764, K. 2000/6252. (Yargıtay Kararları No: 35)

²⁵⁷ HGK., 11.2.1983, E. 4-70, K.123. (Yargıtay Kararları No: 4)

²⁵⁸ 11. HD., 16.6.2003, E. 2003/784, K. 2003/6343. (Yargıtay Kararları No: 47)

²⁵⁹ 11. HD., 22.12.2005, E. 2004/14950, K. 2005/12769 (YKD., Cilt: 32, Sayı: 4, Nisan 2006). (Yargıtay Kararları No: 61)

Dava bu saldırıdan sorumlu olan kişiye karşı açılmaktadır. Aynı zamanda işyeri sahipleri çalıştırdığı kişilerin fiilinden sorumlu olduğundan ona da dava açılabilir.

Bu davanın zamanaşımı BK madde 60'a tabi bulunmaktadır. Zamanaşımı süresi saldırının veya saldırganın öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halde zarara sebep olan fiilin öğrenilmesinden itibaren on yıldır. Yargıtay'ın zamanaşımı süresine ilişkin bir kararında; mimari eserin eser sahibinden izinsiz olarak kullanılması sebebiyle açılan rölöve bedeli ve manevi tazminat bedeli davasında; dava konusu projenin FSEK anlamında bir eser olduğu sonucuna varılarak, tarafların aralarındaki istisna sözleşmesine dayalı bir durum olmadığı; bu nedenle istisna sözleşmelerine özgü BK madde 126'daki 5 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmayacağı sonucuna vararak bir ve on yıllık süreleri kabul etmiştir²⁶⁰.

Açılacak bu davada yetkili mahkeme FSEK madde 66/son'daki gibi eser sahibinin ikametgahı mahkemesi değildir. Tazminat davalarında yetkili mahkeme HUMK hükümlerine göre, davalının ikametgahı mahkemesi olarak belirlenmektedir. Ancak EREL'in görüşüne göre; tazminat davalarının da bu kural dahilinde açılabilmesi gerekmektedir.

b. Mali Hakların İhlali Halinde Tazminat Talepleri;

Mali hakların ihlali hallerinde haksız fiil hükümleri uygulandığından maddi tazminat istenilmektedir. İşleme, çoğaltma, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ihlal edilen eser sahibi veya eser sahibinden bu hakları devralan (veya lisans alan) kimse, FSEK madde 40/2'ye göre; **tecavüz edenin kusuru bulunmak şartıyla** haksız fiil hükümlerine dayanarak tazminat isteyebilecektir²⁶¹. Ancak mali haklara yapılan saldırı eylemi sonucunda, eser sahibinin manevi hakları da zarar görmüş olabilir. Bu durumda önceki bölümde anlatıldığı şekilde maddi tazminata ek olarak manevi tazminat isteminde bulunulabilir.

FSEK 70 gereğince, mali hakların ihlali halinde maddi tazminat talep edebilmek için ortada bir **kusur olmasının** yanı sıra **maddi zararın da bulunması** gerekmektedir. Ancak bir mimari plan veya projeden oluşan eser, izinsiz çoğaltılıp da çoğaltılan nüshaları henüz satışa çıkarılmadıysa; eser sahibinin FSEK madde 68 uyarınca eserin izinsiz çoğaltılan kopyalarını imha, basılan kopyaların kendisine devri talebi veya üç katı tazminat

²⁶⁰ 11. HD., 7.4.2003, E. 2002/10981, K. 2003/3385. (Yargıtay Kararları No: 45)

²⁶¹ YARSUVAT, age., s.22; YAVUZ, age., s.552 Naklen SULUK/ORHAN, age., s.801.

isteme hakkı da vardır. FSEK madde 68'e göre açılacak maddi tazminat davasında ise FSEK madde 70'deki maddi tazminat davasından farklı olarak, davalının kusuru şartı aranmamaktadır.

FSEK madde 68 şu düzenlemeleri getirmektedir.

“Eser, eser sahibinin izni olmadan çevrilmiş, sözleşme dışı veya sözleşmede belirtilen sayıdan fazla basılmış, diğer biçimde işlenmiş veya radyo-televizyon gibi araçlarla yayınlanmış veya temsil edilmiş ise; izni alınmamış eser sahibi, sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebilir. Bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşü esas alınır.

Bir eserden izinsiz çoğaltma yolu ile yarar sağlıyorsa ve çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmamışsa, eser sahibi; çoğaltılmış kopyaların, çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını veya maliyet fiyatını aşmamak üzere çoğaltılmış kopyaların ve çoğaltmaya yarayan film, kalıp ve benzeri gereçlerin uygun bir bedel karşılığında kendisine verilmesini ya da sözleşme olması durumunda isteyebileceği miktarın üç kat fazlasını talep edebilir. Bu husus, izinsiz çoğaltma yoluna giden kişinin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Bir eserin izinsiz çoğaltılan kopyaları satışa çıkarılmışsa veya satış haksız bir tecavüz oluşturuyorsa, eser sahibi tecavüz edenin elinde bulunan nüshalar hakkında ikinci fıkrada yazılı şıklardan birini seçebilir.

Bedel talebinde bulunan kişi, tecavüz edene karşı onunla bir sözleşme yapmış olması halinde haiz olabileceği bütün hak ve yetkileri ileri sürebilir.”

Yargıtay FSEK madde 68'deki istemlerle ilgili olarak mimari eserlere ilişkin şöyle bir karar vermiştir. “... Davacının davalı şirket için atık arıtma tesisi yaptığı, ancak daha sonradan fabrikaya yeni kurulan boya imalat ünitesinin arıtma tesislerinin de davacı mimarın projelerini izin alınmadan kullanmak suretiyle yapıldığı sonucuna varılmıştır. Ayrıca davalının davacıya ait tabelayı da çıkararak kendi tabelasını koymuş olduğu belirlenmiştir.” Yargıtay, bu tespitlerden sonra arıtma tesisleri projelerinin FSEK kapsamında korunmaya değer bir fikri eser olduğu sonucuna varmış ve buna ilişkin eski hale iade talebini kabul etmiş, ancak maddi zararın kanıtlanamaması nedeniyle maddi tazminat talebini reddetmiştir. Yargı-

tay'ın bir başka kararında ise²⁶²; “davacılar tarafından bir üçüncü şirket adına çizilen ve davalı A.Ş. tarafından yaptırılan fabrika binasına ilişkin mimari projenin, mahallinde uygulanarak inşaatın tamamlandığı, ancak davalılar tarafından davacıların izni alınmadan söz konusu projelerin biraz değiştirilerek ek binalar yapılmak suretiyle fikri eser niteliğindeki projelerinin tecavüze uğradığı iddia edilmiş, mali ve manevi hak ihlalleri nedeniyle maddi-manevi tazminat talebinde bulunulmuştur. Mahkemece yapılan yargılama sonucu; ek binaların davacı tarafa ait proje kopyalanmak üzere yapıldığı sabit olmuş ve FSEK madde 68/2 uyarınca eserin, hak sahibinin izni olmadan çoğaltılması sebebiyle (maddi tazminat olarak) eser sahibinin sözleşme olması durumunda isteyebileceği bedelin üç kat fazlasını talep edebileceği” hükme bağlanmıştır.

Yargıtay FSEK madde 68'deki üç kat tazminat talebi konusunda verdiği bir başka kararda²⁶³; bir heykelin izinsiz işlenerek, küçültülüp biblo şeklinde çoğaltılarak satışının yapılmasını hak ihlali olarak kabul etmiş ve bu durumda tazminat hesabı yapılırken FSEK madde 68'de sözü geçen rayiç bedeli belirleyen bilirkişi raporunun denetime elverişli olması gerektiğini vurgulamıştır. Davanın açıldığı ilk Mahkemece, rapordaki miktarın davacının talebi kıyaslanmak suretiyle kabulüne karar verilmişse de; rapordaki rayiç bedele ilişkin belirlemenin dayandığı verilerin raporda açık olarak gösterilmediği, tartışılmadığı, bu şekilde varılan sonucun Yargıtay denetimine elverişli olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca bilirkişi raporunda telif ve çoğaltma hakkı bedelinin, gerekçesi gösterilmeden (davanın açıldığı tarih yerine) rapor tarihine göre belirlenmiş olması da doğru olmamıştır. Bu nedenle Mahkemece eser sahibinin tecavüze konu mali haklarının tayin ve tespitinde FSEK madde 68 göz önüne alınarak, somut verilere dayalı ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre davacıların talebinin değerlendirilmesi gerekirken, rapordaki miktarın davacının talebini karşıladığı gerekçesiyle, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi Yargıtay tarafından doğru görülmemiştir.

Verilecek olan tazminatta bilirkişi raporları gerçekten de zarar tespiti için önem arz etmektedir. Bu anlamda, Yargıtay'ın bir başka kararında²⁶⁴; “bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmasının, raporun denetime elve-

²⁶² 11. HD., 19.3.2002, E. 2001/10702, K. 2002/2515. (Yargıtay Kararları No: 44)

²⁶³ 11. HD., 2.12.2004, E. 2004/2662, K. 2004/11862. (Yargıtay Kararları No: 56)

²⁶⁴ 11. HD., 24.6.2004, E. 2003/11182, K. 2004/7064. (Yargıtay Kararları No:52)

rişli bulunmamasının, rapora ciddi itirazların giderilmeden hüküm kurulmasının bozmayı gerektireceği” belirtilmiştir.

Uygulamada genel olarak davacılar hak ihlallerinin karşılığında tazminat olarak ne talep ettiklerini tam olarak belirtmemektedirler. Bu durumda hakim, HUMK madde 75 gereğince davacının 68. maddedeki üç katı tazminatı mı, 70/2’deki maddi tazminatı mı yoksa aynı maddenin 3. fıkrasındaki kâr yoksunluğunu mu talep ettiği hususunda davacıdan açıklama istemelidir.²⁶⁵

Bu davada davacılar mali hakları tecavüze uğrayan kimselerdir. Yetkili mahkeme ise HUMK’a göre belirlenmektedir. Tıpkı manevi hak ihlallerinde bahsettiğimiz usul kuralları bu konuda da geçerlidir.

c. Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görmeden Doğan Talep;

FSEK madde 70/3; maddi ve manevi hakları ihlal edilen kimselerin, tazminattan başka tecavüz nedeniyle temin edilen kârın da kendisine verilmesini talep edebileceğini hükme bağlamıştır. Bu durum gerçek olmayan vekaletsiz iş görmenin sonucudur. Bu talep, tazminattan farklıdır. Bu düzenleme ile getirilen şudur; hak sahibinin mali veya manevi haklarına tecavüz ederek kâr sağlayan kimse, bunu hak sahibinin menfaati için yapmamış olsa bile, hak sahibi açısından vekaletsiz iş görmüş olacaktır. Söz konusu hükmün esas kaynağı BK madde 414’tür. Ancak bu hükmün bazı özellikleri bulunmaktadır. Her şeyden önce; **“temin edilen kârın devri”**, ne tazminattır ne de zararı ve dolayısıyla tazminatı tayin etme veya hesaplama yöntemidir. Çünkü bu istem zarar olmasa da ileri sürülebilmektedir. **“Temin edilen kâr”** bazen tazminat ile istenmektedir bazen de onun yerine geçmektedir.²⁶⁶

Burada davacı tecavüze uğrayandır. Davalının tayini için FSEK madde 66/1 ve 66/2 deki hükümlere riayet edilmelidir. Ve dava işletme adına da açılabilmelidir.

Yetkili mahkeme ise; yukarıda bahsettiğimiz gibi HUMK’da yetkili olan davacının ikametgahı mahkemelerdir. Tecavüzün refi veya menî için yetkili kılınan eser sahibinin ikametgahı mahkemesi bu talep açısından yetkili değildir.

²⁶⁵ SULUK/ORHAN, age., s.801.

²⁶⁶ Azra ARKAN (AKBIYIK), Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998 Naklen TEKİNALP, age., s. 314.

6. Diğer Davalar ve Talepler:

Daha önceden saydığımız çeşitli davalar yanında mimari eserlere ilişkin bazı özel istemlerde bulunulması da mümkündür. Yargıtay'ın somut olaylar dahilinde verdiği bu istemleri şu örnek kararlarla açıklayabiliriz:

- Mimari eserlere yapılan ilaveler için proje yada yapı mimarı, ek telif ücreti talep edebilir. Yargıtay'ın bu konudaki kararları istikrara kavuşmuştur.

Yargıtay bu konudaki bir kararında²⁶⁷ şöyle hüküm vermiştir. “*Davacı mimar tarafından yapılan mimarlık proje ve planlarının FSEK anla-
mında eser olduğu ortaya konmuştur. Belli bir plan dahilinde yapılan mi-
mari eser daha sonradan maliki davalı tarafından uygulama alanı geniş-
letilmek suretiyle tekrar kullanılmış ve iki katlı bina, üç katlı hale getirile-
rek çeşitli değişiklik ve tadilatlar yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik ve ta-
dilatlara mahkemece zaruri bulunmamıştır. İşbu nedenle, bilirkişi incele-
mesi sonucunda; villanın piyasa rayiç değerine, yapılan eklentilerin belli
bir miktar değer artışı meydana getirdiği (anlaşıldığından, mimara) ek telif
ücreti verilmesine karar verilmiştir.*”

Yargıtay'ın bu konudaki başka bir kararına²⁶⁸ göre; davacılar, 2,5 kat olarak mimari ve statik projelerini hazırladıkları binanın yapımı sıra-
sında, istem üzerine aplikasyon ve kalıp planlarının yapılarak iki kat daha
ilavesiyle 4,5 kat olarak tamamlanan mimari eserin ilave iki katı için telif
bedeli ödenmediğini belirterek FSEK madde 68 uyarınca telif bedeli iste-
miştir. Yerel mahkemece statik projenin FSEK ve Bern Sözleşmesiyle telif
hakkı kapsamına alınmadığı savunulmuş ve davanın bu kısmı reddedil-
miştir. Ancak Yargıtay tarafından yerel mahkemenin bu kararı bozularak
davacıların istemi kabul edilmiştir.

- Yargıtay'a göre; mimari projenin telif ücretinde yaşanan bir uyuşmazlıkta, mimari eserin tamamı dikkate alınmalıdır. Mimari projede yapılacak değişiklik sadece bir kısma ilişkin ise, telif bedeli belirlenirken sadece bu kısım dikkate alınacaktır.²⁶⁹

²⁶⁷ 11. HD., 6.7.1998, E. 1998/3202, K. 1998/5147. (Yargıtay Kararları No: 21)

²⁶⁸ 11. HD., 1.3.1996, E. 1996/982, K. 1996/1263. (Yargıtay Kararları No: 12)

²⁶⁹ “Davacı, mimari projesi ve kontrol mühendisliği davalı tarafından yapılan Ulus 100.Yıl Çarşısı'nın mimari projeden kaynaklanan nedenlerle işletilememesi üzerine, çarşının en önemli giriş katının, telif bedeli ödenmek suretiyle yeniden düzenlenerek hipermarket olarak hizmete sunma zaruriyetinde olduğunu belirterek söz konusu da-

• Bir yapı inşaatının projesi bir mimara yaptırıldıktan sonra bu proje söz konusu yapıya uygulanmamışsa mimar, mimar projenin uygulanmadığı gerekçesiyle bir tazminat talep edemeyecektir. Bu durumda mimar ancak proje bedelini isteyebilecektir ki, bu zaten sözleşme ile kararlaştırılmış ve kendisine ödenmiş olacaktır. Çünkü bu halde mimarın projesi hiç kullanılmamış, yapıya başka bir proje uygulanmıştır.²⁷⁰

- Mimari projenin çoğaltma kıstası da şöyle belirlenmiştir.

Başkasına ait bir mimari projenin kullanımı, FSEK madde 22'deki çoğaltma hakkının ihlalidir. Zira FSEK madde 22'ye göre; “... *mimarlık eserlerine ait plan, proje ve krokilerin uygulanması da çoğaltma sayılır*” denmektedir. Yargıtay, bu kural gereğince maddi ve manevi tazminata hükmetmektedir.²⁷¹

• Mimarın fikri çalışması sonucunda meydana getirdiği eserin karşılığı olarak aldığı telif ücreti, kendi kusuruna dayanmayan bir nedenle geri istenemeyecektir. Buna ilişkin bir kararda²⁷², “*davalı tarafından çizilen. vergi dairesi hizmet binası projesinin uygulanmasından dava dışı İdare’nin vazgeçmesi nedeniyle proje bedeli olarak ödenen bedelin geri istenemeyeceği zira, davacıların sözleşmeyi belirtilen nedenlerle feshetmesinde davalı mimarın kusurunun bulunmadığı, projenin sözleşme gereğince çizilip teslim edilmekle davalının edimini yerine getirdiği gerekçeyle davacının ödenen telif bedellerini geri istemesine dair istemi reddedilmiştir.*”

B. CEZA DAVALARI

Fikri mülkiyet haklarına ilişkin ceza maddeleri, uygulamadan kaynaklanan çeşitli sorunlar ve özellikle üç aydan bir yıla kadar olan hapis ve para cezalarının caydırıcılığının bulunmaması sebebiyle 3.3.2004 ve

vayı açmıştır.” 11. HD., 21.1.1997, E. 1996/6995, K. 1997/109. (Yargıtay Kararları No: 14)

²⁷⁰ 11. HD., 24.3.1995, E. 1994/7485, K. 1995/2463. (Yargıtay Kararları No: 10)

²⁷¹ “Davacı, davalılardan Ahmet’in kendisine ait olan projeleri taklit yoluyla ve izinsiz kullandığını, diğer davalı Mualla’nın da davalı Ahmet tarafından projelerin yolsuz olarak kullanılmasına bilerek göz yumduğunu iddia ederek dava yoluna başvurmuş ve Mahkemece bu talep haklı bulunmuştur.” 11. HD., 25.10.1999, E. 1999/6557, K. 1999/8249. (Yargıtay Kararları No: 27)

²⁷² 11. HD., 10.2.2004, E. 2004/6364, K. 2004/1081. (Yargıtay Kararları No: 49)

23.01.2008 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklik sonucu eser sahiplerinin ve bunları devralan kişilerin mali ve manevi haklarına tecavüz edenler için altı aydan başlayıp beş yıla varan oldukça ağır hapis ve bu süreler paralelinde adli para cezaları getirilmiştir.

FSEK madde 71’de manevi, mali ve bağlantılı hakların ihlali halinde oluşan suçlar şu şekilde düzenlenmiştir:

“Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

1. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticarî amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanımı amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

2. Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koyan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz.

3. Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

4. Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunan kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

5. Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

6. Bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı, tanınmış bir başkasının adını kullanarak çoğaltan, dağıtan, yayan veya yayımlayan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Hukuka aykırı olarak üretilmiş, işlenmiş, çoğaltılmış, dağıtılmış veya yayımlanmış bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı satışa arz eden, satan veya satın alan kişi, kovuşturma evresinden önce bunları kimden

temin ettiğini bildirerek yakalanmalarını sağladığı takdirde, hakkında verilecek cezadan indirim yapılabileceği gibi ceza vermekten de vazgeçilebilir.”

Henüz konuya giriş yapmadan önce ceza ve hukuk yargılamalarının birbiri üzerindeki etkilerine de değinmekte fayda olduğu kanaatindeyiz. HGK’nun verdiği bir karara göre; ceza mahkemelerince saptanan maddi vakıalar hukuk hakimlerini bağlamaktadır. Ancak ceza davasında kusur yönünden alınan bilirkişi raporu hukuk hakimini bağlamamaktadır.²⁷³

5728 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce, suç teşkil eden fiilleri işleyenler, Kanunun düzenleme tarzına göre aslı fail ve yardımcı fail şeklinde ayrılmaktaydı. Eski FSEK madde 74 hükmüne göre, aslı failler FSEK madde 71 ve 72 hükümlerinde belirtilen suçları ya bağımsız olarak veya bir işletmenin temsilcisi veya müstahdemi sıfatıyla çalışırken işleyen kimselerdi. Suçun işlemesine engel olmayan işletme sahibi veya müdürü yahut hangi nam ve sıfatla olursa olsun işletmeyi fiilen idare eden kimse- nin de fail gibi cezalandırılması; cezayı gerektiren fiil işletme sahibi veya müdürü yahut işletmeyi fiilen idare eden kimse tarafından emredilmişse, bunların da fail gibi cezalandırılmaları öngörülmüştü²⁷⁴.

FSEK’in daha önce suçun failini düzenleyen “Fail” kenar başlıklı 74. maddesi, 23.01.2008 tarih ve 5728 sayılı Kanunun 578. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır. FSEK madde 74 hükmü ilga edildikten sonra, Türk Ceza Kanunu’nun ilgililer hakkında “azmettirme” ve “suça iştirak” hakkındaki hükümleri (TCK madde 37-41) uygulanacaktır. FSEK madde 74’de Ceza Hukukunun genel prensiplerine aykırı olarak getirilen, objektif sorumluluk ve tüzel kişileri cezai yönden hükmedilen para cezasından müteselsil olarak sorumlu tutan düzenlemenin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile uyumlaştırılması amacıyla yürürlükten kaldırılması isabetli olmuştur²⁷⁵.

Bu değişiklikten sonra artık FSEK’te öngörülen suçlarda faili tespit ederken TCK’nın konuyu düzenleyen 37. ve devamındaki maddelerinden yararlanmak gerekecektir. Buna göre suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, işlenen suçun faili olarak; suçun işlemesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de yine fail olarak so-

²⁷³ HGK., 17.6.1998, E. 1998/19-523, K. 1998/508. (Yargıtay Kararları No: 19)

²⁷⁴ EREL, age. (2009), s. 354

²⁷⁵ EREL, age. (2009), s. 354

rumlu tutulacaktır. (TCK madde 37). Ayrıca başkasını suç işlemeye azmettiren kimse TCK madde 38 uyarınca “azmettirme”, başkasına suç işlerken yardımcı olan kimse ise TCK madde 39’a göre “yardım etme” sebebiyle sorumlu tutulacaktır²⁷⁶.

FSEK’te düzenlenen bu hükümler; “*Maddi Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar*”, “*Manevi Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar*” ve “*Diğer Suçlar*” olarak incelenebilir.

1. Mali Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar

FSEK 71. maddesine göre; eser sahiplerinin mali haklarına ilişkin saldırılardan doğan suçlar şu şekilde ayrıştırılabilir:

Eser sahibinin bir eserini;

eser sahibinin yazılı izni olmaksızın;

- işlemek²⁷⁷,

- temsil etmek²⁷⁸,

- çoğaltmak²⁷⁹,

- değiştirmek,

- dağıtmak²⁸⁰,

- her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme²⁸¹,

- her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayımlamak²⁸²,

- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz etmek,

- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satmak,

- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri kiralamak suretiyle yaymak²⁸³,

²⁷⁶ EREL, age. (2009), s. 355 ve YAZICIOĞLU, age., s. 309 vd.

²⁷⁷ Bir mimara ait avan projesinin izinsiz olarak uygulama projesi haline getirilmesi.

²⁷⁸ Mimari bir projenin sergide eser sahibinin izni olmadan sergilenmesi.

²⁷⁹ Mimari bir maket çalışmasının mimarın iznini almaksızın hayata geçirilerek inşası.

²⁸⁰ Tez çalışması olarak eski bir binanın restorasyonunu almış olan bir öğrencinin; binaya ilişkin plan, proje, çizim veya her türlü çalışmalarını çoğaltarak yaratıcısı mimardan izinsiz olarak satışa sunması.

²⁸¹ Bir mimari yapının sahibinin izni olmadan projeksiyon ile gösterimi veya birçok mimari projeyi sahiplerinden izin almaksızın bir web sitesinde toplayıp yayınlamak.

²⁸² Televizyonda mimari projenin bir belgesel film şeklinde gösterilmesi veya internette yayını.

- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ödünç vermek suretiyle yaymak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri sair şekilde yaymak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ticarî amaçla satın almak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ithal etmek²⁸⁴,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri ihraç etmek,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak,
- hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri depolamak.

Bu suçları işleyen kişiler hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

Mali haklara ilişkin bir başka suç 71. maddenin son kısmında Ek 4. maddeye atıf yapılarak şöyle düzenlenmiştir: *“Bu Kanunun ek 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında²⁸⁵ bahsi geçen fiilleri yetkisiz olarak işleyenler ile bu Kanunda tanınmış hakları ihlâl etmeye devam eden bilgi içerik sağlayıcılar hakkında, fiilleri daha ağır cezayı gerektiren bir suç oluşturmadığı takdirde, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”*.

Bu maddede mimari eserler açısından belirtilen suçlar şunlardır.

- Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla bilgi içerik sağlayanlar tarafından, bu Kanunda tanınmış, eser sahiplerinin mali (işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve umuma iletim) ve manevi (ilk defa kamuya sunuş hakkı, adının belirtilmesi hakkı, eserde değişiklik yapılmasını yasaklama hakkı, eser sahibinin eseri elinde bulunduran ve sahip olana karşı eserden yararlanma hakkı) haklarını ihlal

²⁸³ Hazırlanan bir kooperatif projesinin mimarından izin alınmadan başka birine kiralanarak bir yapı daha yapılması.

²⁸⁴ Bir köprü projesinin ikinci kopyasının ülkeye sokularak uygulanması.

²⁸⁵ FSEK Ek madde 4/1: *Eser ve eser sahibi ile eser üzerindeki haklardan herhangi birinin sahibi veya eserin kullanımına ilişkin süreler ve şartlar ile ilgili olarak eser nüshaları üzerinde bulunan veya eserin topluma sunulması sırasında görülen bilgiler ve bu bilgileri temsil eden sayılar veya kodlar yetkisiz olarak ortadan kaldırılamaz veya değiştirilemez. Bilgileri veya bu bilgileri temsil eden sayıları ve kodları yetkisiz olarak değiştirilen veya ortadan kaldırılan eserlerin asılları veya kopyaları dağıtılamaz, dağıtılmak üzere ithal edilemez, yayınlanamaz veya topluma iletilemez.*

etmeye (Ek 4. maddenin 3. fıkrasındaki başvuru/uyarı prosedürüne²⁸⁶ rağmen) devam etmek.

Yukarıdaki suçları işleyen kişilere üç aydan iki yıla kadar hapis cezası verilir. Dipnotta da belirttiğim gibi, bu suçun düzenlenmesinde “ihlal etmeye devam etmek” ibaresinin ve fiilinin belirtilmesi sonucu; bilgi içerik sağlayıcısının, hak sahibinin “ bu ihlali durdurun” şeklindeki başvurusu öncesinde ihlali yapılabileceği fakat FSEK Ek 4. maddesindeki hak sahibinin başvurusu/uyarısı ile ihlale son vermek yükümlülüğüne aykırı davranmak yani “ hak sahiplerinin haklarını ihlal etmeye devam etmek” suçunu oluşturan eylem olmaktadır.

2. Manevi Haklara Tecavüz Halinde Oluşan Suçlar

FSEK 71. maddesinin 2 no’lu fıkrasından itibaren manevi haklara karşı işlenen suçlar şu şekilde sayılmıştır:

Bu Kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek:

- Bir eseri, hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın değiştiren, kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

- Başkasına ait esere, kendi eseri olarak ad koymak²⁸⁷. Bu suç işleyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır. Bu fiilin dağıtmak veya yayımlamak suretiyle işlenmesi hâlinde, hapis cezasının üst sınırı beş yıl olup, adli para cezasına hükmolunamaz.

- Bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunmak. Bu suç işleyen kişi altı aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

²⁸⁶ FSEK Ek madde 4/3: Dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla servis ve bilgi içerik sağlayıcılar tarafından eser sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin bu Kanunda tanınmış haklarının ihlali halinde, hak sahiplerinin başvuruları üzerine ihlâlê konu eserler içerikten çıkarılır. Bunun için hakları haleldar olan gerçek veya tüzel kişi öncelikle bilgi içerik sağlayıcısına başvurarak üç gün içinde ihlâlin durdurulmasını ister.

²⁸⁷ Uygulanan bir projenin bina haline gelmesinin ardından bina önüne asılan tabelada bina malikinin, proje mimarı yerine başka bir mimarın yada kendisinin ismini kullanması. Bir avan projesinin uygulama projesi haline getirilerek işlenmesi sırasında avan proje sahibinin adını yazmayarak uygulama projesi sahibinin kendi ismini yazması.

- Hak sahibi kişilerin izni olmaksızın, alenileşmemiş bir eserin muhtevası hakkında kamuya açıklamada bulunmak. Bu suçu işleyen kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Özellikle bir yapı için oluşturulan maket, plan ve projelerin mimar tarafından kamuya açıklanmadan önce izni alınmadan işveren tarafından bir toplantı ile duyurulması veya yayınlanması bu suça örnektir. Mimar tarafından proje kamuya açıklandıktan sonra projenin tüm detaylarının mimardan izin alınmadan olduğu gibi yayınlanması da aynı şekilde suçtur.

- Bir eserle ilgili olarak yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak göstermek. Bu suçu işleyen kişi, altı aya kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- Bir eseri, tanınmış bir başkasının adını kullanarak;

* çoğaltmak,

* dağıtmak,

* yaymak

* yayımlamak.

Bu suçu işleyen kişiler, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.

2008 yılında FSEK de bulunan suçlara ilişkin 71, 72 ve 73. maddeler değiştirilirken, biri dışındaki tüm suçlar tek bir madde olan 71. maddeye toplanmış 72. maddede ise sadece bilgisayar programlarının izinsiz çoğaltılmasına engel olan programları etkisiz kılmaya yönelik programları ve teknik donanımları üretmek, satmak ve bulundurmak suçu bırakılmıştır. FSEK 73. madde ise kaldırılmıştır. Yapılan bu değişiklik esnasında ne yazık ki iki adet suç 71. maddeye aktarılmayıp, unutulmuştur.

Bu suçlardan biri, eski 71/1. maddede yer alan “eser sahibi ve halefinin yazılı izni olmadan bir eseri umuma arz etmek” suçu ve 73/3 de yer alan “mevcut olmadığı veya üzerinde tasaffuf selahiyeti bulunmadığını bildiği veya bilmesi icabettiği mali hakkı veya ruhsatı başkasına devretmek veya vermek yahut rehin etmek veyahut herhangi bir tasarrufun konusu yapmak” suçudur. FSEK yeniden değiştirildiğinde eski Kanunda yeralan bu suçların FSEK düzenlemesi içine konulmasında zorunluluk bulunmaktadır.

3. Diğer Suçlar

FSEK madde 72’de bu suç şöyle düzenlenmiştir:

“Bir bilgisayar programının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasının önüne geçmek amacıyla oluşturulmuş ilave programları etkisiz kılmaya yönelik program veya teknik donanımları üreten, satışa arz eden, satan veya kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”

Bu suç genel olarak mimari eserleri de içeren tüm bilgisayar yazılımlarının hukuka aykırı olarak çoğaltılmasını engellemek için oluşturulmuş ek programları ve yazılımları etkisiz kılmaya yönelik programlar ve teknik donanımlar için koyulmuştur. “Hak yönetim sistemi”ni etkisiz kılmaya yönelik söz konusu yazılımlar ve teknik donanımı üretmek, satmak ve kişisel kullanım amacı dışında elinde bulundurmak bu suç kapsamına girer.

XII. HUKUK VE CEZA DAVALARINDA MÜŞTEREK HÜKÜMLER

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 77, 78 ve 79. maddelerinde hukuk ve ceza davaları için müşterek uygulanabilecek bazı tedbirlere yer vermiştir. Bunlar ihtiyati tedbir kararı, mahkemenin verdiği mahkûmiyet hükmünün ilânı ve yolsuz çoğaltılmış eser nüshalarıyla çoğaltılmaya yarayan kalıp vb. nin zabıt, müsadere ve imhasıdır.

A. İHTİYATİ TEDBİRLER

Hukukumuzda ihtiyati tedbirler HMK madde 389 ve devamındaki maddelerde düzenlenmektedir. FSEK’te ise madde 77’de bu konu HMK’dan daha geniş olarak ele alınmıştır.

FSEK’in “İhtiyati Tedbirler ve Gümrüklerde Geçici Olarak El Koyma” başlıklı 77. maddesi şöyledir. “*Esaslı bir zararın veya ani bir tehlikenin yahut emrivakilerin önlenmesi için veya diğer her hangi bir sebepten dolayı zaruri ve bu hususta ileri sürülen iddialar kuvvetle muhtemel görülürse hukuk mahkemesi, bu Kanunla tanınmış olan hakları ihlal veya tehlide maruz kalanların ya da meslek birliklerinin talebi üzerine, davanın açılmasından önce veya sonra diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını veya açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshalarının veya hasren onu imale yarıyan kalıp ve buna benzer sair çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafaza altına alınmasına karar verebilir. Kararda, emre muhalefetin İcra ve İflas Kanununun 343 üncü maddesindeki cezai neticeleri doğuracağı açıklanır. Haklara tecavüz oluşturulması ihtimali hâlinde yaptırım gerektiren nüshaların ithalat veya ihracatı sırasında, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 57 nci maddesi hükümleri uygulanır. Bu nüshalara gümrük idareleri tarafından el konulmasına ilişkin işlemler Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre yürütülür..”*

Fikir ve sanat eserleriyle ilgili olarak açılmış ve görülmekte olan davalarda yahut henüz bu davalar açılmadan, fikri hakları ve eserleri süratle emniyete almak ve muhtemel bir tecavüz tehlikesini önlemek amacıyla hâkim ihtiyati tedbire hükmedebilir. Hakim bu hususta öne sürülen iddia-

ları kuvvetle muhtemel görürse, esere veya fikri haklara yönelik esaslı bir zararı veya ani bir tehlike tehdidini ortadan kaldırmak yahut oldu-bittileri önlemek için, Kanunda belirtilen tedbirleri alacaktır.²⁸⁸

İhtiyati tedbir kararı gerek hukuk gerek ceza davalarında hakları ihlal veya tehlide maruz kalanların yazılı talebi üzerine alınmaktadır. Başlamış bir tecavüzün devamına engel olmak için de, dava öncesi ve sonrasında ihtiyati tedbir talebinde bulunulabilmektedir. Ancak burada önemli olan hakimin tehlikeyi görebilmesidir.

Hakim, ihtiyati tedbir olarak diğer tarafa bir işin yapılmasını veya yapılmamasını, işin yapıldığı yerin kapatılmasını ya da açılmasını emredebileceği gibi, bir eserin çoğaltılmış nüshaların veya onu imale yarayan kalıp ve buna benzer diğer çoğaltma vasıtalarının ihtiyati tedbir yolu ile muhafazasına da karar verebilir.²⁸⁹

Bu konuda 2004 yılında getirilen yenilikle haklara tecavüz oluşturulması ihtimalinde, yaptırım gerektiren kopyaların ithalat ve ihracatı sırasında Gümrük Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Bu kopyalarına gümrük idarelerince el konulması da mümkündür ve el koyma Gümrük Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yürütülür.

B. HÜKMÜN İLANI

FSEK 78. maddeye göre; hukuk ve ceza davalarında haklı çıkan taraf, menfaati gerekli kılıyorsa masrafı diğer tarafa ait olmak üzere, kesinleşmiş olan mahkeme kararının gazete veya benzer vasıtalarla tamamen veya özet olarak ilan edilmesini talep edebilir. Bu talep, mahkeme hükmünün kesinleşmesinden itibaren en geç üç ay zarfında yapılmalıdır.

Mahkeme hükmünün ilanı, manevi haklardan ad belirtme hakkına tecavüzde ve iktibasta kaynak gösterme yükümlülüğünün ihlâlinde de uygulanan bir müeyyidedir. Bu hallerde FSEK madde 67/II ve III hükümlerine göre açılacak tecavüzün ref'i dâvalarında hükmün, masrafı tecavüz edene ait olmak üzere en fazla üç gazetede ilanı istenebilmektedir. FSEK madde 78'in bu hükme yaptığı atıf uyarınca, ilân talebi için üç aylık hak düşürücü süre, tecavüzün ref'i hükmünün ilanında da geçerlidir. Ancak madde 78'de ilanın şekil ve muhtevasının kararda tespit edileceği belirtil-

²⁸⁸ EREL.age., 315.

²⁸⁹ EREL, age., s. 315.

diğinden, tecavüzün ref'i hükmündeki *en fazla üç gazeteyle ilan* sınırının, diğer hallerde mevcut olmadığı kabul edilmelidir. Nitekim madde 78 ilânın gazeteyle değil, benzer başka vasıtalarla da yapılabileceğini belirtmiştir.²⁹⁰

Hukuk veya ceza mahkemeleri tarafından verilebilecek olan ilan kararı, bu davalar açısından öne sürülen manevi tazminat talepleri için bir tazmin yolu olarak düşünülebilir.²⁹¹

Yargıtay bir kararında davacının talebine rağmen davalı aleyhine verilen hükmün ilanı hususunda olumlu yada olumsuz bir hüküm kurulmamasını bozma nedeni saymıştır. Yargıtay yine aynı kararda ihtiyati tedbire hükmetmek için belirlenen teminatın akıbeti için aynı sonuca varmış bulunmaktadır.²⁹²

Ayrıca tarafları ayrı olan mahkeme kararlarının da ayrı ayrı ilanı gerektiğini belirtmek gerekmektedir.²⁹³

C. ZABIT, MÜSADERE VE İMHA

Bern Sözleşmesi'nin, Roma Sözleşmesi'nin, TRIPS Anlaşması'nın ve AB direktiflerinin etkin bir koruma isteyen hükümlerine uygun olarak değiştirilerek düzenlenen Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gereğince, hak sahiplerinin haklarını korumak amacıyla, bir mimari eserin yazılı planlarının ve çizimlerinin izinsiz olarak çoğaltılan kopyalarına ve çoğaltma için kullanılan suç eşyalarına Savcılık vasıtasıyla el koyulabilir, bunlar zaptedilebilir, müsadere edilebilir ve neticede imha edilir.

FSEK'de yer alan ceza kovuşturmalarında el koyma ve müsadereye ilişkin düzenlemeler; 5728 sayılı Kanun ile 2008 yılında yürürlükten kaldırıldıktan sonra, ceza soruşturmaları ve kovuşturmalarında el koyma ve müsadere hususlarında Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Ayrıca, FSEK'in 68/II. maddesinde, bir özel hukuk önlemi olarak, mali haklara tecavüz vukuunda, hak sahibinin kendisine tanınan seçimlik haklardan biri olan programın çoğaltılmış kopyalarının, çoğalt-

²⁹⁰ EREL, age., s.316.

²⁹¹ AYİTER, s. 269 Naklen EREL, age., s.316.

²⁹² 11. HD., 5.6.2000, E. 2000/4098, K. 2000/5155. (Yargıtay Kararları No: 34)

²⁹³ 11. HD., 7.10.1999, E. 1999/5553, K. 1999/7625. (Yargıtay Kararları No: 26)

maya yarayan film, kalıp ve benzeri araçların imhasını isteyebileceği yönündeki düzenleme ise halen geçerliliğini korumaktadır²⁹⁴.

Yeni TCK’da eski TCK’dan farklı olarak eşya müsaderesi (madde 54) ve kazanç müsaderesi (madde 55) şeklinde iki ayrı müsadere türüne yer verilmiştir. Müsadere genel bir ifadeyle mahkumiyet sonucu olarak, bir eşya veya kazancın devlete geçmesi demektir. Eşya müsaderesi, “iyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak üzere, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan ya da suçun işlenmesine tahsis edilen veya suç sebebiyle meydana gelen eşyanın devlete intikal etmesi”dir. Kazanç müsaderesi ise, “suçun işlenmesi ile elde edilen yahut suçun konusunu oluşturan veya suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi ya da dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların devlete geçmesi”dir.²⁹⁵ Halbuki el koymada, “eşyanın suçun veya tehlikelerin önlenmesi amacı ile ya da müsadereye tabi olduğu için bir kimsenin elinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) öngörülen usullere göre ve rızası dışında geçici olarak alınması” söz konusudur²⁹⁶. Müsadere edilen eşya mahkeme kararının kesinleşmesi ile birlikte devletin hüküm ve tasarrufuna geçer. Bundan sonra o eşya Adalet Bakanlığı’na çıkarılmış olan “Suç Eşyası Yönetmeliği” hükümlerine göre imha olunur²⁹⁷.

Bu bakımdan el koyma müsadereden farklı olup, zilyetliği geçici olarak ortadan kaldıran bir tedbirdir.²⁹⁸ Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 123. maddesinde, ispat aracı olarak yararlı görülen veya eşya ya da kazanç müsaderesinin konusunu oluşturan malvarlığı değerlerinin muhafaza altına alınacağı, yanında bulunduran kişinin rızasıyla teslim etmediği bu tür eşyalara ise el konulabileceği hükme bağlanmıştır. Mali veya manevi hakların ihlal edildiğine dair hak sahibi tarafından yapılan usulüne

²⁹⁴ EREL, age. (2009), s. 366

²⁹⁵ Müsadere hakkında geniş bilgi için bkz. ÖZGENÇ, age., s. 684-693. Naklen EREL, age. (2009), s. 366

²⁹⁶ Elkoyma ile ilgili geniş bilgi için bkz. Nurullah KUNTER/ Feridun YENİSEY/ Ayşe NUHOĞLU, *Muhakeme Hukuku Dalı Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku*, Onbeşinci Bası, İstanbul 2006, s. 932-957; Haluk ÇOLAK/Mustafa TAŞKIN, *Ceza Muhakemesi Kanunu Şerhi, Güncellenmiş-Genişletilmiş 2. Baskı*, Ankara 2007, s. 533-610. Naklen EREL, age. (2009), s. 366

²⁹⁷ EREL, age. (2009), s. 366

²⁹⁸ Teknail ÖZDERYOL, *Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda Düzenlenen Suçlar*, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2006, s. 267 ve Mustafa ALBAYRAK, *Fikir ve Sanat Eserleri ile Markalar Aleyhine İşlenen Suçlar*, Ankara, 2003, s. 35

uygun bir şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı suça konu eşyalarla ilgili olarak CMK hükümleri uyarınca el koyma tedbirlerinin alınmasına yönelik gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür²⁹⁹.

5728 sayılı Kanunla değişik FSEK madde 75/III hükmüne göre: “Şikayet üzerine Cumhuriyet savcısı suç konusu eşya ile ilgili olarak 5721 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre elkoyma koruma tedbirlerinin alınmasına ilişkin gerekli işlemleri yapar. Cumhuriyet savcısı ayrıca, gerek görmesi halinde, hukuka aykırı olarak çoğaltıldığı iddia edilen eserlerin çoğaltılmasıyla sınırlı olarak faaliyetin durdurulmasına karar verebilir. Ancak, bu karar yirmidört saat içinde hakim onayına sunulur. Hakim tarafından yirmidört saat içinde onaylanmayan karar hükmüsüz kalır.”

Ceza davası sonucunda verilecek zabıt, müsadere veya imha kararının tabi olduğu yöntem hususunda; müsadere talebi hakkındaki Türk Ceza Kanunu 54., 55., 60., 64., 70., 74. ve 75. maddeleri ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 256-259. maddeleri hükümleri uygulanacaktır³⁰⁰.

²⁹⁹ EREL, age. (2009), s. 367

³⁰⁰ EREL, age. (2009), s. 373

XIII. GÖREVLİ MAHKEMELER

2001 tarihli değişiklikle FSEK'ten doğan davalarda miktar ve cezanın derecesine bakılmaksızın görevin ihtisas mahkemelerinde olduğu hükme bağlanmıştır. İhtisas mahkemeleri Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi ve Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesidir. Bu mahkemeler Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulmuştur. Diğer bazı büyük illerde de zamanla kurulacaktır. İhtisas mahkemelerinin kurulduğu yerlerde görevli mahkemeler ihtisas mahkemeleridir. Kurulmayan yerlerde ise; ihtisas mahkemesi olarak görev yapacak mahkemelerin Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu tarafından seçilen asliye ceza ve asliye hukuk mahkemeleri olduğu kararına varılmıştır. İhtisas mahkemeleri ile diğer mahkemeler arasındaki ilişki işbölümü değil görev ilişkisidir.

İhtisas mahkemelerinin görevi kamu düzenine ilişkin olup, yargılamanın her safhasında dikkate alınacaktır.³⁰¹

³⁰¹ 11. HD., 28.3.2005, E. 2004/1641, K. 2005/2862. (Yargıtay Kararları No: 59)

MİMARİ ESERLERLE İLGİLİ YARGI KARARLARI

1. (10. HD., 22.1.1976, E. 1975/4935, K. 1976/1294)

... Davalı Kurum, davacı Kooperatifin yapı inşaatında Kontrol Mühendisliği görevini yapan kişiye ilişkin bildirge ve bordroların verilmesi nedeni ile 1232 sayılı Genelgenin 26 ve devamı maddeleri uyarınca ölçümleme yoluna gitmiş ve işverenin itirazı üzerine Komisyon Kurum'un ölçümleme yapma hak ve yönetimini benimseyerek bu itirazı reddetmiştir.

Davacı, söz konusu mühendis, Bağ-Kur üyesi ve bağımsız büro sahibi ve vergi sorumlusu olduğunu ve parasal ödemelerin proje çizme ve denetim hizmeti karşılığı yapıldığını ileri sürerek mühendisin 506 sayılı yasanın 2. maddesi uyarınca sigortalı sayılamayacağını savunmuştur.

Görülüyor ki, olayda çözülmesi gereken ön sorun; yapının projesini çizen ve bunun uygulanmasını sağlayıp, denetleyen bir mühendis ile işveren arasındaki ilişkinin hukuksal niteliğinin saptanmasıdır. Anılan Mühendisin, Bağ-Kur yasasının yürürlüğe konuluş tarihinden önce çalışmış olmasına ve bağımsız büro sahibi ve vergi sorumlusu bir mühendisle hizmet sözleşmesi yapılmasına yasal bir engel bulunmamasına göre, ölçünün sayılan öğeler dışında aranması gereği açıktır. Şu durumda, görevli mühendisin çalışma biçim ve koşullarını incelemekte zorunluluk vardır. Çalışmanın ilk kesiminde mühendis; geometrik biliminin ve tekniğin verilerinden yararlanarak bir tasarı yapmakta ve işverene kesinkes bağlı olmaksızın bir yapıt oluşturmakla, diğer bir deyimle yapının projesini çizmektedir.

Bu proje, bilimsel-tekniksel biçimde, onu çizenin tüm özelliklerini taşıyan bir yapıt sayılmalıdır. Çalışmanın ikinci evresinde mühendis; tasarımın gerçekleştirilmesine çalışmakla birlikte, işverenle olan anlaşmasına göre bunu işyerinde, işverenin sağlayacağı araçlarla ve onun işçileri eli ile ... uygulayacaktır. Bu durumda uğraşı; büyük ölçüde somutlaşmakta ve işverenle olan ilişkiler gitgide yoğunlaşmaktadır. Artık, işin yasalara, sözleşme ve eklerine ve projesine uygun olarak yapılmasında işverenin iş düzeninde yalın ve etkin gözetim ve denetimi söz konusudur. Bütün bunlardan sonra söylemek yerinde olur ki, mühendis ile kooperatif arasındaki anlaşma; istisna ve hizmet bağitlarından oluşmuş bir "Bileşik Sözleşme" niteliğindedir.

Bileşik sözleşmede; iki bağımsız sözleşme kendilerine özgü nitelikleri koruyarak ortak bir amaçla bir araya gelmektedir. Bu tür sözleşmelere

ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesinde uygulanacak hükümler açısından yasalarda açıklık bulunmadığından konu öğretide tartışmalıdır. Dairemiz: bu olayın özelliklerini göz önünde tutarak, bu davada en doğru çözüm yolunun “her sözleşmenin bağlı olduğu hükümlerin uygulanması” görüşünü benimsemektedir. (MK madde 1). O halde, yukarıda açıklanan gerektirici nedenlere göre, işveren hakkında ölçümlemenin; Bileşik Sözleşmenin hizmet kesimi olan “kontrol mühendisliği” bakımından yapılması ve salt bu hizmet karşılığı olan parasal ödemenin tespit edilmesi gerekir.

Mahkemenin; yazılan yasal esasları göz önünde bulundurmadan, düzenlenen bilirkişi raporunu hükmüne dayanak yaparak, her iki görev karşılığı yapılan parasal ödeme üzerinden ölçümleme yapılmasını kabul etmesi yasaya aykırıdır ve hükmün bozulması gerekir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı BOZULMASINA ve davacı yararına takdir edilen 1.000 lira duruşma temyiz harçlarının istek halinde ilgililere geri verilmesine, 22/1/1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

2. (15. HD., 20.9.1976, E. 1976/2108, K. 1976/3038)

Taraflar arasındaki davanın (Ankara Altıncı Hukuk Hakimliğince) görülerek mahkeme ilamında belirtilen gerekçelere binaen verilen 8.4.1976 gün ve 297-171 sayılı hükmün temyizden tetkiki davalı avukatı tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı vekili 26.4.1974 tarihli dilekçesinde; Ayvalık'ta 10 ton kapasiteli sabunhane projesinin davalı Genel Müdürlükçe davacıya ihale edildiğini, projeyi tanımlayan müvekkilinin davalı Genel Müdürlüğün onayına sunduğunu, bu projelerden tesisata ilişkin olanının onaylandığını, mimari projede ise sözleşme hükümleri dışında değişiklik ve ilaveler istendiğini ve bunun sonucunda üç kez proje düzenlendiğini, sonradan onaylanan tesisat projesinde yeniden düzenlenmek üzere iade olunduğunu, davacının bu projelerde davalı tarafından istenilen değişiklikleri yaparak Genel Müdürlüğün onayına arzettiğini, ancak davalının projenin mimari ve estetik endişelerden uzak, basit, gecekondü havası içerisinde ele alındığını belirterek, bu projelerin kabul edilmediğini beyanla, proje değişiklikleri nedeniyle müvekkili'nin uğradığı ... liralık zarar ile ayrıca keşif bedeli olarak ödenen lira ki toplam olarak 22500 lira maddi tazminatın davalıya ödetilmesini istemiştir.

Davalı ise savunmasında: Olayda zamanaşımı olduğunu, davacı tarafından hazırlanarak müvekkili davalı İdareye verilen betonarme projelerinin ekonomik bulunmadığı gibi, sözleşme ve eki şartnameye uygun düşmemesi nedeniyle düzeltilmesinin istediğini bu durumda davacının dava hakkının doğmadığını, haksız açıldığını beyanda davanın reddi istenmiştir.

Mahkemece; davalı İdarenin gerçekten istediği şekilde ve estetik yönden ileri bir eser ortaya çıkmasını istemesi halinde, buna ait hazırlığın yapılması ve önce bir avan proje yaptırması ve uygulama projelerinin de bu esasa göre istemesi veya işi sınırlı bir yarışma ile çözümleme yoluna gitmesi gerekeceğinden, bunları yapmayan İdarenin %60 oranında yapılan iş karşılığını ödemesi gerektiğinin kabulü suretiyle, 11700 liranın davalıya ödenmesine fazla istemin reddine karar verilmiştir.

Ayvalık'ta 1000 ton kapasiteli sabunhane projesi davalı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından davacı Mimar (M.G)ye ihale edilmiş ve aralarında 3.11.1971 günlü eser sözleşmesi düzenlenmiştir.

Mahkemece iddia ve savunma çevresinde bilirkişi incelemesi yapılmıştır. Bilirkişi ise 22.4.1975 günlü raporunda; davacının gerekli düzeltme ve ebat eksikliklerini gidermesi halinde talep ettiği (tazminat hariç) 19500 lira alacağının aynen ödenmesi gerektiğini ancak bu kabil olmadığı takdirde İdarenin kendi elemanlarına bu eksiklikleri düzelttirmesi mümkün bulunduğundan o zaman müellifin geçmiş emek, gayret ve masrafları ile İdarenin projelerinin ikmal için gerekli masrafları göz önüne alarak davacıya ödenmesi gereken miktarın, istenilen meblağın %60'ı oranında 11700 lira olması gerektiğini belirtmiştir.

Oysa ki, bilirkişi raporunda da açıklandığı üzere dava konusu projenin dosya içerisinde bulunmaması dolayısıyla ileri sürülen kusur ve noksanların saptanamadığı anlaşılmaktadır.

Olayda, davacı eser müellifinin emek ve çabası mevcut olmakla beraber, bu projelerin kabulüne davalı İdarenin zorlanabilmesi için, davacı tarafından yapılan sözü edilen projelerin davalı İdarece istenilen nitelikte ve uygulama kabiliyeti olup olmadığının kesin biçimde anlaşılması gerekir.

Bu itibarla davacı tarafından yapıldığı ileri sürülen projelerin mahkemece getirilmesinden sonra taraflarca imzalanmış olan sözleşme, şartname ve Bayındırlık Teknik Şartnamesi hükümleri ile tarafların iddia ve savunması hak ve hakkaniyet esasları da göz önünde tutularak davacının bu projelerde gerekli düzeltme ve ebat eksikliklerini gidermesi halinde projelerin yapılacak inşaat ve maksada uygun olup olmadığı ve uygulama

niteliği bulunup bulunmadığı ve ayrıca bilirkişi raporunda belirtildiği üzere %40 noksan bırakılan işin davalı İdare tarafından kabul edilmesi gerekip gerekmediği hususlarının mahkemece seçilecek bilirkişiye inceletilmesi ve böylece olayda Borçlar Yasası'nın 360. maddesi koşullarının araştırılması icap ederken, eksik incelemeye ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüştür.

SONUÇ: Davalı idarenin temyiz itirazlarının kabulü ile kararının yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı davalı yararına (BOZULMASINA) istek olursa ödediği temyiz peşin harcının temyiz edene iadesine, 20.9.1976 gününde oybirliğiyle karar verildi.

3. (4. HD., 1.7.1977, E. 1976/5913, K. 1977/7617)

Taraflar arasındaki tecavüzün men'i ve tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı reddine ilişkin olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşuldu:

Bilirkişi Prof. O.A. 2.10.1974 günlü oturumda ve davacı vekili hazır olduğu halde bilirkişi olarak seçilmiş bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak davacı vekili bilirkişinin seçimine 2.10.1974 tarihinde ıttıla kesbetmiştir. Usul Yasası'nın 277/2. maddesi hükmüne göre bilirkişinin şahsına karşı itirazlar, öğrenme tarihinden itibaren 3 gün içinde mümkündür. Davacı vekili bu yasal süre içinde adı geçen bilirkişinin seçimine bir itirazda bulunmamış olduğu cihetle bu yöne ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmıştır.

2 - Davacı, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 1966 yılından itibaren aldığı ruhsatnamelere dayanarak Bitlis'in Ahlat ilçesindeki eski eserleri çıkarmak için kazı yaptığını, bu kazılar sonunda birçok anıt, mezar taşı ve eski eserler bulunduğunu, yıllarca süren çalışmalarla bu eserleri yer yüzüne çıkardığını, temizlediğini, bu eserlerin örneklerinin bulunmadığını, bu eserleri profesörlük tezi için kullanmak istediğini, ancak davalının 1972 yılında yayınladığı "Ahlat Türk Mimarisi" adlı kitabında kendisinin yaptığı kazılar sonunda çıkardığı eserlerin resim ve krokilerini bastığını, ayrıca bu araştırmayı davalının yapmış olduğu intibainı veren yanıltıcı beyanlarda bulunduğunu, yasa hükümleri ve ruhsatname münderecatına göre bu eserler üzerinde inceleme yapma, resim ve plan çıkarma, kazı sonuçlarını yayınlama hakkının yalnız kendisine ait olduğunu, yıllarca süren büyük külfetler sonucu bulduğu bu eserleri davalının haksız olarak yayınladığını

dığını, bu suretle bu kazılarda bulunan eserlerin, yayınlanma bakımından, orijinalliğini de kaybettiğini bildirerek davalının elinde bulunan kitapların toplattırılması suretiyle tecavüzün önlenmesine ve 20.000 lira manevi tazminatın davalıdan alınmasına karar verilmesini istemiştir.

Davalı savunmasında, bu araştırmaların davacının tekelinde olmadığını, bir konunun araştırılması ve değerlendirilmesinin serbest olduğunu, davacının bahsettiği eserlerin yapıldıkları günden itibaren ortada duran ve herkesçe bilinen eserler olduğunu, davacı tarafından sadece etraflarının temizlendiğini, kaldı ki kitabında davacı ismine atıfta bulunduğunu, referans verdiğini bildirerek bir tecavüzün bulunmadığından bahisle davanın reddini istemiştir.

Özetlemek gerekirse davacı, kendisinin maddi yükünü de yüklenerek yaptığı kazılarda çıkan eserler hakkında yayın yapma hakkının münhasıran kendisine ait olduğu halde davalının, haksız bir davranışla, bir kısım eserlerin resim ve krokilerini yayınlamak suretiyle kendisinin hakkında tecavüz ettiğini ileri sürmektedir.

Olaya 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümlerinin uygulanma olanağı yoktur. Zira, Yasanın isminden de anlaşıldığı veçhile bu Yasanın uygulanabilmesi için ortada kişinin yarattığı bir eserin mevcut olması gerekir. Adı geçen Yasa'nın tarifine göre eser, sahibinin hususiyetini taşıyan ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ve sinema eserleri sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulüdür (madde 1). Tariften de anlaşılacağı gibi bir eserin, yasa karşısında eser niteliğini kazanabilmesi için iki unsur gereklidir. Birinci objektif unsur ki yasa bunu mahsul (ürün) olarak belirtmiştir. Buna göre eser, evvela temellüke, tasarrufa elverişli maddi bir varlık olarak var olmalıdır. İkincisi de, sübjektif unsur olup eserin sahibinin özelliğini taşıyan bir fikir ve sanat eseri olmasıdır. Olaydan anlaşıldığı üzere davacı, yukarıda unsurları açıklanan bir eserin henüz sahibi değildir. Ancak, yaptığı kazılardan elde ettiği bilimsel buluşlara dayanarak bir eser yaratmayı düşünmüştür. Yani, bu yönde bir düşüncesi, bir fikri vardır. Fakat bir fikir veya sanat eseri, fikir halinde kaldığı sürece eser niteliğini kazanamaz (Ord. Prof. E. Hirsch, Fikri ve Sınai Haklar, 1948 S. 6-10, 130; Prof. Halil Arslanlı, Fikri Hukuk Dersleri, Cilt II, Fikir ve Sanat Eserleri, 1954 S. 42 No. 5) ve dolayısıyla Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın koruyucu hükümlerinden yararlanamaz.

O halde davacının korunmaya değer bir hakkı olup olmadığının dayanağını başka yerlerde aramak gerekmektedir. Davacı 1967 ve 1968 yıl-

larında aldığı kazı ruhsatnamelerini ibraz etmiştir. İşbu ruhsatnamelerin alındığı ve davalının kitabını yayınladığı tarihlerde Asarı Atika Nizamnamesi yürürlüktedir. Bu nizamname hükümlerine göre bu nevi araştırmalar, eser itibariyle, devlete aittir. Ancak devlet, kazı ve sondaj işlerinin kişiler tarafından yapılması için kişilere izin verebilir. Fakat bu izin kişiye özel olup başkasına devredilemeyeceği gibi miras yoluyla da intikal etmez (A.A.N. Md. 22). Kazı ve sondajın bütün gideri kazıyı yapan izin sahibine ait olduktan başka kazı yerinde bulunması gereken devlet temsilcisinin dahi bütün masrafları kazı sahibi tarafından ödenir. Nizamnameye ... göre, kazı tamamlandıktan itibaren 5 yıl süreyle yayın hakkı kazı sahibine aittir ve bu 5 yıldan sonra da, bu eserler hakkında yayın yapmak herkes için serbest olmayıp, her türlü yayın hakkı Milli Eğitim Bakanlığı'na intikal etmektedir. Ruhsatnamelerden birinin tarihi 6.7.1968'dir. Bu tarih bile esas alınsa 6.7.1973 tarihine kadar yayın hakkı davacıya aittir. Oysa davalının kitabı 1972 yılında yayınlanmış olmakla davacının yayın hakkı süresi içinde yayınlandığı anlaşılmaktadır.

Davalının bu davranışı, davacıya karşı haksız bir rekabet teşkil etmektedir. Gerçekten gerek A.A.N., gerekse ruhsatnameler hükümlerine göre kazılarda bulunan ve çıkarılan eserler hakkında yayın yapmak sadece davacıya ait bir haktır. Davacı kendi kişisel ve bilimsel emek ve çalışmaları yanında birçok maddi yükümlülüklerle de katlanarak bu araştırmaları yapmıştır. Örneğin ruhsatnamelerin 17 ve devamı maddeleri hükümlerine göre, bakanlık temsilcisinin ikamet yevmiyesi, ayda 600 liradan aşağı olmamak üzere, davacı tarafından ödeneceği gibi iase ve ibatesi, kazı yerine geliş gidiş masrafları da davacıya aittir. Ayrıca kazı evi, müze, depo v.s. yapılması gerektiği takdirde bunların giderlerini de davacı karşılayacaktır. Yine, kazı yerinin ve eserlerin korunması için tutulacak bekçi ücreti de kazı sahibine aittir. Bunlardan başka, kazı yapılan yer özel veya tüzel kişilere ait ise bu yer, bedeli kazı hakkı sahibi tarafından ödenmek üzere kamulaştırılacaktır. Görülüyor ki davacı çok büyük bir maddi külfet altına girmiş bulunmaktadır. Bu kadar büyük maddi bir yükün altına girmenin, buna bir de kişisel ve bilimsel emek, çalışma ve bilgilerini de katmanın bir tek amacı olabilir: O da, bir bilimsel buluş yapmak, bilime katkıda bulunmak ve bunu kendi adına yayınlatabilme. A.A.N. ve ruhsatname ile davacıya verilen tek hak budur. Davalının, tekel halinde davacıya ait bu hakka tecavüz ettiği kendi ikrarıyla ve yayınladığı kitap ile de sabittir. Bu durumda, bulunan eserlerin tamamının veya bir bölümünün yayınlanmış olması sonuca etkili değildir. Bazen bir tek fotoğrafın yayınlanması veya

bir krokinin çizilmesi yayınlanacak bir bilimsel eserin bütün önemini ve orijinalitesini kaybettirebilir. Referans vermiş olmak da bu durumu düzeltecek nitelikte bir işlem değildir.

Kaldı ki, davacının iddia ettiği gibi, davalı, kitabının önsözünde, Ahlat sanat eserleri hakkında yayınların az olduğunu belirttikten sonra, bu durumun kendisini öğrencilik yıllarında yapmış olduğu çalışmaları toplayarak yayınlamak amacına sürüklediğini, bu çalışmaların 1967 ve 1968 yıllarına dayandığını (ki bu yıllar davacının ruhsatnameli kazı yaptığı yıllardır) ve eksiklerin 1971'e kadar süren bir devre içinde tamamlanmaya çalışıldığını yazmıştır. Gerçekten, bu ifadeler yanıltıcı olup, kendi kişisel çalışma ve araştırmaları sonucu kazıların yapılp eserlerin bulunduğu anlamını veren bir biçimde kullanılmıştır. Gerek ekonomik, gerekse bilimsel alanda eserde rekabet, kişisel ve toplumsal gelişmeye yardımcı olduğu için serbesttir ve korunması gerekir. Fakat rekabet, ancak yasa, ahlak ve iyi niyet ölçüleri içinde kaldığı sürece korunur. Hakkın kötüye kullanılması derecesine vardırıldığı takdirde haksız bir nitelik kazanır. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 56. maddesi, haksız rekabeti "aldatıcı hareket ve hüs-nüniyet kaidelerine aykırı sair suretlerle iktisadi rekabetin her türlü suiis-timali" şeklinde tarif etmiştir.

Yukarıdan beri açıklanan durum ve gerekçeler karşısında ortada haksız bir rekabetin var olduğunu kabul zorunludur. Ticari haksız rekabete ait hükümler TTK'nun 56-65. maddelerinde düzenlenmiştir. TTK'nun Meriyet ve Tatbik Şekli Hakkındaki 6763 sayılı Yasa'nın 41/II-a maddesi ile Borçlar Kanunu'nun (BK) 48. maddesine eklenen ikinci fıkra ile "ticari işlere ait olan haksız rekabet hükümleri mahfuzdur" hükmü karşısında olaya, haksız rekabete ilişkin BK'nun 48. maddesinin uygulanması gerekmektedir. Ancak, BK'nun 48. maddesinin olayda uygulanması, TTK'nun 56-65. maddelerinde düzenlenmiş bulunan haksız rekabete ilişkin ve istisnai nitelik taşımayan genel hükümlerin benzetme yoluyla uygulanması olanağını engellemez. Bu nedenle davacı, işin niteliği itibariyle BK'nun 48. maddesinin tanıdığı ve TTK'nun 58. maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde açıkça gösterilmiş bulunan tespit, men, maddi durumun ortadan kaldırılması, kusur halinde zarar-ziyan ve icabında manevi tazminat davası açabilir (Oser-Schönenberger, İsviçre Medeni Kanun Şerhi, cilt 5, Borçlar Hukuku, Recai Seçkin tercümesi, S. 442 ve d. Prof. Dr. Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku, Giriş-Ticari işletme, 3. Baskı, 1968, S. 468 vd.; Prof. Haluk Tandoğan, Türk Mesuliyet Hukuku, 1961, s. 244-252). Ancak haksız rekabete maruz kalan kişi, yuka-

rıda sayılan davalardan yalnız birini açabileceği gibi hepsini birlikte de açabilir. Davacı, haksız rekabet konusu kitabın toplattırılması yani TTK'nın 58/c. maddesindeki maddi durumun ortadan kaldırılması talebiyle birlikte manevi tazminata da hükmedilmesini istemiştir. Manevi tazminata hükmedilebilmesi için BK'nun 49. maddesindeki koşulların var olması, davacının kişisel haklarının halele uğraması ve davalının kusurunun ağır olması gerekmektedir. Haksız rekabete, iktisadi şahsiyete bir tecavüz saklıdır (Egger, İsviçre Medeni Kanunu Şerhi, Giriş ve Kişinin Hukuku, Volf Çernis çevirisi, 1947, S. 275 No.17). Davalının davranışı davacının hem ekonomik, hem de bilimsel kişisel haklarına bir tecavüz teşkil etmektedir. Davacı bilimsel alanda bir eser vermekten, bilim alanında tanınmak veya daha iyi isim yapmak hakkından mahrum edilmiş bulunmaktadır. Rekabet mücadelesinde başkalarının, müteşebbisin fikirlerini, emeğini, zahmet ve masraflarla elde edilmiş iş mahsulünü kendilerine mal edinememeleri hususundaki talep hakkı şahsiyet fikrine dayanır (Egger, age., s. 281, No. 29). Bu nedenle davalının, davacının kişisel haklarına haksız bir tecavüzde bulunduğu kabulü gerekir. Ayrıca, olayda, davalının ağır kusurunun varlığı da kabul edilmelidir. Şöyle ki, davalı ve davacı aynı bilim dalında çalışma yapmaktadırlar. Davalı bu konuda yasal hükümleri, davacının kazı yaparken ne gibi haklara sahip olduğunu bilmektedir veya bilmelidir. Buna rağmen, hakkı olmadığını bildiği veya bilmesi gerektiği halde davacının çalışmalarının sonuçlarını, davacının tekeli altında bulunmasına rağmen, yayınlaması ve üstelik, bunları, kendi çalışmaları gibi takdim etmesi ağır kusurunu oluşturmaktadır. O halde manevi tazminatla da mahkum edilmelidir.

Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi davacının davasının kabulü gerekirken, uyuşmazlığın hukuki olması karşısında bilirkişiye gidilmesine gerek olmadığı halde bilirkişi incelemesine başvurulması ve Usulün (HUMK) 286. maddesi hükmünce hakimi bağlamadığı halde bilirkişi raporuna dayanılarak hüküm tesis edilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan hükmün bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda iki numaralı bentte gösterilen nedenlerle hükmün temyiz eden davacı yararına BOZULMASINA, 1.7.1977 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

4. (HGK., 11.2.1983, E. 4-70, K. 123)

Taraflar arasındaki “ödence” davasından dolayı yargılama sonunda İstanbul Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesi (tarafından) davanın kabulüne dair verilen 6.6.1979 gün ve 1978/437-335 sayılı kararın incelenmesinin davalı kurum tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Dördüncü Hukuk Dairesi’nin 8.2.1980 gün ve 1979/12383 1573 sayılı ilamıyla Davacı S.A., dava dilekçesinde; S.K.’dan temellük etmiş olduğu ve başka bir sanatçının okumasını yasaklamış bulunduğu “Çile Bülbülüm Çile” adlı eserin televizyonda E.S. adlı bir sanatçının programında yayınlanmış olmasından dolayı 200.000 lira manevi tazminatın ödetilmesini, program kayıtlarının yok edilmesini, hükmün tam metninin günlük bir gazetede yayınlanmasını istemiş ve istediği manevi tazminatın duyduğu eza karşılığı olduğunu açıkladıktan sonra hukuki neden olarak 5846 sayılı Yasaya dayanmıştır. Mahkemece dava aynen kabul edilmiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK’nun) 13. maddesinde fikir eserleri üzerinde sahibinin mali ve manevi menfaatlerinin bu Kanun dairesinde himaye göreceği belirtilmiştir. O halde, anılan özel Kanunda hüküm bulundukça genel nitelikli BK’nun hükümlerinin uygulanması mümkün değildir. Ancak, bu özel Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanununa başvurulabilecektir. FSEK, eser sahibinin mali ve manevi haklarının nelerden ibaret olduğunu sınırlı bir biçimde göstermiştir. Kanunun 14, 15, 16 ve 17/2. maddelerinde eser sahibinin manevi hakları belirtilmiş ve 70. maddesinde yalnız sözü edilen maddelerdeki manevi hakların haleldar edilmesi halinde, diğer koşullar da gerçekleştiğinde manevi zarar adı ile bir paranın verilmesini dava edebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan madde hükümlerine göre, sahibinin eseri üzerinde dört tür manevi hakkı vardır. Bunlar a) Eseri kamu oyuna sunma yetkisi, b) Eserde adın belirtme yetkisi, c) Eserde değişiklik yapma yetkisi ve d) Malik ve zilyede karşı şeref ve itibarın korunmasını isteme yetkisidir.

Davaya konu olan “Çile Bülbülüm Çile” adlı eser yıllarca önce sahibi tarafından kamuya sunulmuştur. Eser okunurken sahibinin adının belirtilmediği ve üzerinde değişiklik yapıldığı ileri sürülmemiştir. Yine eser okunurken malikin şeref ve itibarını kırıcı bir eylem işlenmemiştir. Esasen davaya konu olan eserlerin sahibi davacı değil, S.K. adlı bestekardır. FSEK’nun 52. maddesinin de eser üzerindeki yalnız mali hakların sözleşme ve tasarruflara konu edilebileceği, hükme bağlanmıştır. Manevi hakların temlik edilebileceğine dair bir hüküm yoktur. Nitekim S.K. ile

davacı arasında düzenlenmiş bulunan temliknamede, yalnız mali haklar temlike konu edilmiştir. Kaldı ki, manevi hakların devri de hukuken mümkün değildir. O halde, manevi tazminat adı bir para ödenmesine ve gazete ile hüküm yayınlanmasına ilişkin isteğin bu nedenle reddine karar verilmek gerekirken, kabul edilmiş olması yasaya aykırıdır...gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahkemece önceki kararda direnilmiştir...

Davacı vekili, 14.7.1976 tarihli dava dilekçesinde; merhum bestekar S.K. tarafından bestelenip ölümünden önce her türlü telif hakları 3.7.1954 tarihli temlikname veçhile adı geçen tarafından müvekkilesine devir ve temlik edilen sekiz eserden birini teşkil eden “Çile Bülbülüm Çile” şarkısının, diğerleri ile birlikte Türkiye içinde okuma hakkının münhasıran müvekkilesine ait olmasına ve inhisari durumu Hürriyet, Tercüman ve Son Havadis isimli günlük gazetelerin 1975 ve 1976 yıllarında çıkan değişik nüshalarında, noter ihtarnamesi olarak yayınlanan ilanlarla, başta davalı TRT Genel Müdürlüğü olmak üzere, bil’umum ses sanatçıları ile gazino ve saz salonları sahip ve işleticilerine ve bu arada plak şirketlerine de “son ve kesin duyuru” başlığı altında ihtar edilip duyurulmasına ve hatta telif hakkının devrine ilişkin temlikname bile, davalı Kurumun isteği üzerine, tasdikli bir şekilde Kuruma gönderilmiş bulunulmasına rağmen, davalı tarafından 7.5.1978 tarihinde düzenlenen “Tele Pazar 78” isimli televizyon programında, okuma hakkı sadece müvekkilesine ait olan “Çile Bülbülüm Çile” şarkısının E.S. isimli bir sanatkar tarafından İranlı diğer bir sanatçı ile birlikte aslına ve müzik usulüne uygun olmadan ve diğer bir ifade ile değiştirilmek suretiyle okunduğunu ve bu okunuş şekil ve tarzından müvekkilesinin son derece üzüntü duyduğunu ve esasen merhum bestekârın söz konusu sekiz şarkıyı, aslına ve müzik usulüne uygun bir şekilde, sadece müvekkilesinin okuması hali ile onun sanat güç ve kabiliyetinin nazarı itibara alarak bu şarkıların okuma hakkını bu nedenlerle müvekkilesine devir ve temlik ettiğini ve aynı şarkının yine aynı sanatkar yani E.S. tarafından izinsiz olarak okunmasından dolayı daha önce açtıkları diğer bir davanın kanun yollarından da geçmek suretiyle lehlerine sonuçlanıp kesinleştiğini ileri sürerek bu son olay nedeniyle 200.000 lira “manevi tazminatın” davalı Kurumdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava eylemiştir.

Davacının, davasına dayanak yaptığı ve İstanbul, Beyoğlu Birinci Noterliği tarafından re’sen düzenlendiği anlaşılan 3 Temmuz 1954 gün ve 7221 yevmiye numaralı temlikname aynen: “*bana ait olan; Güneş, Meh-*

tap, Menekşelendi Sular, Mecnun Leyla, Batarken Ufukta Bu Akşam Güneş, O Dudaklar, Çile Bülbülüm Çile ve Yanık Ömer isimli eserlerimin telif haklarını Bayan (S.A.T.)'ye devri temlik ettim ve bedeli bin lirayı kendisinden aldım. Artık bu eserlerde benim hiçbir hakkım ve alakam kalmayıp bütün bunlar Bayan (S.A.T.)'nin mülkiyetine geçmiştir” denilmektedir.

Metni yukarıya aynen derç'edilen temliknameden incelenmesinden de anlaşılacağı üzere, merhum bestekar S.A., temliknamede isimleri yazılı sekiz eseri üzerindeki telif hakkını, hiçbir ayrıma, tabi tutmadan, diğer bir deyişle, hem maddi (malî) ve hem de manevi telif hakkını, birlikte, davacıya temlik etmiş bulunmaktadır. Bu husus temliknamede yer alan, (...*telif haklarımı*) cemi edatı kullanılmış olması ile, yine aynı temliknamedeki, (...*artık bu eserlerde benim hiçbir hakkım ve alakam kalmayıp bütün bunlar bayan (S.A.T.)'nin mülkiyetine geçmiştir*), cümlesinden kesinlikle anlaşılmaktadır. **Her ne kadar, kaideten manevî tazminat talep ve dava hakkı, mağdurun veresesine (MK. M. 85/f. 2'de olduğu gibi) veya manevî tazminatın isteğine dayanak yapılan bir hakkı temellük eden intikal etmesi mümkün değil ise de, bütün Türk hukukçuları ile yabancı hukukçuların da ittifakla belirttikleri üzere, şayet; mağdur manevî tazminat talep hakkını ilerde de arama arzu ve iradesini temliknamede izhar etmiş veya o hakkın aranmasına bir kanun hükmü imkan tanımış (BK. m. 162/f. I) veya işin mahiyeti buna mani değil ise, o zaman, manevî tazminat isteğinin de, temellük eden kimseye intikal ettiğinin kabulü icap eder** (Dr. Nisim Franko, Şeref ve Haysiyete Tecavüzden Doğan Manevî Zararın Tazmini, Ank., 1973, Sh. 210 221), (Prof. Dr. Selahattin Sulhi Tekinay, Borçlar Hukuku, İst. 1979/4. Bası. Sh. 216 219), (Prof. Dr. Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku, C. 1. Genel Hükümler, İst. 1972, 5. Bası, Sh. 650 ve müteakip), (Andreas von Tuhr, Borçlar Hukuku, Cevat Edege Tercümesi, Yargıtay Yayını- No:15, Ankara -1983, Sh. 117 ve müteakip), (Dr. H. Oser Dr. W. Schönenberger Borçlar Hukuku, Dr. Recai Seçkin Tercümesi, Ank. 1947, Sh. 968 ve müteakip). İsviçre Federal Mahkemesi de manevî tazminat taleplerinin devir ve temlikini mümkün görmüştür. BGE 95. II 481 jdt 1971 1 226 Prof. Dr. S. Sulhi Tekinay, age., s. 218. Dip Not. 7. bkz.).

5846 sayılı (Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun) 14-19. maddeleri hükümleri, hem (manevî hakları) kimlerin isteyebileceğini ve hem de hangi hallerde (manevî tazminat) istenebileceğini ayrı ayrı hükme bağlanmış bulunmaktadır. Kanun koyucu, adı geçen Kanun'un 16/f. 2. hükmü ile bir eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değişikliği, o eser

yönünden, manevi tazminat talebi için yeterli bir davranış saydığı gibi, diğer taraftan, **eser sahibinin ölümünden sonra kimlerin “manevi tazminat” isteyebileceklerini de aynı Kanunun 19. maddesi hükmünde belirtmiş bulunmaktadır.** Davacının, temellük eden kimse olarak, gerek BK’nun 162 ve 168. maddeleri hükümlerine göre, kendisine yapılan temlik sonucu ve (işin mahiyeti) icabı olarak manevi tazminat talebine hakkı bulunduğu gibi, ayrıca da **Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 19. maddesi hükmünde kaynaklanan (halefiyet) nedeniyle de, keza, “manevi tazminat” talebine hakkı bulunmaktadır.** Doktrin de aynı görüştedir. Manevi hakların çoğunun kullanılması, mali hakların kullanılmasıyla yakın bir bağlantı gösterir, bu itibarla, manevi haklar, ölümle sona eren “şahsiyet” haklarından farklı olarak, en az mali haklar devam ettiği sürece devam eder. Binaenaleyh, mali bir hakkı devir alan kim-
senin de eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilme yetkisine sahip olduğunun kabulü icap eder. Esasen, mali haklarla manevi haklar arasındaki ayrım sun’i bir ayrımdır, mali hakların da kullanılmasını kapsar. Bilindiği üzere, “manevi haklar” ölenin terekesi dışında kaldığı için, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 19/f. 1, hükmünde sayılan kimseler, manevi hakları, sırf mirasçı sıfatına haiz oldukları için iktisap etmezler. Kanun koyucu, bunları ölen eser sahibine en yakın bağ-
larla bağlı oldukları için, en güvenilen kişiler olarak saymıştır. Fikri Hak-
lar sahasında çalışan yerli ve yabancı müelliflere göre, manevi hakların kullanılmaları eser sahibi tarafından herhangi bir kimseye bırakılabilir, bu kimseler genellikle, (Treuhönder) güvenilen kişidir. Eser sahibinin kendilerine güvenerek “manevi hakları” kullanma yetkisini ter ettiği bu kişiler Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14 16. maddeleri hükümlerinde belirtilen hallerde ve özellikle eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozucu değişmelere maruz bırakılması veya eserin başka herhangi bir suretle me-
sela, bir müzik eserinin mahiyetine aykırı olarak, başka bir müzik aleti ile ve o eserin hususiyetini bozacak bir tarzda icra edilmesi. gibi özelliğinin haleldar edilmesi, manevi tazminat talebine olanak sağlar. **Memleketimizi de dahil olduğu Bern Sözleşmesi ve Birliğinin altıncı maddesi hükmü de, bir sanat eserinin hususiyet ve tamamiyetini bozan her türlü değiştirici davranışı, manevi tazminat talebi için yeterli saymıştır** (Prof. Dr. Halil Arslanlı, Fikri Hukuk Dersleri, II Fikir ve sanat eser-
leri, İst.1954, Sh. 87 94 Prof. Dr. Nuşin Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Ank. 1981 . Sh. 197 205, Ord. Prof. Dr. Ernest E. Hirsch, Das Neue Urheberrechtsfesetz der Türkei, Schhirftenreihe der Ufita, Sh. 51 Prof. Dr. Nuşin Ayiter, age., Sh. 190 Dipnot, 6-8 naklen).

Diğer taraftan, bu davada, davacı tarafından manevi tazminat isteğine dayanak yapılan merhum bestekar S.K'ya ait "Çile Bülbulüm Çile" şarkısının yine E.S. isimli ses sanatkarı tarafından G.....Ticaret A. Şirketi nam ve hesabına plak'a okunmasından dolayı, adı geçen şirket aleyhine, davacının açtığı manevi tazminat davası sonunda, mahkemenin, davacı taraf lehine hüküm tesis ettiği ve bu hükmün de Yargıtay Onbirinci Hukuk Dairesi tarafından onanmak ve daha sonra da davalı tarafın tashihi karar talebinin reddi suretiyle kesinleştiği, bu dava dosyasına ekli İstanbul Onuncu Asliye Hukuk Mahkemesi'ne ait 1976/390 esas ve 1977/16 karar numaralı dosyasından anlaşılmasına binaen, söz konusu dava dosyası içindeki 28.1.1977 günlü mahkeme ilamı, bu dava için delili kat'i teşkil eder (HUMK. m. 295).

Bütün bu nedenlerle, yerel mahkemenin direnme kararının usul ve yasaya uygun bulunduğu sonucuna varılmıştır.

Ancak, özel daire, davacının "manevi tazminat" talebine hakkı olmadığı görüşü ile, davacının dava dilekçesindeki müteveffa bestekar S.K'dan maddi (mali) ve manevi bütün haklarını temellük ettiği sekiz müzik eserinden biri olan "Çile Bülbulüm Çile" şarkısının, dava dışı E.S isimli ses sanatkarı ile İran uyruklu diğer bir sanatkar tarafından birlikte ve eserin Türk Sanat Müziğine ve onun icra edilmiş şekline göre mahiyet ve hususiyetlerini bozucu bir tarzda icra edip etmedikleri yönü ile, keza, aynı eserin televizyon programında söylenirken çalışan müzik aletinin (enstrümanın) çıkardığı ses bakımından eserin özelliğinden haleldar olup, olmadığının ve diğer bir deyişle dava konusu olayda Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 14, 16 ve 70. maddeleri hükümlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini bakımlarından, işin esasını incelememiş olduğu için, bu yönlerin incelenmesi amacıyla dosya Özel Daireye gönderilmelidir.

SONUÇ : Yukarıda gösterilen nedenlerle, davalı Kurumun temyiz itirazlarının REDDİNE, yerel mahkemece verilen direnme kararı usul ve yasaya uygun bulunup sair yönlerin incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesine, 10.11.1982 gününde yapılan ilk toplantıda çoğunluk saplanamadığından, 11.2.1983 gününde yapılan ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

Bu karara iki ayrı karşı oy yazısı yazılmıştır. Birinci karşı oy yazısı Nihat RENDA ve Seyfettin ÇETİNELLİ tarafından kaleme alınmıştır:

KARŞI OY YAZISI (I)

Temyize konu bu davada, manevi tazminat isteğinin kaynaklandığı maddi ve hukuki olgular çoğunluk kararının baş tarafında etraflıca belirtilmiştir. Orada da açıklandığı veçhile; davacı S.A. Temmuz 1954 günlü temliknameye dayanarak 8 şarkı meyanında “Çile Bülbulüm Çile” adlı şarkının da (eserin de) maddi ve manevi telif haklarını merhum bestekar S.K’dan devir aldığını ileri sürmüş ve “başka sanatçılar tarafından okunmasını yasakladığı bu şarkıyı E.S. adlı bir başka sanatçıya, hem de aslına ve özelliğine uygun olmaksızın icra ettiren davalı Kurumdan manevi tazminat istemiştir.

Hal böyle olunca bu davada öncelikle üzerinde durulup, çözümlenmesi gereken sorun, 1954 tarihli temliknamenin davacı yararına doğuracağı hukuksal sonuçların ne olduğunun; bir başka anlatımla davacının bu temlikname ile S.K’ya ait 8 eserin manevi haklarını da devralmasının mümkün olup olmadığını belirlenmesi olmalıdır.

Ancak bu konudaki görüşlerimizi belirmeden önce, çok önemli gördüğümüz bir konuya kısaca değinmek istiyoruz.

1-Bilindiği gibi, manevi giderim talebi münhasıran şahsa bağlı bir karakter taşır; bu karakterinin doğal bir sonucu olarak başkasına devredilemez ve kural olarak mirasçılara geçmez. Bununla beraber MK’nun, nişanın bozulması halinde manevi giderimden söz eden ve bütün manevi giderim davalarına kıyas yolu ile uygulanan (Velidedeoğlu / Kaynar, Türk Borçlar Kanununa Göre Borçlar Hukuku-Umumi Hükümler 3. Bası, İstanbul 1960, sayfa 144), (H.V. Velidedeoğlu, Türk Medeni Hukuku 1 Cüz 1, Umumi Esaslar, 7. Bası, İstanbul, 1968, sayfa 314), (A. Ataay, Medeni Hukuk Uygulama Çalışmaları 1, 2. Bası, İstanbul, 1966, sayfa 94), (A. Ataay, Borçlar Hukukunun Genel Teorisi Birinci Yarım, 2. Bası, İstanbul, 1975, sayfa 96), (S. S. Tekinay, Türk Aile Hukuku, İstanbul, 1966, sayfa 56), (V. Tuhr, Borçlar Hukukunun Umumi Kısmı Cilt 1,2, Yargıtay No: 15, Ankara, 1983, Cevat Edege Çevirisi, sayfa 118, dipnot, 13/a ile ilgili metin), (S.S. Tekinay Borçlar Hukuku, İstanbul, 1979, sayfa 218 ve 536 vd) 85. maddesinin H. fıkrasına göre “...manevi tazminat davası, mirasçıya intikal etmez; şu kadar ki miras açıldığı zaman iddia kabul edilmiş veya dava ikame olunmuş ise mirasçılara intikal eder. Ataay’ın da belirttiği gibi bu fıkra hükmünü İsviçre Medeni Kanuna uygun olarak “...bu talep yani manevi giderim talebi devredilemez; ancak miras açıldığı zaman tanınmış veya borçlu dava edilmiş bulunmuşsa mirasçılara geçer...” tarzında anlamak gerekir (Ataay, age. Borçlar Hukuku, s. 96). O halde

özetlenecek olursak, hükme bağlanmış yada borçlu tarafından tanınmak suretiyle kesinleşmiş manevi tazminat alacağının devrine engel yoktur. Bunun dışında Yasa Koyucu manevi tazminat talebinin devrini yasaklamıştır ki, bunun nedeni manevi zarara uğrayan şahsın kişilik hakları alanına müdahalelerde bulunulmasını önlemek ve dolayısıyla onun menfaatlerini korumak düşüncesine dayanır. Gerçekte de, hükme bağlanmak veya borçlu tarafından tanınmak suretiyle henüz kesinleşmemiş bulunan bir manevi giderim alacağını devralan şahsın, bu alacağı ispatlamak amacıyla delil toplamaya girişmesi, topladığı delilleri ileri sürmesi, alacağı devreden (yani, manevi zarara uğramış olan) şahsın kişilik haklarını yakından ilgilendirir. Hatta çoğunluk görüşüne dayanak yapılmak istenen Tuhr; hak sahibinin dava ikamesi suretiyle dermeyer etmek niyet ve arzusunu göstermiş olması veya sadece bu işi bir avukata vermiş bulunması halinde manevi giderim talebinin mirasçılara intikal edeceğine ilişkin olan ve eski BK'nun 54. maddesinin tefsiri suretiyle oluşturulan federal mahkeme içtihadını çok açık bir dil ile eleştirmekte ve bu içtihadın manevi tazminat müessesesinin gayesine uygun olmadığını vurgulamaktadır (Tuhr, age., sayfa 117, dipnot 9 ve 13), (Karşılaştırınız: Oser/Schönenberger, Borçlar Hukuku, Seçkin çevirisi, sayfa 429 vd.).

O halde, ancak manevi giderim talep hakkı doğduktan sonra, o da bazı koşullarla bu hakkın devrine ve mirasçılara intikaline imkan veren Yasa Koyucu'nun, (olayımızda olduğu gibi) bu hak doğmadan önce başkasına ilişkin bir irade açıklaması hukukça hiçbir hüküm ve sonuç doğurmaz (Tekinay, age., s. 218 ve dipnot 7'de anılan eserler), (Tuhr, age., s. 117), (Oser/Schönenberger, age., s. 429 vd.).

2- Öte yandan, bir an için genelde manevi hakların ve özellikle de eser üzerindeki manevi hakların devrinin mümkün olduğu kabul edilse dahi, 3.7.1954 günlü temlikname manevi hakları kapsamamaktadır. Bu konuda diğer muhalefet görüşüne aynen katılıyoruz.

3- Konuya 5846 sayılı Yasa hükümlerine göre yaklaşıldığında varılacak sonuç şu olacaktır:

a) Bu manevi tazminat davasının dayanağını teşkil eden şarkıyı izin dışı okuma olgusunun eser sahibi olan S.K.'nin ölümünden sonra meydana geldiği ihtilafsızdır.

b) Keza, davacının, eser sahibi olmayıp, sadece sahibinden mali hakları devralmış bir kişi olduğu konusunda da bir uyuşmazlık yoktur. Bilindiği gibi, eser sahibi fikir ve sanat ürününü meydana getiren ve özel-

liğini eserinde belirten kişidir. Eser üzerindeki haklar, esere vücut verilmesiyle kazanılır. Bu nedenledir ki bugün fikir ve sanat eserlerinin tescil edilmesine gerek bulunmamaktadır. 5846 sayılı FSEK'nun 8. maddesi "bir eserin sahibi onu vücuda getirendir" diyerek ilkeyi koymuştur. Eser üzerindeki manevi ve mali haklar, eser sahibi olarak kabul edilen gerçek kişiye aittir. Anılan Yasa, müteakip fıkra hükümlerinde bu ana ilkenin istisnalarını göstermiştir. FSEK, eser sahibinin mali ve manevi yetkilerini ayrı gruplar halinde teker teker saymıştır. 5846 Yasa, manevi hakları 4 madde halinde düzenlenmiştir. (m. 14-17). Bu maddelerde yer alan haklar, eser sahibinin eseri ile olan kişisel ve manevi ilişkisini korumak amacına hizmet ederler. Eser sahibinin eserle kişisel ve manevi ilişkisi, eser üzerindeki mali haklar sona erse dahi ortadan kalkmaz; bir başka anlatımla bu ilişkiler eser sahibinin, eseri üzerindeki mali hakları sona erse dahi (mesela, mali hakların başkalarına devir ve temlikinde olduğu gibi) devam eder. FSEK'nun 18. maddesinde eser sahibinin manevi hakları yaşamı boyunca kullanabileceğini; 19. maddede ise, bunlardan bazılarının eser sahibinin ölümünden sonra belli kişiler tarafından kullanılabilceğini açıklamaktadır. Hemen belirtelim ki, FSEK'nun ön gördüğü manevi haklar, MK'nın 23 vd. anlamındaki kişilik haklarından değildir; eğer öyle olsa idi bu hakların ölümle sona ermeleri gerekirdi. Bu Yasa anlamındaki manevi haklar, mali hakların kullanılması ile iç içe giren özellik taşırlar. Bu bakımdan denilebilir ki MK İle FSEK iki ayrı menfaati düzenleyen ve bu itibarla da birbirini tamamlaması söz konusu olmayan hükümlerdendir (Ayiter, age., s. 114, dipnot 10 ile ilgili metin). Manevi yetkiler, eser sahibini, eseri ile olan kişisel ve manevi ilişkisinde koruyan yetkililerdir. Bu kişisel ve manevi ilişki ölümle sona ermez. Çoğunluk kararında da belirtildiği gibi manevi hakların çoğunun kullanılması, mali hakların kullanılmasıyla yakın bir bağlantı gösterir. Bu yüzden manevi haklar yukarıda da kısaca değinildiği gibi ölümle sona eren şahsiyet haklarından farklı olarak en az mali haklar mevcut olduğu sürece devam ederler. Ne var ki manevi haklar normal miras (hükümlerini) takip etmeyerek, ancak Kanunun (m. 19/1) sınırlı bir şekilde saydığı kimseler tarafından kullanılır. Hirsch'in belirttiği gibi, bu sınırlı kişiler, manevi yetkileri kendi namlarına, fakat ölenin menfaatine kullanan (güvenilen kişi) durumundadırlar. Kaldı ki, bu kişiler tarafından kullanılabilcek olan yetkiler, FSEK 19/II'de öngörülen:

aa) Madde 14'te belirtilen umuma arz ve yayınlamaya karşı koyma yetkisi,

bb) Madde 15'de hükme bağlanan adın belirtilmesi yetkisi,

cc) Madde 15’de öngörülen eser sahipliğinin çekişmeli olduğu hal-lerde hakkın tespitin mahkemeden istenmesi yetkisi,

dd) 16. maddede belirtilen eserde değişiklik yapılmasına izin, vermek ve eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyici, yahut eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozucu değiştirmeler yapılmasına karşı koyma yetkisidir.

Görülüyor ki FSEK., hem yetkileri, hem ölümden sonra manevi yetkileri kullanabilecek olan kişileri numerus clausus olarak saymaktadır. Bu yöntem kıyas yoluna gitme olanağını ortadan kaldırmaktadır (Ayiter, age., s. 201).

Anılan kişiler bu yetkiler dışında başkaca bir yetki kullanamazlar ve hele eser sahibinin ölümünden sonra eser sahibinin eserinin nitelik ve özelliğini bozacak bir üslupla ve batı müziği enstrümanları ile okunduğundan bahisle manevi tazminat isteyemezler.

4- Konu ile doğruya ilgisi bakımından burada bir konunun açıklığa kavuşturulmasında yarar görülmüştür. Çoğunluk görüşü, manevi hakların da devir ve temlik edileceği esastan hareketle, temliknameyi de yorumlamak suretiyle sonuçta davacının manevi tazminat isteyebileceği kanısına varmıştır. Hal böyle olunca burada bir soruya yanıt aramak gerekir. O da manevi hakların devrinin temlikinin mümkün olup olmadığı sorusudur. Yukarıda da açıklandığı ve çoğunluk kararında belirtildiği gibi, manevi hakların çoğunun kullanılmasının mali hakların kullanılmasıyla yakın ilişkisi olduğu kuşkusuzdur. Bu yüzden mali hakkı devralan kimsenin de eser sahibinin ölümünden sonra bir ölçüde bu yetkileri haiz olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak bu yetkilerin kullanılabilmesi hem sınırlıdır ve ayrıca hem de bazı koşulların gerçekleşmesine bağlıdır. Nitekim bu yön, FSEK’in 19/III. maddesinde düzenlenmiştir. Gerçekten Ayiter’in de belirttiği gibi (age., s.202); eser sahibinden veya haleflerinden mali bir hak iktisap etmiş olan kimselerin iki şartın gerçekleşmesiyle manevi yetkileri kullanabilecekleri öngörülmüştür. Bu şartlardan birisi; hayatta ise eser sahibinin, ölmüşse 19/II’de sayılan yetkililerin yetkilerini kullanmamaları; ikincisi de, mali hakkı iktisap edenin söz konusu manevi yetkiyi kullanmada meşru menfaati olmasıdır. Mali hakkı devralan kimse tarafından belli şartlar altında kullanılacak manevi yetkiler ise, madde 19/III’de anılan ve madde 14/III, 15/III ve 16/III’de hükme bağlanan haklardır ki, bunlar da ancak karşı koyma, tespit isteme şeklinde ileri sürülebilecek haklardır. Bu hükmün amacı ise açıkça “eser sahibi yada yakınlarının il-

gilenmemesi halinde mali hak sahibinin, hakkını kullanmasını engelleyen tecavüzlere karşı korunmasını” sağlayabilmektir (Ayiter, age., s. 202).

Ancak manevi yetkilerin nasıl kullanılacağını evvela eser sahibi tespit etmiş yahut bunu herhangi bir kimseye bırakmış olabilir. Kendisine manevi yetkilerin kullanılış tarzını tespit etme yetkisi olan bu “herhangi bir kimse” çok defa mali hakkı devralmış olan kimse olacaktır; fakat eser sahibinin bir yakını, güvendiği bir kimse, bir sanat yada edebiyat uzmanı da olabilir. Ne var ki manevi hakkın kullanılış tarzını, eser sahibinin bu şekilde başka bir kimseye bırakmasını, bir tür yetki verilmesi şeklinde anlamak gerekir ki, (Ayiter, age 206) bu yetki de yukarıda belirtildiği gibi sınırlıdır ve hiçbir zaman ölmüş olan eser sahibi yerine geçip manevi tazminat istenmesine olanak sağlamaz. Esasen doktrinde ittifakla kabul edildiği veçhile, FSEK., eser sahipliğinden doğan hakların sađlararası muamelelerle el deđiřtirmesini, açıkça yalnız mali haklar bakımından öngörülmüřtür. Manevi hakların kullanılması (yukarıda açıklanan yetki verilmesi hakkı ayırık) kural olarak başkasına bırakılamaz. Çünkü bunlar eser sahibine eseri üzerindeki manevi menfaatlerini korumak için tanınmışlardır (Ayiter age. 206), (Duygun Yarsuvat, Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, İstanbul, 1977, sayfa 98, paragraf 94), (Nesim I. Franko, Türk Borçlar Kanununa Göre Yayın Sözleşmesinin Hükümleri, Ankara, 1981, sayfa 205 ile ilgili metin), (İlhan Öztrak, Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, Ankara, 1971, sayfa 40 vd.), (Nuşin Ayiter, Mamelek Kavramı Üzerine İnceleme, Ankara, 1968, sayfa 115, özellikle 116 dipnot. 79 ile ilgili metni), (Kenan Tunçomağ, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, İstanbul, sayfa 1124 vd.). Hal böyle olunca manevi hakların devir ve temlikine ilişkin olarak düzenlendiđi iddia edilen temliknamenin hukuksal bir sonuç doğuracađı kabul edilemez ve bu dava manevi tazminat isteđinin dayanađı yapılamaz.

5- Öte yandan, bu olayda bir haksız rekabetin varlıđından da söz edilmeyeceđi cihetle bu davaya haksız rekabetle ilgili 18.2.1981 gün ve 1980/1 E. 1981/2 K. sayılı İçtihadı Birleřtirme Kararındaki ilkenin de uygulanması düşünülemez. Bu bakımdan haksız rekabete ilişkin olan ve Yasa hükümlerine uygun düşmeyen önceki bir kararın bu dava için kati delil niteliğinde kabulü olanaksızdır.

SONUÇ:Gerek yukarıda belirttiđimiz nedenlerle ve gerekse aynen katıldıđımız diđer muhalefet řerhindeki görüşlerle yerel mahkeme kararını bozulması oyundayız ve bu itibarla da “direnme kararının dođru olduđu” yolundaki çoğunluk kararına muhalifiz”.

İkinci karşı oy yazısı Mükremin POYRAZ, Şerafettin SEYHUN ve Cahit KSEKİN tarafından yazılmıştır:

KARŞI OY YAZISI (II)

Bir eserin sahibi, onu vücuda getirendir (FSEK. m.1). Davaya konu olan musiki eserini vücuda getirenin S.K olduğunda uyumsuzluk yoktur. Adı geçen sağığında bu eser üzerindeki mali haklarını davacıya devretmiştir. 3.7.1954’de düzenlenmiş bulunan temlikname başlıklı belgenin metni yukarıda genel kurul çoğunluğunun kararında aynen yazılıdır. Ancak bu belgede sözü edilen hakkı deyimine yalnız mali haklar girebilir. Çünkü bir eser üzerindeki manevi haklar devredilemez, Bu yön FSEK. nun 48. maddesinin 1. fıkrası hükmünden açıkça anlaşılmaktadır. Orada belirtildiğine göre “Eser sahibi veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları...,başkalarına devredebilirler”. Şu halde manevi hakların devri söz konusu olamaz. Miras yolu ile sadece mali hakların intikal edebileceğine dair aynı Kanunun 63. maddesinin 1. fıkrasındaki açık hüküm de bunu doğrulamaktadır.

Temliknamede “telif hakları” denilmek suretiyle cemi edatının kullanılmış olması çoğunluğun görüşünde belirtildiği gibi mali hakkı yanında manevi hakkın da temlike katılmış olmasından değil, telif hakkı devredilen eserin birden çok olmasından ileri gelmektedir. Bu davanın davacısı olan kişi, eser sahibinin mirasçısı olmadığına göre manevi tazminat isteme hakkının mirasçıya geçip geçmeyeceği veya hangi hallerde geçebileceği üzerinde durulmasına da gerek yoktur. Çünkü az önce belirtildiği gibi ister miras nedeniyle, isterse temlik yolu ile olsun, kendi özel Yasasında eser üzerindeki manevi hakların başkasına geçmeyeceğinin hükme bağlanmış olması karşısında bunun aksi ileri sürülemez.

O halde davacı S.A., eser sahibi olmayıp sadece sahibinden mali hakları devralmış bir kişi durumdadır. FSEK.nun 19. maddesinin 3. fıkrası hükmüne göre eser sahibinden mali bir hak iktisap eden kimse ancak meşru bir menfaati bulunduğunu ispat suretiyle eser sahibine aynı kanunun 14, 15 ve 16. maddelerinin üçüncü fıkralarında tanınan hakları, kendi namına kullanabilir. Oysa davaya konu olan işte eser sahibinden mali hak devralan davacı tazminat isterken bir menfaati bulunduğunu ve bunun meşru olduğunu ispat etmediği gibi, aynı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtildiği şekilde sahibinin, ölümünden sonra öncelikle sağ kalan eşi ve çocuklarının ve diğer yetkililerin sözü edilen kullanmadıklarını ne ileri sürmüş ne de ispat etmiştir. Genel kurul çoğunluğunun kararında

da anılan madde hükmüne dayanılması halinde devralanca manevi tazminat istenebileceği açıklanmış olmakla beraber orda belirtilen koşulların var olup olmadığı üzerine hiç durulmamıştır.

Mahkemece verilen ilk kararda dava kabul edilirken sadece şarkının başkasına izinsiz okutturulmuş olması manevi tazminat işleyebilmenin nedeni olarak gösterilmiş ve direnme kararında aynen (...*şarkının okunmasında malikin şeref ve haysiyetini kırıcı bir eylemin mevcudiyeti taleple alakalı değildir. Buradaki ihlal edilen menfaat, davacının şahsi bakımından tamamen kendisine mal etmiş olduğu şarkının başka bir kişi tarafından sunulmasıdır. Sanat esprisi bakımından kendisi için önemli olan da budur. Ve kendisini özen keyfiyet de bu olduğu için manevi tazminat takdir edilmiştir*) aynı gerekçe tekrarlanmıştır.

Bozma kararında açıkça belirtildiği gibi; sadece bu gerekçe ile manevi tazminata hükmedilemez. Çünkü, Yasa hükmüne göre eserin başkası tarafından okunmuş olması tek başına manevi tazminat istemeye hak vermemektedir. Böyle bir olaya dayanılarak manevi tazminat işlenebilmesi için ayrıca eser okunduğu sırada sahibinin adının belirtilmemesi gerekmektedir. Davaya konu olan olayda eser okunurken, sahibinin adının belirtilmediği yolunda bir iddia ileri sürülmemiştir. Genel kurul çoğunluğunun kararında eserin izinsiz okunmasından ibaret Mahkeme kararındaki benimsemenin manevi tazminat istenilmesine yol açacağı kabul edilmekte, eserin çalınıp söylenirken özelliğinin haleldar olması halinde böyle bir tazminat istenebileceğinden söz edilmektedir. Gerçekten FSEK'in 16. maddesinin son fıkrasında izin verilmiş olsa bile eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere eser sahibinin muhalefet hakkını muhafaza edeceği yazılıdır.

Dava dilekçesinin bir bölümünde, eserin aslına uygun olarak okunmadığından söz edilmektedir. Ancak, anılan Kanunun yukarıda belirtilen 19. madde koşulların var olduğu bir an için kabul edilse bile Mahkemece, çalınıp okunurken eserin mahiyet ve hususiyetinin bozulup bozulmadığı üzerinde hiç durulmamıştır. Sadece eserin izinsiz okunmuş olması nede-nine dayanılarak manevi tazminat takdir ve hükmolunmuş ve bu karar yalnız davalı tarafından temyiz edilmiştir. Her ne kadar verilen karar sonucunu itibariyle davacı yararına ise de HUMK'nun 427. maddesi hükmüne göre davada haklı çıkmış olan taraf dahi hukuki yararı olması şartıyla hükmü temyiz edebilir. Genel kurul çoğunluğunca da benimsendiği gibi gerekçesi yönünden kanuna uygun düşmeyen kararı davacı da o yönden temyiz etmeli ve eserin mahiyeti ve hususiyetinin bozulduğuna dair bir

iddiası varsa bu iddianın ispatına olanak verilmediğini ileri sürerek kararın bozulmasını istemeliydi. Bunu yapmadığına göre ortada davalı yararına usulen kazanılmış bir hak oluşmuştur. Bu kazanılmış hak karşısında sözü edilen yönün incelenmesine artık olanak kalmamıştır.

Kaldı ki davacı yargılama aşamalarında böyle bir inceleme yapılmasını istememiş, aksine son oturumda mevcut delillere göre karar verilmesini istemiştir. O halde eserin mahiyet ve hususiyetinin bozulduğu yolunda sabit olmuş bir iddia yoktur. Bu itibarla Genel Kurul çoğunluk kararında belirtildiği üzere, eserin dava dışı kişiler tarafından çalınıp okunması sırasında özelliğinin haleldar olup olmadığı incelenmek üzere dosyanın Özel Daireye gönderilmesine gerek olmadığı gibi, bu yön üzerinde Mahkemece de, Özel Dairece (de) o yolda bir inceleme yapılmasına hukuken imkan bulunmamaktadır.

Temyiz olunan kararın bu nedenlerle bozulması oyunda bulunduğu-muzdan çoğunluğun kararına katılmıyoruz.

5. (4.HD., 28.5.1984, E. 1984/2865, K. 1984/5113³⁰²)

Dava, maddi ve manevi tazminat isteminden kaynaklanmaktadır.

Davada, davacı; Ağa Han Mimarlık ödülüne konu Ankara'daki Türk Tarih Kurumu Binası'nın mimari (iş) ve projesinin davalıyla birlikte yapıldığını ve 1961 yılında Kurum ile sözleşme imzalandığını, ilaveten Kurum ile olan ilişkilerin gene birlikte yürütüldüğünü ve hatta ücretin de yarı yarıya alındığını, neticede ortak yaratmak çabası ile müştereken vücuda getirilen bir eser ve bu esere bağlı bir hak söz konusu olduğu halde kendisinin yardımcı mimar olarak takdim edildiğini ve söz konusu ödülü davalının tek başına aldığını ileri sürerek davalıya ödül olarak tediye edilen miktarın yarısını maddi tazminat olarak ve ayrıca adının gizlenerek projenin davalıya mal edilmesi suretiyle kişilik ve manevi değerler bakımından uğranılan zarar karşılığı da manevi tazminata hükmedilmesini dava ve talep etmiştir. Yerel Mahkemece iddia sabit görülerek ve dava konusu tarafların ortak ürünü olduğu kabul edilerek talebe aynen hükmedilmiştir.

Günümüzde olduğu kadar çağlar boyunca da sanatın çok önemli bir dalını oluşturan **mimarlık; dar anlamda yapıların fikri temelini oluşturan plan ve projeleri hazırlamak, yapıların gerçekleştirilmesi döne-**

³⁰² YKD, C.X,S.12/1984,s.1790-1795; DÖNMEZ, s. 354-358.

minde denetim ve yönetim hizmetlerini üstlenmek biçiminde tanımlanabilir. Başka bir ifade ile de **mimar, yapı projesini, yapı sanatı ve tekniği kurallarına göre tasarlayan ve düzenleyen, yapının gerçekleştirilmesine kadar onu yöneten ve denetleyen, teknik bilgisi ve becerisi olan meslek sahibi kişidir** (Walter Sauter’e atfen Doç. Dr. İbrahim Kaplan, Türk İsviçre Hukukunda Mimarlık Sözleşmesi ve Mimarı Sorumluluğu, Ankara 1983, sayfa 7). Mimarlık hizmetlerinin ve dolayısıyla mimarın yükümlülüklerinin sırasıyla ön (avan) proje, kesin proje, uygulama ve detay (detay) projeleri, gider tahmini (yaklaşık yapı maliyeti), ihale dosyasının düzenlenmesi hizmetleri, yapının mesleki denetim hizmetleri, yapının teknik bakımından denetim ve yönetimi hizmetlerinden (teknik uygulama sorumluluğu) oluştuğu doktrinde tartışmasızdır. Ne var ki , **bu hizmetlerin temeli, eserin orijinalliğinin ve mimari niteliklerinin kaynağı, sanatsal değerinin ve sanat anlayışının belgesi önemle ve öncelikle ön (avan) projesidir. Çünkü mimarın form, dizayn ve estetik anlayışı bu ön projede gerçekleşmiştir.** Zaten Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi’nin 3. maddesinde ön projenin, belli bir yapının kesin ihtiyaç programı, öngörülen maliyet tavanı, arsa verileri, varsa proje yarışmasındaki fen tavsiyesine uygun çözüm getiren bir proje olduğuna, ön projede vaziyet planı ile kat ve çatı planları, kesit görünüşler ve mimari raporların bulunacağına ilişkin hükümler bu düşüncenin en önemli kanıtıdır. Bütün bunlara ilaveten İnşaat Mühendisleri Odası ile Mimarlar Odası’nca düzenlenen “Mimari Proje Standartları”nın 3. maddesinde ön projenin hazırlanmasında yapının taşıyıcı bünyesi ile tali sistemleri, tesisat sorunları ve bunlarla ilgili tesisler göz önünde bulundurulur denilmek suretiyle, **ön projenin mimarlık eserinin yada mimari çalışma ürününün, mimarın sanat ve teknik karakterini ve yapının bütünlüğünü oluşturan temel öge olduğu vurgulanmaktadır.**

Davaya konu yapının ön projesinin Kurum ile davalı arasında 1951 yılında imzalanan sözleşme uyarınca yalnızca davalı tarafından gerçekleştirildiği tartışmasızdır. Esasen davacı vekilinin 6.5.1981 tarihli cevaba cevap dilekçesinin üçüncü sayfasında kabul edildiği üzere 1958 yılında mezun olan ve ancak 1954 yılından sonra, o da öğrenci olarak davalı ile birlikte çalışan davacının bu ön projeye hiçbir katkısı olmayacağı da açıktır. Söz konusu ön (avan) projenin Kurum Yönetim Kurulu’nca beğenildiği ve 1952 yaz başında Basımevi Bloku’nun yapımına başlandığı, ancak çeşitli nedenlerle Kurum binasının inşasına başlanamadığı, aradan 9 yıl geçtikten sonra 1961 yılında bu kere davacının da imzasını taşıyan 1961 tarihli bir

sözleşme ile esas yapının projelerinin kabul ve 1963 Haziran ayında da inşaat geçildiği dosya içinde bulunan belgeler içeriğinden anlaşılmaktadır. O halde davada çözümlenmesi gereken ana sorun, 1961 tarihli kesin projeye konu yapının **gerçekten tarafların ortak çalışma ürünü olup olmadığı ve kesin proje ile 1951 tarihli ön proje arasında bağlantılı ve ilişki bulunup bulunmadığıdır**. Yoksa anlaşmazlığı bir sanat ürününün taşıdığı temel ilkeler ve özellikleri bir kenara bırakarak adi ortaklık kuralları içerisinde çözümlenmek yada mimarlık sözleşmesinde davacının da taraf olmasını eserin ortaklaşa gerçekleştirildiği biçiminde kabul etmek mümkün değildir.

Davaya konu yapının taraflarca üretilen ortak bir eser olduğunu kabul eden Yerel Mahkeme, bu konuda hiçbir kanıt ve gerekçe göstermemiş, yalnızca bilirkişi raporunda benimsendiği ifadesiyle yetinmiştir. Gerçekten Mahkemece benimsenen ve hükme esas tutulan 20.10.1983 tarihli bilirkişi kurulu raporuna sonuç bölümünde “sözleşmenin sarih olarak belirttiği eşit ortaklık dışında bir statünün mütalaa edilemeyeceği” açıklanmaktadır. Ancak böyle bir sonuca ulaşılmasının hukuki, makul, mantıklı ve inandırıcı delilleri bilirkişi kurulu raporunda genel ifadelerin dışında açıklanmış değildir. Bilirkişi kurulu yetersiz raporunda yalnızca taraf sorularını cevaplandırmakla yetinmiş ve uyuşmazlık konusu üzerinde ciddi bir incelemede bulunmamıştır. Özetle bilirkişi raporu hiçbir şekilde hüküm tesisine elverişli görülmemiştir. Bilirkişi kurulu taraf sorularını cevaplandırırken bile açık ifadeler yerine daima kapalı, her iki anlama da gelebilen, kesin görüş taşımaktan kaçınan, çelişik ve müphem beyanları tercih etmişlerdir. Örneğin, uyuşmazlığın ve anlaşmazlığın esasını teşkil eden konuda; Raporun (2-b) maddesinde “1951 ve 1961 yılında ve inşaat safhasında projede önemli değişiklikler yapıldığı da ortadadır” biçiminde aksi bir düşünceye yönelinmiştir. Hemen takiben (C) bendinde ise sırasıyla “Proje, taslak ve etütler üzerinde yapılan düzeltme araştırmaların, kimin gösterdiği doğrultuda yapıldığı konusunda kesin bir görüş ifade etmemiz mümkün değildir” cümlesini takiben “Ancak ortaklar arasında kıdemli ve daha tecrübeli olan Turgut’un kararların alınmasında genellikle daha etkin rol oynadığını tahmin edilebilir” düşüncesi ortaya konulmuştur. Ama bununla da yetinilmemiş, bu kez paragrafta “öte yandan, böyle bir durum diğer ortağın kararları üzerinde hiç etkisi olmadığı anlamına da gelmez” cümlesiyle son verilmiştir. Raporun diğer bölümleri de hemen aynı üslup özelliğini taşımaktadır. Böyle bir raporun benimsenmesi ve hükme esas tutulması yerel mahkemenin önemli bir yanılışıdır.

Diğer bir yanılgı ise, bilirkişi incelemesinin sınır, nitelik kapsamını yeterince belirlemeyen Mahkemenin dosyayı bilirkişi incelemesine tabi tutmasıdır.

Şöyle ki;

a) Davada ,davacı iddiasının temeli, Ağa Han Mimarlık Ödülüne Türk Tarih Kurumu Binası proje müellifinin taraftar olduğu, daha açık bir deyimle ortak çalışma ürünü olan projeye (davacının ortak) bulunduğu düşüncesinden kaynaklanmaktadır.

b) Projenin temelini oluşturan 1951 tarihli ön (avan) projenin dava-
lının bağımsız ürünü olduğu ve kurumca benimsenip kabul edildiği ve o tarihlerde davacının henüz orta öğretimde öğrenci bulunduğu tartışmasızdır. Davacı, 6.5.1981 tarihli cevaba cevap dilekçesinde davalının 1957’de yaptığını beyan ettiği proje ile 1961’de birlikte yapılan proje arasında hiç-bir ilgi ve ilişki olmadığını iddia etmektedir.

c) O halde kapalı bir biçimde ifade edilmekle birlikte davacının iddiası, 1961 tarihli projenin 1951 tarihli projeye dayanmadığı, tamamen yeni ve bağımsız proje olduğu ve bu yeni projenin tarafların ortak katkısıyla gerçekleştirilmiş bulunduğu hususlarından ibarettir. Bu durumda böyle bir iddianın sahibi davacının iddiayı ispat etmesi, bu konudaki delillerini ibraz etmesi, kendi katkısının neler olduğunu açık ve net bir biçimde ayrıntılı olarak belirtmesi ve nihayet bu katkının ortaklaşa bir ürün değerlendirmesine esas sayılabilecek bir orana yükselmesi gerekmektedir. Yerel mahkemece bu hususlar ve özellikle ispat külfetinin davacıya ait bulunduğu olgusu üzerinde yeterince durulmamış ve inceleme bir hukuksal dayanağa oturtulmamıştır.

Öyle ise mahkemece yapılacak iş;

aa) davacıya gerekli açıklama yaptırıldıktan ve varsa delilleri ibraz ettirdikten sonra dosya bu konuda benzeri büyük mimarlık yarışmaları jürilerine katılmış, yeterli deneyime sahip ve tamamı teknik elemanlardan oluşan uzman bir kurula tevdi edilmelidir.

bb) **Anılan kurulun, ve özellikle 1951 ve 1961 tarihli projelerin bir mukayesesini yapması ve son projede ilk projeye göre eserin bütününde, sanat, estetik, biçim ve mimari detaylar yönünden önemli değişikliklerin bulunup bulunmadığını ve neticede sonraki projenin yeni bir proje sayılıp sayılmayacağını belirlemesi ve değişikliklerin çok ayrıntılı mimari tahlilini yapması gerekmektedir. Şayet sonraki projedeki değişiklikler eserin ana karakterini değiştirmiyorsa, tasa-**

rım ve mimari anlayış açısından ilk projedeki ilkelere dayanıyorsa davanın reddedilmesi zorunludur.

cc) Buna karşı ikinci proje birincisinden tamamen bağımsız nitelikte yada çok az etkilenmiş bir yeni proje mahiyetinde kabul ediliyorsa, bu taktirde değişikliğe konu hususlarda ve bütün ayrıntılarda taraflardan hangisinin gerek biçim ve gerekse kompozisyon yönünden sanat ve mimarlık anlayışı ile teknik bilgisinin egemen olduğu araştırmalı ve açıkça ortaya konulmalıdır.

dd) Tabiatıyla bu incelemede belirgin olarak tespit edilmesi gereken **davacı katkılarının eserin bütününe göre oluşturduğu oran matematisel olarak açıklanmalıdır. Bu şekilde belirlenecek oranın eserin ortak çalışma ürünü sayılabilecek bir seviyeye ulaşp ulaşmadığı belirtilmelidir.**

ee) **Bilirkişi incelemesinde tarafların dava konusu esere katkıları belirlenirken ve özellikle son projedeki ilk projeye göre yapılan değişiklikler ele alınırken, tarafların o tarihteki (yani 1961 yılındaki mimarlık bilgileri, tecrübeleri, eserleri ve savundukları mimari çizgi, biçim hacim ve sanat anlayışları, kısacası) mimari kariyerleri önemle göz önünde tutulmalıdır.** Davacının sonradan mimari övgüye değer eserler meydana getirmesinin bu dava ile hiçbir ilgisi yoktur. 1958 yılında mezun olduğu kabul edilen davacının 1958-1961 arası mimarlık çalışmalarının değerlendirilmeye alınması ve davalının da 1961 yılına kadar sürdürdüğü faaliyetlerin son projenin değerlendirilmesinde temel kabul edilmesi kaçınılmazdır.

Yerel Mahkemece bütün bu hususlar yeterince araştırılıp değerlendirilmeden; sonraki projenin ilk projeden tamamen ayrı ve yeni bir proje olup davacının ortak katkısıyla gerçekleştirildiği inandırıcı bir biçimde tespit edilmeden, sözleşmede davacının taraf olarak imzasının bulunmasının yada adi ortaklık ilişkisinin varlığının bir sanat eserinin ortaklaşa gerçekleştirildiği konusuna kesinlikle delalet edemeyeceği düşünülmeden eksik incelemeye dayalı bilirkişi kurulu raporuna dayanarak davanın aynen kabulü doğrultusunda hüküm tesisi ve usul hükümlerine aykırı olup bozmayı gerektirir.

6. (11. HD., 15.4.1992, E. 1992/490, K. 1992/1984³⁰³)

1- Taraflar arasındaki çekişme 21.1.1985 tarihli ... Bankası İzmir-Deniz Bostanlısı Toplu Konutlar Proje Yaptırma Sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Davacı, dava konusu projeleri yaparak davalı bankaya teslim etmiş ve bedeli 26.000.000.TL.yı almıştır. Bundan sonra eser üzerinde hiçbir surette emeği geçmemiştir. Bu durumda, (davacı tarafından) yapılarak davalıya teslim edilen projelerin sahibi davalı bankadır. Bu husus ayrıca sözleşme ekli ‘Proje Yapım Şartnamesi’nin amaç ve kapsam başlıklı ikinci sayfasında yer alan “proje İdarece tasdik edildikten sonra İdarenin malı olacağından, İdare gerekli gördüğü her türlü tadilatı işin seyrine göre proje müellifinin muvafakatini almadan yapabilecektir” hükmünden de anlaşılmaktadır. O halde, davacının 100.000.000 TL. kentsel tasarım müelliflik ücreti ve 400.000.000 TL. mimari müelliflik ücreti isteminin yasal dayanağı bulunmadığından davacı vekilinin bu kısma ilişkin karar düzeltme isteği yerinde görülmemiştir.

2- Ne var ki Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 16/son madde ve fıkrasına göre, eser sahibi (yüklenici) kayıtsız ve şartsız izin vermiş olsa bile şeref ve itibarını yahut eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozan her türlü değiştirmelere muhalefet hakkını muhafaza eder. Bu haktan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüzdür. Yasanın bu açık hükmü gözetilerek davacının manevi tazminat istediği yönünden içlerinden biri hukukçu, diğerleri konusunda uzman bilirkişilerden teşkil olunacak bir bilirkişi kurulu ile keşif yapılarak, davacı tarafından yapılarak davalıya teslim olunan projelerin, davalı banka tarafından uygulama projesine dönüştürülmesi sebebiyle yasada açıklanan anlam ve amaca göre eserin manevi tazminatı gerektirecek nitelikte “mahiyet ve hususiyetinin” bozulup-bozulmadığı hususunda rapor alınması ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, hükmün bu kısmının yanılğı ile onanmış olduğu anlaşıldığından Dai-remizin 11.11.1991 gün ve 1991/1793-5364 sayılı onama kararının manevi tazminata ilişkin bu kısmının kaldırılarak usul ve yasaya aykırı kararın bozulması gerekmiştir.

7. (4.HD., 22.10.1992, E. 1991/5141, K. 1922/11254)

Taraflar arasındaki tespit davası üzerine yapılan yargılama sonunda, ilamda yazılı nedenlerden dolayı (Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye

³⁰³ YKD, C. 18, S. 10/1992, s. 1585-1586; BEŞİROĞLU, s. 1280-1282

Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi) İsimli 12 ciltlik eserin hazırlanmış hali ile yayınlanması durumunda telif ücretinin % 65'inin Hamit mirasçısı davalı Erdem'e, % 15'inin davacı Sadi'ye, % 10'unun davacı Zarife ve % 10'unun da davalı Erdoğan'a ait olacağının tespitine ilişkin hükmün süresi içinde davacılar avukatı ile davalılardan Erdem avukatı taraflarından temyiz edilmesi üzerine; tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor okunduktan sonra dosya incelendi, gereği konuşuldu.

Davacılar Sadi ve Zarif; davalı Erdoğan ve diğer davalı Erdem'in miras bırakanı Hamit Zübeyir ile birlikte “Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Çağlarında Türk Kazı Tarihi” isimli eseri hazırladıklarını, ancak Zübeyir'in ölümünden sonra davalı Erdem'in eseri yalnız Hamit adına basılmak üzere eser sahibi olarak Kültür Bakanlığı'na verdiğini, bu nedenle ortak esere ait telif ücretinin hangi oranda paylaştırılacağının tesbitine karar verilmesini istemişlerdir. Mahkeme, eser sahibinin Hamit olduğunu kabul etmiş, ancak eserin hazırlanmasında davacılar ve davalı Erdoğan'ın katkıları gözetilerek 12 ciltlik eserin hazırlanmış haliyle yayınlanması durumunda telif ücretinin % 65'inin Hamit varisi Erdem, % 15'inin davacı Sadi, % 10'unun Zarif ve 10'unun da davalı Erdoğan'a ait olacağının tespitine karar vermiştir.

Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 10/1. maddesi; “birden fazla kimsenin iştirakiyle vücuda getirilen eser ayrılmaz bir bütün teşkil ediyorsa, eserin sahibi onu vücuda getirenlerin birliğidir” kuralı ile “ortak eser” kavramını kabul etmiştir.

Ortak eserden söz edebilmek için, “eserin birden fazla kimsenin yaratıcı ortak çabası ve katkılarıyla meydana gelmesi” gerekir. Çaba ve katkıların az veya çok olması önemli değildir; yeter ki yaratıcı çaba ve katkı bulunsun (Ayiter, Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, s. 100). Bu nedenle çaba ve katkının nicelikli değil nitelikli olması gerekir. Sırf yol gösterme veya yardım etmek ortak eser için yeterli olamaz. Bir sanat eserinin yaratılması için “onun şekillenmesine eylemli olarak yaratıcı çaba ile katılmak” gerekir. Bir eserin yaratılmasına yardımın sözkonusu olması halinde ise; çaba, yaratıcı olmamakla yaratıcı çabaya bağımlı olarak görülmektedir. Bir teknik ressamın kendisine verilen çizmesi, bir profesörün yazacağı bilimsel eser için asistanın bibliyografyaya malzeme toplaması, heykeltıraşın yardımcısının kendine verilen modele göre bronz kalıbını hazırlaması veya taş blok yontması gibi hallerde ortak eserden söz edilemez (Ayiter, age., s. 101). Nitekim

FSEK'nun 10/III. maddesinde bu “bir eserin vücuda getirilmesinde yapılan teknik hizmetler veya teferruata ait yardımlar iştirakli esas teşkil etmez” şeklinde açıklanmıştır. Bu durumda yapılan yardım, bir vekalet veya eser sözleşmesi ilişkisini ortaya koyar.

Olayımızda, davacıların davalı Erdoğan'ın eserinin hazırlanmasında yaratıcı çaba katkıların bulunmadığı, ancak eserin yaratılmasına yardım ettikleri anlaşılmaktadır. Davacı Zarf, eser için Devlet arşivlerinde tarama yaparak buldukları belgeleri zaman zaman tercüme de yaparak yazar Hamit'e göndermiştir; diğerleri de Hamit'in hazırladığı yazıları daktilo etmek ve belge toplamak gibi yardımlarda bulunmuşlardır. Davacılar, esere kendilerinin de yaratıcı çabalarının katkılarının bulunduğunu kanıtlayamamışlardır. Aslında davacıların eserin meydana gelmesinde kendi çaba ve katkılarının “yaratıcı çaba” olduğu yolunda bir iddiaları da yoktur. Nitekim, davacı Zarf'in davalı Erdem'e yazdığı 29 Kasım 1986 günlü mektupta ki “... kitabı birlikte yazdık diyemezler. Yardım ediyorlardı, yardımları da şöyle idi; Hamit Bey bütün zamanını gecesini gündüzünü harcayarak kısım kısım kaleme aldığı notları bir araya getirip tamamladığı bahisleri daktiloya çekmek; belgeleri Hamit Beyin isteği ve tavsiyesi olmasa idi, ben neden, niçin inceleyecek ve bulduklarımın fotokopilerini gönderecektim; fikir ve düşünce yalnız Hamit Bey'indir...” şeklindeki açıklamaları da katkının yaratıcı olmayıp, yardım şeklinde olduğunun kabulünün doğru olduğunu göstermektedir.

O halde; mahkemenin, eserin sahibinin Hamit olduğu yolundaki kabulü doğrudur; ancak buna rağmen eserin telif hakkı bedelini taraflar arasında paylaştırmaması ise hatalı olmuştur. Davacıların yardımları nedeniyle sözleşmeye dayanan bir alacak hakları varsa bir eda davasıyla istenmesi olanağı olduğu da unutulmamalıdır.

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz eden davalı Erdem yararına (BOZULMASINA), aynı nedenlerle davacıların temyiz itirazlarının reddine ve davalı Erdem'den peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine, 22.10.1992 gününde oybirliğiyle karar verildi.

8. (11. HD., 26.1.1995, E. 1994/7727, K. 1995/461)

Davacı vekili, müvekkilinin 1975 yılından beri ilkokullar için kitaplar bastırıp sattığını, davalılardan Nazmi'nin de daha önce müvekkili ile birlikte çalıştığını, bilahare müvekkilinden ayrılarak diğer davalılarla bir-

likte “Mutlu Yayıncılık” firmasını kurduklarını, davalı Nazmi’nin 1. Baskıda “Yıldız Okuma” 2. baskıda “Mutlu Okuma” isimli kitapları yazarak piyasaya sürdüğünü, oysa bu kitapların sahifelerinin tertibi, içeriği, kullanılan cümleler vs. bakımından müvekkilinin yazdığı “1. Sınıflar İçin Okuma-Anlatım-Dilbilgisi” kitabıyla iltibas yaratır nitelikler taşıdığını ileri sürerek davalıların haksız rekabetinin men’ini, kitapların toplatılmasını, basım ve dağıtımının önlenmesini, 10.800.000 TL maddi, 10.000.000 TL manevi tazminatın tahsiliyle hüküm özetinin gazeteyle ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, müvekkillerinden Nazmi ve Z. Emine’nin müellif, diğerlerinin dağıtımçı ve yayıncı olduklarını, mevcut benzerliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uyma zorunluluğundan kaynakladığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; davalıların maksadın haklı göstereceği orandan fazla alıntılar ve benzetmeler yaparak, dil, üslup, dizayn, örnekleme konularında davacıya ait kitaptan alıntılar yaptıkları, bu halin haksız rekabet oluşturacağı gerekçeleriyle haksız rekabetin men’ine, davalılar kitabının basım, dağıtım, satışının durdurulmasına, dağıtılanların toplanmasına, 10.800.000 TL maddi, 5.000.000 TL manevi tazminatın tahsiline, hüküm özetinin gazeteyle ilanına hükmedilmiştir.

Kararın davalılar vekilince temyizi üzerine;

Dairemizin 28.6.1994 tarih ve 1994/1346 E. 5622 K. Sayılı ilamıyla; davalılar vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Davalılar vekili, bu kez karar düzeltme isteminde bulunmuştur.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davalılar vekilinin HUMK’nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

9. (11. HD., 13.3.1995, E. 1994/6106, K. 1995/1880)

Davacı vekili, müvekkilinin imal ettireni ve yapımcısı sıfatıyla münhasır eser sahibi bulunduğu (Krallar Kralı; At, Avrat, Silah; Davudo; Silaha Yeminliyim; Tehlikeli Adam ve Üçünüzü de Mıhlarım’) adlı filmleri üzerindeki yasak kalkınca Kültür Bakanlığı’na kayıt ve tescil için yapılan başvuru sırasında, davalının bu filmlerle ilgili olarak açtığı hasımsız dava

sonucu aldığı tespit kararına dayanarak kayıt ve tescil girişiminde bulunduğu öğrenildiğini, bu kararın müvekkili bakımından kesin hüküm oluşturmayacağını ileri sürerek, davaya konu filmlerin eser sahibinin FSEK 15/3 md. uyarınca müvekkili olduğunun tespitini, davalının vaki ve muhtemel tecavüzün önlenmesini, davalının hasımsız tespitinin geçersiz kılınmasını ve hüküm özetinin anılan Yasa'nın 78. maddesi uyarınca ila-nını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, dava konusu filmlerden “At, Avrat, Silah” filminin Erman Film yapımı olduğunu, “Davudo” filminin yapımcısının ise belli olmadığını, davaya konu filmlerin 11.8.1975 tarihli sözleşmeyle Yıldız Film şirketince müvekkiline satılarak, filmlere ait tüm teknik materyallerin teslim edildiğini, geçen süre içerisinde bu filmlerle ilgili mülkiyet uyuşmazlığının çıkmadığını, FSEK'nun 29. maddesinin öngördüğü 20 yıllık koruma süresinin dolması nedeniyle 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanununun 5 ve 8. maddelerine göre Bakanlık nezdinde tescil ve mülkiyet hakkını kullanabilmek amacıyla müvekkilince hasımsız olarak açılan tespit davasının kabulü sonuçlandığını, davacının yapımcı sıfatıyla eser sahibi bulunduğu filmlerin mali haklarını kapsayan tüm mülkiyet haklarının satış ve devir yolu ile elden çıkardığını, davacının manevi haklarına bir ilişkinin söz konusu olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, mübrez belgeler, tespit dosyası ve bilirkişiler kurulu raporuna dayanılarak, davaya konu tüm filmlerin yapımcısının davacı olduğu, uyuşmazlığın özünün bu filmler üzerindeki mali hakların kime ait olduğu noktasında toplandığı, söz konusu filmlerin 1965 ve 1966 yıllarında alenileştiği, davalının açtığı hasımsız dava sonunda Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.4.1993 gün ve 1992/209-211 sayılı tespit kararının davacıyı bağlamayacağı, bu filmlerin kim tarafından vücuda getirildiği hususunda beliren çekişme nedeniyle davacının FSEK 15/3 maddesine göre tespit davası açma hakkının bulunduğu, anılan Yasa'nın 14, 15 ve 16. maddelerinde öngörülen umuma arz ve adın belirtilmesi yetkisi ile eserde değişiklik yapılmasını önleme hakkını içeren manevi haklara davalının tecavüzünün söz konusu olmadığı, ancak FSEK 69/1 maddesine göre mali veya manevi haklarında tecavüz tehlikesine maruz kalan eser sahibinin muhtemel tecavüzün önlenmesini isteyebileceği, davalının tespit davası açarak hasımsız tespit kararı almasının, davacının manevi haklarına tecavüz tehlikesi yaratacağından muhtemel tecavüzün önlenmesine karar verilmesi gerektiği; öte yandan, eser sahibine tanı-

nan mali hakların tabi olduğu 20 yıllık sürenin geçmiş olması nedeniyle mali haklara ilişkin tecavüzün önlenmesi davasının reddi gerektiği gerekçesiyle hasımsız tespit ilamının hükümsüzlüğü ile, davaya konu filmlerin eser sahibinin davacı olduğunun ve manevi hakların da davacıya ait olduğunun tespitine, davacı manevi haklarına muhtemel tecavüzün FSEK 69. maddesi gereğince önlenmesine, hüküm özetinin ilanına, 20 yıllık koruma süresi geçtiğinden davacının mali haklara tecavüzün önlenmesi hakkındaki talebin reddine karar verilmiştir.

Hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, tarafların aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davacı tarafın, davaya konu (6) adet filmin eser sahibinin FSEK. nun 15/3 uyarınca davacı olduğunun ve buna bağlı olarak filmlerin mali ve manevi haklarının, TV yayın haklarının davacıya ait bulunduğu ve 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanununun 5. maddesi uyarınca, Kültür Bakanlığı nezdinde kendi adına kayıt tescil ettirebileceğinin tespitinin; davalının vaki ve muhtemel tecavüzünün önlenmesine ve davalının sağladığı hasımsız tespitinin geçersizliğinin belirlenmesini istemiş; Mahkemece ise, FSEK. 29 maddesince, öngörülen 20 yıllık koruma süresinin dolmuş olması nedeniyle davacının korunmağa değer mali haklarının bulunmadığını, anılan Yasa'nın 26/1 mad. uyarınca herkesin, eser sahibine tanınan mali haklardan yararlanabileceğinden bahsedilerek mali hakların korunmasına ilişkin tüm taleplerin reddine, davalının bu filmlerle ilgili olarak hasımsız tespit kararı alması suretiyle Yasanın 15/son maddesinde öngörülen eser sahipliği konusunda çekişme yarattığı ve umuma sunma, adın belirtilmesi isteme ve eserde değişiklik yapılmasını önleme yetkilerini kapsayan manevi haklarına ilişkin davacı eser sahibinin bu hakkına muhtemel tecavüzün önlenmesine ve bu tecavüz olgusuna mesnet olan hasımsız tespit ilamının hükümsüz kılınmasına karar verilmiştir.

1.1.1952 tarihinde yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre; bir sinema eserinin sahibi, onun imal ettireni (yapımcısı) olup, eserin umuma sunulmasıyla başlayan alenileşmeden itibaren 20 yılın geçmesiyle eser üzerindeki mali hakları sağlayan koruma süresi sona ermekte ve Yasanın 46. ve 47 maddelerinde sayılan dışında, eser sahibinin bu esere ilişkin mali hak, tekel ve ayrıcalığı ortadan kalkmaktadır. Davaya konu filmlerin alenileştiği 1965 ve 1966 yıllarına nazaran koruma sürele-

rinin dolduğu ve süreye bağlı fikri hakları da bağlayıcı sonuç doğuran yasaklamaya dair hükümet tasarrufları ile oluşan kesintiler nedeniyle dahi olsa süresinin durması veya kesilmesi söz konusu olmayacağından, Mahkemenin bu husustaki kabulü isabettir. Özel Yasa niteliğindeki 4.2.1987 tarih ve 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik eserleri Kanunu'nda film eserlerinin koruma sürelerine ilişkin bir süre öngörülmemiş olmakla beraber, eser sahibi veya çoğaltma, yayma ve gösterim haklarını içeren mali hakları geçerli bir biçimde devralan kişinin başvurusu üzerine, mali hakların kullanılmasına işlerlik kazandırmak üzere Kültür Bakanlığınca, eserin kayıt ve tescili yapıldıktan sonra eser sahibine veya mali hakları devralan kişiye "İşletme Belgesi" verileceği düzenlemesi yer almaktadır. Esasen, davalının sağladığı hasımsız tespit kararı da, sözü edilen Yasa'nın 5. maddesi doğrultusunda İşletme Belgesi istihsalı ile bu filmlerin dağıtım ve gösterim hakkını edinme amacına dönüktür. Davaya konu filmlerin eser sahibi olduğu isabetle saptanan davacının, bu filmleri Kültür Bakanlığı nezdinde kendi adına kayıt ve tescil ettirebileceğinin tespiti istemi hakkında bir karar verilmesi ve davalının yaptırdığı kayıt ve tescile ilişkin belgelerin getirilmemesi ve değerlendirme dışı tutulması doğru olmamıştır.

3-Davalı tarafın temyizine gelince:

Davacının korunmağa değer mali hakları bulunmadığı kabul edildiği halde; davalı tarafından sadece mali hakların kullanılması amacı ile alınmış bulunan Beyoğlu 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14.4.1993 tarih ve 1992/209 E, 1993/2111 K. sayılı hasımsız tespit ilamının, davacının bu filmleri üzerindeki eser sahibi olmasından kaynaklanan manevi haklarına ileriye dönük (muhtemel) tecavüzün ne şekilde yol açabileceğinin karar yerinde tartışılmaması ve gerekçelendirilmemesi doğru olmadığı gibi, konu 6 filmin yanı sıra "Büyük Soygun" adlı çekişme dışı bir filmin mülkiyet haklarının da davalıya ait olduğunu hüküm altına alan bu ilamın tümüyle hükümsüz kılınarak iptal edilmesi de, talebin aşıl原因 olarak hakları haledar edici bulunmuştur.

Mahkemece yapılması gerekirken iş; yukarıdaki açıklamalar ışığında, davacı tarafın talep ettiği tescil belgelerini getirip, çekişmeli eserlerin sahibi olan davacının, herhangi bir koruma süresi öngörmeyen 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 5. maddesi uyarınca, filmlerin kayıt ve tescilini isteyip istemeyeceğini; davalının bu yoldaki kayıt ve tescilinin geçerli olup olmadığı, anılan özel Yasa ve hükümleri çerçevesinde, davacının mali haklarının hukuki korunma görüp görmeyeceği ve salt mali haklarla ilgili olarak davalıca sağlanan tespit ilamının, davacının

manevi haklarına ne şekilde tecavüz tehlikesi oluşturduğu hususları üzerinde durulup etraflıca irdelenip tartışılarak ve gerekirse Ticaret Hukuku, Fikri Hukuk ve Sinemacılık uzmanlarından oluşturulacak bilirkişiler kurulundan kapsamlı rapor alınarak, sonucuna göre davanın esasına dair bir karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ve yetersiz gerekçeyle verilen hükmün bozulması gerekmiştir.

10. (11. HD., 24.3.1995, E. 1994/7485, K. 1995/2463)

Davacı vekili, müvekkilinin mimari projelerini hazırladığı otel binası inşaatına davalı S.K'nin projeye uygun sayılmayacak biçimde başladığını ve inşaatın 4. kata kadar bu şekliyle devam ettiğini, bilahare inşaat alanı malikinin değişmesi sonucu yeni malik olan diğer davalı Şirketin, proje müellifi olan müvekkilinin onayını almaksızın yapıyı hastaneye dönüştürdüğünü, müvekkilinin tadilat projesinin onayına muvafakat etmediğini onay makamı olan Çankaya Belediyesi'ne bildirdiğini, buna rağmen değiştirilen onayının engellenemediğini, müvekkilinin müellif olarak 5846 sayılı Yasa ile korunan telif haklarının açıkça ihlal edildiğini ileri sürerek 15.000.000 lira maddi ve 10.000.000 lira manevi olmak üzere toplam 25.000.000 lira tazminatının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Şirket vekili, inşaatın müvekkili Şirket tarafından özel hastane yapılmak üzere satın alındığını, müvekkili eser sözleşmesinin tarafı olmadığından kendisine husumet yöneltilemeyeceğini, müvekkilinin otel projesini kullanmadığını, özel hastane projesini de davacıya yaptırmak zorunda olmadığını ve satın alma sebebine göre muvafakat alınmasına da gerek olmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı S.K. vekili, müvekkilinin sattığı gayrimenkulle bir ilgisinin kalmadığını, davanın mahiyeti gereği BK'nun 60. maddesi uyarınca zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin olayın meydana gelişinde hiçbir katkı ve sorumluluğunu bulunmadığını, ortada kanuna aykırı bir fiil bulunmadığını ve talebinde fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, projeler arasında hiçbir benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacı vekili temyiz etmiştir. Dairemizce hükmün onanmasına karar verilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkeme kararında belirtilip Yargıtay ilamında benimsenen gerektirici sebeplere göre davacı vekilinin HUMK'nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteginin reddi gerekir.

11. (11. HD., 12.12.1995, E. 1995/6393, K. 1995/9199)

Davacı vekili müvekkiline ait “Emmoğlu” şiirinin davalılardan Turan Bayburt (Ferdî Tayfur) tarafından izinsiz olarak ve şiirin özellikleri bozularak bestelendiğini ve davalı Ferdifon Kasetçilik A.Ş. tarafından da “Prangalar” adlı kasette kullanıldığını, davalıların müvekkilinin bilgisi dışında eserin anlam içerik ve niteliğine ters olan video klipler hazırlanmak suretiyle müvekkilinin mali ve manevi haklarına tecavüze bulunduklarını, davalılardan Ferdî Tayfur'un eserin kaset yapılması hakkını bazı firmalara da satmak suretiyle büyük kazançlar sağladığını, oysa davalı tarafın yaptıkları kasetler için sadece (1.000.000)'ar lira para ödediklerini ve müvekkilinin meşguliyetinin yoğun olduğu bir sırada okumasına fırsat olmadan bir makbuz imzalattıklarını, oysa FSEK. 16/3'e göre eser sahibinin izni bile olsa eserin mahiyeti ve hususiyetlerini bozan, şeref ve itibarı sarsan değişiklikler yapılamayacağını ileri sürerek şimdilik (100.000.000) lira manevi, (900.000.000) lira maddi tazminatın davalılardan tahsiline, FSEK. 69. maddesi gereğince vaki tecavüzün menine karar verilmesini talep ve dava etmiş, birleştirilen İstanbul Asliye 7. Ticaret Mahkemesinin 1994/87 esas sayılı dosyada ise davalı Ferdifon A.Ş.'nin “Emmoğlu” içerikli şiirin bir bölümünün “Prangalar” ve “Seni Arıyorum” adlı compact disc'lerde çoğaltarak yayın ve ticaret yaptığını belirterek (110.000.000) lira maddi, (70.000.000.) lira manevi tazminatın davalı şirketten tahsili istemiştir.

Davalılar vekili, cevabında, davacının 6.6.1992 tarihli yazı ile müvekkillerinden Ferdifon A.Ş. ye söz konusu müzik yapıtını dilediği sanatçıya seslendirmesi için izin verdiğini ve telif ücretini tahsil ettiğini, davacının Emmoğlu adlı eserin, davalılardan Ahmet Selçuk İlhan tarafından şiir biçiminde okunmasına ve Ferdifon A.Ş. tarafından yayınlanmasına da 11.8.1992 tarihli izin belgesi ile rıza gösterildiğini, ancak bu rızasını 6.6.1992 tarihli belgenin, karbon kağıda konularak elde edilen nüshası üzerine yazdığını ve telif ücreti aldığını 6.6.1992 tarihli belgeyi farkında olmadan imzaladığı yolundaki davacı iddiasının varit olmadığını, bilahare Emmoğlu adlı müzik yapıtının büyük ilgi toplaması nedeniyle işbu davanın açıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan delillere ve 6.6.1992 tarihli belgeye göre; davacının davalılarla anılan eseri çoğaltmaları, yaymaları, plak ve benzeri sanatsal faaliyetlerde bulunmaları konusunda geniş kapsamlı olarak izin verdiği, bu belgenin hile ve hata sonucu verildiği hususunun ispatlanamadığı, kaldı ki eserin anonim olduğu, davacıya ait olduğu kabul edilse dahi onun rızası alınarak telif hakkının davalılara ücreti mukabili devredildiği, diğer yandan eserin icra edilmesi esnasında davacıyı küçük düşürecek eserin orijinallikinden ayrılıp, onun özelliğini bozacak herhangi bir durumun da tespit edilmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davacı tarafın, davalılarca savunmasına dayanarak yapılan 6.6.1992 10.7.1992 ve 11.8.1992 günlü belgelerin iradeyi bozucu nedenlerle alındığı iddiasının sabit olmadığı anlaşılmakla, aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Davalılardan Ferdifon A.Ş. nin savunmasını ispat için ibraz ettiği 6.6.1992 günlü belgenin içeriğine göre, davacı Şemsi Belli'nin Emmoğlu adlı şiirinin tüm mali haklarını ivazlı olarak adı geçen davalı Şirkete devir ettiği ve bu davalının, Emmoğlu adlı şiiri, bu belgeye göre, aynen tamamen veya kısmen kullanabileceğini, çoğaltma, işleme, yayma değiştirme haklarına sahip olacağını, tamamen veya kısmen kendi kullanabileceği gibi dilediğine kendi sanatkarının sesi ile devir ve kullandırmakta serbest olduğunu, eseleri bant, kaset, plak bilumum ses, ses ve görüntü nakleden araçlarda kullanabileceğini, bu haklara bütün dünya ülkelerinde sahip olduğunu, kendisinden bu eserler nedeniyle hiçbir hak ve alacağı kalmadığını beyan ederim, diyerek de devir işlemini beyan ettiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere 5846 sayılı FSEK'nun 48 ve devamı maddelerinde mali hakların devrinden söz edilmektedir. Tartışmalı olmakla beraber, manevi haklar kural olarak devir edilemez. Mali haklar süresiz olarak da devir edilebilir. Bu durumda, bu devir süresi, eserin koruma süresi kadardır. Davalı şirketçe ibraz edilen ve içeriği aynen belirtilen devir belgesine göre, davacı taraf, dava konusu olan Emmoğlu adlı şiiri tüm mali hakları ile süresiz olarak devir ve temlik etmiştir. Bu durumda, davalı Şirket en geniş biçimde bu hakları kullanabilir. Ve başkalarına da devir edebilir hakka sahip olmuştur. Hal böyle olunca, davacının Emmoğlu adlı şiir için hiçbir mali hakkı kalmadığı sonucuna varılmıştır. Davalı Şirket, dava ko-

nusu şiirin anonim olduğunu da savunmuş ve hatta Mahkeme kararında da değinilmiş ise de, davalının ibraz ettiği belgenin içeriği ve çelişkili savunma karşısında, Mahkemenin bu kabulü doğru görülmemiştir.

Ancak, davacının manevi hakları devir etmediği anlaşılmıştır. Bu nedenle davacının manevi hakları yönünden ileri sürdüğü tüm iddiaların ve özellikle eser sahibinin adının gösterilmemesi ve eserin şeref ve itibarının düşürüldüğü hususları üzerinde durulması gerekir. Davacının manevi haklar yönünden ileri sürdüğü iddialarının esastan incelenmesi gerektiğinden ve bu konu bir uzmanlığı da gerektirdiğinden, tarafların başkaca delilleri var ise ibraz olanağının sağlanması ve uzman bilirkişi kurulundan rapor alınması ve hasıl olacak sonuç çerçevesinde bir karar verilmesi gerekirken, bu hususun gerekçesiz biçimde değerlendirilmesi doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

3-Davacı ayrıca, Turan Bayburt (Ferdî Tayfur) ve Ahmet Selçuk İlhan için de Emmoğlu adlı şiir için dava açmış bulunmaktadır. Az önce değinildiği üzere, davacı taraf, mali hakkı bakımından tüm haklarını devir ettiği için, artık bu davalının aleyhine de mali haklar yönünden bir dava açamaz. Ancak, davacının manevi haklar yönünden açtığı davanın esastan incelenmesi gerekir. Bu itibarla, ikinci bentte açıklandığı gibi, davacının manevi hakları için davalılar Tayfun ve Ahmet hakkındaki davanın da incelenmesi gerekirken, yazılı biçimde karar tesisi yasaya aykırı görülmüştür.

12. (11. HD., 1.3.1996, E. 1996/982, K. 1996/1263)

Davacılar vekili, davalıya ait Mihriban Boysan Lisesinin 2,5 kat olarak mimari ve statik projelerini hazırladıklarını, yapım sırasında Millî Eğitim Müdürlüğünün isteği üzerine aplikasyon ve kalıp planlarının yapılarak iki kat daha ilavesiyle 4,5 kat olarak tamamlandığını, davalının 2 ilave kat için istenen telif ücretini ödemediğini, FSEK 68 maddesi uyarınca telif ücretinin 49.405.920 TL olduğunu belirterek yasal faizi ile tahsilini dava etmiştir.

Davalı savunmasında proje bedelinin taşeron tarafından ödendiğini savunmuştur.

Mahkemece statik projenin FSEK ve Bern Sözleşmesiyle telif hakları kapsamına alınmadığına karar verilmiştir.

Karar, davacı vekilinin temyizi üzerine Dairemizce bozulmuştur.

Davacı vekili karar düzeltilmesi isteminde bulunmuştur.

Yargıtay ilamında belirtilen gerektirici sebeplere ve Mahkemece bozmaya uyulduğu

taktirde aynı Mahkemenin 1995/17-139 esas sayılı ve konusu aynı olan davacı dosyasının celp edip inceledikten sonra değerlendirilmesinin tabii bulunmasına göre, davalı vekilinin HUMK'nun 440. maddesinde sayılan hallerden hiçbirisini ihtiva etmeyen karar düzeltme isteğinin reddi gerekir.

13. (11. HD., 1.7.1996, E. 1996/2451, K. 1996/4820)

Davacı vekili, davalılardan C.... Şirketine ait Gebze Fabrikalarının atık su arıtma tesislerinin müvekkili şirket tarafında gerçekleştirilmiş olup, plan ve projesi ve meydana getirilen eser üzerinde davacının FSEK'na göre korunmaya değer üstün hakkı olduğunu, hal böyleyken Fabrikaya yeni kurulan boya imalat ünitesinin arıtma tesisleri için davalıların aralarında sözleşme yaptığını, ancak A... şirketinin kısa ve ekonomik yönden sonuca varmak istediğini, müvekkiline ait eserin mahiyetinin bozularak riske edildiğini, bu nedenle bu tesisin referans gösterilmediğini, ayrıca A... şirketinin ana yol cephesine kendisine ait tabelayı asarak sanki tüm tesisin kendi tarafından yapılmış izlenimi verdiğini, davacının maddi ve manevi zarara uğradığını ileri sürerek, davacıya ait eser üzerindeki tecavüzün önlenmesi ile eski hale getirilmesine, davalı A...'a ait levhanın kaldırılmasına, şimdilik (25.000.000) lira maddi ve (25.000.000) lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere bilirkişi raporuna nazaran, davacı tarafından tesis edilen atık su tesislerinin FSEK. kapsamında ve korunması gerekli bir ilmi fikir eseri olduğu, davacının izin ve muvafakati olmadan proje tadilatı yapılmayacağı, eser üzerindeki davacı logosunun kaldırılarak davalı A... şirketi levhasının asılmasının yine davacı haklarına tecavüz olduğu ve fakat maddi tazminata ilişkin zararın ise kanıtlanamadığı sonucuna varılarak, davacı tarafından tesis edilen atık su tesisi üzerindeki davalıların tecavüzlerinin önlenmesine ve eski hale getirilmesine, davalı A...'a ait levhanın tesislerden kaldırılmasına, takdir olunan (25.000.000) lira manevi tazminatın davalılardan tahsiline, maddi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Karar davalılar vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalılar ve kilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

14. (11. HD., 21.1.1997, E. 1996/6995, K. 1997/109³⁰⁴)

Davacı vekili, mimari projesi ve kontrol mühendisliğini davalının yaptığı Ulus 100. Yıl Çarşısı'nın mimari projeden kaynaklanan nedenlerle verimli bir şekilde işletilemediğini, Çarşının en önemli giriş katının açık ve boş olduğunu, buranın yeniden düzenlenerek hipermarket şeklinde hizmete sunulmasının zaruret olduğunu, daha önce proje değişikliğine izin verilmesi hususunda açılan ilk dava red edilmiş ise de, bu aşamadan sonra davalının 21.4.1995 tarihli yazı ile (13.000.000.000) lira telif hakkı talep ettiğini, bunun fahiş olduğunu ileri sürerek projede değişiklik izninin davalı mimara verilecek makul bir bedel karşılığında verilmesi, aksi takdirde davalının eser üzerindeki telif hakkının makul bir bedel üzerinden davacıya devrine karar verilmesini talep ve etmiştir.

Davalı vekili, aynı konuda açılan ilk davanın Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin E. 1990/22, K.1991/173 sayılı kararı ile reddedildiğini, ortada kesin hüküm bulunduğunu, 100. Yıl Çarşısı ve Büro Binasının komple bir eser olup, bir bölümünün telif hakkının satın alınmasının mümkün olmayacağını, müvekkilinin eseri üzerinde değişiklik yapılmasına muvafakati bulunmadığını ve buna da hakkı olduğunu, telif hakkının bir bedel karşılığı dahi devrine de razı olmadığını, buna rağmen Mahkemece aksi kanaate varılacak olursa, uzun bir çalışma sonucu bedeli ve fikri çalışma ile ortaya konmuş ve yarışmayı kazanmış eser üzerindeki emeğin manen de belirlenmesi gerektiğini yalnızca proje çizim bedeline hükmedilmeyeceğini, öte yandan müvekkilinin hizmetlerine karşılık bir kısım haklarının da ödenmediğini alacakların güncelleştirilmiş bedelinin (3.194.304.460) lira olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere bilirkişiler kurulu raporuna nazaran, taraflar arasında görülen ilk davanın, (eserin) tadiline izin verilmesine ilişkin olduğu, oysa bu davanın telif hakkının satın alınması suretiyle proje değişikliğine yönelik olduğu, (ilk) davada telif hakkı için ... (13.000.000.000) lira ödenmesi halinde proje değişikliğine izin verildiği, bu durum karşısında kesin hükümden söz edilmeyeceği,

³⁰⁴ Bkz. Yasa Hukuk, C. XVI, S. 192/1997, s. 1582 vd.

davalının telif ücretini belirleyip talep etmesi karşısında uyuşmazlığın, telif ücretinin belirlenmesinde toplandığı, mahallinde icra edilen keşif ve uzman bilirkişiler kurulu raporuna göre; davalının telif hakkı olarak (2.300.840.880) lira isteyebileceği gerekçesiyle davanın kabulüne, proje değişikliği ve tadilatı hususunda davacıya izin verilmesine, bu izin için davalıya tespit edilen (2.300.840.880) lira telif hakkı ödenmesine, bu bedeli ödeninceye kadar davalıya değişiklik yapılmaması konusunda hapis hakkı tanınmasına karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve davalının davacı İdareye hitaben ve cevaben verdiği 21.4.1995 tarihli yazısında eser üzerindeki telif hakkının güncelleşmiş değerinin tereddüde mahal bırakmayacak şekilde (13.000.000.00) lira olarak bildirilmesi ve anılan teklifin kayıtsız ve şartsız yapılması ve bu durum karşısında, davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir.

2-Ancak, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 1, 2, 4 ve 13 ncü maddeleri birlikte değerlendirildiğinde çarşı ve büro binasından oluşan dava konusu eser, proje ve yapıdan müteşekkil bir bütün olup, telif hakkının belirlenmesinde çarşı ve büro binasından oluşan eserin tamamı için sarf edilen fikri ve bedeni faaliyetleri ile manevi hakların değerlendirilmesi zorunludur. Bu durumda mahkemece, çarşı ve büro katlarında oluşan eserin bir bütün olarak değerlendirilmesi, ancak davacının yalnız çarşı katında proje değişikliği yapacağını ileriye sürüp izin talep etmesi karşısında, davalının isteyebileceği telif hakkı ücretinin gerektiğinde bilirkişilerden ek rapor alınarak, bu çerçevede davalının isteyebileceği uygun telif hakkı ücretinin belirlenmesi gerekirken, bu husus gözden kaçırılarak yazılı şekilde hüküm tesisi doğru değildir.

15. (11. HD., 26.6.1997, E. 1997/2854, K. 1997/5116)

Davacı vekili, müvekkiline ait “Guide to İzmir” adlı eserin basım ve pazarlanması hususunda davalı Şirket ve onun yöneticileri olan diğer davalılar ile anlaşma yapıldığını bu anlaşmaya göre; davalıların “yapımcı” olarak basım ve satışı yapmalarının ve eser sahibi olan davacıya % 15 oranında ücret ödenmesinin kararlaştırıldığını, bu kitabın birinci ve ikinci baskıları için müvekkilinin 139.625.000 lira alacaklı olduğunu ileri süre-

rek, bu meblağın reeskont oranında faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili, dava konusu “İzmir Rehberi”nin müvekkili A... Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlandığını, diğer davalıların bu olayla bir ilgisi bulamadığından onlara husumet yöneltilemeyeceğini, davalı P... Basım Ltd.’nin ayrı bir tüzel kişilik olduğunu davacı ile müvekkili A... Hizmetleri A.Ş. arasında herhangi bir sözleşme yapılmadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, taraflar arasındaki sözlü anlaşma gereğince davacının % 15 oranına göre alacak miktarının 318.750.000 lira olduğu, ancak taleple bağlı kalınması gerektiği sonucuna varılarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığını delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunamamasına ve dava konusu rehber kitabın yapımcısı davalı A... Hizmetleri AŞ olup, baskı ve dağıtımın P... Basım Hizmetleri Ltd. Şirketi tarafından yapılmış olmasına göre davalılar vekilinin bu şirketler ilişkin temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, davalı gerçek kişiler M.M.İ. ve İ.İ. ile davacı arasında bir sözleşme yapılıp yapılmadığı araştırılmadan ve bu davalıların şahsi olarak kitabın yayınlanmasından ne gibi menfaat elde ettikleri belirlenmeden haklarında hüküm kurulması doğru görülmemiş ve kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

16. (HGK., 17.12.1997, E. 1997/11-836, K. 1997/1075)

... Davacı vekili, müvekkilinin tescilli “Loft” markası ile giyim eşyası üretip pazarladığını, müvekkillerinin bu mamullerinin ancak sözleşme imzalayan bayiileri vasıtasıyla satılabileceğini, davalının ise bayi olmadığı gibi taklit “Loft” markalı kalitesiz ürünleri iş yerinde pazarladığını, bu hususun markaya tecavüz ve haksız rekabet olduğunu ileri sürerek haksız rekabetin tespit ve men’ine, şimdilik 5.000.000 TL. maddi ve 250.000.000 TL. manevi tazminatın tahsiline, ilana karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin ürünleri dava dışı B... Ltd. Şti.’nden fatura karşılığı olarak satışa sunduğunu, taklit olduğunu bilmediğini, aleyhine haksız rekabet davası açılmayacağını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere nazaran, davalının, davacı markası ile iltibasa imkan verir şekilde taklit markalı ürünleri işyerinde bulundurarak pazarladığı, bu hususun marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğu, ancak maddi ve manevi tazminat istenebilmesi için davalının kusurunun varlığının gerektiği, oysa, davalının söz konusu ürünleri dava dışı firmadan alarak pazarlamış olup, esasen iyi niyetli olduğunun davacı tarafından da kabul edildiği, bu durumda tazminat isteminin yersiz olduğu gerekçesi ile davanın kısmen kabulüne, davalı eyleminin davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğunun tespit ve men'ine, elde edilen ürünler üzerindeki "Loft" markası ve diğer tanıtma vasıtalarının imhasına, maddi ve manevi tazminat talebinin reddine, ilana karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

TTK'nun 58 nci maddesi hükmüne göre haksız rekabet nedeni ile zarar gören kimsenin isteyebileceği şeylerden birisi de kusur varsa zarar ve ziyanın tazmini ile BK.'nun 49. maddesinde gösterilen şartlar varsa manevi tazminat olup, BK.'nun 49 maddesi daha geniş bir kavram olan "şahsi menfaatin ihlali" esasına dayandığı halde, TTK'nun 58. maddesi sadece "iktisadi menfaatin ihlaline" ve hatta böyle bir tehlikeye maruz kalınmasına dayanmaktadır. Mahkemece, davalı eyleminin davacının marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet olduğu tespit edilerek men'ine karar verilmiş ve bu gerekçe davalı tarafından temyiz edilmemiştir. Marka haklarına tecavüz ve haksız rekabet esas itibarıyla bir haksız fiil olup, ticaret ile uğraşan davalının basiretli bir tacir gibi davranması, özellikle bayileri tarafından satışa sunulan davacı ürünlerinin, üstelik taklit edilmiş benzerlerini rastgele piyasadan alıp satış için işyerinde bulundurmaması gerekir. Öte yandan davacı vekili, imzası ile tasdik ettirilmeyen 3.7.1995 tarihli celsedeki beyanının zapta sehven maddi hata ile yanlış geçirildiğini, 4.7.1995 tarihli dilekçesi ile açıklamış ve yargılama sırası maddi tazminat taleplerinde neye dayandıklarını açıklamıştır. Bu durumda Mahkemece, davacı yararına taktir edilecek maddi ve manevi tazminata da hükmetmek gerekirken, davalının iyi niyetli ve kusursuz olduğundan bahisle bu yöne ilişkin istemlerinin reddi doğru olmamıştır... gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahkemece önceki kararda derinilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı :

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi Usul ve Yasa'ya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ: Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı (BOZULMASINA) oyçokluğu ile karar verildi.

17. (11. HD., 27.4.1998, E. 1998/1104, K. 1998/2748)

Davacı vekili, müvekkillerinin yazar Recep Bilginer'e ait telif haklarının temsilcisi olduğunu, yazarın 'İsyancılar' ismindeki tiyatro eserinden yararlanma hakkının bazı koşullarla müvekkili ajans tarafından davalıya devredildiğini, taraflar arasındaki sözleşmenin 3. maddesine göre davalının bu hakları başkalarına devredemeyeceğinin belirlenmesine karşın, anılan tiyatro eserinin muvafakat ve bilgileri dışında "O.. Organizasyon" ismindeki firmaya devredildiği ve eserin Almanya'da 19 kez temsil olduğunu, gösterilerde her bir biletin ortalama 30 DM fiatla satıldığını asgari bir hesapla beher temsili 100 kişinin izlediğinin kabul edilmesi halinde toplam 57.000 DM'lık bir hasılat elde edildiğini, aradaki sözleşmeye göre telif hakkının hasılatın % 40'ı olduğunu ileri sürerek 22.800 DM karşılığı 1.279.400.000 TL'nin reeskont faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili davaya cevabında; davaya konu Almanya turnesinin organizasyonunun dava dışı O.. Organizasyon Ltd. Şti.'ne verildiğini, bununla amacın turnede yapılan gösterilerin ücretsiz olması nedeniyle gerekli giderlerin O.. Organizasyon tarafından üstlenilmesinden kaynaklandığını, turnedeki amacın ticari olmadığını, ... müvekkili ile O.. Organizasyon arasında imzalanan sözleşmeye göre (eser sahibi yada haleflerine) ekstra telif ücreti ödemesinin organizasyon şirketi tarafından üstlenildiğini, durumun davacıya bildirilmesi üzerine davacı ile organizatör şirket arasında ekstra telif hakkı için sözleşme imzalandığını belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran; yazarın 27.4.1994 günlü anlaşma ile “İsyancılar” isimli tiyatro eseri üzerindeki kullanma haklarını davacı Şirkete devrettiği, davalının davacı ile yapmış olduğu sözleşmeye aykırı hareketi nedeniyle taleple bağlı kalınarak davacının talep ettiği 2.379.400.000 TL’nin dava tarihinden itibaren % 57 ve değişen oranlarda reeskont faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Davacı şirketin, yazar Recep Bilginer’in “İSYANCILAR” adındaki tiyatro eseri üzerindeki temsil hakkını kullanma yetkisini 27.4.1994 günlü sözleşmeyle devraldığı anlaşılmaktadır. Davacının devraldığı bu yetkiyi 26.9.1995 tarihli sözleşme uyarınca başkasına devredilmemek koşuluyla davalıya devredildiği hususunda bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık davalının Almanya turnesindeki temsillere ilişkin olarak dava dışı O.. Organizasyon ve Dış Tic. Ltd. Şti. ile imzaladığı 2.2.1996 tarihli sözleşme ve 8.2.1996 tarihli ek sözleşmelerden kaynaklanmaktadır. Davacı ile davalı arasında imzalanan sözleşme bakımından, davalının temsil yetkisini ... bir başka gerçek veya tüzel kişiye devredemeyeceği hususu tartışmasız olmasına karşın, davacının bahse konu turnenin organizasyonunu yapan, uyuşmazlık dışı O.. Organizasyon Ltd. Şti. ile yapmış olduğu 3.4.1996 tarihli sözleşmenin niteliği üzerinde durulması, değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm tesis edilmesi (gerekirken) noksan incelemeyle yazılı olduğu şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.

18. (11. HD., 4.5.1998, E. 1998/1096, K. 1998/3035)

Davacı vekili, davalının yapımcısı olduğu başrollerinin Yılmaz Güney, Erol Taş ve Seyyal Taner’in oynadığı Kafkas Şeytanı (Aslan Bey) adlı sinema eserinin televizyon ve video gösterim hakları ile tüm haklarının 9.7.1981 tarihli anlaşma ile müvekkile bırakıldığını, durumun 27.11.1991 tarihli belge ile teyit edildiğini, ancak davalının aynı hakların kendisinde bulunduğu yolunda uyuşmazlık yarattığını ileri sürerek; filmin her türlü gösterim hakkının davacıya ait olduğunun tespiti ve haksız rekabetin tespit ve men’ini, filmin Kültür Bakanlığı’nda kayıt ve tescil ettirilebileceğinin tespitini istemiştir.

Davalı, sözleşmenin sadece Avrupa video ve televizyon haklarının davacıya devrine ilişkin olup, 5 yıllık süresi olduğunu, negatif hakkının

kendisinde olduğunu, sözleşmenin noterde yapılmasının geçerlilik koşulu olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; taraflar arasında yapılan 9.7.1981 tarihli **anlaşma ile filmin dünya üzerinde her türlü gösterim hakkının davacıya devredildiğine, devrin 27.11.1991 tarihli belge ile de teyit edildiğine, devrin FSEK 52. maddesine uygun olduğunun tespitine ve haksız rekabetin önlenmesine** karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı vekilinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

19. (HGK, 17.6.1998, E. 1998/19-523, K. 1998/508³⁰⁵)

Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Düzce Asliye 2. Hukuk Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/10/1995 gün ve 1993/271-1995/63 sayılı kararın taraf vekilleri tarafından temyizinin istenilmesi üzerine, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin 23/6/1997 gün ve 1997/4072-6493 sayılı ilamı ile; "...aynı olay sebebiyle, **Ceza Mahkemesince saptanan maddi olgular ve davalı N.Ç.'nin olayda kusurlu bulunduğuna dair Mahkeme tarafından alınan bilirkişi raporu Hukuk Mahkemesini de bağlar.** Bu nedenle (Hukuk) Mahkemesince alınan ve davalının olayda kusurlu bulunmadığı yolunda görüş bildiren bilirkişi raporuna itibar edilmemesi yerindedir. **Ancak bu durumda, Ceza Mahkemesince saptanan kusur oranının bağlayıcı olmadığı** gözetilerek, davalının olaydaki kusur oranının saptanması yönünde yeni bir bilirkişi raporu alınması gerekirken, davalı N.Ç.'nin tam kusurlu olduğu kabul edilerek yazılı biçimde tazminatın tamamından sorumlu tutulmuş bulunması usul ve yasaya aykırıdır..." gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; Mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere göre, Hukuk

³⁰⁵ DEMİRKIRAN, DEMİR ve BİLGİN S. 44-45

Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

20. (11. HD., 22.6.1998, E. 1998/3246, K. 1998/4717)

Davacı vekili; müvekkilinin 88 Blokluk 1500 Konutluk S... Sitesi'nin mimar ve müellifi olduğunu, eserin mimarlık literatürüne geçtiğini ve gerek yerli, gerekse yabancı ülkelerde ödüllere aday gösterildiğini, FSEK 4. maddenin 3. fıkrası uyarınca eser niteliğinde olduğunu, **davalı yönetim (tarafından) eserin orijinalitesini bozacak şekilde dış kısmının çeşitli renklere boyandığını ileri sürerek**, (yapılan) eylem haksız tecavüz oluşturduğundan tecavüzün durdurulması, eserin telif haklarına uygun olarak eski hale getirilmesini, takribi 200.000.000 TL eski hale getirme masrafı ile 1.000.000.000 TL manevi tazminatın davalıdan yasal faiziyle birlikte tahsilini, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; rengin karakteristik özelliği olmadığını, manevi tazminat koşullarının bulunmadığını ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; FSEK uyarınca fikri ürünün eser niteliğinde sayılması için iki koşul gerektiği, objektif koşulun fikri ürünün bir fiziki unsura tespitinin elverişli olması yani iktisaden değerlendirilebilir olması, sübjektif koşul olarak da eserin sahibinin özelliğini yansıtmayı gerektiği, dava konusu eserin bu iki koşulu da taşıdığı, **eser sahibi olan davacının projesine uygun olarak yapılan boyasının davalı tarafından değiştirilmek suretiyle orijinal halinin bozulduğu gerekçesiyle davanın kabulüne**; eserde yapılan değişikliğin eski hale getirilmesi amacıyla orijinal rengine boyatılması suretiyle tecavüzün önlenmesine, **450.000.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline**, hüküm özetinin ilanına, fazla manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.³⁰⁶

21. (11.HD., 6.7.1998, E.1998/3202, K.1998/5147³⁰⁷)

Güzel sanat eseri, haksız ve eser sahibinin rızası olmaksızın değiştirilmişse, eski halin iadesi mümkünse ve değişikliğin izalesi ammenin ve

³⁰⁶ Bu karar vekalet ücreti kısmı dışında onanmıştır.

³⁰⁷ YKD, C. 19,S. 4/1998,s. 289-290 ve BATİDER, C. XIX, S. 4/1998, s. 289 vd.

malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa, eser eski hale getirilir, aksi halde eser sahibi özgün **eserdeki değişikliğin kendisi tarafından (yapılmadığının) tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırılmasını isteyebilir...** Kanun; değişikliklerin tam olarak kaldırılmasını şartlara bağlamıştır. Bunlardan eski halin iadesinin mümkün olması ...eşyanın tabiatından doğmaktadır... İkinci şart ise, kendi içinde bir ikameye imkan bırakmaktadır. **Değişikliğin kaldırılması (izalesi) ya ammenin ya da malikin menfaatlerini esaslı surette haleldar etmiyorsa eser eski hale getirilir.** Kamu'nun veya malikin menfaatleri, eserin eski hale getirilmesi halinde esaslı surette zarara uğrayacaksa, yapılan değişikliğin kaldırılması yani eski hale getirilmesi haklı görülmez.

22. (11. HD., 6.7.1998, E. 1998/3202, K. 1998/5147³⁰⁸)

Davacı vekili, müvekkilinin davalının maliki olduğu 3 no'lu villanın mimari ve statik projelerinin müellifi olduğunu, mimari proje ve planlarının bilimsel eser sayıldığını, dolayısıyla davalının villasının mimarlık eseri niteliğinde olduğunu, villa tamamlandıktan sonra müvekkilin izni alınmaksızın ilave ve değişikliklere uğradığını, bu değişikliklerin sonunda inşaat alanının 115 m² arttığını, kısıtlı alanların tam yararlı alanlara dönüştürüldüğünü, villanın değerinin arttığını, bu konuda davalıya ihtarlar yaptığını, mimarlık eserinin rızasız işlendiğinin açık olarak görüldüğünü dolayısıyla FSEK 21. maddedeki işleme hakkına tecavüz edildiğini, bunun yanı sıra villanın iki katlı görünümünün değiştirilerek üç katlı bir görünüm oluşturulduğunu, Bodrum katının cephesinin değiştirilerek, üst katlarla bağdaşmayan çirkin bir görünüm kazandırıldığını, maddi ve manevi tazminat koşullarının oluştuğunu ileri sürerek, FSEK. 70/3 ve 68/1 maddesi uyarınca 50.000.000 TL maddi ve 10.000.000 TL manevi tazminatın haksız eylem tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın bir yıllık zamanaşımına uğradığını, müvekkilinin eyleminin işleme olarak kabul edilemeyeceğini, tazminat koşullarının oluşmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, yaptırılan bilirkişi incelemesinde; villaya ait mimari projenin davacıya ait olduğunun Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nce onandığı ve projeye göre her bağımsız bö-

³⁰⁸ YKD, C. 19, S. 4/1998, s. 289-290; BATİDER, C. XIX, S. 4/1998, s. 289-290

lümde ne yapılacağını özetlendiğini, ayrıca 11. blokta tadilat ve kayma yapılması nedeniyle bunların mühürlendiği daha sonra 3194 sayılı Yasa maddeleri Anayasa Mahkemesi'nce iptal edildiğinden söz konusu binalara iskan belgelerinin verilmediği, Mimarlar Odası yazısına göre davacının Odaya ait borcunun bulunduğu, mimarlık hizmet yetki belgesinin bulunmadığını, villalar yerinde incelenip onanmış projeler ile mevcut binaların karşılaştırılması yapıldığında, binada bir takım değişiklikler ve ilaveler yapıldığının tespit edildiği, binaya yapılan ilavelerin binanın sağlamlığını ve emniyetini sağlamak amacıyla değil, doğrudan doğruya binayı büyütmek ve kullanım alanını genişletmek amacıyla yapıldığını, bu değişiklik ve eklentilerin binanın görünüşünü ve planını önemli ölçüde değiştirdiğini, 3 katlı bina haline dönüştürdüğünü, binanın özgün mimarisini ortadan kaldırdığını, FSEK 68. maddesi anlamında davacının dava konusu alacağının %50 ilave ile 39.976.439 TL olarak hesaplanabileceği, ancak FSEK 70/3 maddesine göre hesap yapıldığında istem konusu olan 50.000.000 TL'nin uygun olacağını beyan edildiği, FSEK 70/3 maddesine göre yaptırılan bilirkişi incelemesinde, villanın piyasa rayiç değerinde eklentilerin 1.224.880.000 TL bir artış meydana getireceğinin belirtildiği gerekçesiyle davanın kabulü ile 50.000.000 TL maddi tazminatın 17.3.1994 tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte ayrıca 10.000.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere ve delillerin taktirinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve dilekçede saklı tutulan hakların zamanaşımı süresi içinde her zaman istenebileceğine ve bilirkişi raporları kısmi dava için bağlayıcı olup esas davada bağlayıcı niteliğinin bulunmamasına göre taraflar vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

23. (11.HD., 01.02.1999, E. 1998/8794, K. 1999/311³⁰⁹)

Davacı vekili, müvekkili şirketin davalılardan O.Ç. ile yaptıkları sözleşme ile yazarı olduğu, "Liseler İçin Osmanlı Tarihi 1" adlı eserin 1993-1994 öğretim yılından başlamak üzere 5 yıl süre ile mali haklarını ve ruhsatını satın aldığını, buna rağmen davalı yazar O.Ç.'ın kitabı, basım ve yayınının yapılması için müvekkiline teslim etmediğini ve diğer davalı

³⁰⁹ BATİDER, C. XX, S. 1/1999, s. 108-109.

şirket ile ayrı bir sözleşme imzaladığını, bunun üzerine davalılara gönderilen ihtarnameye davalı yazar tarafından gönderilen cevabı ihtarnameyle sözleşmenin feshedildiğinin bildirildiğini ileri sürerek, kazanç kaybı (1.000.000.000.-) lira'nın reeskont faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili davaya cevabında; taraflar arasındaki sözleşmenin 5. maddesinin davacı tarafından ihlali nedeniyle davalı yazar tarafından sözleşmenin feshi yoluna gidildiğini, öte yandan müvekkili şirkete bu hususta herhangi bir ihtarname keşide edilmediği gibi cevap verilmediğini, istenilen tazminatın fahiş olduğunu ve davanın reddi gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece; iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna nazaran, taraflar arasındaki 29.05.1993 tarihli eser sözleşmesinin 4. maddesinde bahsedilen ruhsatın **5846 Sayılı Kanunun 56. maddesine göre tam ruhsat niteliğinde olduğu ve bu nedenle eser sahibinin çoğaltma ve yayma haklarının bu sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe bir başka kişi veya kuruluşa devredemeyeceği, 5846 sayılı Yasanın 58. maddesi uyarınca cayma koşullarının oluşmadığı ve sözleşmenin devam ettiği, davalı eser sahibinin diğer davalıya yaptığı devrin anılan Yasanın 54. maddesi uyarınca geçersiz olduğu ve diğer davalı şirketin iyi niyetinin korunmayacağını,** olay nedeniyle davacı tarafın 890.000.000.- lira tazminat talebinin haklı olduğu gerekçeleriyle, bu miktar tazminatının reeskont faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, fazlaya ilişkin istemin reddine karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekilince temyiz edilmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, hükme dayanak alınan 29.06.1997 günü bilirkişi raporunda; davaya konu eserin 102.000 adet basımının yapıldığından hareketle tazminat hesabı yapılmışsa da, davalılar vekilince toplam basımın 57.000 adet olduğu bildirilmiş ve mahkemece yazılan müzekkere cevaplarına göre, belirlenebilen iki matbaada toplam 45.000 adet basım yapıldığı tespit edilmiştir. Davalı şirkete gönderilen müzekkereye verilen yanıtta toplam basım adedinin bildirildiği anlaşıldığından, tazminat hesabının davalının kabulünde olan 57.000 adet kitap üzerinden yeniden hesaplanması gerekli olduğundan, 102.000 adet kitap üzerinden tazminat hesabına dayanılarak

hüküm tesis edilmesi doğru görülmemiştir. Bu durumda Mahkemece yapılacak iş; bilirkişi heyetinden açıklanan miktara ilişkin ek rapor alınarak, belirlenecek miktarda tazminata hükmetmekten ibaretken, yanlış hesaba dayalı bilirkişi raporuna dayanarak hüküm tesisi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmektedir.

24. (11. HD., 26.4.1999, E. 1999/594, K. 1999/3250 ³¹⁰)

“Davacı vekili; müzik yapımcılarının ses kayıtları üzerindeki eser sahibinin haklarına komşu haklarını müvekkilinin devraldığını, davalının müvekkilinden izin almaksızın komşu hak sahibi olduğu müzik eserlerini radyosunda yayınladığını ileri sürerek; müvekkil tarafından yayınlanan tarifeye göre 240.000.000.000 lira tazminatın dava tarihinden itibaren en yüksek ticari faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini, fazlaya ilişkin hakkın saklı tutulmasını istemiştir.

Davalı vekili; davacının FSEK 42. maddesinde belirtilen “meslek birliği” olmadığını, bu nedenle aktif dava ehliyeti bulunmadığını istenen miktarın da fahiş olduğunu ileri sürerek davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre; davacının yapımcı firmalardan eser sahibine komşu hakları devraldığı, bu nedenle FSEK 80. maddesi uyarınca komşu hak sahibi olan davacının, eser sahipleri gibi tecavüzün ref ve men’i ile tazminat talep hakkı bulunduğu, bilirkişi raporunda davacının aktif dava ehliyeti olmadığı yolundaki görüşe bu nedenle itibar edilmediği, davacının tazminat hesabına esas aldığı 240.000.000 liranın temlik alınan 58 yapımcı firmanın eserlerinin tamamının karşılığı olduğu, oysa davalının yayınladığı eser sayısının 10 adet olduğu, tazminat hesabının da buna göre hesaplanması gerektiği, bilirkişi raporunun bu açıdan da eksik olması karşısında davacı tarafın bilirkişiden ek rapor alınmasını da istemiş olmasına göre, FSEK. 80/1. maddesi uygulanması ile 68. maddesi uyarınca takdiren 30.000.000 lira üzerinden davanın kısmen kabulü ile bu miktarın dava tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden davalıdan tahsiline, tespiti yapılan eserlerin yayının men’ine, karar özetinin ilanına, fazla istemin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

³¹⁰ Bkz. Yasa Hukuk, C. XIX, S. 218/2000, s. 102-104

Davacı vekili, müzik yapımcısı firmaların yayınlanmış oldukları yapımlarının kayıtlı bulunduğu; ses kaseti, kompakt disk, plak ve benzeri ses ve görüntü taşıyıcıların içerdiği eser sahiplerinin haklarına komşu ve müzik yapımcılarına ait olan “radyo ve televizyonla yayın hakları”nı devir aldığını ileri sürerek işbu davayı açmış bulunmaktadır.

Doğru bir sonuca varmak için “komşu hak” kavramının irdelenmesi gerekir. Bu kavram pozitif hukukumuzda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 7.6.1995 gün 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucu girmiştir. 5846 sayılı Kanunun 4110 sayılı Kanunla değişik 80/1 maddesiyle “*eser sahibinin maddi ve manevi hakların halel getirmemek şartıyla fikir ve sanat eserlerini özgün bir biçimde icra eden, yorumlayan icracı sanatçılara bir icrayı ilk defa tespit eden ses taşıyıcısı yapımcıları ve radyo televizyon kuruluşlarının, eser sahibinin haklarına komşu hakları vardır*” hükmü getirilmiş ve 1997 tarihinde yayınlanan “Eser Sahibinin Haklarına Komşu Haklar Yönetmeliği”nin 4. maddesinde de komşu hak (olarak) “*eser sahibinin haklarına zarar vermeden ve onun rızası ile bir eserin özgün biçimde icra eden veya icrasına katılan, bir icrayı ya da sesleri ilk defa tespit eden, yayınlayan gerçek ve tüzel kişilerin münhasır sahip oldukları icrayı tespit etme, çoğaltma, kiralama, telli-telsiz her türlü araçla yayınlama ve kamuya açık yerlerde temsil suretiyle bunlardan faydalanma haklarının*” bulunduğu belirtilmiştir. Aynı yasanın 80/IX. maddesinde de komşu hak sahiplerinin mali ve manevi haklarının ihlal edilmesi halinde eser sahibi gibi dava açabilecekleri belirtilmiş, ancak mali hakların kullanma yetkisinin devri halinde yani ruhsat verme halinde ruhsat sahibinin tecavüzün ref’i tazminat davasını açıp açamayacağı hususunda bir hüküm gerekmemiştir.

FSEK 48/II madde uyarınca, eser sahibi veya mirasçıları bir mali hakkın sadece kullanma yetkisini devir edebilirler. Bu durumda mali hak özü itibarıyla eser sahibinin mal varlığında kalmakla birlikte, maddi bir malın hasılat kirasına verilmesinde olduğu gibi, mali hakkı kullanma ve semerelerinden yararlanma yetkisi ruhsat alan tarafa geçmiş olur (FSEK 56/III). Ruhsat veya lisans verme ilgili mali hakka özgün olan kullanma veya yararlanma yetkilerinden bir kısmının veya tamamının mali haktan ayrılarak ruhsat sahibine tahsis edilmesi olarak benimsenmektedir. **Kullanma yetkisinin ruhsat veya lisans ile devri; Kanun tarafından mali hakkı tahdit eden, kayıtlayan bir tasarrufa işlemi kabul edilmiş olup, tam ruhsat sahibi haiz olduğu yetkileri gerek mali hak sahibine gerekse üçüncü şahıslara karşı öne sürebilecek ve kullanmayı engelleyen**

müdahaleleri men ettirebilecektir. Tam ruhsatta, mali hakka ait kullanma yetkisi tamamen ruhsat sahibine devir edildiğinden, devir alan da bu yetkiyi kendi başına kullanabilecek ve tecavüzün menı ve refi davası ile birlikte 68. ve devam maddelerinde yazılı bedel davasının açabilecektir (Bkz. Prof. Dr. Şafak N. Erel Türk Fikir ve Sanat Hukuku, Yenilenmiş, 2. Bası 1998 sh. 260 vd. 293 sh., Dr. Halil Arslanlı, Fikri Hukuk Dersleri II, Fikir ve Sanat Eserleri). 16.6.1995 gün 4110 sayılı Yasa ile değişik 42. maddesinde; meslek birliklerinin, meslek birliklerine üye olmaları halinde (üyelerinin) yazılı yetki belgesinde belirtilen eseri ve ona ilişkin mali haklarının takibi, telif ücretinin tahsili (20/2 md) ve üyelerinin ortak çıkarlarını korumak amacıyla tüzel kişiliğe sahip (oldukları) ve bu meslek birliklerinin dava açabilecekleri ve Türk uyruklu eser sahiplerinin mali haklarının ülke içinde kurulan meslek birlikleri dışında başka birlik ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemeyecekleri (FSEK 42/son) hükme bağlanmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda olayı irdelersek davacının yasada yazılı anlamda bir meslek kuruluşu olmadığı açıktır. Ancak, **eser sahibi ve komşu hak sahibleri mali haklarını üye olduğu meslek kuruluşuna devir edebileceği gibi**, FSEK 48/2 ve 56. maddeleri uyarınca **mali hakkını tam ruhsat vermek suretiyle başkasına devir etmesi halinde yukarıda anılan kurallar doğrultusunda tam ruhsat sahibinin de dava hakkı bulunduğu kabulü gerekecektir.** Nitekim 556 sayılı KHK'nin 21/6. maddesinde “*aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin bu Kanun Hükmünde Kararname uyarınca açabileceği davaları kendi adına açabilir*” hükmü getirmiş olup, inhisari lisans sahibine marka sahibi gibi mütevacize karşı her türlü dava açabilme hakkı Kanun tarafından benimsenmiş olup, 5846 sayılı Yasa uyarınca aksi “Tam Ruhsat Sözleşmesi”nde kararlaştırılmamış olmak şartıyla tam ruhsat ile mali hakka ait kullanma yetkisini eser sahibi ve komşu hak sahibinden devir alan tam ruhsat sahibinin de Markalar Kanunundaki inhisari lisans sahibi gibi, eser sahibi ve komşu hak sahiplerinin üçüncü kişilere karşı açabilecekleri davaları (hakları bunlardan devralanlarında) kendi adına açabileceklerini kabul etmek gerekir. **Aksinin kabulü halinde eser sahibi ve komşu hak sahibi, tam ruhsatla mali hakka ait kullanma yetkisini tamamen ruhsat sahibine devir ettiğinden, tam ruhsat sahibine dava hakkı tanınmaması halinde eser ve komşu hak korunmasız kalacaktır.** Bu gerçekler ve dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının

gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanmasına karar verilmesi gerekmiştir.

25. (11. HD., 1.10.1999, E. 1999/1726, K. 1999/7358)

Davacı vekili, davalı ile müvekkili şirket arasında yapılan sözleşme uyarınca müvekkilinin yaptığı TV dizisinin televizyon kanalında gösterimleri yapıldıktan sonra, davacının başka TV Kanalına yapmış olduğu aynı isimli TV dizilerinin yayınlandığı aynı saate, davalı şirketin elindeki eski TV dizilerini yeniden gösterime almak suretiyle haksız rekabette bulunduğunu ileri sürerek, “Olacak O Kadar” adlı TV dizilerinin eser sahibinin müvekkili şirket olduğunun tespitini, haksız rekabetin ref ve önlemesini dava etmiştir.

Davalı vekili, taraflar arasındaki sözleşme uyarınca eserlerin tüm mali ve manevi haklarının müvekkiline ait olduğunu, birden çok yayın hakkının da kendilerinde bulunduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre, davacının dayandığı sözleşmelerde davacı tarafından meydana getirilecek eserlerin ... TV için yayına hazırlanmasının öngörüldüğü, eserin tüm mali ve manevi haklarının davalı ile dava dışı .. A.Ş. ye ait olduğu, sözleşmelerin taahhüt olarak geçerli bulundukları gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Davacı ile davalı ... Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş arasında düzenlenen 12.1.1993 tarihli sözleşme ile davacı şirket 13 bölümden oluşan “Olacak O Kadar” isimli televizyon dizisini ... TV’inde gösterilmesi için yayına hazırlama konusunda anlaşmışlardır.

Yine davacı, davalı şirket ile bağlantılı olduğunu iddia ettiği dava dışı ...A.Ş ile yapmış olduğu 8.7.1993 tarihli sözleşme ile bu kez 16 bölümden oluşacak “Olacak O Kadar” isimli dizi şeklindeki eseri .. TV için yayına hazırlamıştır.

Her iki sözleşmede anılan diziler davacı tarafça hazırlanmış ve bunlar davalıya ait .. TV sinde yayınlanmıştır. **Davacı vekili her iki sözleşmenin 4110 Yasa ile değişik 5846 sayılı Yasanın 48/3 ve 52 maddeleri uyarınca geçersiz olduğunu, buna göre maddi ve manevi hakların davalıya gitmeyip müvekkilinde kaldığını ileri sürmüş ise de, davacı ta-**

rafından yapılan diziler davalıya teslim edilmiş ve 29 bölüm olarak davalıya ait .. Televizyonunda yayınlanmış, böylece edimler ifa edildikten sonra sözleşmenin geçersizliğini ileri sürmenin MK. 2 maddesine aykırı olduğu anlaşıldığından davacının bu yöne ilişkin temyiz itirazı kabul edilmemiştir.

2- Taraflar arasında bağlanan sözleşmenin 3. maddesinde “yapımcı tarafından üretilen programlarda görev yapan sanatçıların meydana getireceği dizilerin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu karşısında bir bütün olarak her türlü manevi ve mali hak sahibi mutlak suretle şirkettir. Şirket eserin her türlü televizyon yayın hakkına sahiptir. Bir veya birden fazla yayınlanabilir” hükmü konulmuştur.

Davacı vekili geçersizlik iddiasında, mali hakların devrine ilişkin sözleşmelerde bu hakların teker teker sayılması gerektiğini, sınırsız hak devrinin mümkün olmadığını, eserin kararlaştırılan sayıdan fazla sayıda ve bütünlüğünü bozacak şekilde bölümler (halinde) parçalanarak gösterime sunulmasının da eser sahibinin mali haklarına tecavüzün oluşturacağını ileri sürmüş olup, rapora muhalefet yazan bilirkişi de davacı iddiasını doğrular mahiyette görüş bildirmiş olmasına rağmen, Mahkemece davacı itirazları yeterli şekilde araştırılmadan muhalefetli bilirkişi raporuna dayanılarak karar verilmesi doğru olmamıştır.

3- Ayrıca FSEK’nun 14. maddesi uyarınca eser sahibinin kayıtsız şartsız izin vermesi halinde bile, manevi haklardan sözleşme ile vazgeçmek hükümsüz olduğundan, manevi hakları çiğnemenen eser sahibinin bu eylemlere karşı koyma ve manevi tazminat isteme hakkı vardır. Uygulamada manevi hakların kullanılmasına izin vermek mümkün olduğundan mahkemece taraflar arasında bağitlanan sözleşmenin 3. maddesinin manevi haklardan sözleşme ile vazgeçme mi yoksa kullanmaya izin anlamında mı olduğu, gerekli şekilde araştırılmamış ve Karar’da bu husus tartışılmamıştır. Diğer taraftan, eserin parça parça ve bütünlüğünün bozularak yayınlandığı hususu da gerekli şekilde irdelenmemiştir. Mevcut kanıtlara göre, davalı televizyonunda eserin iddia edilen biçimde yani parça parça ve eserin bütünlüğünün bozularak yayınlanmasının gerçek olması halinde, bunun eser sahibinin manevi haklarını ihlal edip etmediğini yeterli açıklıkta tartışılmamış, Karar’ın gerekçe kısmında bilirkişi raporuna atıf yapılmış ve incelenen bilirkişi raporunda bu konular gerekli açıklıkta yer almamıştır. Bu durumda Mahkemece, iddia edilen hususların gerekli şekilde araştırılması, gerektiğinde bilirkişi dinlenmesi ve hasıl ola-

cak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme sonucunda yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.

26. (11. HD., 7.10.1999, E. 1999/5553, K. 1999/7625 ³¹¹)

Davacı vekili; müvekkilinin “Çevre Hakkı” adlı eserin eser sahibi olduğunu, eserin 1992 yılında davalı tarafından basımının yapıldığını, taraflar arasında mali hakkın devri konusunda sözleşmenin de olmadığını, dava dışı .. Yayıncılık A.Ş.’ye yazılı sözleşme ile hakkı olmadığı halde eserin çoğaltma/yayma şeklindeki mali haklarını devir ettiğine dair yazılı sözleşmenin sunulduğunu, bu sözleşmeye göre indirimli ilan hakkı ve parasal ödeme olarak davalının 320.000.000.TL aldığını, indirimsiz ilan tarifi dikkate alındığında davalının menfaatinin 350.000.000 TL yi bulacağını, bu miktar açılan tazminat davasında dikkate alınmadığı için mükerrer ödeme olmayacağını ileri sürerek 350.000.000 TL’nin vekaletsiz tasarruf tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalıdan tahsiline, hükmün FSEK 78. madde uyarınca ilanına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; davacının Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde .. Yayıncılık A.Ş. aleyhine açtığı davada, müvekkilinin müdahil olduğunu, ilgili davada da aynı talepte bulunduğunu, mükerrer bir talep olduğunu, davacı .. Yayıncılık’tan nakit olarak 155.000.000, indirimli ilan bedeli olarak 165.000.000 TL alındığını ancak bunun tamamının davacının telifine ait olmayıp içinde baskı için yapılan masrafların da olduğunu, elde edilen yararın tamamının telife yönelik olarak düşünölemeyeceğini, talebin fahiş olduğunu, ilk davada seçimlik hakkın .. Yayıncılık A.Ş. aleyhine kullanılması nedeniyle müvekkiline husumet düşmeyeceğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamında “Çevre Hakkı” adlı eserin sahibinin davacı olduğu, davacının eser üzerindeki mali haklarını davalıya devir ettiğine dair sözleşme olmadığı, bu hususun Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin 1995/634 E-1996/653 K. Sayılı kesinleşen ilamında da sabit olduğu ve davalının devir yada kullandırma hakkı olmadığı halde davacının mali haklarını 3. şahsa devir ettiği ve bunun karşılığında indirimli kitap ilanı tarifi üzerinden %47 oranında indirimden yararlanarak .. Yayıncılık A.Ş’nin mevkutele-

³¹¹ Bkz. FMR, C. I, S. 2/2001, s. 217-219; ERDİL, s. 186-187 ve 220-222; BEŞİROĞLU, s. 1154-1155

rinde ilanlar yaptırdığı, indirimsiz ilanlar gözetildiğinde davalının davacının eserini promosyon olarak kullandırmakla talep edilen miktardan daha çok kâr elde ettiği, FSEK 70/3. maddesi uyarınca davacının bu kârı isteyebileceği dikkate alınarak 350.000.000 TL'nin 21.4.1995 tarihinden itibaren reeskont faizi ile davalıdan tahsiline, Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesinde Karar ilan edildiğinden ve FSEK 78. maddeden beklenen menfaat gerçekleştiğinden ilan talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, taraf vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddine,

2-Davacı vekili temyiz itirazlarına gelince; Mahkemece red gerekçesi yapılan Kadıköy Asliye 1. Ticaret Mahkemesi'nin 1995/634 E. 1996/635 K. Sayılı dava dosyasındaki taraflar ile bu davacının tarafları farklı olduğundan, Mahkemece, bu davada verilen kararın da FSEK 78. madde uyarınca ilanına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile reddi doğru görülmemiştir”.

27. (11. HD., 25.10.1999, E. 1999/6557, K. 1999/8249)

Davacı vekili, davalı Ahmet'in mimar olan müvekkille ait projeleri taklit yoluyla ve izinsiz kullandığını, diğer davalı Mualla'nın da Ahmet tarafından projelerin yolsuz olarak kullanılmasına bilerek göz yumduğunu, kontrol görevini yaparken kasıtlı olarak ihmalde bulunduğunu iddia ederek, davalı Ahmet tarafından proje kullanılması nedeniyle haksız rekabet neticesi elde edilen menfaate karşılık 500.000.000 lira maddi ve 100.000.000 lira manevi tazminatın faizi ile birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı Mualla ..., kendisinin projesinin diğeriyle benzerlik taşıyıp taşımadığını araştırma görevi olmadığını savunarak davanın reddini istemiş, diğer davalı vekili de davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre yaptırılan bilirkişi incelemesinde, davacının projesi ile davalı Ahmet ..'in projelerinin aynı olduğu, davalının eyleminin FSEK'nun 22. maddesine aykırılık oluşturduğu, davacının bundan dolayı olan zararının 1.577.790.642 lira olarak belirlendiği, denetim görevi olan davalı Mualla'nın kendilerine

verilen eserin bir başkasının projesiyle aynı olup olmadığını re'sen kontrol etme, karşılaştırma görevi yükletilmediği, ancak bu konuda ihbar veya talep var ise inceleme yapmasının (beklenebileceği) ve davacı tarafından, davalının kötü niyetli ve sorumlu olduğunun kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davalı Mualla ... aleyhine açılan davanın reddine, davalı Ahmet ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulü ile 500.000.000 lira maddi ve 80.000.000 lira manevi tazminatın yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgeler, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına ve davacı vekili dava dilekçesinde niteliğini belirtmeksizin faiz talebinde bulunmamasının, yasal oranda faiz olarak istediğinin anlaşılması gerekmesine göre, davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

28. (11. HD., 18.11.1999, E. 1999/2264, K. 1999/9338)

Davacı vekili, müvekkili ile davalı Nejat ... arasında bağitlanan üç ayrı sözleşme ile Nejat ... ve ekibince sahnelenen “Miğferine Çiçek Eken Asker”, “Şeyini Şey Ettiğimin Şeyi” ve “Marka Paşa” adlı üç ayrı tiyatro eserinin video çekim ve yayın haklarının davacıya devredildiğini, bu tiyatro oyunlarının davacı tarafından sinema teknikleri kullanılarak video filmleri olarak imal edildiğini, televizyonda yayın haklarının da davacıya ait olduğunu, buna rağmen davalı Nejat ...'un izni ile diğer davalıya ait televizyon kanalında gösterildiğini ileri sürerek, dava konusu filmlerin televizyon yayın haklarının davacıya ait olduğunun tespitine, (yayınının) men'ine ve 500.000.000 TL maddi tazminatın davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Nejat ... vekili, davacının dayandığı sözleşmelerde söz konusu tiyatro oyunlarının televizyonda gösterim hakkının davacıya devredilmediğini, sadece ev videolarında gösterme hakkının verildiğini, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nda FSEK eserlerinin mali haklarının teker teker sayıldığını, yine FSEK 52 maddesine göre sözleşme konusu mali hakların ayrı ayrı gösterilmesinin zorunlu olduğunu, olayda bir yıllık zamanaşımı süresinin olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalı vekili, dava konusu eserlerin televizyonda gösterim hakkını (FSEK md. 25) Nejat ...'un 21.3.1994 tarihli sözleşme ile müvekkiline devrettiğini savunarak davanın reddi istemiştir.

Mahkemece; iddia, savunma, dosyadaki kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davalı Nejat ...'un başrolünü oynadığı dava konusu tiyatro oyunlarının video çekim ve yayın hakkını sözleşmelerle davacıya devrettiği, 3257 sayılı Sinema, video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 8. maddesi gereğince bu eserlerin çoğaltma, yayma ve gösterim haklarının eserin işletme belgesinin sahibi olan davacıya ait olduğu, bu eserlerin (video çekimlerinin) sinema eseri niteliğinde olduğu ve davacının izni olmadan diğer davalıya ait televizyon kanalında gösterilemeyeceği, bu nedenle davacının 2.700.999.999 TL tazminat talep edebileceği gerekçesiyle taleple bağlı kalınarak davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı, davalılar temyiz etmişlerdir.

Dava konusu tiyatro oyunları, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) kapsamında eser niteliğinde olup, aynı Kanunun 52. maddesine göre mali haklara ilişkin sözleşmede hangi hakları devredildiğinin açıkça gösterilmesi zorunludur.

Davalı Nejat ... ile davacı arasında yapılan sözleşmelerde Nejat ... ve ekibince oynanan tiyatro eserlerinin video çekimi ve yayın hakkının davacıya devredildiği, satıldığı belirtilmiş, televizyonlarda gösterim hakkının da verildiğinden söz edilmemiştir. Şayet televizyonlarda gösterim (yayın) hakkı da devredilmiş olsaydı, bunun sözleşmeye açıkça yazılması gerekirdi. Anılan Yasa hükmü karşısında sözleşmelerin televizyonda yayın hakkını da kapsadığı yolunda daha geniş bir yoruma tabi tutulması mümkün değildir. Davacının 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri Kanunu uyarınca ilgili Bakanlıktan eser işletme belgesi almış olması, dava konusu hakların davacıya devredildiğine dair yeterli kanıt olamaz.

Mahkemece bu hususlar üzerinde durulmadan yazılı şekilde davanın kabulü doğru görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.

29. (4. HD., 23.11.1999, E. 1999/6241, K. 1999/10212³¹²)

...Davacı tarafında çizilen iki projenin halen yapılmış olan iş merkezindeki binada kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmışsa ne ölçüde kullanıldığı, diğer bir anlatımla iş merkezinin ortaya çıkmasındaki görünüm ve sonucun, özgün olup olmadığı, bu bağlamda Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'nın 6. maddesinde tanımını bulan **“işlenme”** olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu üzerinde durulmamıştır... bu nedenlerle Kararın BOZULMASINA... karar verilmiştir.

30. (4.HD., 23.11.1999, E. 1999/6241, K. 1999/10212³¹³)

Davacı , davalılardan Hüseyin .. ile davalının arsası üzerinde yapılacak olan iş merkezinin mimari projesinin çizimi için anlaşıldığını, bunun sonunda davalıya iki adet proje sunduğunu, bu projelerin davalı tarafından kabul edilmemiş olmasına karşın, sonradan diğer davalının yeni bir proje tanzim ettiğinden söz etmek suretiyle binanın yapımını tamamlandığını, binanın yapımında kullanılan proje iddia edildiği gibi davalı Recep ... tarafından çizilen olmayıp projenin davacı tarafından yapılanlardan (ibaret)olduğunun tespitini ve bu bağlamda maddi ve manevi tazminata karar verilmesini de istemiştir.

Davalılar, davacının çizdiğini iddia ettiği projenin uygulama projesi olmadığını, uygulama projesine esas teşkil edecek nitelikte bulundukları, çizilen projelerin kendileri tarafından kullanılmadığını, binanın yapımında kullanılan projenin kendine özgün bir proje olup, davalılardan Recep ... tarafından çizilmediğini savunmuşlardır.

Yapılan yargılama sonunda Mahkeme, davacının davasına dayanak yaptığı projelerin hazırlık çalışmalarından ibaret olduğu ve bundan dolayı da Fikir ve Sanat Eserleri Yasası hükümleri uyarınca kendisine bir hak sağlayamayacağı, ancak davacının yaptığı bu çalışmanın karşılığı olarak bilirkişilerce belirlenen çalışma ücreti karşılığının ödeneceğini belirtmek suretiyle bu bölüm için hüküm kurup diğer istekleri reddetmiştir.

Karar, taraflarca temyiz edilmiştir.

Dosyadaki kanıtlara göre, davacı tarafından davalı Hüseyin ...'e ait yer üzerinde yapılacak iş merkezi için bir anlaşma yapıldığı, bunun sonu-

³¹² ERDİL, FSEK, s. 26-27

³¹³ Yasa Hukuk, C. XIX, S. 226/2000,s. 1227-1228

cunda davacı tarafından yapılan çizim ve çalışmaların adı geçen davalıya sunulduğu konusunda taraflar arasında bir uyuşmazlık bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu olan yön, davacının yaptığı çalışma sonucu meydana getirdiği projelerin hazırlık çalışması mı, yoksa uygulama projesi niteliğinde mi bulunduğu ve bu projenin yapılan iş merkezinde ne ölçüde uygulandığı, diğer bir anlatımla binanın yapılışında kullanılan projenin, davacının yaptığı projelerin ne ölçüde özelliklerini taşıdığı ve yine davacının yaptığı projeye göre halen binanın yapısındaki projenin ayrı bir özellik taşıyıp taşımadığı noktasında toplanmaktadır.

Uyuşmazlık çözümünde uygulanması gereken 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 1. maddesinde, sahibinin özelliklerini taşıyan her nevi fikir ve sanat ürünü olan çalışmanın sonucunda elde edilecek ürünün eser sayılabileceği, aynı Yasanın 4. maddesinde mimarlıkla ilgili çalışmanın da güzel sanat eserleri içerisinde yer aldığı görülmektedir.

Somut olayda, davacı tarafından çizilen iki projenin halen yapılmış olan iş merkezindeki binada kullanılıp kullanılmadığı, kullanılmışsa ne ölçüde kullanıldığı, diğer bir anlatımla iş merkezi ortaya çıkmasındaki görünüm ve sonucun özgün olup olmadığı, bu bağlamda Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 6. maddesinde tanımını bulan “işleme” olarak kabul edilip edilmeyeceği hususu üzerinde durulmamıştır.

Şu durumda Mahkemece yapılacak iş; halen yapıлып tamamlanmış bulunan iş merkezindeki projenin ...davacının çizdiği projelerin özelliğini taşıyıp taşımadığını, taşımışsa ölçüsü ve böylece davacının maddi ve manevi değerlerine bir saldırı olup olmadığı hususu incelenmeli, bunun için ilgili kurumdan denetime elverişli rapor alınmalı, raporda davacı tarafından Mimarlar Odasından alınan 31.7.1997günlü rapor ile yine aynı Odaya alınan ve davalılardan Recep ... hakkında verilen disiplin cezasına ilişkin karar da irdelenmeli, davacının maddi ve kişilik değerlerine saldırının bulunduğu, ancak ölçüsünün belirlenmemesi durumunda tazminatın belirlenmesinde Borçlar Kanunun 42. maddesinden yararlanılmalı, varılacak sonuca göre bir hüküm kurulmalıdır. Bu yönün gözetilmemiş olması ve yetersiz bilirkişi raporuna dayanılarak yazılı biçimde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

31. (11. HD., 16.12.1999, E. 1999/5797, K. 1999/10400)

Davacı vekili, ...Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 180 ve 209 sayılı KHK'nin 2. fıkrası ile verilen yetki ve görev çerçevesinde

hazırlanan; 1994 yılına ait inşaat birim fiyatlarına esas, “işçilik, araç ve gereç listeleri” ile “yapı işleri birim fiyat tarifeleri eki fiyat listeleri”nin bastırılıp üzerine “para ile satılmaz” ibaresi konulmasına rağmen, davalının bu eseri çoğaltıp bastırarak satışa çıkardığını ileri sürerek, davalının haksız eyleminin önlenmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, cevabında, müvekkiline ait eserin başlı başına ayrı bir çalışma ve araştırma yayını olup, yeni bir eser olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece; iddia ve savunmaya, toplanan delillere, bilirkişi raporuna nazaran, Kanun Hükmünde Kararname ile hazırlanması ve yayını davacı Bakanlığa verilen “1994 yılı yapı işleri birim fiyat tarife” ve “eki fiyat listelerinin” uzun bir araştırma sonucu hazırlandığı ve “1994 yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” adı altında yayınlandığı, davalı tarafından hazırlanan kitapta ise davacı eserinin geniş ölçüde kullanıldığı, yayının FSEK. 31. madde kapsamı dışında kaldığı, davalı eyleminin haksız olduğu gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaaya aykırı bir yön bulunmamasına ve **Dairemizin emsal kararlarında da değinildiği gibi, davacı İdare tarafından belirlenen inşaat birim fiyatlarının unsurları ile ilgili bilgi ve cetvellerin FSEK’nun 31. maddesi anlamındaki belgelerden sayılamayacağından** davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

32. (11. HD., 27.12.1999, E. 1999/9039, K. 1999/10796)

Davacı vekili, davalı şirketin işletmekte olduğu ..., ... ve ... TV televizyonlarında yayın ve ticaret konusu yapılan müvekkiline ait “Emmioğlu” ve “Bir Yangının Külü” isimli eserlerin müvekkilin izni alınmadan, eser sahibi adı belirtilmeden ve eserin özelliğini bozacak şekilde tahrif edilerek, değişik tarihlerde yayım konusu yayılması nedeniyle, müvekkilinin FSEK’den doğan mali ve manevi haklarına tecavüzden dolayı, şimdilik 50.000.000 TL maddi ve 50.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan tahsilini istemiş, 1999/45 sayılı dava ile fazla ilişkin hakkı saklı olarak 403.600.000 TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre; dava konusu “Emmioğlu” ve “Bir Yangının Külü” adlı **fikri ürünlerin eser niteliğinde olup, davalının TV kanallarında izinsiz yayımlandığının belirlendiği**, İstanbul 8. Ticaret Mahkemesi’nin 1996/636 esas dosyasının “Emmioğlu” adlı eserin tüm mali haklarının devredildiğine ilişkin kesin hüküm oluşturmayaacağı, ayrıca **söz konusu dosyadaki belgenin FSEK’nun 52. md. uyarınca, geçerli bir devir belgesi sayılmayacağı, sayılsa bile işleme hakkının tekrar devredilebilmesi için eser sahibinin muvafakatinin zorunlu bulunduğu bu nedenle davacının dava açma hakkı olduğu**, her izinsiz yayın için 25.200.000 TL tazminat belirlendiği, davalı vekili ek dava için zamanaşımı itirazında bulunmuş ise de, eylemin cezai yaptırımı gerektirmesi nedeniyle davanın 5 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde açılabilceği, yayınların yapıldığı ... ve .. TV’nin davalı şirkete ait olmadığına anlaşıldığı, bu nedenle davalının ... TV’de yapılan yayınlardan sorumlu olduğu gerekçesiyle, davanın ... TV’deki yayınlar yönünde kabulü ile 50.000.000 TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, birleşen dava yönünde 176.400.00 TL’nin davalıdan tahsiline, ... ve ... TV’ye yönelik istemlerin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme Kararının gerekçesinde dayanan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir.

33. (11. HD., 04.05.2000, E. 2000/600, K. 2000/3862)

Davacı vekili, müvekkili ile davalılarca oluşturulan mimarlık ortaklığınca 1957 yılından 1967 yılına kadar projeler üretildiğini, bilahare müvekkilinin ortaklıktan ayrıldığını, davalılarca çeşitli dergilere verilen de-mec ve yazılan yazılarda, birlikte üretilen ortak projelerden söz edilirken davacı isminden hiç bahsedilmeyerek, sanki eserlerin kendileri tarafından yapılmış olduğu izlenimi verildiğini, 1994 yılında yayımlanan “Projeler-Yapılar / Doğan Tekeli-Sami Sisa” adlı eserde davacı ile ortak üretilen eserler tanıtılırken, kronoloji bölümüne konulan (nokta) işareti ile teamüle aykırı ve yetersiz şekilde davacı adına yer verildiğini, davalıların bu şekildeki eylemlerinin davacının FSEK’dan doğan haklarının ihlali olduğunu ileri sürerek, adı geçen eserin toplatılmasına, satılmamış eserlere eklene-

cek broşür ile durumun açıklanmasına, 1.000.000.000.- lira manevi tazminata hükmedilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, söz konusu eserin yaratılmış eserlerin tanıtılmasına yönelik olmayıp, davalı mimarların kendileri ve eserlerini tanıtmaya yönelik monografi olduğunu, eserlere katkısı bulunanların yeterince tanıtıldığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, davanın reddine ilişkin verilen karar Dairemizce gerekçe yokluğundan dolayı bozulmuş olup, bozma ilamına Mahkemece, toplanan delillere, dosya kapsamına nazaran, **davalıların; kendi yaşamları ve yarattıkları eserleri tanıtmak için yayınladığı otobiyografi niteliğindeki kitapta, katkıları bulunan diğer kişiler ve bu arada davacıyı gerekli yerlerde yeterince belirttikleri, davacı isteminin FSEK'in 15/3. maddesinde belirtilen husus ile ilgili olmadığı, bu itibarla son bilirkişi raporuna iştirak edilmediği, ikisi mimar olan ilk bilirkişiler kurul raporunun meslek kuralı ile ilgili değerlendirme bakımından yerinde olduğu, bu itibarla davacının kişilik ve eser sahibi haklarına yönelik bir tecavüz bulunmadığı** gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

34. (11. HD., 5.6.2000, E. 2000/4098, K. 2000/5155)

Davacı vekili, müvekkilinin "Türk Dernekleri Hukuku" isimli kitabın yazarı ve telif hakkı sahibi olduğunu, kitabın 1987, 1991 ve 1996'da 3 kez basıldığını, davalıların kendi isimleri altındaki kitaptan iktibas yaptığını, kitabın 78-352 sayfalara arasının müvekkilinin eserinden aynen alındığını ileri sürerek davalıların müdahalelerinin men'ine ve tecavüzün ref'ine, maddi kayıp yönünden fazlaya ait hakları saklı kalmak kaydıyla 1.000.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar E. ve A.T., A.T.'nin basımevinde çalışan işçi olması nedeniyle davanın husumetten reddini, basımevinin sadece baskı işçiliğini yaptığını, dizgi, kapak ve iç kapak mizanpajlarının basımdan sonra B.U.'a

iade edildiğini ayrıca davacının, telif hakkına sahip olduğuna dair kaydın olmadığını savunarak davanın esasta da reddini talep etmişlerdir.

Davalı Z...Yayıncılık Ltd. Şti vekili, müvekkilinin yayıncı olarak sorumlu olmayacağını, yazarın sorumlu olacağını, manevi tazminatın şartlarının oluşmadığını savunarak davanın reddini talep etmiştir.

Davalı B.U. vekili, davanın reddini talep etmiştir.

Davalı A.H.İ.'na ilanen tabligat yapılmıştır.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporuna ve tüm dosya kapsamında **davalıların, davacının eserinin özellikle 75 ila 352. sayfaları arasındaki bölümünü FSEK'e aykırı biçimde aynen iktibas ettikleri, FSEK 35. maddesinde öngörülen iktibas serbestisinin kötüye kullanıldığı** gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, 600.000.000 TL manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre davacı vekilin aşağıdaki bentler dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddine,

2-Ancak, davacı; dava dilekçesinde, yazarı ve telif hakkı sahibi olduğu “Türk Dernekleri Hukuku” adlı eserine, davalılarca yapılan müdahalenin men’ini, tecavüzün ref’ini, davalılarca yayınlayan kitabın basımının ve yayımının yasaklanmasını, mahkeme hükmünün FSEK. 78. madde uyarınca tirajı yüksek bir gazetede yayınlanmasını talep ettiği halde, Mahkemece davacının bu talepleri hakkında olumlu ya da olumsuz karar verilmemesi doğru görülmemiş, hükmün bozulması gerekmiştir.

3-Yine, mahkemece dosya üzerinde verilen 8.12.1997 tarihli ihtiyati tedbir kararının uygulanması için davacıdan alınan 50.000.000 TL teminat hakkında da olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi doğru görülmemiştir.

35. (11.HD., 03.07.2000, E. 2000/4764, K. 2000/6252³¹⁴)

“...19/2. madde ve fıkrasında, aynı Yasanın 19/1. maddesinde sayılan kimselerin; eser sahibinin ölümünden sonra, eser sahibine 14,

³¹⁴ Bkz. BATİDER, C.XX, S.4/2000,s. 265-267

15 ve 16. maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları kullanılabilecekleri öngörüldüğünden, manevi zararın giderilmesi isteme haklarının da bulunduğu kabulü gerekmektedir. Dairemizin uygulaması da bu yöndedir. Mahkemece açıklanan hususlar nazara alınarak davalılar yararına münasip bir miktarsa manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken,...”.

37. (11. HD., 26.02.2001, E. 2000/10536, K. 2001/1632)

Davacı vekili, Prof. Dr. P.K.’nin “P... for the 21. St. Century” adlı kitabının müvekkili tarafından “Yirmi Birinci Yüzyıla ...” adı altında yorumlanıp, özetlenerek Türkçe’ye çevrildiğini, bu derlemenin 05.08.1993 ve 19.08.1993 tarihleri arasında Yeni Günaydın gazetesinde derleyen kişi olarak müvekkili belirtmek suretiyle yayınlandığını, davalının 22.11.1993 tarihinde İstanbul’da vereceği konferans sırasında katılanlara dağıtılmak suretiyle bu derleminin kitapçılık haline getirileceğine dair müvekkilinin olurunun aldığını, ancak davanın düzenlendiği konferansa katılan kişilere dağıtılan kitapçıkta müvekkilinin adına yer verilmediğini, böylece FSEK’nun 6 ve 23. maddelerine aykırı davranıldığını ileri sürerek 100.00.000.- TL maddi ve 100.000.000.- TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalıdan tahsiline talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, kitapçıkta davalı adına yer verilmemesinin baskı hatasından kaynaklandığını, konferansa katılanlara bu hususun açıklandığını, tazminat koşullarının oluşmadığını, davacıya ücretinin ödendiğini, esasen eserin çeviri bir eser olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, kitapçılıkta davacı adına yer verilmemesinin baskı hatasından kaynaklandığını, konferansa katılanlara açıklandığı, davalının kötü niyeti olmadığı ve davacıyı zarara uğratma kastının bulunmadığı, FSEK’na göre tazminat koşullarının oluşmadığı gerekçesiyle davanın reddine dair verilen kararın davacı vekilince temyizi üzerine karar Dairemizin 09.11.1995 tarih ve 1995/5813-8404 sayılı ilamıyla “Davalı, konferansa katılarak gerekli açıklamanın yapıldığını tanık beyanlarıyla kanıtlamıştır. Davacı ise, açıklamanın yapılmadığını, kendisinin de bu hususu tanıklarıyla kanıtlayacağını iddia ederek tanık dinletmek istemiştir. Yerel Mahkeme bu istemi nazara almayarak davacıya tanık dinletmesi için imkan tanımamıştır. Oysa davacının delil listesinde tanık deliline de başvurulacağı açıklanmıştır. Şu halde, davacıya da tanıklarının göstermesi için kesil mehil verilmesi ve hasıl olacak sonucuna göre yeniden değerlendirme

yapmak gerekirken...”denilmek suretiyle bozulması üzerine Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yeniden yargılama sonucunda, 22.11.1993 tarihinde davalı şirket tarafından düzenlenen sohbet toplantısında, **davacının tercüme ettiği eserin davacının ismi yazılmaksızın kitapçılık şeklinde bastırılarak dağıtıldığını ve eserin davacı tarafından tercüme edildiğine dair bir açıklamanın yapılmadığını, bu şekilde eylemin FSEK’in 16/3. maddesine aykırılık teşkil ettiği ve davacının kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığı, ancak davacının bu olaydan ötürü maddi zarara uğramadığı gibi davalının da bu dağıtımdan maddi kazanç sağladığının kanıtlanmadığı gerekçeleriyle; takdiren 100.000.000.- TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, maddi tazminatın reddine karar verilmiştir.**

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hükm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalı vekilin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

38. (11. HD., 19.03.2001, E. 2001/226, K. 2001/2031)

Davacılar vekili, müvekkili O.C.’in uluslararası bir üne sahip kariyer sanatçısı olduğunu ve sanat eserlerindeki Ç... imzasının Patent Enstitüsü’nce tescil edildiğini, diğer müvekkilinin bu eserler üzerinde mali hak sahibi olduğunu, davalıların müvekkillerine ait eserleri ürettikleri t-shirt, çanta, yağmurluk gibi eşyalar üzerinde basmak konusunda müvekkil Gülhan ile **sözlü anlaşma** yaptıklarını ve buna göre, satış bedeli üzerinden % 10 telif ücreti ödemeyi kabul ettiklerini, sözleşmenin bir yıla kadar sürdüğünü, ancak davalıların telif ücreti ödeme edimini yerine getirmediklerini, bunun üzerine sözleşmenin feshedildiğini, ancak davalıların karikatürleri kullanmaya devam ettikleri halde müvekkilin imzasını ve logosunu kullanmadıklarını ileri sürerek, davalıların tecavüzünün önlenmesini, müvekkili O. için 2.000.000.000.-TL manevi, her bir müvekkil için 1.000.000.000.-TL maddi tazminatın davalılardan talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, davaya bakmaya Ürgüp Asliye Hukuk Mahkemesi’nin yetkili olduğunu, taraflar arasında 10 yıl için sözleşme yapıldığını, karşılığında 5.000.000.000.-TL ödeneceğinin kararlaştırıldığını ve bu meblağın bir kısmının davacılara ödendiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlara göre, yetki itirazının 5846 sayılı Kanun'un 66/son maddesi gereğince reddedildiği, telif anlaşması ve mali haklarının devrine dair sözleşmenin yazılı olması gerektiği halde taraflar arasında böyle bir sözleşme bulunmadığı, ancak tarafların yazılı beyanlarından davacıların, davacı O.'ın karikatürlerinin bulunduğu turistik eşyaların davalılarca satış ve dağıtımına izin verildiğinin açıkça anlaşıldığı, dolayısıyla davacı G.'in telif ücreti istemesinin yasaya aykırı kabul edildiği, FSEK'nun 66. maddesi gereğince izinsiz değişiklik yapılmış ve imzasız piyasaya sürülmüş eşyaların dağıtım ve satışının durdurulması, davacının uğradığı zararın üç katına karar gerektiği gerekçeyle, davacı G.G.'ün davasının reddine, 2.000.000.000.-TL manevi ve 1.000.000.000.-TL maddi tazminatın davalılardan tahsili ile davacı O.'a verilmesine, davalıların eylemlerinin önlenmesine ilişkin tedbirin devamına karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin yerinde görülmeyen aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, taraflar arasında FSEK. nun 48 nci maddesi uyarınca, mali hakların

devrine ilişkin, anılan Yasanın 52 nci maddesine göre düzenlenmiş yazılı bir sözleşme mevcut değilse de, aralarında sözlü sözleşme olduğu konusunda uyuşmazlık yoktur. Bu durumda, dava konusu eserlerin davalılarca kullanılmasında davacının muvafakati olduğu kabul edilmelidir. Taraflar arasında yazılı sözleşme bulunmadığından mali hakların devir kapsamını saptamak da mümkün değildir. Fakat, davacının mali haklarının davalı tarafça kullanılmasından dolayı bir zararı olduğu kuşkusuz ise de, zararın hesaplanma tarzı anlaşılamadığı gibi, davalı taraf arada bir sözleşme varmış gibi yaptığı ödemelerin tazminat hesabında dikkate alınmadığı saptanmıştır.

O halde Mahkemece, davacının uğradığı zarar miktarının bu konuda uzman

bilirkişilerce saptanması ve davalı tarafın yaptığı ödemelerin de, tazminat hesabında nazara alınması gerekirken, bu hususlar gözetil-

meden, kısmi tazminat davasının tümüne karar verilmesi doğru görülmemiş ve kararın bu nedenle bozulması gerekmiştir.

3- Diğer yandan, davacının manevi zararının ne şekilde oluştuğu gerekçe gösterilip, karar yerinde tartışılmadan, istenen manevi tazminata aynen hükmedilmesi de isabetli olmamış ve kararın bu nedenle de bozulması gerekmiştir.

39. (11. HD., 22.3.2001/11107, K. 2001/2279)

Davacı vekili, müvekkilinin, davalı tarafından yayınlanan Fanatik ve Posta Gazetelerinde 1995 ile 1999 tarihleri arasında yayımlanan 200 adet köşe yazısına karşılık telif ücretlerinin ödenmediğini ileri sürerek 15 milyar lira telif ücretinin faizi ile tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili cevabında, davacının söz konusu yazıları kendi isteği ile ve hobi olarak yazdığını, amacının ‘şan olsun – ismim duyulsun’ olup, davacının bu amacına da ulaştığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia ve savunmaya, toplanan delillere, tanık anlatımlarına nazaran, taraflar arasında yazılı bir sözleşmenin bulunmadığı, her ne kadar, davacının bahsettiği yazıları sabit ise de, bir çok ünlü kişinin bir maddi karşılık beklemeden bu tür yazılar yazdıkları, davacının da bu şekilde yazdığı, bir telif hakkı ücret alacağı bulunmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına ve **davacının, davalı yayın kuruluşunda davaya konu teşkil eden yazılarını yazmaya başladığı 6.8.1995 tarihinden davanın açıldığı tarih olan 11.11.1999 tarihine kadar, ... 200 adet yazı için hiçbir ücret talep etmeden yazılarını düzenleyerek vermiş olmasına, bu yayın kuruluşundan ayrıldıktan sonraki, bu yöne ilişkin istemi(nin) MK.nun 2. maddesinde ifadesini bulan objektif iyiniyet kurallarına aykırı düştüğünün kabulü gerekmesine, keza bu düşüncüyü, davacının yeni yazılarını verdiği davalıdan başka yayın kuruluşundan da (ücret) talep etmediği vakiasının doğrulamış olması karşısında, yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması** gerekmiştir.

40. (11. HD., 29.03.2001, E.2001/143, K. 2001/2548³¹⁵)

Davacı vekili, müvekkilinin proje müellifi olduğu Büyük S... Otel'in, davalı İl Özel İdaresi tarafından diğer davalıya kiralandığını, kiracı tarafından müvekkilinin onayı alınmaksızın Otelin mimari yapısını ortadan kaldıracak kapsamda ilave ve tadilatlar yapıldığını ileri sürerek, eserin eski hale getirilmesini ve maddi-manevi tazminat talep etmiştir.

Davalı İl Özel İdaresi vekili, sorumluluk ve giderlerin kiracıya ait olmak üzere, kullanım amacına uygun olarak zorunlu tadilatlar yapıldığını, müvekkilinin sorumluluğu bulunmadığını savunmuştur.

Davalı K. vekili, kira sözleşmesinden proje müellifi onayının müvekkili tarafından alınacağına ilişkin hüküm bulunmadığını, eserin bedii vasfı olmayıp, tadilatların kullanım amacına uygun şekilde yapıldığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre; davacının proje müellifi olduğu Otelde, davalılar arasında yapılan kira sözleşmesi uyarınca, eser sahibi davacıdan izin alınmaksızın çok kapsamlı değişiklikler yapılmak suretiyle, maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle 6 milyar lira maddi, 6 milyar lira manevi tazminatın yasal faiziyle davalılardan tahsiline, eserin eski hale getirilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekilleri ile davacı vekili temyiz etmiştir.

1- Davacı vekili, HUMK.nun 433 maddesi uyarınca katılma yolu ile kararı temyiz etmiş ise de, davacı vekiline ilk temyiz dilekçesi 20.10.2000, ikinci temyiz dilekçesi 17.10.2000 tarihinde tebliğ edilmiştir. Katılma yolu ile temyiz dilekçesi 28.11.2000 tarihinde harçlandırılıp aynı tarihte temyiz defterine kaydedilmiş bulunduğu anılan maddedeki 10 günlük yasal temyiz süresi aşılmış olmakla davacının temyiz isteminin reddi gerekmiştir.

2- Davalıların temyizine gelince; dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalıların aşağıdaki 3 ve 4 nolu bentlerin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

Davacı, dava dilekçesinde proje müellifi olduğu otelin, izni alınmadan mimari projesinin önemli şekilde değiştirildiğinden bahisle tazminat ve eski hale getirme talep etmiştir. Taraflar arasındaki uyuşmazlık; eserin

³¹⁵ Bkz. YKD, C. XVII, S. 8/2001, s. 1210 vd.; FMR, C. II, S. 1/2002, s. 173-176; BEŞİ-ROĞLU, s. 1166- 1168

teknik ve estetik yönden yapılan değişikliklerinin davacının maddi ve manevi haklarını ihlal edip etmediği ve eserin eski hale getirilmesinin mümkün olup olmadığı, bu durumun da malikin haklarının önemli şekilde ihlal edip etmediği noktasında toplanmaktadır.

Güzel sanat eseri, haksız ve eser sahibinin rızası olmaksızın değiştirilmişse, eski halin iadesi mümkünse ve değişikliğin izalesi ammenin ve malikin menfaatlerini esaslı suretle haleldar etmiyorsa, eser eski hale getirilir, aksi halde eser sahibi özgün eserdeki değişikliğin kendisi tarafından (yapılmadığının) tanıtılmasını veya eserdeki adının kaldırılmasını veya değiştirilmesini isteyebilir. 4110 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önce mimari eserleri istisna eden bu hüküm, bugün, anılan hükümleri kapsamı içine almıştır. Kanun, değişikliklerin tam olarak kaldırılmasını şartlara bağlanmıştır. Bunlardan biri, yani eski halin iadesinin mümkün olması, Kanunun öngördüğü bir şart olmayıp, eşyanın tabiatından doğmaktadır.(...) İkinci şart ise, kendi içinde bir ikameye imkan bırakmaktadır. Değişikliğin kaldırılması (izalesi) ya ammenin, yada malikin menfaatlerini esaslı suretle haleldar etmiyorsa eser eski hale getirilir. *Kamu'nun veya malikin menfaatleri eski hale getirilmesi halinde esaslı surette zarara uğrayacaksa, değişikliğin kaldırılması, yani eski hale getirilmesi haklı görülmez* (Bkz. Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Fikri Mülkiyet Hukuku, 1999 Baskı, s. 297).

Mahkeme gerekçesinde ve hükme esas anılan bilirkişi raporunda, malikin hakları yönünden yasada öngörülen bu ilkeler üzerinde durulmamıştır.

Yukarıda açıklanan ilkeler gözetilmek suretiyle yeniden bilirkişi raporuna alınarak, tazminat ve eski hale getirme talepleri yönünden hasıl olacak sonuç dairesinde bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir.

4- Ayrıca, infazının ne şekilde yapılacağı karar yerinde ayrıntılı bir şekilde açıklanması gerekirken, infazı mümkün olmayacak şekilde, soyut olarak eski hale getirme kararı verilmesi de isabetli olmamıştır.

41. (11. HD., 4.6.2001, E. 2001/2687, K. 2001/5080³¹⁶)

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (eski) 8/2. maddesine göre; aralarındaki sözleşmeden aksi anlaşılmadıkça, memur, hizmetli ve işçilerin işlerini görürken meydana getirdikleri eserlerin mali hak sahipleri bunları çalıştıran veya tayin edenlerdir. Bu hükme dayanılarak davacı şirket lehine mali haklarına tecavüz olduğundan bahisle maddi tazminata karar verilmiş ise de, davacı şirket anılan maddede açık bir şekilde belirlendiği üzere davaya konu eserin mali hak sahibi olup, eserin manevi haklarının sahibi değildir. Anılan Kanunda mali ve manevi haklar ayrı ayrı düzenlenmiş olup, manevi haklar tadadi olarak gösterilmiştir. Sayılan bu haklardan dolayı manevi tazminat isteme hakkı da manevi hak sahibine aittir. O halde; **davaya konu eserin mali hak sahibi olan davacının bu eserden dolayı manevi tazminat istemeyeceğinin kabulü ile, bu istek kaleminin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde manevi tazminata hükmedilmesi doğru görülmemiştir.**

42. (11. HD., 3.12.2001, E. 2001/6140, K. 2001/9459)

Davacılar vekili, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince, müvekkillerince hazırlanan mimari projenin davalıya teslim edildiğini ve Mimarlar Odasına müracaat edildiğini, ancak evrak ve belgelerin davalılar tarafından kasıtlı olarak verilmemesi nedeniyle projenin onayının geciktiğini, projeyi tam olarak hazırlayan müvekkillerin ücreti hak etmelerine rağmen 250.000.000 lira dışında başkaca ödeme yapılmadığı gibi, projelerin başka mimarın imzası ile güncelleştirmek suretiyle müvekkillerinin FSEK'ten kaynaklanan mali ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek, tahsil edilenin düşülmesinden sonra kalan 2.750.000.000 lira proje bedeli ve 9.000.000.000 lira mali, 3.250.000.000 lira manevi tazminatın temerrüt tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden faizi ile birlikte davalardan müteselsilen tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalılar vekili, davanın Ticaret Mahkemesi iş alanına girdiği, davalı S.'in sözleşme tarafı olmadığından husumet ehliyetinin bulunmadığını, davacıların sözleşme ile yükledikleri edimi yerine getirmemesi nedeniyle projenin başka mimara hazırlattırdığını savunarak, asıl davanın reddi ile davacıların edimlerini yerine getirmemesi nedeniyle yurt dışın-

³¹⁶ YKD, C. 27, S. 10/2001, s. 1537- 1539

daki iş bağlantısının iptal edildiğini ileri sürerek, şimdilik 2.000.000.000 lira zararın davacılar tarafından tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Mahkemece, davacıların serbest meslek mensubu olmaları ve FSEK 2/3. ve 76/1. maddesi gereğince davanın Asliye Hukuk Mahkemesi görevine girdiği gerekçesiyle işbölümü itirazının reddine, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, taraflar arasında imzalanan sözleşme gereğince davacıların mimari projeyi hazırladıkları, proje bedeli için 250.000.000 lira dışında ödeme yapılmadığı, keşide edilen ihtara verilen yanıt ile de bedel isteminin reddedildiğini ve (davacılarca hazırlanan) projenin detay farklılıkları oluşturularak, başka bir mimara onaylatılarak kullanıldığı, eylemin FSEK. 22 ve 76. maddelerine aykırı olduğu gerekçesiyle; asıl davanın 2.750.000.000 lira proje ücreti, 9.000.000.000 lira mali hak ve 2.500.000.000 lira manevi tazminat olarak kısmen kabulüne, karşı davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, davalılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

43. (4. HD., 18.2.2002, E. 2001/10696, K. 2002/2010³¹⁷)

“...2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince; dava, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan kaynaklanan tazminat istemine ilişkindir. Davacı kendisi tarafından çizilen yapı projesinin izinsiz olarak davalılar tarafından kullanılmasından dolayı maddi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece istemin kısmen kabulüne karar verilmiştir. Karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; **davacının çizdiği projenin hukuka aykırı olarak kullanımından kaynaklandığına göre, zararın kaynağı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 68. maddesi olup, hesaplamanın da bu maddeye göre yapılması gerekir. Eser sahibinin izni olmaksızın projenin kullanılması halinde projenin 2. ve 3. kez kullanılması sebebiyle asgari ücret tarifesine göre belirlenen miktardan indirim yapılması ve proje masraflarının düşülmesi de doğru de-**

³¹⁷ Bkz. ERDİL, s. 160

ğildir. Mahkemece bu hususlar gözetilmeden yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir”.

Bu karara şöyle bir karşı oy yazısı yazılmıştır:

“Bir projenin parasal değerine etkili olan unsurlar içinde tasarım, çizim ve malzeme bedelleri önemli yer tutar. Davacı tarafından çizilen projenin davalılarca kopyalanıp kullanıldığı iddia edildiğine göre, davacı ayrı bir orijinal tasarım yapmadığı gibi çizim yapmamış ve malzeme masrafına da katlanmamıştır. Davacının zararının belirlenmesinde bu hususlara dikkat edilmesi gerekirken her şeyi ile yeni, çizimi davacı yanca yapılmış ve malzemesi davacı yanca temin edilmiş bir projenin bedeline karar verilmesi hakkaniyete uygun düşmemektedir. Bu nedenle yüce çoğunluğun tam bedele karar verilmesi gerektiğine dair bozma kararına katılamıyoruz. ”.

44. (11. HD., 19.03.2002, E. 2001/10702, K. 2002/2515 ³¹⁸)

Davacılar vekili, davacılarından A.B. tarafından diğer davacı şirket adına çizdiği davalı A.Ş. tarafından yaptırılan fabrika binasına ilişkin mimari projenin, çizilen proje mahallinde uygulanarak inşaatın tamamlandığı, ancak **davalılar tarafından müvekkillerinin izni alınmaksızın söz konusu projeler biraz değiştirilmek suretiyle, davalı T... İlaç A.Ş.’ne ait ek binalar yapılmak suretiyle davacıların fikri eser niteliğini taşıyan projesine tecavüzde bulunarak mali ve maddi hakların ihlal edildiğini ileri sürerek, 58.009.500.000- lira maddi ve 20.000.000.000.- lira manevi tazminatın davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.**

Davalı T... İlaç A.Ş vekili, T... Sağlık Ürünleri Fabrikası projesinin davacılara çizdirildiğini, ihtiyaç nedeniyle ek binalar yapıldığını, söz konusu binaların dış cephelerinin zorunlu olarak ilk bina cephesine uygun olarak inşa edildiğini, fikri esere tecavüzün söz konusu olmadığını, istenen tazminatın da fahiş olduğunu savunarak, davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar vekili, fikri esere tecavüz ve kopyalama iddiasının doğru olmadığını, dış cephenin benzetilmesinin zorunluluktan kaynaklandığını, istenen tazminatın çok fazla olduğunu savunarak, davanın reddini istenmiştir.

Mahkemece, iddia, savunmanın, toplanan kanıtlar ve yaptırılan bilirkişi incelemesine göre, davalı T... İlaç A.Ş. tarafından yaptırılan fabrika ana binasına ait projenin davacı A.B. tarafından çizildiğini, davalı şirkete

³¹⁸ Bkz. ERDİL, s. 13-14 ve 162-164.

binaların yetersiz gelmesi üzerine **ek binalar yapılmasına karar verildiği, ancak proje çizimini diğer davahların üstlendiği, fakat ek projelerin davacı A.B.'ca çizilen ana binaya ait proje kopyalanarak yapıldığını sabit olduğu,** mimari eserin 5846 sayılı Yasa uyarınca fikir ve sanat eseri niteliğinde olup, davalıların izinsiz kopyalama eyleminin eser sahibinin mali manevi haklarına tecavüz oluşturduğu, davacıların isteyebileceği maddi tazminatın 14.815.566.590- lira olarak belirlendiği ve olayın özelliği dikkate alınarak, 7 milyar lira manevi tazminat takdir edildiği gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar, taraf vekilleri temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, taraf vekillerinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan diğer tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, **FSEK'nun 68/2. maddesinde, eserin hak sahibinin izni olmadan çoğaltılması halinde, izni alınmamış eser sahibinin sözleşme olması durumunda isteyebileceği bedelin üç kat fazlasını isteyebileceği hükme bağlanmıştır.** Bu madde hükmü karşısında, taraflar arsında bir sözleşme olmaması halinde ilgili meslek kuruluşundan rayiç bedeli tespit edilerek tazminatın hesabı ilke olarak doğrudur. Ne var ki, somut olayda davalı T... A.Ş. nin açtığı ihaleye davacıların katıldığı ve 25.03.1997 tarihinden fiyat belirlemek suretiyle teklif verdikleri de anlaşılmaktadır. Şu halde, davacılar ile davalı T... A.Ş. arasında sözleşme imzalanırsa idi teklifle belirlenen fiyat üzerinden yapılacağı kuşkusuzdur. Artık burada taraflar arasındaki sözleşme bedeli belirli ve somutlaşmış olduğuna göre, farazi bir sözleşmenin varlığı ile bunun bedeli üzerinden tazminat hesaplanması doğru görülmemiştir.

Bu bağlamda Mahkemece, davacıların isteyebileceği mali zararın, verdikleri teklif bedeli esas alınarak belirlenmesi ve oluşacak sonuç çerçevesinde bir hüküm kurulmak gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması yerinde görülmemiş ve kararın bu nedenle davalılar yararına bozulması gerekmiştir.

3-Davacılar vekilin **manevi tazminata ilişkin temyiz itirazlarına gelince; tarafların sosyal ve ekonomik durumları, dava konusu projenin önem ve değeri, kopyalama biçimi dikkate alındığında FSEK'in 70/1-2 nci maddeleri karşısında daha uygun bir manevi tazminatın**

takdiri gerekirken, olayın özelliğine uygun düşmeyen az miktarda manevi tazminat takdiri isabetli görülmemiş ve kararın bu nedenle davacılar yararına bozulması gerekmiştir.

45. (11. HD., 07.04.2003, E. 2002/10981, K. 2003/3385)

Davacı vekili; müvekkilinin, davalının halen maliki bulunduğu kültür varlığı niteliğindeki yapının rölöve projesini, önceki dava dışı malikin isteği üzerine hazırladığını, bu projenin eser niteliğinin bulunduğunu, davalının bu projeyi restorasyon çalışmalarında müvekkilinden izinsiz kullandığını ileri sürerek, rölöve proje bedeli olan 4.500.000.000- lira ile ... 8.000.000.000- lira manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, binanın satın alınmasıyla birlikte projenin de bina ile birlikte müvekkiline geçtiğini, projenin fikri eser sayılmayacağını, müvekkilinin eser sözleşmesinin taraflarından olmadığını, bu sözleşmenin BK'nun 126/son maddesi uyarınca 5 yıllık zamanaşımına tabi olduğunu, miktarların yüksek istendiğini savunarak, davanın zamanaşımı, husumet ve esas yönlerinden reddi istenmiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve toplanan kanıtlar doğrultusunda davanın; fikir ve sanat eseri niteliğindeki projenin sahibi davacının açtığı maddi ve manevi tazminat davası olduğu, davacının projeyi 1992 yılında hazırladığı, istisna sözleşmesinden doğan bu davanın BK'nun 126/son maddesi uyarınca 5 yıllık zamanaşımına uğradığı gerekçeleriyle, davanın ... reddine karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili temyiz istemiştir.

Dava, 5846 sayılı FSEK'den kaynaklanan mali ve manevi haklara ilişkin tazminat isteminden ibarettir.

Dava konusu projenin, eser sahibi davacının izni olmaksızın, taşınmazın sonraki maliki davalı tarafından kullanılması suretiyle mali ve manevi hakların ihlal edildiği iddia edilmiştir. **Projenin hazırlanmasına ilişkin istisna sözleşmesi, davacı ile taşınmazın (dava dışı) önceki maliki arasında yapılmış olup, bu sözleşmenin tarafı olmayan sonraki malik davalı aleyhine açılan bu dava, bu sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Bu itibarla, taraflar arasındaki hukuki ilişkinin istisna sözleşmesine dayandığından bahisle, davanın BK'nun 126. maddesindeki 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde açılmadığı gerekçesiyle, davanın reddi**

doğru olmamıştır. Kaldı ki, davalı taraf dahi savunmasında, müvekkilinin bu sözleşmenin tarafı bulunmadığını ifade etmiştir.

Bilirkişi kurulu raporunda dava konu proje, 5846 sayılı FSEK'in 4. maddesinde geçen mimarlık eseri kabul edilmiş, Mahkemece de davanın konusunun fikir ve sanat eseri niteliğindeki projeden kaynakladığı gerekçe de vurgulanmış olup, davalı taraf aksi yöndeki savunmasına rağmen hükmü, gerekçe yönünde temyiz de etmemiştir.

Bu durumda, davalı tarafın zamanaşımına ilişkin def'isi ve gerektiğinde tazminat miktarına ilişkin esasa yönelik savunmaları, 5846 sayılı FSEK. hükümleri çerçevesinde ele alınmak, sonucuna göre karar verilmek gerekirken, hukuki nitelemede yanılgıya düşülerek yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamıştır.

46. (11.HD., 15.05.2003, E. 2003/2276, K. 2003/4996)

Davacı vekili; davalılardan (birinin) müvekkillerinin bir çalışanı, diğerinin ise genel müdürü olduğunu ancak sadakat yükümlülüğü ihlal ederek dava dışı B... firmasıyla anlaştığını daha sonra görevinden istifa ederek müvekkillerine ait fikri eserleri izinsiz kullandığını ileri sürerek, haksız rekabetin tespiti ve menı ile 250.000 ABD Doları maddi ve 50.000 ABD Doları manevi tazminatın faiziyle davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan deliler ve yaptırılan bilirkişi incelemesi sonucuna göre; davalının davacı I... şirketinde görevli iken, o şirkete ait proje işlemlerini kendi yararına kullandığı, B... firması ile anlaştığı ve hüsnüniyet kurallarına aykırı eylemlerde bulunduğu gerekçesiyle davanın (kabulü ile maddi tazminatın) kısmen tahsiline, fazlaya ilişkin istem ile manevi tazminat isteminin reddine karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

47. (11. HD., 16.06.2003, E. 2003/784, K. 2003/6343)

Davacı vekili, müvekkilinin Orhan Veli'nin bütün eserlerinin yayın ve telif haklarına sahip olduğunu, davalı B.E. tarafından hazırlanan ve diğer davalı Bakanlık tarafından yayınlanan "Orhan Veli Kanık (Hayatı, Sanat ve Eserlerinden Seçmeler)" adlı kitapta ise, müvekkilinin telif ve yayın haklarına tecavüz edildiğini ileri sürerek, yasaya aykırı iltibas ile yayın ve telif haklarına tecavüzün men'ini, 5.000 kitabın satışının engellenmesinden doğan kâr kaybı zararı 318.095.000.-TL ile FSEK'in 68/1. maddesi uyarınca 291.667.500.-TL maddi tazminat ve 500.000.000.-TL manevi tazminatın faiziyle birlikte davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekilleri, davanın reddini istemişlerdir.

Mahkemece, davanın reddine dair verilen karar, Dairemizin 18.11.2000 günlü kararı ile davacı yararına bozulmuş, davalılar vekilinin karar düzeltme istemi Dairemizce reddedilmiştir.

Mahkemece, bozma kararına uyularak yapılan yargılama sonunda, **davalı Bakanlığın diğer davalıya hazırlattığı eserden dolayı; Orhan Veli'nin eserlerinin mali haklarını devralmış olan davacının mali haklarını kısmen ihlal ettiği ve nispi düzeyde telif bedeli ödenmesi gerektiği, manevi hakların devrinin mümkün olmaması nedeniyle kendine intikal etmemiş olan manevi haklar konusunda davacının talepte bulunamayacağı, 5846 sayılı Yasa'nın 70/3. maddesi uyarınca istenen maddi tazminatın ise kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davacının FSEK'in 70/1 ve 70/3. maddeleri gereğince istenen manevi ve maddi tazminatın isteminin reddine, FSEK'in 68. maddesine göre 87.500.250.- TL mali haklar tazminatının yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, hüküm özetinin ilanına, diğer talebin reddine karar verilmiştir.**

Karar, davacı ve davalı B.E. vekillerince temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, mahkemece uyulan bozma kararı gereğince hüküm verilmiş olmasına ve delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davacı ve davalı B.E. vekillerinin bütün temyiz itirazları yerinde değildir.

48. (11. HD., 22.09.2003, E. 2003/2117, K. 2003/8131)

Davacı vekili, müvekkil tarafından özgün biçimde tasarımlanan bilgi işlem programına yapımcı kodu alınmış olduğunu, davalının izinsiz olarak bu programı kopyaladığını ve kendi çalışması gibi internet ortamında yayınladığını, müvekkilinin mali ve manevi haklarına tecavüz edilmiş olduğunu ileri sürerek tecavüzün men'i ile 1.000.000.000.-TL manevi ve 100.000.000.-TL maddi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, programların temel yapılarının farklı olduğunu, kullanılan bilgilerin kamuya açık olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, **davaya konu programda mevzuatın belirli bir dizi ve plan halinde yapılması nedeniyle eser niteliğinde olduğu, davanın eyleminin programı aynen alıp, yayın yöntemi ile yayınlamak olduğu, bu eylemin FSEK'ye aykırı olduğu gerekçesiyle, 100.000.000.-TL maddi ve 750.000.000.-TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.**

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına ve **somut olayda 5846 sayılı Yasa'nın 15. maddesi hükmünün ihlal edilmiş olmasına göre aynı Yasa'nın 70. maddesi hükmü gözetilerek manevi tazminata hükmedilmiş olmasında bir usulsüzlük bulunmadığından** davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile hükmün onanması gerekmiştir.

49. (11. HD., 10.02.2004, E. 2003/6364, K. 2004/1081)

Davacılar vekili, davalının müellifi olduğu mimari projenin, müvekkillerince yapımı üstlenilen vergi dairesi inşaatında kullanılmak üzere anlaşma yapıldığını, ancak, ihale makamının kararı nedeniyle projenin uygulanmasından vazgeçildiğini, davalının proje bedeline karşılık aldığı 4 adet toplam 1.000.000.000.- TL'lik çeklerden bir adedinin ödendiğini ileri sürerek, ödenen miktarın istirdadı ile (kalan) 3 adet çek için müvekkillerinin borçlu olmadıklarının saptanmasını istemiştir.

Davalı vekili, davacıların sözleşmeyi K... Müh. Ltd. Şti. ile imzaladığını, müvekkiline husumet yönetilemeyeceğini, sözleşmenin feshedil-

mediğini ve projenin çizilip davacılara verildiğini, bedelinin geri alınmasının söz konusu olamayacağını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, **davalı tarafından çizilen İnegöl Vergi Dairesi hizmet binası projesinin uygulanmasından dava dışı İdarenin vazgeçmesi nedeniyle proje bedeli olarak ödenen bedelin geri istenemeyeceği, zira davacıların sözleşmeyi belirtilen nedenle feshetmesinde, davalının kusurunun bulunmadığını, projenin sözleşme gereğince çizilip teslim edilmekle davalının ediminin yerine getirdiği gerekçesiyle, dava reddedilmiştir.**

Kararı, davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

50. (11. HD., 18.05.2004, E. 2004/5177, K. 2004/5598)

Davacı vekili, müvekkili kooperatif inşaatlarının mimari projelerini davalılardan A.B., statik projelerini ise, diğer davalının yaptığını, davalılardan N.B.'un aynı zamanda müvekkili kooperatifin kontrol mühendisliği görevini yapmakta iken, görevine son verildiğini, inşaatın devam edebilmesi için temel tadilat projesinin çizilmesi gerektiğini, bu proje davalılardan N.E.'un bilgisi dahilinde inşaat mühendisi dava dışı M.Y. tarafından çizildiğini ve belediyece onaylandığını, çatı tadilat projesinin ise davalı N.E. tarafından imzalanmadığı için belediye onayı alınmadığını, müvekkili kooperatif ve üyelerinin mağdur olduğunu ileri sürerek, taraflar arasındaki muarazanın giderilmesine, yapılmış olan projenin tamamlanması için M.Y. veya başka bir mühendise imza yetkisi verilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili, çatı tadilat projesi ile ilgili olarak müvekkilesi A.B.'un üzerine düşen sorumluluklarını yerine getirdiğini, diğer müvekkili N.E.'in davacıya ait blokların betonarme ve statik projesini yapmakla, proje müellifi olduğunu, projede yapılacak tüm tadilatların fikir eseri olmakla müvekkiline ait olduğunu, proje müellifliğinin devredilmesinin mümkün olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, benimsenen bilirkişi raporuna göre, mimari proje müellifi davalı A.B.'e yönelik davanın reddine, diğer davalı proje müellifi N.E.'e yönelik olarak kabulü ile inşaat mühendisi M.Y. tarafından düzen-

lenecek olan Hurma 9175 ada 3 parsel üzerinde yapılan inşaatlardan B ve C Blok çatı katı tadilatı ile betonarme ve statik tadilat projesine, proje müellifi adına yetkisi verilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16/2 nci maddesi uyarınca, zaruri görülen değiştirmelerin eser sahibinin izni olmaksızın da yapılabilmesine göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde değildir.

2- Dava, muarazanın giderilmesi ve tadilat projesine proje müellifi imza yetkisi verilmesi istemine ilişkindir.

Davalılardan A.B. bakımından davanın reddine karar verildiği halde, hüküm tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince, bu davalı lehine, vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken, bu noktada bir karar verilmemesi doğru olmamıştır.

51. (11. HD., 01.06.2004, E. 2003/10569, K. 2004/6137)

Davacılar vekili, müvekkillerinden A.M.'ya ait mimari projenin 04.03.1991 tarihli sözleşme ile İstanbul Bahçeşehir 1. Etap 1-2 kısım inşasında kullanıldığını, projenin mali haklarının diğer davacı şirkete ait olduğunu, davalı E.. Pazarlama A.Ş. nin aynı projeyi 2. Etap inşaatlarda kullanmak için sözleşme yapmak istediğini, ancak bu konuda tarafların uyuşmadığını, davalı M... A.Ş. nin İzmir Mavişehir'de inşa ettiği konutlarda izinsiz olarak müvekkilinin projesini kullandığını ileri sürerek, 45.000.000.000.-TL mali hak ve 1.000.000.000.- TL manevi tazminatın tecavüz ya da dava tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden temerrüt faizi ile birlikte davalılardan birlikte ve zincirleme olarak tahsilini istemiştir.

Davalı M... A.Ş. vekili, dava konusu Mavişehir konutlarının projesinin, müvekkilinin daha önce Kuru Sitesi ve Konutkent projelerinin geliştirilmiş hali olduğunu ve davacı mimarın Bahçeşehir'de uygulanan projesi ile ilgili olmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Davalı E... Pazarlama A.Ş. vekili, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacıların eser sahibi olduğu projenin; davalı M... A.Ş. tarafından İzmir Mavişehir’de inşa edilen konutlarda tünel kalıp sisteminin uygulanmasından doğan teknik zorunluluklar dışında % 85 oranında benzerlik ve alıntı şeklinde eser sahiplerinin izni olmaksızın kullanıldığı, davalı E... Pazarlama A.Ş.’nin projenin uygulanmasında etken rol almadığı ve inşaatların pazarlamasında aracılık ettiği gerekçesiyle davalı M... A.Ş. açısından davanın kısmen kabulü ile 37.344.208.493.-TL maddi, 1.000.000.000.-TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren reeskont oranı üzerinden faizi ile birlikte tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davacı vekili ve davalı M... A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve davalı E... Pazarlama A.Ş.’nin davacıların projesinin izinsiz kullanımında sorumluluğunu gerektirir işlem ve eylemlerin kanıtlanamamış olmasına göre, davacı vekilinin davalı E... Pazarlama A.Ş. ne yönelik temyiz itirazlarının reddi gerekmektedir.

2- Davalı M... A.Ş. vekili, gerek İstanbul Bahçeşehir Konutları, gerekse dava konusu edilen İzmir Mavişehir konutlarında uygulanan projenin daha önceden Ankara’da Konutkent ve Koru Sitesi konutlarının inşasında kullanıldığı ve ilk ve orijinal projenin Ankara’daki konutlarda uygulanan proje olduğunu, bu nedenle davacının projesinin de aslında Ankara’da uygulanan projenin benzeri olduğunu savunmuştur. Mahkemece, davalının bu savunması üzerinde durulmamış, salt davacının projesinin uygulandığı Bahçeşehir konutları ile dava konusu İzmir Mavişehir konutları projesi arasında kıyaslama yapılarak sonuca gidilmiştir. O halde mahkemece, davalı M... A.Ş.’nin Ankara’daki Konutkent/Korusitesi konut projelerinin ilk ve orijinal proje olduğu yolundaki savunması üzerinde durularak, Ankara-İzmir ve İstanbul’daki konut projelerinin birlikte uzman bilirkişiler aracılığı ile gerektiğinde yerinde keşif yapılmak suretiyle, İzmir’de uygulanan projenin Ankara’daki konutlarda kullanılan proje olup olmadığı, davacıların İstanbul konutlarında uygulanan projesinin Ankara konutları projesinin kopyası/işlemesi ve İzmir’de uygulanan projenin de Ankara projesi ile İstanbul projesinin işlemesi olup olmadığının saptanarak, sonucuna göre karar verilmesi gerekir iken, eksik inceleme sonucu yazılı gerekçeyle hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

3- Bozma neden ve şekline göre davacı vakilinin yukarıda 1. bentte açıklanan hususlar dışında diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine gerek görülmemiştir.

52. (11. HD., 24.06.2004, E. 2003/11182, K. 2004/7064)

Davacılar vekili, müvekkillerince daha önce hazırlanan mimari projelerin hemen aynısının, davalılarca sanki kendi eserleri imiş gibi üzerine kendi adlarını yazarak İdareye verdiklerini ve bu projelendirme nedeniyle ihale makamınca toplu konut kredisi alındığını, müvekkillerinin eser sahipliğinden doğan zararlarının HUMK'un 193/son maddesi uyarınca açılmış sayılma kararı ile sonuçlanan önceki davayla sabit olduğunu ileri sürerek; 10.500.000.000.- TL mali hak tazminat ile 700.000.000.- TL manevi tazminatın en yüksek ticari faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılar vekili cevabında, davacıların İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hazırladıkları Atakent Toplu Konut Projesinin deprem sonrası uygulama alanının kalmadığını, daha sonra açılan ihaleyi kazanan dava dışı yüklenici için müvekkillerince hazırlanan projenin önemli farklılıklar taşıdığını, esasen davacılarca ait projenin daha önce birkaç kez uygulanarak alenileştiğini, özgür eser niteliği kalmadığını, ilk dava tarihinden itibaren temerrüt faizi istenemeyeceğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, 2000/331 Esas sayılı dava dosyası kapsamındaki kanıtlara ve bilirkişi raporlarına dayanılarak, davacıların dava konusu toplu konut projelerinin FSEK'in 2/3 maddesi anlamında özgün bir mimari tasarım ürünü olduğu ve bilimsel eser olarak korunduğu, davalılarca bu eserin izinsiz kullanılıp değişiklik yapılmasının aynı yasanın 15 ve 16. maddelerine aykırılık oluşturduğu, davacı tarafça 68. maddeye dayanıldığından taraflar arasında zahiri bir sözleşmenin gerçekleştiği ve **zamanaşımı süresinin (10) yıl olduğu**, ilk dava tarihinden itibaren faiz istenebileceği gerekçesiyle, 10.500.000.000.- TL maddi ve taktir edilen 500.000.000.- TL manevi tazminatın 07.06.1999 tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalılar vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve **haksız eylem tarihinden itiba-**

ren temerrüt faizi istenebilecekken, dava dilekçesindeki istem doğrultusunda açılmamış sayılma kararı ile sonuçlanan ilk dava tarihinden itibaren temerrüt faizine hükmedilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalılar vekilinin aşağıdaki bent dışında kalan ve yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak, mali hak tazminatının hesaplanması ve buna esas alınan veriler yönünden; **iki mimarın yer aldığı ilk bilirkişiler kurulu raporu ile bir mimarın bulunduğu ikinci bilirkişiler kurulu raporu arasında var olan çelişkiler giderilmediği gibi, hükme dayanak alınan ikinci raporu benimsenme ve üstün tutulma nedenleri de gerekçeli kararda gösterilmemiştir.**

26.11.2002 tarihli ikinci bilirkişi raporuna yönelik olarak davalılar vekilince verilen 24.12.2002 tarihli dilekçedeki istem doğrultusunda, projelerin içerdiği yapı sınıfı binaların kitlesel kurgu özelliklerinin benzeşme derecesi, tazminat hesabına temel oluşturacak hizmet bedeli cetvellerinin hangi yıla ait olmak gerektiği, davalıların hazırladığı projeye dayalı yapı ruhsatının özellikleri, davalıların eylem tarihine nazaran güncelleştirme fiyat farkı hesabında hangi katsayının baz alınabileceği ve diğer hususlara ilişkin raporlar arası çelişkinin giderilmesi amacıyla ve gerekirse istinabe yolu ile davalı tarafın projesinin uygulandığı toplu konut alanında keşif yapılarak, oluşturulacak yeni bilirkişiler kurulundan kapsamlı rapor alındıktan ve 5846 sayılı FSEK.in dava tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan 68/son maddesi hükmü uyarınca ilgili meslek birliğinden davacı tarafın projesinin tabi olduğu hizmet bedeli de öğrenilip, yapılacak tazminat hesabı denetlendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesinde ve böylece uyuşmazlığın doğru çözüme ulaştırılmasında zorunluluk görüldüğünden, temyiz itirazlarının kabulü ile kararın bozulması gerekmiştir.

53. (11. HD., 21.9.2004, E. 2003/12452, K.2004/8678)

Davacı vekili, müvekkilinin İngiltere ve daha bir çok ülkede yayınlanmakta olan “Weakest Link” (En Zayıf Halka) isimli yarışma programının eser sahibi olduğunu, 4.9.2001 tarihinden itibaren davalı şirketin herhangi bir izin ve anlaşma olmaksızın müvekkilinin hak sahibi olduğu yarışma programını, aynı format, içerik ve kurallarla “Kim Gitsin?” ismi ile yayınlamaya başladığını ve 26 bölüm olarak devam ettiğini bu durumun FSEK.ne aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, FSEK’in 68. maddesi uyarınca telif ücretinin üç katı olan 214.500 USD. nin 4.9.2001 tarihinden

itibaren faiziyle birlikte aynen veya fiili ödeme tarihindeki TL karşılığının tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin yayınladığı programı, lisans sözleşmesi ve yayın sözleşmeleri çerçevesinde hak sahibi olan şirketlerden bedeli ödemek ve yayın hakkını almak suretiyle yayınlandığını, müvekkilinin yayın hakkına sahip olduğu yarışma programı ile davacının eser sahibi olduğunu iddia ettiği, programın genel bir takım benzerliklerin dışında ayniyet arz etmediğini, istenen tazminatın fahiş olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, bilirkişi raporu ve dosya kapsamına göre, “En Zayıf Halka” olarak tercüme edilen programın orijinal eser olup, davacıya ait olduğu, davalının yayınlandığı “Kim Gitsin?” isimli programın davacının programı ile ayniyet derecesinde benzer olduğu, bu nedenle eser sahibi olan davacının çoğaltma hakkının ihlal edildiğini ve (programın) kopya edildiği, davalının lisans sözleşmesine dayandıkları iddiasının yerinde olmadığı ve FSEK’nun 68. maddesi uyarınca davacının üç katı tazminat isteyebileceği gerekçesiyle, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Karar, davalı vekilince temyiz edilmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

54. (11. HD., 11.10.2004, E. 2004/393, K. 2004/9567)

Davacı vekili, sanatçı H.G.’e ait olan müzik eserlerinin yayın hakları dava dışı M... Plak Evi’ne ait iken tüm hakların 1992 yılında müvekkiline devredildiğini ve bu durumun müzik eseri işletme belgesine şerh edildiğini, anılan eserden 5 adedinin davalı tarafından kopya edilerek piyasaya sunulduğunu, bu durumun müvekkilinin zararına yol açtığını ileri sürmek, müzik eseri işletme belgesinin iptaline, ihlale uğrayan mali haklara karşılık davalının elde etmesi mümkün görünen menfaatin karşılığı 1.500.000.000.TL. maddi ve 500.000.000.TL. manevi tazminatın davalıdan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, T.T.K.nun 62. maddesi uyarınca bir yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu, eser sahibinin mirasçıları tarafından 1994 yılında

müvekkiline muvafakatname verildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre, **davanın hukuksal niteliğinin haksız eylem olduğu, eylemin devam ettiği sürece zamanaşımının işlemeyeceği**, dava konusu eserler üzerinden davacının komşu hak sahibi olarak mali ve manevi hakları bulunduğu, **eser sahibinin mirasçıları tarafından daha sonra davalıya yapılan temlikin davalıya karşı geçerli olmadığı**, davacının FSEK'in 80/10. maddedeki haklardan yararlanabileceği, davalının sağladığı kârın tazminat olarak istenebileceği gerekçesiyle, işletme belgesinin iptali isteminin İdari Yargının görevine girdiğinden reddine, 867.953.153.TL: maddi ve 350.000.000.TL manevi tazminatın davalıdan tahsiline, eserlerin üretim ve satışının durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar, taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve uyuşmazlığın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanmış olması nedeniyle karar altına alınan manevi tazminatın dayanağının anılan Kanununun 70. maddesi olduğu, karar yerinde T.T.K.nun 58. maddesinin kullanılmış olmasının sonuca etkili bulunmamasına göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Dava, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat isteğine ilişkindir.

Davacı, maddi tazminat olarak, “davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığını” hükmün altına alınmasını dava etmiştir.

Mahkemece hükme dayanak yapılan bilirkişi raporlarında, ortalama kaset ve CD fiyatlarına göre, itiraz üzerine düzenlenen raporda ise, kaset ve CD'lerin toptan satış tutarlarından bunların fabrika satış fiyatları düşülerek tazminat hesap edilmiştir. Mahkemece bu hesaplar irdelenerek sonuca varılmışsa da, **davaya konu kasetlerin ve CD lerin piyasaya sürülmesine kadar davalı tarafından yapılan imalat giderlerinin belirlenip, bu kalemlerin fabrika çıkış fiyatı olarak saptanan meblağın kapsamında olup olmadığı; böylece davacı lehine hükmedilen tazminatın hesabında imalat masraflarının düşülüp düşülmediği konusunda Yargıtay denetimine elverişli bilgilere rastlanmıştır.** Mahkemece de bilirkişi raporundaki rakamlar baz alınarak sonuca varılmıştır. Değinilen

nedenlerle ilgili olarak Mahkemece bilirkişilerden ek rapor alınmadan hükme varılması hatalı olduğundan davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün bozulmasına karar verilmek gerekmiştir.

55. (11.HD., 14.10.2004, E 2004/9774, K 2004/9844)

Davacı vekilleri, müvekkil şirketin davalılardan E... Pazarlama Ltd. Şti'ne ait inşaatın mimari, statik betonarme projelerini yaptığını, daha sonra projeye göre yapılan binanın Teknik Uygulama Sorumluluğu görevinden ayrıldığını, bilahare müvekkilleri şirketin yetkililerinin ... mimari projelerinin tadilata uğratıldığını, projelerinin bütünlüğünü bozulduğunu tespit ettiklerini, tadilat projesini yapanın ve mimari proje şeklini değiştirenin davalılardan Y... İnşaat Ltd. Şti. diğer davalı A.Y.'in ise tadilat projesini yapan mühendis olduğunu, 5846 sayılı Yasa'nın 2/3 ve 4/3 madde hükümleri gereğince müvekkilleri Şirketçe yapılan projenin fikir sanat eseri, güzel sanat eseri olduğunu, aynı Yasa'nın 16. maddesi gereğince, eser sahibinin izni olmadan bu proje üzerinde hiçbir değişikliğin yapılamayacağını, ileri sürerek, tecavüzün ref'i inşaatın eser sahibi müvekkilleri Şirket tarafından yapılan projesine uygun hale getirilmesine, sonradan yapılan ilavelerin kal'i suretiyle tecavüzün giderilmesine, 5.000.000.000 lira manevi tazminatın davalılardan müteselsilen tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalılardan E... Mobilya Dekoratif Ürünler Tic. A.Ş. ve A.Y. vekilleri, davanın zamanaşımına uğradığını, tadilat projelerinin bizzat davacı tarafça hazırlandığını, eksik olarak iade edildiğini ve sonradan davalılardan E... Mobilya ve Dekoratif Tic. A.Ş.'ye verilmediği için, yeniden hazırlanmak zorunda kalınan projeler olduğunu savunarak, davanın reddini istemişlerdir.

Diğer davalı şirket, davaya yanıt vermemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davacı proje mükellefinin onayı alınmaksızın projede değişiklik yapıldığının sabit olduğu, davacının bu değişikliği 06.12.1999 tarihli ihtarname ile öğrendiği, dava tarihi 30.07.2001 günü itibarıyla B.K. 60. maddesi uyarınca davanın bir yıllık zamanaşımı süresi içerisinde açılmadığı, **daha önce şikayette bulunulmaması nedeniyle, ceza zamanaşımını süresinin uygulanamayacağı**, eserin eski hale getirilmesinin fahiş zarar doğuracağını, yıkımın davacıya bir yarar sağlamayacağı gerekçeyle, manevi tazminat isteminin zamanaşımı, men'i müdahale, eski hale

getirme kal isteminin, inşaatın yıkımının fahiş zarar doğuracağından davanın reddine karar verilmiştir.

Karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.

Dava, 5846 sayılı FSEK'ten kaynaklanan tecavüzün önlenmesi, inşaatın projesine uygun hale getirilmesi, yapılan ilavelerin kal'i ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Davacı vekilleri tarafından, müvekkiline ait mimari projenin, davalılar tarafından tadilat projesi ile bütünlüğünün bozulduğunun, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16. maddesi hükmü gereğince eser sahibi müvekkilinden izin alınmaksızın proje üzerinde değişiklik yapılamayacağı ileri sürülmüş, bir kısım davalılar vekillerince, tadilat projesinin bizzat davacı tarafça hazırlandığı, hazırlanan tadilat projesinin müvekkillerinden E... ve Dekoratif Ürünleri Tic. A.Ş.'ye verilmediği için yeniden hazırlattırıldığı savunulmuş, Mahkemece yazılı gerekçelerle davanın reddine karar verilmiştir.

Oysa, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca, eser sahibinin izni olmadıkça eserde değişiklik yapılması olanaklı değildir. Ancak, Mahkemece yapılan keşif sonucu, **davacı şirketin; onaylı tadilat projesi almadan, onaylı kendi projesinin şeklini, boyutlarını, görünümünü değiştirerek inşaatın bodrum ve zemin katında uygulama yaptığı, bilirkişi raporu ile belirlenmiş olup**, esasen bu husus Belediye tarafından da 27.10.1998 tarihli tespit de tutanak altına alınmıştır.

MK'nın 2. maddesine göre, herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz.

O halde, **davacı şirketin yukarıdaki açıklamalar ışığında MK'nın 2. maddesine aykırı davrandığının** ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 16/2. maddesi uyarınca, zaruri görülen değiştirmelerin eser sahibinin izni olmaksızın da yapılabileceğinin **kabulü gerekir**.

Bu durumda, mahkemece, davanın açıklanan gerekçelerde reddi gerekirken, esasa ilişkin yazılı gerekçelerle reddi yerinde değil ise de, sonucu itibarıyla doğru olan hükmün onanmasına karar vermek gerekmiştir.

56. (11. HD., 2.12.2004 , E. 2004/2662, K. 2004/11862)

Davacılar vekili, davalı tarafın müvekkili GESAM üyesi heykel sanatçısı M.T.'nin eseri Atatürk portre rölyefini alçı döküm aslından kopya-

lama, küçültme ile kristal cam olarak işleme suretiyle imal ederek, muhtelif ebatta biblo olarak çoğaltıp piyasaya sunduklarını, eser sahibinin izni olmaksızın eserin kullanımı ve piyasa sunumunun sanatçının haklarını ihlâl ettiğini ileri sürerek, şimdilik 2.000.000.000.-TL maddi, 2.000.000.000.-TL manevi olmak üzere toplam 4.000.000.000.-TL.sının faiziyle davalılardan tahsilini talep ve dava etmiştir.

Davalı şirket vekili, dava ve talep haklarının zamanaşımına uğradığını, davaya konu Atatürk portresinin kamuya mal olduğunu, davacıya ait olduğu yolunda bir delil bulunmadığını savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kabulü ile 2.000.000.000.-TL manevi tazminatın davacı M.T., 2.000.000.000.-TL mali hak bedeli olan maddi tazminatın davacı Meslek Birliği için olmak üzere davalı şirketten tahsili ile davacılara verilmesine, tazminatlara temerrüt tarihi olan 19.07.1996 tarihinden itibaren değişen oranlardaki reeskont faizinin uygulanmasına Meslek Birliği'nin manevi tazminat isteminin reddine, davalı A.K. hakkındaki dava atıye bırakılmış olduğundan bu davalı hakkında hüküm tesisine yer olmadığına karar verilmiştir.

Kararı, davalı G.. Kristal Eşya San. ve Tic. A.Ş. vekili temyiz etmiştir.

1- Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre mümeyiz davalı vekilinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2- Ancak, eser sahibinin mali haklarına tecavüz hususuna ilişkin yasal düzenlemeyi içeren 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 68/1. maddesinde, izni alınmamış eser sahibinin sözleşme yapılmış olması halinde isteyebileceği bedelin veya emsal veya rayiç bedel itibarıyla uğradığı zararın en çok üç kat fazlasını isteyebileceği, bu bedelin tespitinde öncelikle ilgili meslek birliklerinin görüşünün esas alınacağı belirtilmiştir.

Somut davada Mahkemece, rapordaki miktarın davacının talebi ile kıyaslanmak suretiyle kabulüne karar verilmişse de, rapordaki rayiç bedele ilişkin belirlemenin dayandığı verilerin raporda açık olarak gösterilmediği, tartışılmadığı, bu şekilde varılan sonucun Yargıtay denetimine elverişli olmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca, bilirkişi raporunda telif ve çoğaltma hakkı-

nın gerekçesi gösterilmeden rapor tarihine göre belirlenmiş olması da doğru olmamıştır. Buna göre **Mahkemece eser sahibinin tecavüze konu mali haklarının tayin ve tespitinde yukarıda açıklanan FSEK'nun 68. maddesindeki hususlar göz önüne alınarak, somut verilere dayalı ve denetime elverişli bir rapor alınarak sonucuna göre, davacıların talebinin değerlendirilmesi gerekirken, rapordaki miktarın davacının talebini karşıladığı gerekçesiyle, yazılı şekilde eksik incelemeye dayalı olarak karar verilmesi doğru görülmemiş, kararın bu yönden mümeyiz davalı yararına bozulması gerekmiştir.**

3- Kabul şekline göre de; Mahkemece hüküm altına alınan miktarlara “19.07.1996 tarihinden itibaren değişen oranlarda reeskont faizi uygulanmasına” karar verilmişse de, 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Yasa'da 01.01.2000 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 4489 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesinde yasal faiz ve reeskont faizi ayrımının mevcut olması nedeniyle davacıların “kanuni faiz” yönünde talepte bulunmalarına rağmen, hükmolunan maddi ve manevi tazminatların HUMK'un 74. maddesine aykırı olarak talebi aşar şekilde “re-eskont faiziyle tahsiline” karar verilmesi doğru görülmemiş olup kararın bu nedenle de mümeyiz davalı yararına bozulması gerekmiştir.

57. (T.C Ankara Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 08.12.2004, E. 2004/111, K. 2004/338)

Davacı vekili, müvekkili Prof. Yaşar M.H.'in uluslar arası düzeyde bir çok ödül kazanmış ve tanınan bir mimar olduğunu, 1964 yılında dava konusu Ankara Stad oteli için açılan proje yarışmasına müvekkilinin S... Kolektif Şirketi mimarları olarak dava dışı D.T. ve S.S. ile birlikte katıldıklarını ve yaptıkları projenin birinci olduğunu, daha sonra otel yapımı aşamasında şirketin tasfiye ve devirler ile Stad Otel Projesine ait hakların müvekkiline bırakıldığını ve “*projenin ikmal ve inşaatının mesleki kontrollüğü ve iç mimari/dekorasyon projeleri tanzim ve kontrolü*”nün de müvekkilinin yapım ve uhdesine verilmesi sonucunda otelin tamamlanarak 1970’de hizmete girdiğini belirtmiştir.

Davacı vekili, müvekkilinin Otelde 1996 yılında yapılan bir tadilat için icazet verdiğini, bilahare 2002 yılında da otelde tadilat yapılacağını Basın’dan öğrendiğini, geçmiş yıllarda yapılanlar da dahil izinsiz olarak yapılan tadilatların Ankara 4. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2002/319 D. İş sayılı dosyadaki 25.12.2002 tarihli bilirkişi raporunda belirlendiğini, ya-

pılan ve yapılacak işlerin basit bir onarımın ötesinde tamamen projede değişiklik ve ilaveler içerdiği, tespit edilen ilave ile orijinal proje ve inşaatın bedii vasfının tecavüze uğrayıp , 1600 m2 aşkın ilave yapıldığını, şimdi ise otelin işletmesinin Radisson Sas firmasına verilerek 5 yıldızlı otele dönüştürülmek üzere konferans, lokanta, kahvaltı, kafeterya, balo salonu ve sauna, jimnastik salonu gibi ek bölümler yapılacağını, mal sahibinin bu değişiklikler için müvekkilinden izin istemediğini, oysa bu değişikliklerin mimari eserde bütünlüğü, eser sahibinin hususiyet ve üslubunu bozucu tecavüzler olduğunu, bina içinde de yıkım ve duvar örmeler olduğunu ve esas projeye uymayan taşkın inşaat yapıldığını öne sürmüştür.

Davacı vekili, muhtelif orijinal projeye yapılan tadilat alanları toplamının 5480.21 m² olduğunu bilirkişi raporunda ayrıntılı olarak açıklanan bu izinsiz değişikliklerin eser sahibi müvekkilinin mali manevi hakların ihlal ettiğini, otel avan projesinde müvekkilinin diğer mimarlarla beraber birlikte 1/3 oranında eser sahibi olduğunu, daha sonraki tasfiye nedeniyle bizzat yürüttüğünü tatbikat projesi ve iç mimari ve tefrişle ile ilgili uygulama projelerinin ise tek başına eser sahibi olduğunu ifade etmiştir. Mevcut yapının yeni projelerle değiştirilmesinin fikri hukuka işleme anlamına geldiğini ve bu hakkın müvekkiline ait mali hak olduğunu ve otelin 5 yıldızlı konuma getirilmesi için müvekkilinin izni dışında başka mimarlarca yapılan projeler ile gerçekleştirilen eklenti ve değişikliklerin FSEK 21. maddesindeki işleme hakkının ihlali olduğunu, zira yapılan 20.000 m2 civarında ekleme ve değişikliğin sonucu otelin aslı muhafaza edilmekle birlikte orijinal halinin değişmiş olacağını, sonuçta mutlaka işleme eser oluşması gerektiğini, dava konusu mimari eserin estetik ve özgün niteliği itibarıyla güzel sanat eseri niteliğinde olduğundan yapılan değişikliklerin FSEK 16. maddesindeki manevi hak ihlali oluşturduğunu, aynı hususların otelin iç mekan düzenlemeleri için de geçerli olduğunu bu bakımdan; FSEK 68 ve 70/3 maddelerine göre şimdilik 300.000.000.000.- TL mali haklar tazminatının ve 70/1 'e göre de 100.000.000.000.- TL manevi haklar tazminatının olay tarihinden itibaren reeskont faiziyle davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı vekili, davacının tek başına dava açamayacağını, davaya dayanak alınan delil tespiti raporunun usulsüz olup, özensiz hazırlandığını, maddi hatalar içerdiğini, Stad Oteli binasının estetik ve bedii vasfı olmadığından güzel sanat eseri sayılmayacağını, proje müelliflerinin mesleki hataları ve eksiklikleri nedeniyle yangın merdiveninin ve jeneratörün bulunmadığını, binanın fonksiyonel ihtiyaçlarından dolayı izin alınmasının

gerekmediğini, statik, tesisat ve elektrik projelerinin FSEK kapsamında koruma altında olmadığını, yine otelin iç sabit ve hareketli dekorasyonunun da güzel sanat eseri olamayacağını, zamanla eskiyen mobilyanın ve değişen otelcilik kavramının gereklerine uygun değişikliklerin yapılmasının doğal olduğunu, işleme hakkı ihlalinin söz konusu olmayacağını, tüm tadilatlarının onaylı projeler kapsamında gerçekleştirdiğini, otelin 5 yıldızlı otele dönüştürülmesinin söz konusu olmadığını, önceden olduğu gibi Türkiye standartlarına göre 4 yıldızlı olmaya devam edeceğini, mevcut yapının aynen muhafaza edildiğini, ilave inşaat yapılmasının olanaksız olduğunu, otelde tadilat yapılmadığını, Otelin yapısının buna uygun olmadığını, Otel ve restoran bloğunda tamir ve yenileme çalışmalarının toplam 15.800 m² yerde çalışmayı gerektirdiğini, bilirkişi tespit raporunda 20.063.25 m²'lik ek inşaat ve tadilatın yapılmadığını, davacının mali ve manevi hakları ihlal edilmediğinden davanın reddini savunmuştur.

... **Bilirkişi heyeti** tarafından düzenlenen 24.09.2004 tarihli **raporda**; Stad Otel binasına ait proje (avan proje) müelliflerinden birisinin de davacı olduğu, binanın bu projeye göre inşa edildiği, **avan projenin sahibinin hususiyetini taşıyan bir fikri ürün olduğunu**, ancak mimari yapının projesi her ne kadar ödül kazanmış ise de, binanın yapıldığı dönem koşullarında teknik anlamda özgün bir çalışma olmakla beraber fonksiyonelliği ön planda olan ancak estetik niteliği olmayan **bir yapı olmasından dolayı binanın fiziki varlığının güzel sanat eseri olmadığını** belirmişlerdir.

Bilirkişi heyeti raporlarında devamla, **dava konusu olayda proje ve bina üzerinde yapılan değişikliklerin işleme olmadığı, proje müellifinin güzel sanat eseri niteliği olmayan bir yapıda fikri hakkı olamayacağını**, ancak projenin yeni bir binada kullanılmasını önleyebileceğini; sonradan yapı üzerinde gerçekleştirilecek değişikliklere FSEK 16. maddesi ile getirilen düzenlemeler dışında müdahale edemeyeceğini; **dava konusu yapıda davalının mimari eser vasfı bulunmayan binanın fiziki varlığı üzerinde değişiklik yaptığını; mülkiyet hakkına dayanılarak ihtiyac nedeniyle yapılan değişikliklerin koruma dışı olduğunu**; kaldı ki **davalının maliki bulunduğu binada gerçekleştirdiği değişikliklerin hic birisinin eser sahibi davacının şeref ve haysiyet zedeleyecek veya projenin nitelik ve özelliğini bozacak nitelikte olmadığını**; sonuç olarak, binadaki değişikliklerin haklı nedene dayandığı ve davacının FSEK kapsamında ihlal edilmiş mali ve manevi haklarının bulunmadığı mütalaa edilmiştir.

Mahkememizce yapılan incelemede; öncelikle davacı mimari (avan) projenin müelliflerinden birisi olduğundan FSEK 10. maddesi anlamında birlikte eser sahiplerinden birisi olduğundan mahkememizdeki bu davada davacı sıfatı bulunmaktadır. Bu yöne ilişkin davalı savunması yerinde görülmemiştir.

Davacının da eser sahibi olduğu avan proje ve bu projenin uygulanması sonucu inşa edilen Stad Oteli binasındaki izinsiz olarak yapılan değişikliklerin FSEK kapsamında mali ve manevi hak oluşturup oluşturmaya-acağı hususuna gelince;

1. FSEK’na göre “ilim eseri” olan avan proje, aynı zamanda “mimarlık eseri” olabilir mi ?

Dava konusu projenin FSEK 2/3. maddesi kapsamında bir ilim eseri olduğu tartışmasızdır. Ancak, FSEK 4/3 maddesi kapsamında mimari eser sayılıp sayılmayacağı hususunun da belirlenmesi gerekir. Çünkü, **bedii vasfı bulunmayan projeler FSEK 2/3. maddesine göre ilim eseri olmakla beraber, şayet estetik değere sahip bir avan proje ise FSEK 4/3. maddesine göre hem bu proje ve hem de projenin uygulanması sonucu ortaya çıkan yapı güzel sanat eseri olarak korunabilecektir.**

Mimarlık hizmetlerini sırasıyla avan (ön) proje, kesin proje, uygulama detay projeleri, yapı maliyeti, ihale dosyasının düzenlenmesi, yapının mesleki ve teknik denetim ve yönetimi oluşturur. Bu ***hizmetlerin en önemlisi, eserin orijinalliğinin ve mimari niteliklerinin kaynakları, sanatsal değerinin ve sanat anlayışının belgesi olan avan projedir.*** Çünkü mimarın form, dizayn ve estetik anlayışı avan projede gerçekleşmiştir. ***Bu bakımdan avan proje; mimarın sanat ve teknik karakterini ve yapının bütünlüğünü oluşturan temel öğedir.***

Öğretide, FSEK 4/3. maddesindeki mimarlık eserleri kavramı ile koruma altına alınanın mimari plan, kroki ve maketler değil, doğrudan doğruya mimari yapının kendisi olduğu belirtilmektedir. Ancak, yukarıdaki paragrafta açıkladığı üzere; teknik projelerden ayrık olarak “avan proje”nin de estetik değere sahip olması halinde mimarlık eseri olarak korunması mümkündür. Aksi taktirde, estetik değere sahip bir avan projenin herhangi bir nedenle uygulanamayıp bina yapılamaması halinde, bu projenin sırf uygulanmadığı ve yapı halinde dönüşmediği için güzel sanat eseri sayılamaması gibi bir sonuca ulaşılır ki, bu durum FSEK 4/3. maddesi ile bağdaşmaz.

2. Dava konusu Stad Oteli “projesi” ve “binası” mimarlık (güzel sanat) eseri midir?

Bilirkişi heyeti 24.09.2004 tarihli raporlarında; Stad Oteli proje ve binasının teknik değeri olan, ancak estetik niteliği olmayan, insanda coşku ve hayranlık uyandırmayan bir yapı olduğu, varlığını fonksiyonelliğine borçlu olduğu, nitekim otel binasına yapılan ziyaretlerinin amacının da bir güzel sanat eserinin seyri değil, konaklamak olduğu saptandığından binanın güzel sanat eseri olmadığını belirtmişlerdir.

Her ne kadar bir proje veya yapının güzel sanat eseri sayılıp sayılmayacağı hususu bir uzmanlık konusu ise de, bu değerlendirmenin sadece mimarlık bilimine göre değil, aynı zamanda FSEK kapsamında yasal unsurlar irdelenmek suretiyle hukuk bilimine göre de incelenerek bir sonuca ulaşılması gerekmektedir.

FSEK 1b-a bendinde eserin tanımı yapılmış, 4. maddesinde de güzel sanat eserinin estetik değere sahip olması gerektiği açıklanmıştır. **Bilirkişi heyetinin, binanın insanda coşku ve hayranlık uyandırmaması; fonksiyonelliğinin ön planda olması ve literatürde bu teknik özellikleriyle yer alıp, insanların sadece otel olarak kullanmak amacıyla ziyaret etmeleri nedenleriyle güzel sanat özelliği bulunmadığı görüşüne mahkememizce iştirak edilmemiştir.**

Şöyle ki; dosyaya sunulan yazışma ve belgelerden, dava konusu projenin 1964 yılında yapılan bir yarışmada birincilik ödülünü aldığını ve bu projeye uygun inşaatında 1970 yılında tamamlandığını anlaşılmaktadır.

Öncelikle raporu hazırlayan bilirkişi heyetindeki öğretim üyesi olan mimar bilirkişiler; 1964 yılları koşullarında başkent Ankara’nın en önemli merkezlerinden birisi olan Ulus’a inşa edilecek gökdelen nitelikli önemli bir mimari yapı (otel, restaurant, sinema, çarşı ve yer altı garajında oluşan bir kompleks olup genel olarak STAD OTELİ adıyla anılmaktadır) için açılan ödüllü bir yarışmanın amacını göz önüne almamışlardır. Böyle bir yarışmanın amacı sadece Ankara’ya fonksiyonel ve otel amacına hizmet eden bir bina kazandırmaktan ibaret olamaz. Ulus meydanı – İstasyon ve Çankaya arasında karakteristik bir ortak noktaya inşa edilecek olan yapı için yarışmayı kazanacak olan projenin, her bakımdan binanın yapılacağı Ulus semtinin tarihi ve kültürel dokusuna uygun, aynı zamanda da modern bir başkenti simgeleyen mesajlar içeren farklı ve özgün çalışma olması gerekeceği tartışmasıdır. Aksi taktirde, sadece ticari amacın ön planda olduğu bir bina inşa edilseydi, ödüllü bir yarışmaya ve jüriye gerek kal-

maz; açılacak ihale sonucu en düşük fiyatı veren bir mimarlık firmasına iş bırakılırdı.

Bilirkişi heyetinin binanın coşku verici olmadığı ve sanat olarak ziyaret edilmeyip, sadece otel müşterilerinin geldiği bir yapı olduğuna dair görüşlerinin de; soyut ilkelere uzak ve günümüz değerlerinin etkisi altında yapıldığı anlaşılmaktadır. Stad Oteli'nin hizmete açılmasından sonraki uzunca bir dönemde Ankara'nın en önemli ve görkemli yapılarından birisi olması nedeniyle, Ankara'da yaşayan veya ziyaret eden herkesin Ulus semtindeki diğer tarihi ve turistik yerlerle birlikte Stad Oteli'nin varlığından da haberdar oldukları, uzunca bir süre siyaset ve sanat dünyasından bir çok insanın uğrak yeri olduğu bilinmektedir. Şüphesiz aradan geçen yılların da etkisiyle kentin merkezinin Ulus'tan Kızılay ve daha yukarılara doğru kayması, yapılaşma yoğunluğu ve büyük ve lüks otellerin hizmete girmesi nedeniyle binanın eski cazibesinin yitirmiş olması kaçınılmaz bir sonuçtur.

Ancak, *bir yapının FSEK 4/3. maddesi anlamından güzel sanat eseri olarak kabul edilmesi için mutlaka 2863 sayılı KTVKK hükümlerine göre "tarihi ve kültürel değerdeki korunması gerekli anıt yapı" niteliğinde veya herkesin ziyaret amacıyla gittiği bir yer olması da gerekmemektedir. Aksi, taktirde literatüre geçmeyen, resmi kurumlarca tescil edilmeyen ya da ziyaret için müzelere konulmayan hiçbir çalışmaya FSEK anlamında "güzel sanat eseri" denilmesi mümkün olamayacaktır.*

Bu bakımdan binanın mimari eser niteliğinde olup olmadığı değerlendirilirken proje ve yapının gerçekleştirildiği tarihteki koşullar ve mimari anlayışın göz ardı edilmemesi gerekir. Böylesi önemli bir yapıyla ilgili olarak açılan ödüllü yarışmayı kazanmak için mimarların kalıcı, özgün, estetik ve aynı zamanda da işlevsel, yani güzel sanat eseri niteliğinde bir binanın projesini çizecekleri açıktır. Nitekim dosyadaki binanın dış ve iç cephe resimlerinden ve açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere, projenin aynen uygulanması sonucunda da, örneğin beton güneş kırıcı üç yöne dönük uzay girişler v.b. çizimler kullanılmak suretiyle, estetik bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Esasen bilirkişi raporunda da içerik olarak binanın özgün ve estetik değeri olduğu açıklandığı halde, bu verilere rağmen sonuç olarak binanın güzel sanat eseri olmadığına dair düşüncelerine itibar edilmemiştir.

3. Avan proje uygulanarak ortaya çıkarılan “bina” ; projenin çoğaltılması mıdır? Yoksa bir işleme eser midir?

Dava konusu eserin niteliği bu şekilde belirtildikten sonra diğer uyuşmazlık konularına gelince: Davacı vekili, bir mimari projenin gerçekleştirilmesi, mimari bir yapı haline getirilmesinin esas eser olan “avan proje” ye bağımlı bir uygulama olduğunu, o nedenle her mimari eserin bir anlamda “işleme eser” olduğunu iddia etmekle ve yine bitmiş bir mimari yapıda daha sonra yapılacak yeni ekleme ve değişikliklerin de projenin kısmen işlenmesi sayılacağından mutlaka eser sahibinin iznini gerektirdiğini iddia etmiştir.

Uygulamada ve öğretide kabul edilen görüş, bir projenin mimari yapı haline getirilmesi, eseri “işlemesi” olmayıp FSEK 22. maddesi anlamında “çoğaltmasıdır”. Çünkü, FSEK 6/1. fıkrasına göre; işleminin diğer bir eserden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan nitelikte olması gerekmektedir. Yine aynı maddenin 5. bendine göre de, **güzel sanat eserinin bir şekilde diğer şekillere sokulması işlemidir.** Örneğin; Stad Otelinin boyutlarının aynı ölçeklerde küçültülerek minyatür maketinin yapılması hali eserin işlenmesidir. Böyle bir durumdaki işleme faaliyet; niteliği itibariyle asıl esere tabi olan fakat iktisaden ondan bağımsız olarak değerlendirmeye elverişli yeni bir esere vücut verilmesidir. İşleyen kişi eser sahibi olabileceği gibi bir başkası da olabilir. Eser sahibi dışındaki birisi yapılan böyle bir işleme şahsi kullanma amacını taşıdığı sürece FSEK 38. madde kapsamındadır. Ancak, işleme eser niteliğindeki maketin ticari gaye ile çoğaltılabilmesi için FSEK 21. maddesine göre eser sahibinin izni gerekir.

Bilirkişi heyeti raporunda, projenin yapılıp davalı mal sahibine teslim edilmesi ve uygulanarak yapının tamamlanması sonucunda eser sahibinin, projenin uygulanmasından doğan (yapı üzerindeki) mali haklarının tükendiğini belirtmiştir. Oysa yukarıda açıklandığı gibi, projenin tesliminden ve uygulanarak yapı tamamlandıktan sonra da, eser sahibinin “proje üzerindeki çoğaltma hakkı” ve “güzel sanat eseri niteliğinde olan dava konusu bina üzerindeki işleme hakkı” devam eder. Bilirkişi görüşüne bu bakımdan da katılmak mümkün olmamıştır.

Uyuşmazlığın daha iyi değerlendirilebilmesi için; yaratıcı bir faaliyet sonucu ortaya çıkan “proje” ile; bu projenin çoğaltılması sonucu çıkan “yapı”nın klasik anlamda bir çoğaltma olup olmadığının da saptanması gerekir.

...Mimari projelerin de FSEK 2. maddesindeki diğer eserler gibi kabul edilmesi halinde; tıpkı bir kitabın çoğaltılması durumunda çoğaltılan nüshalar ile asıl eser arasında bir fark olmadığı gibi.; projenin çoğaltılması sonucu ortaya çıkan “yapı” ile “proje” arasında bir fark olmadığı, yapının uygulandığı projenin tıpatıp aynısı olduğu sonucuna varılacaktır. Oysa, FSEK 2/3. maddesi kapsamındaki bir mimari projenin uygulanması sonucu ortaya çıkan yapı; bağlantılı bir çok proje ve unsurlardan oluşan (statik, tesisat, malzeme, inşaat, işçilik, arazi yapısı v.b.) farklı fiziki, teknik ve ustalık gibi özellikleri ve gerektiğinde yapılacak bir takım değişiklikleride içermektedir. Örneğin 100 konutlu bir sitede aynı projenin 100 kez çoğaltılması halinde, her konutta yukarıdaki unsurlar da etken olacağından, bir binanın diğerine, kitap ve fotoğraf nüshaları gibi, tıpatıp benzer olduğu söylenemez. **Bu bakımdan bir projenin uygulanması her zaman klasik anlamda bir çoğaltma kabul edilemez, Bu eylem, çoğaltma ile işleme karışımı ancak karakterinin baskın olduğu bir durumdur.**

Ancak, söz konusu olan proje FSEK 4/3. maddesi kapsamında bir “mimarlık eseri” ise; bu projenin aslına ve tüm özelliklerine sadık kalınarak uygulanması sonucu “yapı”nın meydana getirilmesi hali FSEK 22. maddesi kapsamında yani klasik anlamda bir “çoğaltma” olacaktır.

Bedii vasfı bulunan bir projenin başarısız ve kötü uygulanması sonucu ortaya çıkan yapı güzel sanat eseri vasfına haiz olmayabilir. Böyle bir durumda proje üzerindeki haklar korunduğu halde binanın mimarlık olarak korunması mümkün olmayabilir.

Bedii vasfı bulunmayan bir projenin uygulanması sırasında kullanılan malzeme ve el sanatları gibi projeyi tamamlayıcı unsurlar bir araya gelerek, ortaya çıkan yapının projeden bağımsız FSEK 4/3. maddesi anlamında bir güzel sanat eseri sayılması da mümkündür. Ayrıca hiç projesi olmayan, tamamen kişisel birikim ve beceri ile meydana getirilen yapılarda aynı kapsamda güzel sanat eseri sayılabilir.

Projenin çoğaltılması sonucu çıkan binanın her somut olayda ayrı ayrı değerlendirilmesi, projenin ve binanın hukuki durumlarının FSEK 2/3. ve 4/3. maddelerine göre belirlenmesi ve uyuşmazlıkların bundan sonra çözümü gereklidir.

Şayet mimari proje, bedii vasfı bulunmayan FSEK 2/3. maddesine göre bir ilim eseri niteliğinde ise; eser sahibinin “proje” üzerindeki mali ve manevi hakları korunmakla birlikte; projenin uygulanması sonucu ortaya çıkan “bina” yukarıdaki paragrafta yazılı diğer estetik un-

surları da içermiyorsa, FSEK 4/3. maddesine göre mimarlık eserlerinden sayılamayacağından; projeyi çizen mimarın klasik anlamda çoğaltma sayılamayan “bina” üzerinde telif hakkının bulunduğu kabul edilmeyecektir. Böyle bir “binada orijinal projeye aykırılık” hallerinin ise İmar Yasası ve ile ilgili özel düzenlemeler ile önlenmesi gerekecektir.

Dava konusu olayda olduğu gibi, hem mimari (avan) “proje”, hem de bu projenin uygulanması sonucu ortaya çıkan “yapı”nın FSEK 4/3. maddesi kapsamında “mimarlık eseri” olması durumunda “klasik anlamda bir çoğaltma” mevcuttur. Hem “proje” hem de “yapı” gerektiğinde güzel sanat eseri olarak birbirinden bağımsız olarak korunabilmesine rağmen, her ikisinin de bir mimarlık eserindeki buluşmasının; “proje” ve “uygulanması”ndan oluşan bir bütünün tamamlayıcı parçalarını oluşturmaları söz konusudur. Dolayısıyla mimari eser niteliğindeki bir binada “yapı üzerindeki projeye aykırı” değişikliklere karşın FSEK hükümleri uyarınca dava açmak mümkündür.

Bu bakımdan, Mahkememizce, dava konusu olayda FSEK 4/3. maddesine göre mimari eser olan avan projenin uygulanması sonucu, aynı nitelikteki mimari yapının tamamlanması eylemi FSEK 22. madde kapsamında bir “çoğaltma” olarak kabul edilmiş ve davacının Stad Oteli binasındaki değişikliklerden dolayı mali ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasıyla dava açmakta hukuki yararı bulunduğu kanısına varılmıştır.

4. Mimari eser niteliğindeki proje ve yapı’daki tadilat ve değişiklikler yeni bir işleme eser olabilir mi?

Davacı vekili somut olayda ayrıca; mimari eserde yapılan değişiklikler sonucunda, asıl eserin varlığının muhafaza edildiğini, fakat yeni bir mimari eser meydana getirildiğini öne sürerek bu yolla işleme hakkının ihlal edildiğini de öne sürmüştür. Günümüzde bir örneği kolayca bulunamamakla birlikte, gerçekten güzel sanat eseri olan bir yapının birtakım değişiklikler yoluyla işlenmesi suretiyle yeni bir işleme eser meydana getirilmesi mümkündür. Buna geçmişten bir örnek verilmek gerekirse; Bizans döneminde bir kilise olarak inşa edilen ve güzel sanat eseri niteliği tartışmasız olan Ayasofya’nın, İstanbul’un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet’in emri ile yapılan değişiklikler sonucu camiye dönüştürülmesidir. Bina Osmanlı dönemindeki Padişah ve sadrazamlar dönemlerinde de muhtelif değişikliklere uğramıştır. Bunlardan birisi de Mimar Sinan tarafından yapılan minareler ve daha sonra eklenen medresedir. Halen müze

olan kullanılan aynı bina Ayasofya Cami olarak da bir sanat şaheseridir. Anılan değişiklikler sonucunda ilk Ayasofya kilisesinden istifade suretiyle vücuda getirilip de bu esere nispetle müstakil olmayan nitelikte bir “işleme eser” yaratılmıştır. Çünkü, gerek “kilise” ve gerekse “cami” olarak birbirlerinden karakteristik özelliklerini bozmadan ve mimarlarının özgün ve yaratıcı anlayış ve estetik üsluplarını “aynı yapıda” ve fakat “ayrı ayrı” taşımaya devam etmektedirler.

Somut olaya geldiğimizde ise, Bilirkişi raporunda davalı tarafından yapılan değişikliklerin nelerden ibaret oldukları açıklandıktan sonra; bu değişikliklerin ihtiyaçtan kaynaklanan zorunlu değişiklikler olduğu ve eserin bütünlüğünü bozucu nitelikte olmadığı belirtilmiştir. Bu durumda imar mevzuatına göre gerekli izinler alınmak suretiyle gerçekleştirilen söz konusu tadilat projenin ve binanın içinde ve dışında birbirinden kopuk halde muhtelif yerlerindeki değişikliklerin özgün bir mimari üslup taşıdığını ve aynı binada hem asıl eser hem de işleme eserin bir arada, fakat farklı karakterleri yansıttıklarını söylemek, bilirkişi raporuna göre olanaksızdır. Bu bakımından da davacının işleme hakkının (ihlal) edildiği iddiası kabul edilmemiştir.

5. Eser sahibinin manevi hakkı (eserde değişiklik yapılmasını men etmek) ihlal edilmiş midir?

Dava konusu olayda davacının mali haklarının ihlal edilmediği sonucuna varıldıktan sonra, FSEK 16. maddesine göre manevi hakkının ihlal edilip edilmediğinin de tartışılması gerekmektedir.

Davacının eser sahibi olduğu Stad Otel’ndeki proje ve binadaki değişikliklerin FSEK 16. maddesine göre, eserin mahiyet ve hususiyetlerini bozucu eser sahibinin şeref ve itibarını zedeleyici nitelikte olmaması gerekir. Mimari eserin estetik işlevsel (fonksiyonel) olması gereği nedeniyle, değişikliklerin yapının mimarlık anlayışı ve estetik üslubunu bozup bozmadığına bakılması gerekir. Dava konusu projenin uygulandığı yapının bir “otel” olması nedeniyle, aradan geçen yaklaşık 30 yıllık süre itibarıyla; günün değişen koşulları ve gereksinimlerine cevap verebilmek için, kullanım amacına dayalı yenilenmesiyle genişletilmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Mimari yapıda, “yapı maliki” tarafından, Anayasa ve Medeni Yasa hükümlerine göre korunan, mülkiyet hakkı kullanırken, eser sahibinin mali ve manevi hakları ihlal edilmemek kaydıyla, zorunlu değişiklikler her zaman yaptırılabilir. Bu değişikliklerin mutlaka eser sahibi tarafından veya onun izni ile yapılabileceğini kabulü, yapı ma-

likinin anayasal güvence altındaki mülkiyet hakkına ağır bir müdahale oluşturur.

Bu bağlamda, güzel sanat eseri niteliğindeki bir “yapının malikinin mülkiyet hakkından doğan tasarruf yetkisinin” sınırını da FSEK’ndaki “eser sahibinin mali ve manevi hakları” oluşturulmaktadır. Başka bir deyişle, yapı maliki güzel sanat eseri olan binasında, kullanımdan kaynaklanan ihtiyaçları nedeniyle, dilediği zaman tadilat yaptırabilir. Ancak, örneğin eserin bütünlüğünü bozamaz veya projeden istifade suretiyle FSEK 6. maddesi anlamında bu esere nispetle müstakil olmayan işleme eser (yeni bir proje) meydana getiremez veya aralarında özel bir sözleşme olmadığı taktirde projeyi izinsiz olarak çoğaltarak yeni bir yapı daha meydana getiremez. Aksi taktirde eser sahibinin FSEK’ndan doğan haklarını ihlal etmiş olacaktır.

Dava konusu yapının otel olması nedeniyle; binanın sağlamlığı, emniyetinin sağlanması yanında binanın **kullanım alanını büyütme ve genişletmek için** de zorunlu tadilat ve değişiklikler yapılabilir. Aksi taktirde, otel olarak inşa edilmiş olan bir yapının değişen konfor ve hizmet ihtiyaçlarına cevap vermesi ve kullanımı olanaksız hale gelir. **Asıl olan** bu değişiklikleri içeren **tadilat projesi ve uygulanmasının eserin bütünlüğünü bozmamasıdır.** Bilirkişi raporunda, bu değişiklikler teker teker değerlendirilirken; ihtiyaçtan kaynaklandığı, proje ve binanın bütünlüğüne bir zarar vermediği, eser sahibinin şeref ve haysiyetini zedelediği mütalaa edilmiştir.

Bilirkişi mütalaasının teknik değerlendirmeye yönelik olan bu bölümdeki açıklamaları Mahkememizce de kabul edildiğinden; sonuç olarak davacının mali ve manevi haklarının ihlal edilmediği kanaatine varılmak suretiyle davanın reddine karar verilmesi gerekmiştir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle; Davanın reddine, ... (karar verilmiştir.)

58. (11. HD., 21.12.2004, E. 2004/2772, K. 2004/12672)

Davacı, kendisinin çizmiş olduğu Osmaniye İli’nin haritasını davalı Belediyenin izinsiz olarak çoğaltıp ücretli ve ücretsiz olarak dağıttığını, bu şekilde haklarına tecavüz edildiğini ileri sürerek, tecavüz ref’i ve müdahalenin önlenmesine, 2.000.000.000.- TL maddi ve 4.000.000.000.-TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, haritanın davacının kendi ürünü olmadığını, Adana haritalarından elde edildiğini savunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve benimsenen bilirkişi raporlarına göre davalının eyleminin 5846 sayılı FSEK. Kapsamında haklarına saldırı oluşturduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne, teca-vüzün önlenmesine ve 1.500.000.000.-TL maddi ve 500.000.000.-TL ma-nevi tazminatın davalıdan tahsiline karar verilmiştir.

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

1- Dava, 5846 sayılı FSEK. Kapsamında müdahalenin önlenmesi ve maddi ve manevi tazminatın istemine ilişkindir.

Mahkemece, tazminat istemi bakımından kısmen olmak üzere davanın kabulüne karar verilmiş ise de yapılan bilirkişi incelemeleri uyuşmaz-lığın çözümü için yeterli değildir. Delil tespitine ilişkin dosyada harita mühendisinden **alınan raporda, sadece her iki haritanın aynı olmadığını irdelemiş, özgün bir eser olup olmadığına hiç değinilmemiştir. Yargılama sırasında mahkemece alınan raporu düzenleyen bilirkişi-lerden hiçbir harita mühendisi olmayıp, bu raporda dava konusu haritanın sahibinin özelliklerini yansıtan özgür bir eser olduğunu be-lirtilirken, soyut olarak belirtilmiş ise de saptamanın kabul edilebilir dayanaklarını göstermemiştir.**

Bilirkişilerce raporda, zorunlu benzerlik olacağından, bağımsız bir çalışma ve emek unsurunun varlığı halinde özgünlüğün kabulü gerektiği belirtildikten sonra, soyut olarak davacının bu bağımsız çalışmayı yaptığı kabul edilerek, kopyalanmak suretiyle esere saldırının varlığından söz edilmiş ise de bu bağımsız emek unsurunun neler olduğu açıklanmamıştır. Mahkemece de bu rapora göre davanın kabulüne karar verilmiştir.

Anılan Yasa'nın 2/3. maddesinden her nevi haritanın eser niteliğinde olduğu anlamı çıkıyor ise de, Yasanın korunmasından yararlanacak bir eser olup olmadığı, bu hükmün 1/B maddesi hükmüyle birlikte değerlendirilerek "sahibinin özelliklerini taşıyıp taşımadığının tespitine bağlı"dır.

Bu durumda, **Mahkemece aralarında haritacılık konusunda uzman bir bilirkişinin de bulunduğu yeni bir bilirkişi kurulu oluşturula-rak, bir haritanın nasıl meydana getirildiği, dava konusu haritanın sahibinin özelliklerini yansıtıp yansıtmadığı, yansıtıyor ise bunları neler olduğu hususunda rapor alınmak, gerektiğinde dava konusu haritanın nasıl meydana getirildiği yolunda davacının da beyanına başvurulmak suretiyle, sonucuna göre bir hüküm kurulmak gerekir-**

ken, yetersiz bilirkişi raporuna dayalı olarak, yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmamıştır.

2- Yukarıda açıklanan bozma neden ve şekline göre, davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik gerek görülmemiştir.

59. (11. HD., 28.3.2005, E. 2004/1641, K. 2005/2862)

Davacılar vekili, müvekkillerinin murisi A.D.ye ait “Bugün ...” adlı eserin davalılar tarafından izinsiz bir şekilde ve eserin müzik formu ve metnini değiştirmek suretiyle kaset ve CD yapılarak piyasaya sürüldüğünü, televizyon ve radyolar ile konserlerde kullanıldığını ileri sürerek, davalılardan şimdilik 3.000.000.000 TL: maddi 1.120.000.000 TL. manevi tazminatın temerrüt faiziyle birlikte tahsilini, davalıların fiilinin önlenmesini, hüküm özetinin ilanını talep ve dava etmiştir.

Davalı İ.T. vekili ile ... Müzik Yapım A.Ş vekili davanın reddini savunmuş, diğer davalı duruşmalara katılmamış ve savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, davanın FSEK ile ilgili olduğu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 15.10.2003 tarih ve 436 sayılı kararı ile Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin faaliyete geçtiği gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine, talep halinde dosyanın görevli ve yetkili Ankara Fikir ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verilmiştir.

Kararı, davalı İ.T. vekili temyiz etmiştir.

Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillere gerektirici sebeplere ve **görevin kamu düzenine ilişkin olup, davanın her aşamasında nazara alınması gerekmesine** göre, mümeyyiz davalı vekilinin yerinde bulunmayan tüm temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

60. (11. HD., 4.4.2005, E. 2004/6683, K. 2005/3135)

Davacılar vekili, 5846 sayılı Kanundaki düzenleme nedeniyle davalı Meslek Birliği ile TÜROB arasında, otellerden mekanik ve canlı müzik kullanmasına yönelik telif bedellerine ilişkin olarak protokol düzenlendiğini, müvekkillerinin de meslek birlikleri ile görüşmeler yaptığını ancak taleplerin yasaya aykırı hükümler içermesi nedeniyle görüşmelerin sona erdirildiğini, Meslek Birliğinin tip sözleşmesinin tamamen davalı lehine olup, hakkaniyete uygun bir telif bedeli ödemek isteyen müvekkillerini güç durumda bıraktığını, davalının haklarının sınırlarının tespiti gerekti-

ğini ileri sürerek, bu dava ile davalının üyelerinin kimler olduğunun ve hangi üyenin hangi icraları bakımından davalıya yazılı mali hak yetki belgesi verdiğinin tespitini, telif ücreti ödenmesini isteme hakkı bulunup bulunmadığının tespitini, umumi mahallerle kullanım bandrolünün Kültür Bakanlığı tarafından çıkarılana kadar kaset ve CD dinletimi nedeniyle ücret ödemesini talep hakkı olmadığının tespitini, otellerdeki radyo ve TV yayınlarının izlenmesi halinde FSEK 25. maddeye göre ücret ödemesini talep hakkı olmadığının, böyle bir talebin mükerrer tahsilat teşkil edeceğinin tespitini ve davalının talep haklarının tespiti ile hakkın ve hakim durumun kötüye kullanılması sureti ile rekabeti bozucu şartları oluşturmamasını engellemesi suretiyle ile çekişmenin giderilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili, davacıların müvekkili Birliğin yetki belgesine sahip olduğu icracı sanatçıların mali hak bedellerini ödemediğini, bu bedeli talep haklarının Yasadan kaynaklandığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Mahkemece iddia, savunma ve dosyadaki belgelere göre; **davacıların tespitini talep ettikleri hususların derhal tespiti gereken hususlardan olmadığı, bunların açılacak bir eda davasında incelenecek ve değerlendirilecek konulardan olduğu, ayrıca davalının üyelerinin zaman içinde değişebileceği, değişen eserler için de yetki verildiği, eda davasına konu olabilecek hususların tespit davası ile mahkemeye getirilmesinin yerinde olmadığı** gerekçesiyle, koşulları oluşmayan davanın reddine karar verilmiştir.

Kararı davacılar vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasa aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacılar vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

61. (11. HD., 22.12.2005, E. 2004/14950 K. 2005/12769)

5846 sayılı FSEK'nın 63. maddesi gereğince, bu Kanun ile tanınan mali haklar miras yolu ile intikal eder. Eser sahibinin aynı Kanun'dan doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılara intikal etmekle birlikte, eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek olanlar ; tayin edilmişse vasiyeti tenfiz memuru, tayin edilmemişse sağ kalan eşi, çocukları, mansup mirasçıları ana babası ve kardeşidir.

Görülen davada, işleme eser sahibinin mirasçısı olan davacıların isteminin, eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK'in 14/1. maddesi yoluyla aynı Yasa 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduğuna göre, FSEK'in 19/1. maddesi uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olamayacağından dolayı istem reddedilmiştir. (5846 s.FSEK m. 14, 15, 16, 19, 63, 70)

Taraflar arasında görülen davada (İstanbul Birinci Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi)'nce verilen 18.03.2004 tarih ve 2001/1251-2004/131 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı Abdullatif vekili tarafından istenmiş olmakla, dava dosyası için tetkik hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacılar vekili, davalı şirkete ait B.....Yayınları'nın çevirmeni olan müvekkillerinin (çevirisini yaptığı) Thomas'a ait "K....." isimli eseri (çevirmen eser sahibinin) murisi Behzat'ın ... izni ve bilgisi dışında yayımlandığını, bu suretle davalıların müvekkillerinin mali ve manevi haklarına haksız olarak tecavüze bulunduklarını ileri sürerek, ... eser sözleşmesi yapılmış olması halinde istenecek bedel olan 2.000.000.000.-TL sınırı FSEK'in 68. maddesi uyarınca üç katı olan 6.000.000.000.-TL ile manevi zarar karşılığı olarak 4.000.000.000.-TL sınırı faizleriyle birlikte davalılardan tahsiline, verilecek kararın gazetede ilanına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Abdullatif vekili, müvekkilinin ve diğer davalıların davaya konu eseri yeniden yayınlarken eser üzerinde her hangi bir değişiklikte bulunmadıklarını, çevirmenin ismini ilk baskıda olduğu gibi aynen belirttiklerini, bu durumda davacıların manevi zarara uğradıkları iddiasının yerinde bulunmadığını, davacıların maddi tazminat taleplerinin de kabulünün mümkün bulunmadığını, çünkü 1000 adet basılan eserin ancak 300 adedinin piyasaya sürüldüğünü, müvekkilinin bu eserden dolayı bir kazanç sağlamadığını savunarak davanın reddini istemiştir.

Diğer davalılar, davaya yanıt vermemişlerdir.

Mahkemece, iddia, savunma, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre, davanın kısmen kabulü ile 2.000.000.000.-TL manevi tazminat ile 888.960.000.-TL maddi tazminatın dava tarihinden itibaren yasal faiziyle birlikte davalılardan tahsiline, fazla istemlerin reddine, hüküm kesinleştiğinde masrafları davalılardan alınmak üzere Türkiye genelinde yayın

yapan tirajı en yüksek üç gazeteden birinde bir kez yayınlanmasına karar verilmiştir.

Kararı, davalı Abdullatif vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, Mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, mümeyyiz davalı vekilinin aşağıda (2) nolu bendin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-5846 sayılı FSEK'nun 63. maddesine göre, bu Kanun'un tanıdığı mali haklar miras yolu ile intikal eder. Eser sahibinin aynı Yasa'da doğan manevi hakları ise ölümü halinde mirasçılara intikal etmezler. Ancak, eser sahibinin ölümünden sonra manevi hakları kullanabilecek kimseler FSEK'nun 19. maddesinde belirtilmiştir. FSEK'in 19/1. maddesine göre, eser sahibi 14/1 ve 15/1. maddesi ile tanınan yetkilerinin kullanış tarzını tespit etmemişse yahut bu hususu herhangi bir kimseye bırakmamışsa; bu yetkilerin ölümünden sonra kullanılması, vasiyeti tenfiz memuruna, bu tayin edilmemişse sırasıyla sağ kalan eşi ile çocuklarına ve mansup mirasçılara, ana babasına, kardeşlerine aittir.

Aynı Yasa'nın 19/2. maddesine göre de, eser sahibinin ölümünden sonra yukarıdaki fıkrada sayılan kimseler; eser sahibine 14,15 ve 16. maddelerin üçüncü fıkralarında tanınan hakları eser sahibinin ölümünden itibaren 70 yıl kendi namlarına kullanabilirler.

Davacılar da, işleme eser sahibi olan miras bırakanın eşi ve çocuğu olup, 19. maddeye göre manevi hakları kullanabilecek kişilerdir.

Dava konusu uyuşmazlıkta çözümlenmesi gereken husus, işleme eser sahibinin ölümünden sonra bu eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arz edilmesi nedeniyle FSEK'in 14/1. fıkrası yoluyla aynı Yasanın 70/1. maddesine göre davacı mirasçıların manevi hak tazminatı isteyip istemeyeceklerine ilişkindir. Bunun dışında, miras bırakana ait işleme eserin izinsiz olarak umuma arz edilmesinin ve yayımlanma tarzının ayrıca onun şeref ve haysiyetini zedeleyecek mahiyette olduğu yani FSEK'in 14/3. maddesinin de ihlal edildiği hakkında bir iddia ve taraflar arasında uyuşmazlık mevcut değildir.

O halde, öncelikle FSEK'in 19. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının mirasçılara sağladığı hak ve yetkilerinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

5846 sayılı FSEK'in 19. maddesinin düzenleme biçimi göz önüne alındığından, anılan maddenin birinci fıkrasında; yukarıda sayılan kişilere "sırasıyla" FSEK'in 14/1 ve 15/1. maddelerinde düzenlenen manevi hakların "kullanım tarzını tespit etme yetkisinin" verildiği, ikinci fıkrada ise, aynı Yasanın 14, 15 ve 16. maddelerinin üçüncü fıkrasında sayılan manevi hakları 70 yıl için "kendi namlarına kullanma hakkının" verildiği anlaşılmaktadır. Böylece, 19. maddede ayrı ayrı hak ve yetkilerin niteliği, bu hakları kullanabilecek kimseler ve sınırları belirterek eser sahibinin ölümünden sonra da bu maddede sayılan manevi haklar koruma altına alınmıştır.

FSEK'in 19/1 maddesinde sayılan kimseler, 14/1 ve 14/2. fıkrası kapsamındaki manevi hakların kullanım tarzını eser sahibinin ölümünden sonra onun arzusuna uygun olarak belirleyecek ve bu haklarını koruyacaklardır. Başka bir anlatımla, Yasada adı geçenler murise ait, eserinin umuma arz edilip edilmemesi, yayımlanma zamanı ve tarzını tayin yetkisi ile eseri sahibinin adı veya müstear adı ile yahut adsız olarak umuma arz etme veya yayımlama yetkisinin kullanımını murisin arzusuna uygun bir biçimde yerine getireceklerdir. Ayrıca, murisin sayılan manevi haklarına bir tecavüz halinde de, adı geçen kişiler kendilerine tanınan bu yetkinin doğal bir sonucu olarak tecavüz edene karşı tecavüzün ref'i ve men'i davalarını açabilecekleridir.

FSEK'in sözü edilen 14/1 ve 15/1. maddelerinin ihlali halinde 19/1. fıkrada adı geçenlerin - somut uyuşmazlıktaki mirasçıların dahil- manevi tazminat isteyip istemeyecekleri hususunun açıklığa kavuşturulması için aynı maddenin ikinci fıkrasının da birlikte incelenmesi gereklidir.

FSEK'in 19/2. fıkrasında adı geçenlerin sahip oldukları haklar ve bunların sınırları birinci fıkrada farklı bir biçimde düzenlenmiştir. **İkinci fıkrada, 14,15 ve 16. maddelerinin üçüncü fıkralarında sayılan manevi haklar bakımından adı geçenlere, eser sahibinin ölümü ile birlikte halefiyet veya mirasçılık sıfatından ayrı olarak 70 yıl süre ile kandan doğan bağımsız bir hak tanınmıştır. Söz konusu hak ile, eser sahibinin ölümünden sonra şeref ve haysiyetini zedeleyecek nitelikteki manevi hak ihlallerinin ortaya çıkması veya eser sahipliğinin ihtilafı olması hallerinde, maddede adı geçenlere her türlü önleyici (tecavüzün ref'i ve men'i) ve tazminat davaları ve yine eser sahipliğinin tespiti davasını açmak imkanı verilmiştir.**

FSEK'in 19/1. maddesindeki hallerde ise, adı geçenlere kendi namlarına kullanabilecekleri müstakil bir hak tanınmamıştır. Bu fık-

rada sayılan haklar; eser sahibinin 14/1 ve 15/1. fıkralardaki haklarının kullanım tarzını belirleme yetkisi ile sınırlı olup, anılan hakların ihlali halinde maddede **adı geçenlere** tecavüzün giderilmesi ve önlenmesi için gerekli davarlı açabilmek hakkını verdiği halde; **FSEK'in 70/1. maddesine dayalı tazminat isteme hakkı vermez.**

Bu açıklamalardan sonra somut uyuşmazlığa dönüldüğünde; işleme eser sahibinin mirasçısı olan davacıların isteminin, eserin davalı şirket tarafından izinsiz olarak umuma arzı nedeniyle FSEK'in 14/1. maddesi yoluyla aynı Yasanın 70/1. maddesine dayalı manevi hak tazminatı olduğuna göre, FSEK'in 19/1. fıkrası uyarınca davacıların tazminat talep etme hakları olmayacağından dolayı istem reddedilmelidir. Mahkemece aksine düşüncelere tazminata hükmedilmesi doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.

MİMARLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ³¹⁹

MADDE 1: TARAFLAR

MİMAR

Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Oda Sicil No :
SMH Büro Tescil No :
Vergi Dairesi ve No :
Telefonve adres :

İŞVEREN / İŞSAHİBİ

Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Vergi Dairesi ve No :
Hesap No :
Telefon ve adres :

Bu sözleşmede taraflar, MİMAR ve İŞVEREN / İŞSAHİBİ olarak anılmıştır. İŞVEREN / İŞSAHİBİ adına, Mimara bildirimde bulunmaya yetkili kişi:
..... Mimarın yokluğunda adına bildirimde bulunmaya yetkilendirilmiş kişi:.....
.....'dır.

MADDE 2:

A) SÖZLEŞME KONUSU YAPININ:

İlçe	Belediye	Mahalle veya Semt	Cadde veya Sokak	İmar Durumu Tarihi	Pafta	Ada	Parsel

B) MİMARLAR ODASI MESLEKİ DENETİM UYGULAMA ESASLARI'NA GÖRE YAPININ:

Kullanma Amacı	Yapım Sistemi	Kat Adedi	Toplam İnş. Alanı	Taban Alanı	Top. İnşaat Maliyeti	Yapı Birim Mal. Grubu	Bölge Katsayısı	Sınıf ücret Oranı	Bağımsız Böl. adedi

³¹⁹ Mimarlar Odası Genel Merkezi web sitesi http://mo.org.tr/mevzuatdocs/1.tip_sozlesme.doc (İşbu sözleşme ne yazık ki hukuki anlamda rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir sözleşme değildir. Sadece asgari koşulları göstermek amacıyla ve uygulamada sürekli kullanıldığı için sunulmuş olup, her bir özel durumda tarafların yükümlülükleri ve haklarına göre mutlaka yeniden ve mümkünse bir hukukçuya danışılarak düzenlenmelidir.)

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN ESASI

İŞVEREN / İŞSAHİBİ / İŞSAHİBİ, bu sözleşme ile yukarıda yazılı işe ait mimarlık hizmetlerinin 5. Maddede işaret edilmiş olanlarının tamamının MİMAR'ın sorumluluğu ve koordinasyonu altında yapılmasını, MİMAR da, bu çalışmaları eksiksiz ve kusursuz olarak ve süresi içinde yapmayı, TARAFLAR, yükümlülüklerini bu Sözleşmenin eki olan “**Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi**” hükümlerine uygun olarak yerine getirmeyi karşılıklı olarak kabul ve taahhüt etmişlerdir. Sözleşme eklerinin hükümlerine ilave edilecek uygulama koşulları 6. Maddede belirlenmiştir.

MADDE 4: İŞVEREN/İŞSAHİBİ’NİN SAĞLAYACAĞI BİLGİ VE BELGELER

İŞVEREN / İŞSAHİBİ, sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte ve sözleşme tarihinden itibaren en çok () gün içerisinde aşağıda yazılı belge ve bilgileri MİMAR’a verecektir.

- 4-1:Hukuki Belgeler :.....
- 4-2:İmar Belgeleri :.....
- 4-3: Teknik Belgeler :.....
- 4-4:Yatırım Bütçesi Bilgileri:.....

İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından MİMAR’a verilecek yukarıdaki bilgi ve belgelerin doğru ve geçerli olması esastır. Bu belge ve bilgilerin MİMAR’a tesliminde gecikme olması durumunda, yada temini görevi MİMAR’a verilmesi durumunda temininde geçecek süreler, sözleşme süresine ilave edilir. Bu süre (...) ayı geçemez.

MADDE 5: MİMAR TARAFINDAN YAPILACAK MİMARLIK HİZMETLERİ, HİZMET BEDELLERİ VE İŞ SÜRELERİ

Bu sözleşme uyarınca İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından istenen ve MİMAR tarafından yapılması kabul ve taahhüt edilen işlerin karşılığında aşağıda yazılı bedelleri, MİMAR’a ödemeyi kabul ve taahhüt etmiştir. MİMAR, Sözleşme kapsamındaki iş aşamalarını aşağıda yazılı süreler içerisinde tamamlamayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Bu süreler MİMAR tarafından yapılan çalışmalar ile ilgili sürelerdir. İş sahibinin inceleme ve onay süreleri, mesleki denetim, ruhsat, ön izin vb. işlemlerinin, ihalenin yapılması ve diğer hizmetlere ait gerçekleşme süreleri MİMAR’ın çalışma sürelerine dahil değildir. İŞVEREN / İŞSAHİBİ’nin proje inceleme süreleri karşılığında yazılı değilse, her iş aşaması süresinin %20’sini aşamaz. Süreler “işgünü” olarak belirlenmiştir.

5-1 : MİMARİ PROJE HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI

Hazırlık ve Ön Etüd Çalışmaları

- **Ön Proje Çalışmaları**
- **Kesin Proje Çalışmaları**
- Uygulama Proje Çalışmaları
- **Uygulama Projeleri**
- Sistem ve Montaj Detayları
- İmalat Detayları
- Teknik Şartnameler
- Metraj, Keşif, Maliyet Analizi
- İhale Çalışmaları
- İhale Belgeleri hazırlanması
- İhalenin yapılması

5-2 : MİMARİ UYGULAMA VE YÖNETİM HİZMETLERİ İŞ AŞAMALARI

- Mimari Mesleki Kontrollük Hizmetleri (MUS)
- Yapıldı Projelerinin Teslimi
- Kesin Hesaplar
- Kabul – Teslim

5-1 : MİMARİ PROJE HİZMETLERİ BEDELİ :YTL
(..... gün)
(.....)
.....)

5-2 : MESLEKİ UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ BEDELİ
:.....YTL (..... ay)

(.....)
Mesleki Uygulama Sorumluluğu Hizmetleri bedellerinin yukarıda yer alan bedel-
leri sözleşme tarihinde hesaplanmış bedellerdir. İşin yapıldığı tarihlerde geçerli olan
Tarifelerine göre güncellenecektir.

5-3 : DİĞER MİMARLIK HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA MİMAR'A ÖDENECEK BEDELLER:

.....
.....
(.....)
.....)

MADDE 6: İLAVE KOŞULLAR

Taraflar bu sözleşmenin eki olan "Mimarlık Hizmetleri şartnamesi ve En Az Be-
del Tarifesi" hükümleri dışında aşağıda yazılı koşulları yerine getirmeyi karşılıklı olarak
kabul ve taahhüt etmişlerdir.

.....
.....
.....

MADDE 7: ÖDEME ŞEKLİ

İş sahibi, 5. Maddede yazılı bedelleri MİMAR'a aşağıdaki şekilde ödeyecektir.

7-1: 5-1. Maddede yazılı hizmetlerin her aşamasının bedeli o iş aşamasının ta-
mamlanarak İŞVEREN / İŞSAHİBİ'ne teslimi ya da İŞVEREN / İŞSAHİBİ'nin kabu-
lünü gerektiren iş aşamalarının onaylanması ile MİMAR'a ödenir.

7-2: 5-3 Maddelerde yazılı hizmetlerin bedelleri bu çalışmalar MİMAR tarafından
tamamlanarak İŞVEREN / İŞSAHİBİ'ne teslimi ile birlikte defaten ödenir.

7-3: 5-2. Maddede yazılı Mimari Mesleki Kontrollük bedelleri, bu iş aşamalarının
toplam bedelinin iş süresine bölünmesi ile aylık olarak ve hizmetin yapıldığı yılın tarife-
sine göre hesaplanarak ödenir.

7-4: Ödemeler, Sözleşme'de başkaca bir hüküm yoksa, nakit olarak veya Mİ-
MAR'ın Bankası, Şubesi'ndeki no'lu hesabına havale edilerek ya da yatırılarak yapılır.

7-5: MİMAR, Sözleşme'de başkaca bir hüküm yoksa, her ödeme karşılığında
ödemeden hangi iş aşaması karşılığında yapıldığını belirten açıklama ile Serbest Meslek
Makbuzu ya da Fatura düzenleyecektir. Her ödemeye KDV ilave edilecektir.

7-6: Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından üstle-
nilecektir.

MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Mimarlar Odası'nın hâkimliğine başvurulabilir. Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözümlenememesi halinde, Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşme “**Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi**” hükümlerine göre feshedilebilir.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ

3194 sayılı İmar Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi, Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi, Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları, vd..... bu sözleşmenin ekidir.

MADDE 11: İşbu sözleşme (2) sayfeye yazılı (10) maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (..... /..... /.....) tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşmenin bir örneği Mimarlar Odası'na teslim edilecek, 1 örneği MİMAR, diğer örneği İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından saklanacaktır.

MİMAR
Adı-soyadı-mühürü

İŞVEREN
Adı-soyadı-kaşesi

MİMARİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ³²⁰

MADDE 1: TARAFLAR

MİMAR

Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Oda Sicil No :
SMH Büro Tescil No :
Vergi Dairesi ve No :
Telefon ve adres :

İŞVEREN / İŞSAHİBİ

Adı, Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Vergi Dairesi ve No :
Hesap No :
Telefon ve adres :

Bu sözleşmede taraflar, TUS MİMAR ve İŞVEREN / İŞSAHİBİ olarak anılmıştır.

MADDE 2 - İŞİN KONUSU

Yukarıda tarafları belirtilen işbu sözleşme aşağıdaki yazılı koşullarla taraflarca **MİMARİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ** olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.

MADDE 2:

A) SÖZLEŞME KONUSU YAPININ:

İlçe	Belediye	Mahalle veya Semt	Cadde veya Sokak	İmar Durumu Tarihi	Pafta	Ada	Parsel

B) MİMARLAR ODASI MESLEKİ DENETİM UYGULAMA ESASLARI'NA GÖRE YAPININ:

Kul-lanma Amacı	Yapım Sistemi	Kat Adedi	Toplam İnş. Alanı	Taban Alanı	Top. İn-şaat Maliyeti	Yapı Bi-rim Mal.Gru-bu	Bölge Katsayısı	Sınıf üc-ret Oranı	Bağımsız Böl.aded

³²⁰ Mimarlar Odası Genel Merkezi web sitesi <http://mo.org.tr/mevzuatdocs/TUSSOZLESME.doc> (İşbu sözleşme ne yazık ki hukuki anlamda rahatlıkla tavsiye edebileceğimiz bir sözleşme değildir. Sadece asgari koşulları göstermek amacıyla ve uygulamada sürekli kullanıldığı için sunulmuş olup, her bir özel durumda tarafların yükümlülükleri ve haklarına göre mutlaka yeniden ve mümkünse bir hukukçuya danışılarak düzenlenmelidir.)

Bu parselde yapılacak inşaat;..... niteliğindedir.

MADDE 3 – MİMARİ TUS HİZMETİ SÜRESİ (YAPIM SÜRESİ)

Bu sözleşme, yukarıda bilgileri yer alan yapının ay süre ile Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu Hizmeti için geçerlidir.

MADDE 4 - MİMARİ TUS HİZMETİ BEDELİ VE ÖDEMELER

İŞVEREN / İŞSAHİBİ, TUS mimara yukarıdaki özelliklere sahip yapının MİMARİ TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU HİZMETLERİ karşılığı olarak :

TOPLAMYTL bedeli, (yazı ile YTL.) Mimari TUS hizmeti süresi olan ay süresince AYLIK YTL/ay (yazı ile YTL.) olarak ödeyecektir.

4-a : Ödemeler aylık olarak yapılacaktır.

4-b : TUS mimarın işverenden alacağı bedel TMMOB Mimarlar Odası Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi”nin altında olamaz.

4-c : İnşaatın süresinden önce bitirilmesi halinde TUS mimara sözleşmede belirtilen ücretin tamamı ödenecektir.

4-d : TUS mimar, her ay hizmetlerine bağlı olarak yapılan ödeme karşılığı fatura kesecek, bir örneğini Mimarlar Odası'na ibraz edecektir.

4-e : Bu sözleşmedeki aylık bedel, hizmetin yapıldığı yıl için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından açıklanan “Mühendislik ve Mimarlık Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri” bedellerinden güncellenerek ödenecektir. Bu tebliğin yayınlanmasının gecikmesi halinde, tebliğin Resmi Gazetede yayımı tarihinden önce, o yıl içinde verilen hizmetlerin bedeli, önceki yılın bedeli ile aradaki fark hesaplanarak Mimara yapılacak bir sonraki ödemeye ilave edilir.

4-f : Yapım süresinin her hangi bir nedenle bu sözleşmedeki TUS hizmeti süresini aşması durumunda taraflar ek sözleşme yapmak zorundadırlar. Ek sözleşmede, Mimari TUS hizmetinin bedeli, ait olduğu yılın tarifelerinden hesaplanır.

4-g : Damga Vergisi ile ilgili yükümlülük İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından üstlenilecektir.

MADDE 5 - DİĞER HÜKÜMLER

5-a : Taraflar ilgili Yasalar, Yönetmelikler ve Tüzük ve Şartnameler gereği yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmek zorundadır.

5-b : Taraflardan herhangi birinin sözleşmeye aykırı davranması halinde, bu durum sözleşme ihlali yapan tarafa yazılı olarak bildirilecektir.

5-c : Sözleşmedeki adresler tarafların yasal adresleridir. Taraflar adres değişikliklerini en geç 7 işgünü içinde birbirlerine, ilgili idareye ve Mimarlar Odası'na bildirecektir.

MADDE 6 - ÖZEL ŞARTLAR Sözleşmede yazılı olmayan hususlarda aşağıda yazılı mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

6-1:
6-2:

MADDE 7 - İKAMETGAH

Sözleşmenin 1. maddesindeki adresler, tarafların kanuni ikametgahlarıdır ve bu adreslere yapılacak her türlü tebliği kendilerine yapılmış sayılacağını şimdiden kabul

etmişlerdir. Taraflar adres değişikliğini en geç 7 gün içinde bir birlerine, ilgili kurumlara ve Mimarlar Odasına bildireceklerdir.

MADDE 8: ANLAŞMAZLIKLAR

Taraflar arasında doğabilecek anlaşmazlıkların çözümü uzlaşma yoluyla sağlanamadığı takdirde, uzlaşmazlığın bütün taraflarının isteği üzerine Mimarlar Odası'nın hakemliğine başvurulabilir. . Anlaşmazlıkların sulh yoluyla çözülmemesi halinde, Mahkemeleri yetkilidir.

MADDE 9: SÖZLEŞMENİN FESHİ

Bu sözleşme “**Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi**” hükümlerine göre feshedilebilir.

MADDE 10: SÖZLEŞMENİN DOĞAL EKLERİ

3194 sayılı İmar Kanunu, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6235-7303 Sayılı TMMOB Kanunu, 3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 5272 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili yönetmelikler, 3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği, TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil Ve Mesleki Denetim Yönetmeliği, Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi Ve En Az Bedel Tarifesi, Mimari Teknik Uygulama Sorumluluğu (Fenni Mesuliyet) Hizmetleri Şartnamesi ve En Az Bedel Tarifesi, Mimari Proje Çizim ve Sunuş Standartları, vd..... bu sözleşmenin ekidir.

MADDE 11: İşbu sözleşme (2) sayfeye yazılı (11) maddeden ibaret olarak düzenlenmiş ve taraflarca (..... /..... /.....) tarihinde imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu sözleşmenin bir örneği Mimarlar Odası'na teslim edilecek, 1 örneği MİMAR, diğer örneği İŞVEREN / İŞSAHİBİ tarafından saklanacaktır.

MİMAR
Adı-soyadı-mühürü

İŞVEREN
Adı-soyadı-kaşesi

KAYNAKÇA

AKBIYIK ARKAN, Azra : Gerçek Olmayan Vekaletsiz İş Görme, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1998.

ARAL, Fahrettin: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, Ankara, 2000.

ARIDEMİR GENÇ, Arzu : Türk Hukukunda Eser Sahibinin Çoğaltma ve Yayma Hakları, Vedat Kitapçılık, Kasım, İstanbul, 2003.

ARSLANLI, Halil : Fikri Hukuk Dersleri, II: Fikir ve Sanat Eserleri, 1954, İstanbul.

ATAMAN, OROL S. : Fikir ve Sanat Eserleri Kanun'daki "Sanatsal Gözetim" ve "İşlenme" Kavramları Üzerine Düşünceler, Mimarlık Dergisi, S.1995/266, s. 10-11.

ATEŞ, Mustafa : Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması, Seçkin Yayınları, Ocak, Ankara, 2003.

AYİTER, Nurşin : Hukukta Fikir ve Sanat Ürünleri, Sevinç Yayınları, Kasım, 1981, Ankara.

BELGESAY, Mustafa Reşit : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, 1955, İstanbul.

BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku Dersleri-Hususi Borç Münasebetleri, Ankara, 1958.

BİLGE, Necip : Borçlar Hukuku - Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1971.

ÇAKALIR, Yalçın : Mimarlık Sözleşmesi, Ankara, 1976.

DEMİRKIRAN, İhsan / DEMİR, Aysel Cemile / BİLGİN, Çağlar : Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 10 Yıllık Emsal Kararları (1995-2004), Seçkin yayınları, 2004, Ankara.

DEVELİOĞLU, Ferit / KILIKÇINI Neval : Osmanlıca – Türkçe Sözlük, Rafet Zaimler Kitapevi, İstanbul, 1983.

ERDİL, Engin : İçtihatlı ve Gerekçeli Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Şerhi, Beta Yayınları, Nisan, 2005, İstanbul.

EREL, Şafak : Türk Fikir ve Sanat Hukuku, İmaj Yayıncılık, Ankara, 1998.

ERTAŞ, Şeref / GÖKYAYLA, Emre : “Mimari Projeler Üzerindeki Telif Hakkı, Prof. Dr. Seyfullah Edis’e Armağan, DEÜ Yay., İzmir, 2000.

GÖKTÜRK, Hüseyin Avni : Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri, Ankara, 1951 .

HATEMİ/SEROZAN/ARPACI : Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992.

HIRSCH, Ernst E. : Hukuki Bakımdan Fikri Say, C. II: Fikri Haklar (Telif Hukuku), İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1943.

KARAASLAN, Merih : Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu: Yeni Düzenlemeler Mimarlığa Neler Kazandıracak, Mimarlık Dergisi, S. 1995/265, s.8-9.

KÖTELİ, Mustafa Argun : Mimarlık Sözleşmesi, 1985, İstanbul.

KILIÇ, Bilge : Fikir ve Sanat Eserleri Hukukunda “Eser” Kavramı, LEGAL Fikri ve Sinai Haklar Dergisi, Legal Yayıncılık, C.1, S.1, s. 106 vd., İstanbul, 2005.

OLGAÇ, Senai: İstisna Akdi - Borçlar Hukuku - Akdin Muhtelif Nevileri (VI)”, İstanbul, 1966.

OĞUZMAN M. Kemal / SELİÇİ Özer / OKTAY-ÖZDEMİR Saibe : Eşya Hukuku, İstanbul, 2006.

ÖNGÖREN, Gürsel : İnternet Hukuku, Öngören Hukuk Yayınları, İstanbul, 2006.

ÖZTRAK, İlhan : Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Haklar, 2. Bası, 1977, Ankara.

PEKİN, Salih Zeki :Fikir ve Sanat Eserleri Yasası İle Kazanımlarımız ve Mimar Olarak Yapmamız Gerekenler, Mimarlık Dergisi, S. 1995/266 .

SELİÇİ, Özer : “Mimarlık Sözleşmesinin Hukuki Niteliği-Temsil ve Vekaletle İlişkin Sorunlar”, İstanbul, 1977.

SULUK, Cahit / ORHAN, Ali : Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku, C. II, Arıkan Yayıncılık, Eylül, İstanbul, 2005.

TANDOĞAN, Haluk: “İstisna Akdi Kavramı, Unsurları ve Benzeri Akitlerden Ayırt Edilmesi-İmran Öktem’e Armağan”, Ankara, 1970.

TANDOĞAN, Haluk: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi, C.2, Ankara, 1982.

TEKİNALP, Ünal : Fikri Mülkiyet Hukuku, Beta Yayınları, Eylül, 2004, İstanbul.

TOPÇUOĞLU, Hamide : Fikri Haklar Ders Notları, Ankara, 1964.

TUNÇOMAĞ, Kenan : Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C.2, İstanbul, 1977.

UYAN, Göktürk : İsviçre-Türk Hukukunda Mimari Proje Düzenleme Sözleşmesinin Hukuki Niteliği, Beta Yayınları, 1. Bası, Şubat, İstanbul, 2006.

ÜSTÜN, Gürsel : Fikri Hukukta İşleme Eserler, Besam Yayınları, İstanbul, 2001.

ÜSTÜN, Gürsel : “Yargısal Uygulamada Fikri Haklar”, İBD., C.73; 1999.

YARSUVAT, Duygun : Türk Hukukunda Eser Sahibi ve Hakları, 2. Bası, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 1984.

YAVUZ, Cevdet : Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5. Bası, Beta Yayınları, İstanbul, 1997.

YILMAZ, Ejder : Hukuk Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara 1976.

ZEVKLİLER / AYDOĞDU / PETEK : Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkisi, Ankara, 2001.

SON SÖZ

Bu çalışma “mimari eserler” konusunda daha ayrıntılı çalışmaların başlayabilmesi için örnek olarak hazırlandı. Bu yönde hukukçu dostlarımız, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz kitabımızda belirtilen her bir konu başlığından yeni kitaplar çıkarabilirler. Ancak bu çalışmalarında bizim bilerek ihmal etmiş olduğumuz uluslararası öğretiyi yakından inceleyip yapılan tartışmaları çalışmalarına yansıtmaları şarttır.

İleride zaman ve güç bulabilirsek, mimarları yakından ilgilendiren eser sözleşmesi ve inşaat ile ilgili mevzuat ve yargı kararlarını inceleyerek bu kitaba dahil etmeyi de düşünmüyor değiliz.

Gün ola, harman ola...

Gürsel Öngören

Filiz Ceritoğlu

